



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

경영성과급의 임금성



고려대학교 대학원

법학과

박성미

2023년 2월

박 지 순 교수지도
석 사 학 위 논 문

경영성과급의 임금성

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함

2022년 10월

고려대학교 대학원

법 학 과

박 성 미



박 성 미의 법학 석사학위논문 심사를 완료함.

2022년 12월

위원장 하 경 효 (인)

위 원 박 종 희 (인)

위 원 박 지 순 (인)



경영성과급의 임금성

박 성 미

법학과

지도교수: 박 지 순

초록

그간 법원은 임금성을 판단함에 있어 객관적 판단 지표를 설정하고 개별 사안마다 유형론적인 해석을 하여 임금성 판단의 통일적 기준을 마련하지 못하였다. 이러한 상황에서 종래 법원은 개인성과급의 임금성을 인정하면서도 집단성과급의 임금성을 부정해 왔으나, 대법원이 2018년 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정하면서 학계에서는 임금 개념의 핵심이 되는 근로의 대가의 의미에 대해 다양한 견해가 제기되었다. 또한 상기 판결로 인해 민간기업에서도 경영성과급의 임금성과 관련된 다수의 재송이 촉발되었는데 문제는 각 법원이 상반된 결론을 내리고 있다는 것이다. 심지어 동일한 사실관계 하의 사건에서조차 다른 결론의 판결이 내려지고 있어 논란이 더욱 거세지고 있다. 이러한 경영성과급의 임금성에 대한 논란을 해결하기 위해 본 논문에서는 임금성 특히 임금 개념의 가장 핵심인 ‘근로의 대가’의 의미를 정립하고 판단 요건을 명확히 확정된 후 경영성과급의 임금성에 관한 견해를 제시해 보고자 하였다.

이를 위해 본 논문에서는 먼저 임금의 본질과 임금 관련 법제, 타 법령과의 유기적인 관계 등 임금의 일반론에 대해 논하였다. 「근로기준법」상 임금에 관한 정의 규정과 쌍무유상계약인 근로계약에 따라 임금이 노무급부에 대한 반대급부로서 지급되는 점을 고려하면 임금의 법적 성격은 현실적인 근로제공을 전제로 한 노동의 대가로 보아야 한다. 일반적인 타 국가와 구분되게 우리나라는 임금에 관한 정의 규정을 「근로기준법」상 별도로 규정하고 있다. 또한 민법상 보수 등과 다르게 임금에 강제규정성을 부여하고 위반 시 수급자를 처벌하는 임금에 관한 특별한 보호를 하고 있는 법제도를 고려하면 임금의 개념과 범위를 확정함에 있어 법적안정성과 근로자 보호라는 합목적성의 적절한 조율이 필요하다. 또한 민법상 보수나 법제도의 취지에 따라 폭넓



은 개념을 인정하고 있는 사회보험법상 보수·소득과는 다르게 근로기준법 상 임금 개념은 제한될 필요가 있다, 위와 같은 관점하에서 근로의 대가의 의미를 살펴보았다.

이후 본 논문에서는 임금 개념의 핵심인 ‘근로의 대가’의 의미와 임금의 범위를 확정하기 위해 법원의 종래 판결과 경영성과급의 임금성과 관련성을 가지는 최근 판결인 개인성과급, 공공기관 경영평가성과급, 복지포인트의 임금성에 관한 판례를 살폈다. 또한 근로의 대가를 판단함에 있어 크게 ‘근로제공 관련성’ 또는 ‘지급의무성’ 중 어느 것을 핵심적 요건으로 판단하는지에 따라 나뉘는 다양한 견해를 분석하였다. 이를 통해 임금의 본래적 특성상 근로제공과 상호 관련성을 가지는 점, 법문상 근로의 대가임이 명확히 명시되어 있는 점, 지급의무는 청구권에 바탕을 둘 때만 의미가 있다는 점, 임금청구권에 대한 입증책임 주체 등을 고려하여, 근로의 대가의 의미는 ① 근로제공 관련성(근로제공과 금품 지급간에 직접 또는 밀접한 관련성)과 ② 지급의무성(임금청구권을 인정할 수 있도록 지급액 등을 산출할 수 있는 구체적인 지급 조건에 관한 법원의 존재)을 함께 판단해야 한다는 결론을 도출하였다. 더불어 근로의 대가를 구성하는 요건에 대한 직접적인 판단이 아닌 다른 요소를 통한 추정 여부 및 입증책임의 전환 여부도 근로의 대가의 의미 정립 및 범위 확정시 쟁점이 된다. 그러나 우리나라의 임금 관련 법제는 일본(통상임금, 평균임금 산정 시 기간 제한)과는 다르기 때문에 지급의무성을 중심으로 근로의 대가를 추정하고 임금성을 폭넓게 인정할 경우 임금의 강행규정성 등 특별한 보호의 범위가 지나치게 확대되고 법적안정성에도 부정적 영향을 미치는바 현행 법제하에는 임금성을 추정하는 것은 적절하지 아니하다.

경영성과급의 임금성의 경우 근로제공 관련성이 인정될 수 있는지가 가장 쟁점이 된다. 경영성과의 달성에 따른 보상은 경영학상 인적자원 관리에 대한 보상의 하나로 반드시 근로의 대가와 견련관계 하에서 발생된 금원이 아닌 점, 경영성과의 달성은 주로 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여 등과 회사의 외부적 요인인 시장상황 동종업계 동향 등이 총체적으로 결합되어 이루어지는 것으로 근로제공은 이중 하나의 요인에 불과하다는 점, 근로제공과 쌍무적 견련관계에 있는 근로의 대가로서의 임금은 근로제공의 내용을 살펴보아야 하는데 최근 문제가된 하급심 판결은 직무나 역할에 대한 고려 없이 회사의 경영목표 달성을 성과급의 발생기준으로 한 것으로 근로제공 관련성이 없다고 볼 수 있는 점, 개인성과급은 경영성과급과 다르게 주로 개인의 근로제공에 따라 성과급의 발생 여부가 달라지며 개인이 실적 달성 여부를 통제하는 것이 가능하기 때문에 개인성과급의 임금성 인정과 경영성과급의 임금성 인정은 반드시 연계될



필요는 없다는 점, 공공기관 경영평가성과급은 매년 평가가 실시되고 평가 결과가 산출이 되면 지급이 되는 것으로 경영성과 달성이라는 별도의 조건을 필요로 하지 않기 때문에 공공기관 경영평가성과급과 민간기업의 경영성과급은 근로제공 관련성에 있어 달리 볼 수 있어 양자가 결론을 달리하는 것이 불합리하지 않은 점, 최근 대법원 전원합의체 판결에서 복지포인트의 임금성을 부정하면서 근로복지기본법상 입법자의 의사를 중시한 점을 고려하면 경영성과급의 특성 상 근로제공 관련성은 인정될 수 없다.

또한 지급의무성의 의미는 근로자가 청구 시 사용자가 지급을 거절할 수 없는가의 관점으로 봐야 하며 이때 청구는 사용자의 재량에 따라 임의로 지급을 결정할 수 있는 것이 아니라 법원(法源)상 명시된 경영성과 달성 시 임금지급청구권을 확정할 수 있다는 의미로 봐야 하기 때문에 경영성과 달성 정도에 따라 지급액을 특정할 수 없는 경우에는 지급의무성을 인정할 수 없다. 즉, 민법상 보수에는 포함될 수 있더라도 특별한 보호를 받는 「근로기준법」 상 임금은 아니라고 보는 것이 타당하다.

일본, 미국, 독일 모두 우리나라와 같이 경영성과에 따라 지급 여부가 달라지거나 지급의무성도 명확하지 않은 경영성과급에 대해서는 임금성을 부정하고 있어 비교법상 경영성과급의 임금성이 보편적으로 인정되고 있다고 보기도 어렵다.

결론적으로 경영성과급은 각각의 지급에 관한 법원(法源)에 따라 지급조건이 특정되어 경영성과 달성시 지급액이 산출될 수 있는지에 따라 지급의무성 요건이 인정되는 경우도 있을 수 있으나, 경영성과급의 특성상 근로제공 관련성이 부정되는 이상 근로대가성은 부정되는바, 설사 지급의무성이 인정된다고 하더라도 임금성이 인정될 수는 없다. 임금성 논란을 근본적으로 해결하기 위해서는 우리와 법제를 같이하는 일본과 같이 편익 실현을 위한 도구적 개념인 통상임금과 평균임금을 법 취지에 맞도록 기간 제한을 하되, 임금성을 폭넓게 인정하는 방식을 통해 법적안정성과 합목적성을 조화시키는 방향으로 법을 개정하거나 미국 및 독일과 같이 경영성과로 지급하는 것에 대한 당사자의 의사가 명확하고 사용자의 재량권이 인정되는 금품에 대해서는 그 취지와 지급실태에 맞도록 임금성을 부정하여 제한적으로 해석하고 법정안정성을 확보하는 것이 경영성과급의 활성화를 위해 더욱 필요하다.

주제어: 임금, 근로의 대가, 근로대가성, 성과급, 경영성과급, 경영평가성과급, 집단성과급, 개인성과급, 복지포인트



A Study on the Wage Nature of Business Performance-Based Incentives

by **Park Sung Mi**

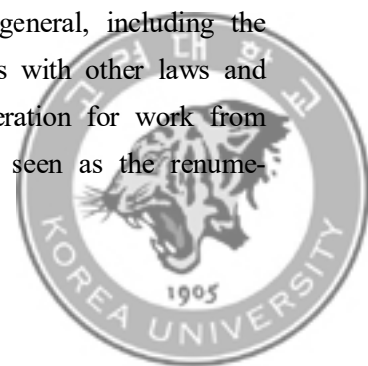
Department of law

under the supervision of Professor **Park Ji-Soon**

Abstract

The courts have made a typological interpretation for each individual case by setting objective scales in judging wage nature, but have not yet established unified criteria for determining wage nature, thereby conventionally denying the wage nature of group incentives, while acknowledging the wage nature of individual incentives. However, since the Supreme Court recognized the wage nature of the pay for business performance of public institutions in 2018, various opinions have been voiced among academics about the meaning of remuneration for work, which is at the heart of the concept of wages. In addition, the above ruling by the Supreme Court has triggered a number of lawsuits related to the wage nature of business performance-based incentives in private companies, but the problem is that each court is making conflicting conclusions about similar lawsuits. Judgments with different conclusions made on cases under the same facts have caused even greater controversy. With this in mind, this study aims to establish the meaning of wage nature, especially 'the remuneration for work', which is the core of the concept of wages, to clarify the criteria for determining wage nature, and to present some ideas to resolve the controversies over the wage nature of business performance-based incentives.

To this end, this study first discusses theories of wages in general, including the nature of wages, wage-related legislation, and organic relationships with other laws and regulations. And this study examines the meaning of the remuneration for work from the following perspectives: the legal nature of wages should be seen as the remuneration



ration for work on the premise of providing actual work, given that wages are paid in return for work in accordance with the definition of wages under the 「Labor Standards Act」 and the employment contract, which is a bilateral paid contract; it is necessary to properly balance the purpose of legal stability and worker protection under the Korean legal system, which, unlike those of other countries, provides a separate definition of wages under the 「Labor Standards Act」 and unlike remuneration under the Civil Act, has special protection provisions for wages that impose compulsory regulations to wages and punish their violators; and it is necessary to limit the definition of wages differently from remuneration or income under the Social Insurance Act, which widely recognizes the concept of wages according to the purpose of the civil law or the legal system.

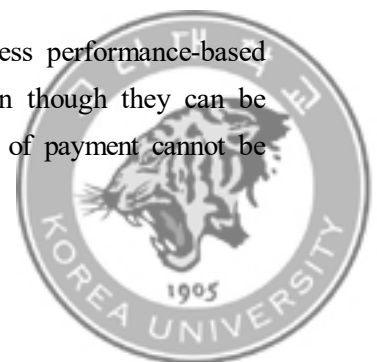
Then, this study examines previous rulings by courts and recent rulings related to the wage nature of business performance-based incentives, including precedents regarding individual incentives, the pay for business performance of public institutions, and welfare points to determine the meaning of 'the remuneration for work', which is the core of the concept of wages, and the scope of wages. And this study also analyzes various views divided according to whether the remuneration for work is judged based on 'the relatedness of providing work' or 'the obligatory nature of payment.' As such, considering that wages are mutually connected with the provision of work due to their inherent characteristics and are clearly stated in the law as the remuneration for work, that the obligatory nature of payment is meaningful only when based on the right to claim, and who has the burden of proving the right to claim wages, this paper comes to the conclusion that the meaning of the remuneration for work should be judged based on ① the relatedness of providing work (direct or close relationship between the provision of work and payment of money and goods) and ② the obligatory nature of payment (the existence of a legal basis for specific payment conditions by which the payment amount can be calculated to recognize the right to claim wages). In addition, estimating the remuneration for work based on factors other than the requirements for the remuneration for work and shifting the burden of proof of the remuneration to the employer is also an issue when establishing the meaning and scope of the remuneration for work, but this is not appropriate under Korea's current legal



system, considering that Korea's legal system is different from Japan's (there is no period limit when calculating average wages), the mandatory nature of wages and legal stability, and special legal protection for wages.

The most controversial issue is whether the relatedness of providing work can be recognized for the wage nature of business performance-based incentives. However, business performance-based incentives cannot be recognized as related to providing work in that the remuneration for achieving business performance is one of the rewards for human resource management in business administration, and is not necessarily money generated in relation to the provision of labor; business performance is mainly achieved by an overall combination of the managing abilities of the management, the contribution of the company's capital or assets, and the external factors such as market conditions and trends in the same industry, and the provision of labor is only one of these factors; wages as the remuneration for work, which is closely related to the provision of work, should be examined from the point of view of the content of the provision of work, but a recent problematic ruling by a lower court is based only on the achievement of the company's management goals as the criterion for generating the performance-based pay, regardless of duties or roles, thereby lacking the relatedness of providing work; unlike business performance-based incentives, individual incentives depend mainly on the provision of work by the individual, and it is possible for the individual to control whether or not the performance can be achieved, so it is not necessary to recognize the wage nature of business performance-based incentives in connection with the wage nature of individual incentives; and the pay for business performance of public institutions is evaluated every year, and is paid when the evaluation results are calculated without requiring a separate condition of achieving business performance. and thus the pay for business performance of public institutions and business performance-based incentives in private companies should be viewed differently in terms of the relatedness of providing work, so it does make sense for the two to reach different conclusions.

In addition, it is reasonable to deny the wage nature of business performance-based incentives specially protected under the Labor Standards Act, even though they can be included in remuneration under the Civil Act, at least if the amount of payment cannot be



specified according to the degree of achievement of business performance. This is because the meaning of the obligatory nature of payment should be interpreted from the perspective of whether the employer cannot refuse payment when the worker makes a claim as the claim does not mean that the employer can arbitrarily determine the payment at his/her discretion but that the right to claim payment of wages can be recognized.

Even in the comparative law, it cannot be said that the wage nature of business performance-based incentives are universally recognized. This is because Japan, the U.S., and Germany all deny the wage nature of business performance-based incentives, which depend on business performance, and the obligatory nature payment is not clearly defined as in Korea.

In conclusion, the requirements for business performance-based incentives may be recognized depending on whether the terms of payment are specified based on a legal basis for each business performance-based incentive and whether the amount of payment can be calculated upon achievement of business performance, but nevertheless, as long as the relatedness of providing work is denied, the remuneration for work is not recognized due to the nature of business performance-based incentives, and the wage nature of business performance-based incentives cannot be recognized even when the obligatory nature of payment is recognized. In order to fundamentally resolve the controversies over wage nature, it is necessary to improve ordinary wages and average wages, which are instrumental concepts for realizing benefits, to increase legal stability by limiting the period to suit the purpose of the law, as in Japan, which has the same legal system as Korea. And in order to revitalize business performance-based incentives, it is all the more necessary to secure legal stability by interpreting as denying the wage nature of money and other valuables for which the intention of the parties to paying for business performance is clearly defined in advance and the employer's discretion is recognized, as in the US and Germany.

Key Words : Wages, Remuneration for Work, Performance-Based Incentives, Business Performance-Based Incentives, Pay for Business Performance, Group Incentives, Individual Incentives, Welfare Points



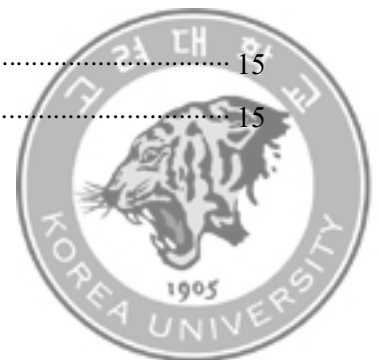
주요 목차

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구의 방법과 내용	3
제2장 임금에 대한 일반적 논의	6
제1절 임금의 법적 성격	6
제2절 근로기준법상 임금의 개념	15
제3절 임금 관련 법제의 구조와 비교	26
제3장 임금 판단의 핵심 요건인 근로대가성	39
제1절 서설	39
제2절 근로대가성에 대한 판례의 변화	40
제3절 임금성 판단의 핵심 요건인 근로의 대가	61
제4절 근로의 대가의 의미와 판단방법	73
제4장 경영성과급의 임금성 판단	84
제1절 경영성과의 배분	84
제2절 경영성과급의 임금성 관련 다양한 견해	88
제3절 경영성과급의 임금성 관련 판례 검토	99
제4절 경영성과급의 임금성 관련 비교법적 검토	131
제5장 결 론	146
참고문헌	152

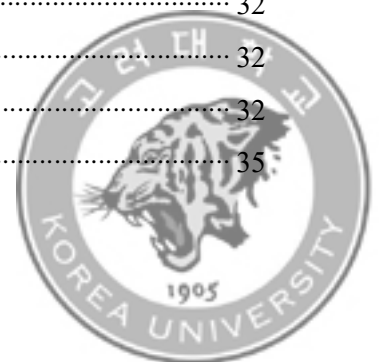


목차

국문초록	i
영문초록	iv
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구의 방법과 내용	4
제2장 임금에 대한 일반적 논의	6
제1절 임금의 법적 성격	6
I. 임금의 법적 성격에 대한 검토 필요성	6
II. 임금의 법적 성격에 관한 학설	7
1. 노동대가설	7
2. 노동력대가설	8
3. 근로관계보상설	9
4. 각 학설에 대한 검토	9
III. 우리나라 판례	11
1. 임금 이분설의 폐기	11
2. 법적 성격에 관한 대법원 전원합의체 판결의 입장에 대한 견해 대립	13
3. 검토	13
IV. 소결	14
제2절 근로기준법상 임금의 개념	15
I. 임금 관련 법규정에 관한 체계적 검토 필요성	15



II. 「근로기준법」 상 임금	16
1. 「근로기준법」 상 임금 정의 규정	16
2. 임금 개념의 구성	16
(1) 사용자가 근로자에게 지급	16
(2) 근로의 대가	18
(3) 명칭 불문	18
(4) 일체의 금품	18
III. 「근로기준법」 상 평균임금·통상임금	19
1. 검토 필요성	19
2. 평균임금과 통상임금 관련 법령	20
(1) 평균임금	20
(2) 통상임금	21
(3) 검토	21
3. 평균임금·통상임금과 임금의 구분 가능성	22
(1) 현행 법제 하에서 구분 가능한지 여부에 대한 견해	22
(2) 판례의 태도	23
(3) 검토	24
IV. 소결	24
제3절 임금 관련 법제의 구조와 비교	26
I. 임금 관련 법제 구조와 각 법령간 비교 필요성	26
II. 노동관계법 상 임금 관련 규정	28
1. 「근로기준법」 상 임금 관련 규정	28
2. 기타 노동관계법 상 임금 관련 규정	29
3. 검토	31
III. 임금과 구별되는 개념으로서 보수 등 관련 법제	32
1. 민법상 보수 관련 규정	32
2. 사회보장법상 보수(소득세법상 근로소득) 관련 규정	32
IV. 「근로기준법」 상 임금과의 비교	35



1. 민법상 ‘보수’의 의미와 「근로기준법」 상 임금과의 비교	35
2. 사회보험법상 ‘보수’의 의미와 「근로기준법」 상 임금과의 비교	37
V. 소결	37

제3장 임금 판단의 핵심 요건인 근로대가성 39

제1절 서설 39

제2절 근로대가성에 대한 판례의 변화 40

I. 기존 판례의 태도 40

1. 임금성 관련 판례 법리 40

(1) 임금성 판단 법리를 최초로 제시한 판결 40

(2) 근로제공 관련성을 최초로 구체화한 판결 41

(3) 이후 임금성 관련 판례의 태도 42

(4) 종래 판례의 태도에 대한 검토 44

II. 최근 판례의 태도 45

1. 개인성과급의 임금성 45

(1) 개인성과급의 임금성 판결의 변화 45

(2) 개인성과급의 임금성을 부정한 대표적인 판결 47

1) 주요 사실관계 47

2) 대법원의 판결 요지 48

(3) 검토 48

2. 2018년 이후 공공기관 경영평가성과급의 임금성 50

(1) 공공기관 경영평가성과급의 판결 50

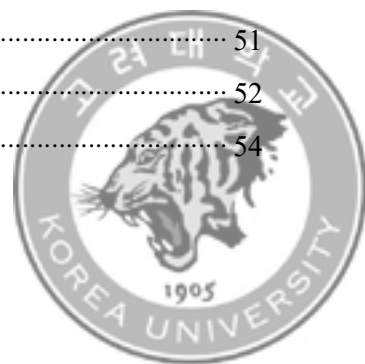
(2) 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 최초로 인정한 판례 51

1) 주요 사실관계 51

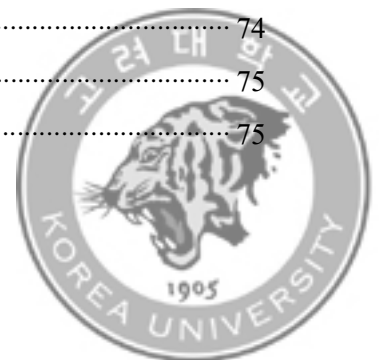
2) 대법원의 판결 요지 51

(3) 검토 52

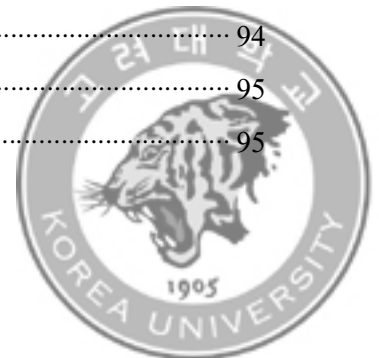
3. 복지포인트의 임금성 54



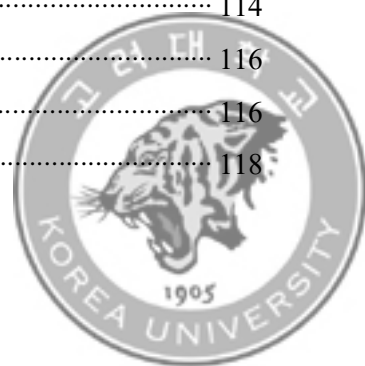
(1) 복지포인트의 임금성 판결의 변화	54
(2) 복지포인트의 임금성을 최초로 부정한 판결	55
1) 주요 사실관계	55
2) 대법원의 판결 요지	56
(3) 검토	58
III. 소결	59
제3절 임금성 판단의 핵심 요건인 근로의 대가	61
I. 근로의 대가에 대한 다양한 해석론	61
II. 학설의 태도	61
1. '근로제공 관련성' 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해	62
(1) 근로제공 관련성을 필수 요건으로 보는 견해	62
(2) 주된 요소(근로제공 관련성)와 보충적 요소를 통한 추정을 인정하는 견해	63
(3) '지급의무발생'과 '근로제공'과의 직접·밀접적 관련성 유무라는 견해	64
2. '지급의무성'을 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해	66
(1) '계속성·정기성' 및 '지급의무성' 인정시 근로대가성 추정하는 견해	66
(2) '근로제공 관련성'과 '지급의무성'을 임금성 요건으로 추정하는 견해	68
(3) '근로의 대가'를 추정하고 객관적·주관적 요소를 동시에 고려하는 견해	69
(4) 주관적 요소로 판단하되 사회통념에 따라 '근로의 대가'를 추정하는 견해	70
III. 소결	72
제4절 근로의 대가의 의미와 판단방법	73
I. 쟁점 검토의 방향성	73
II. 근로의 대가 판단 지표와 그 의미	73
1. 근로제공 관련성	73
(1) 근로제공 관련성의 의미	73
(2) 근로제공 관련성 필요 여부	74
2. 지급의무성	75
(1) 지급의무성의 의미	75



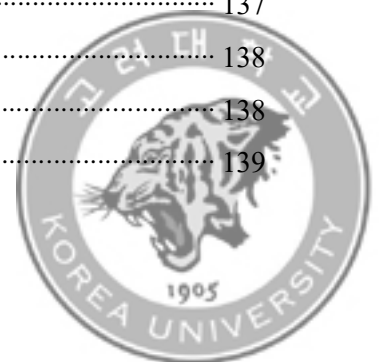
1) 불확실성(불확정성)	76
2) 노동관행	77
(2) 지급의무성 필요 여부	78
3. 계속성·정기성	78
(1) 계속성·정기성의 의미	78
(2) 계속성·정기성의 필요 여부	79
Ⅲ. 근로의 대가 지표간 우위성 및 추정 가능 여부	80
1. 지표간의 관계	80
2. 근로의 대가에 대한 추정 가능 여부	80
Ⅳ. 근로의 대가의 판단 방법	81
 제4장 경영성과급의 임금성 판단	 84
제1절 경영성과의 배분	84
Ⅰ. 성과배분제의 의의	84
Ⅱ. 경영성과급의 의의	86
1. 경영학에서의 경영성과급	86
2. 경영성과급의 특징	86
3. 경영성과급의 도입 연혁 및 도입 배경	87
제2절 경영성과급의 임금성 관련 다양한 견해	88
Ⅰ. 경영성과급 임금성 관련 논의 필요성	88
Ⅱ. 경영성과급의 (평균)임금성 관련 학설	89
1. 근로제공 관련성	89
(1) 긍정설	90
(2) 부정설	92
(3) 검토	94
2. 지급의무성	95
(1) 노동관행 인정 여부	95



(2) 지급액의 확정성	96
3. 평균임금제도의 취지 등	97
III. 소결	98
제3절 경영성과급의 임금성 관련 판례 검토	99
I. 의의	99
II. 경영성과급의 임금성과 최근 대법원 판결의 비교	103
1. 개인성과급과 판결과 경영성과급의 임금성 비교	103
(1) 비교 필요성과 쟁점	103
(2) 개인성과급의 임금성 인정 판결과 경영성과급의 임금성 판단 여부	103
(3) 검토	104
2. 공공기관 경영평가성과급 판결과 경영성과급 임금성 비교	106
(1) 비교 필요성과 쟁점	106
(2) 공공기관 경영평가성과급의 임금성 인정 판결과 경영성과급 임금성 판단 여부	106
(3) 검토	107
3. 복지포인트 판결과 경영성과급 임금성	108
(1) 비교 필요성과 쟁점	108
(2) 복지포인트 임금성 부정 판결과 경영성과급 임금성 판단 여부	109
(3) 검토	110
1) 근거 법령의 비교	110
2) 근거 법령 외의 요소 비교	111
III. 민간기업 경영성과급 임금성에 대한 최근 하급심 판결	113
1. 최근 하급심 판결의 유형화	113
2. 삼성전자 경영성과급 임금성 관련 2개 사건 판결 비교	114
(1) 사실관계 및 판결 결과	114
(2) 법원 판단 기준별 논거 비교	116
1) 근로제공 관련성에 대한 판결의 논거	116
2) 사용자의 지급의무성에 대한 판결의 논거	118



3) 계속성·정기성에 대한 판결의 논거	118
4) 평균임금의 취지 등에 대한 논거	119
(3) 검토	119
3. SK하이닉스 및 현대해상화재보험의 경영성과급의 임금성 사건 판결 비교	121
(1) 사실관계 및 판결 결과	121
(2) 법원 판단 기준별 논거 비교	124
1) 근로제공 관련성에 대한 판결의 논거	124
2) 지급의무성에 대한 판결의 논거	125
3) 계속성·정기성에 대한 판결의 논거	127
4) 평균임금의 취지 등에 대한 논거	127
(3) 검토	128
IV. 소결	129
제4절 경영성과급의 임금성 관련 비교법적 검토	131
I. 의의	131
II. 외국의 임금의 개념 및 경영성과급의 임금성	131
1. 일본	131
(1) 임금의 개념(정의)	131
(2) 임금의 요건	132
(3) 경영성과급의 임금성 여부	133
2. 미국	134
(1) 임금(일반급)의 개념	134
(2) 임금(일반급)의 요건	135
(3) 경영성과급의 일반급 여부	136
1) 보너스	136
2) 이익배분	137
3. 독일	138
(1) 임금의 개념	138
(2) 임금의 요건	139



1) 근로제공과 금품 제공 목적	139
2) 지급청구권 배제 가능 여부	140
(3) 상여금의 임금성 여부	140
(4) 경영성과금의 임금성 여부	141
1) 목표달성상여금	141
2) 이익분배금	142
4. 검토	142
III. 소결	144
 제5장 결 론	 146
 참고문헌	 152



표 목 차

[표 1] 종래 임금성 관련 대법원 판결의 변화	43
[표 2] 개인성과급의 임금성 관련 판결	46
[표 3] 근로의 대가 관련 견해 유형화	72
[표 4] 근로의 대가 판단 방법	83
[표 5] 성과배분의 의미	84
[표 6] 집단성과급의 임금성 관련 판결	100
[표 7] 경영성과급의 (평균)임금 해당성 관련 민간부문 최근 판결	101
[표 8] 경영성과급 임금성 관련 하급심 판결 지급형태별 유형화	113



제1장 서론

제1절 연구의 배경과 목적

임금성 여부 즉, 임금의 개념과 범위는 임금에 관한 근로자의 법상 권익 보호의 범위를 어느 정도로 설정하는 것이 합당하나에 관한 문제이다. 임금성을 넓게 해석할 경우 임금에 관한 법제가 강행규정성을 가지고 있음을 고려하면 법적안정성에 반하게 되며 반대로 임금성을 좁게 해석할 경우 근로자의 임금 보호라는 합목적성에 반하게 된다. 이러한 이유로 인해 각 관점에 따라 임금의 개념과 범위를 다르게 정의하고 판단하는 다양한 견해가 제기될 수밖에 없다. 다만, 노동관계법은 별도로 임금에 관한 정의 규정을 두고 있지 않고 「근로기준법」상 임금 개념을 준용하여 각 법령을 해석하고 적용하고 있기 때문에 「근로기준법」상 임금의 개념과 범위를 어떻게 설정하는지에 따라 노동관계법 전반에 영향을 미치게 된다. 따라서 임금의 개념에 대한 명확한 정립과 그 범위에 관한 합리적 판단은 매우 중요한 문제이다.

종래 임금에 관한 주된 논의는 ‘임금’ 그 자체보다는 통상임금·평균임금을 중심으로 이루어져왔다. 2013년 12월 대법원은 정기상여금 등 각종 수당의 통상임금 인정 여부와 관련하여 전원합의체 판결을 통해 통상임금의 외연을 넓히고 요건도 명확히 하여 통상임금에 관한 이점표를 제시해주었다. 그러나 통상임금의 전제가 되는 ‘임금’ 특히, 임금 개념의 핵심적 요소인 ‘근로의 대가’의 의미에 대해서는 명확하게 판단하지 않았다.

그간 법원은 ‘근로의 대가’와 관련하여 객관적 판단지표를 중심으로 개별 사건별로 유형론적 해석을 하면서 각 판결마다 일관된 기준을 적용하지 않았다. 특히 성과급과 관련하여 종래 대법원의 주류적인 입장은 임금성 여부에 대해 다툼이 있었던 개인성과급에 대해서는 다수의 판결을 통해 임금성을 인정하는 것으로 정리하면서도, 집단성과급에 대해서는 매년 경영성과 및 노사합의에 따라 지급여부 및 지급액이 달라지



기 때문에 불확정적이라는 이유로 ‘계속성·정기성’ 및 사용자의 ‘지급의무성’이 인정되지 않아 임금의 지급이 아니라고 보거나¹⁾ 성과급의 도입 취지(경영성과의 일부 분배 목적), 성과급의 지급여부 및 지급액을 결정하는 요소들이 근로제공과 직접적 관련성이 없는 경영실적, 파업여부 등이며 실제 이에 따라 성과급 지급률이 변동되었기 때문에 ‘근로의 대가’에 해당하지 않는다고 보아²⁾ 임금성을 부정해왔다.

그러나 2018년 말 대법원이 ‘공공기관 경영평가성과급’ 임금성 판결(한국감정원, 한국공항공사 사건 등)에서 사용자의 ‘지급의무’ 및 ‘계속성·정기성’만을 기준으로 집단성과급의 임금성을 인정하는 판결을 하였고, 이후 다수의 공공기관 소송에서도 경영평가성과급의 임금성이 인정되었다. 이후 상기 판결로 인해 민간기업 집단성과급인 경영평가성과급의 임금성과 관련된 다수의 재송이 촉발되었다.³⁾

이에 학계 및 실무에서도 경영성과급의 임금성에 관한 논쟁을 중심으로 ‘근로의 대가’의 개념(요건)과 판단 방법에 관한 다양한 견해가 제시되었다.⁴⁾ 근로의 대가에 대한 개념(요건)과 판단 방법에 관한 견해의 대립은 2019년 대법원이 ‘복지포인트’ 전원합의체 판결에서 임금성을 인정하면서 더욱 심화되었다.⁵⁾ 이는 대법원이 ‘공공기관 경영평가성과급’ 판결과 다르게 복지포인트의 임금성을 판단하면서 근로제공과 사용자의 금품 지급 간에 ‘직접 또는 밀접한 관련성’을 ‘근로의 대가’를 판단하기 위한 필

1) 대법원 2005. 9. 9. 선고 2004다41217 판결(현대자동차 사건); 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009다86246 판결(국민은행 사건)

2) 대법원 2006. 2. 3. 선고 2005다54029 판결(현대중공업 사건)

3) 매일노동뉴스 2021. 9. 7 기사, “경영성과급도 근로 대가” 불붙는 집단소송 (<http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=204814>)

4) 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼(제28호)」, 노동법이론실무학회, 2019; 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 「산업관계연구(제29권제3호)」, 한국고용노사관계학회, 2019.; 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 343호)」, 중앙경제, 2019.; 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 「노동법률(통권 343호)」, 중앙경제, 2019.; 정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 「노동법률(통권 340호)」, 중앙경제, 2019.; 박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총(제49집)」, 한국비교노동법학회, 2020.; 권오성, “경영 성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 346호)」, 중앙경제, 2020.; 이정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구”, 「외법논집(제44호 제2권)」, 한국외국어대학교 법학연구소, 2020. 임상민, “성과상여금의 (평균)임금성”, 「사법(55호)」, 사법발전재단, 2020.

5) 박종희, “복지포인트의 임금성”, 「노동법포럼(제28호)」, 노동법이론실무학회, 2019.; 한광수·김희성, “복지포인트의 임금해당성”, 「노동법논총(제48집)」, 한국비교노동법학회, 2020.



수적 요건으로 제시하였기 때문이다.

현재 민간기업 ‘경영성과급’의 임금성에 관한 하급심 판결이 연이어 내려지고 있으나 각 재판부마다 매우 상이한 결론이 내려지고 있어 논란이 되고 있다. 심지어 동일한 회사의 경영성과급 임금성 사건은 각각 다른 법원에 제기되었을 뿐 같은 사실관계 하에서의 판단이었음에도 상반된 결론이 내려짐에 따라 더욱 문제가 되었다.⁶⁾ 이러한 상반된 판결은 노사 양 당사자에게 극심한 혼란을 초래했을 뿐만 아니라 학계에도 ‘근로의 대가 및 경영성과급의 임금성 판단’과 관련한 논쟁을 야기하였다.⁷⁾ 위와 같은 배경으로 인해 최근에는 임금 개념의 핵심이 되는 ‘근로의 대가’의 의미와 판단 요건에 대한 다양한 견해와 이를 바탕으로 한 ‘경영성과급의 임금성 판단’에 대해 많은 연구가 이루어지고 있다.⁸⁾

따라서 본 연구는 「근로기준법」 상 임금의 가장 핵심 개념인 ‘근로의 대가’의 의미와 판단 요건 그리고 판단 방법을 명확히 확정하려는 시도를 기본으로 하면서, 이를 바탕으로 경영성과급의 임금성 인정 여부에 대해 판단하되, 비교법상 경영성과급의 임금성 인정 여부에 관한 보편적인 입장과 경영성과급을 포함한 임금성에 관한 분쟁을 근원적으로 해결하는 방법에 대해 고찰하도록 한다. 이를 통해 노사 당사자간에 법적안정성을 도모하고 경영성과급 제도 도입 및 운영을 더욱 활성화시켜 근로자들의 삶과 질의 향상에 기여함을 목적으로 한다.

-
- 6) 박용희, “삼성전자 퇴직금 소송, 법원서 판단 엇갈렸다…수원고법선 “근로자 패소””, 「노동법률(통권 362호)」, 중앙경제, 2021, 70면
- 7) 심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 「월간노동리뷰(2021년 8월호)」, 한국노동연구원, 2021; 박진엽 “집단적 경영성과급의 임금성”, 「법학연구(제30권 제3호)」, 경상대학교 법학연구소, 2022.
- 8) 조상욱, “경영성과급 임금성의 법적 쟁점”, 「노동법률(통권 367호)」, 중앙경제, 2021.; 김희성·성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼(제35호)」, 노동법이론실무학회, 2022.; 김희성·이준희, “경영성과급의 근로 대가성 인정요건에 관한 판례 검토”, 「노동법논총(제54집)」, 한국비교노동법학회, 2022.; 김희성, “성과배분으로서 경영성과급은 근로의 대가인 임금에 해당하는가”, 「노동법률(통권 371호)」, 중앙경제, 2022.; 신동윤·성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 「사회법연구(제46호)」, 2022.; 이셋별·권오성, “임금에 관한 최근 판결 경향의 검토”, 「노동법포럼(제36호)」, 노동법이론실무학회, 2022.; 최진수, “임금의 양대 요건으로 본 경영성과급”, 「노동법률(통권 371호)」, 중앙경제, 2022.



제2절 연구의 방법과 내용

「근로기준법」 상 임금 개념의 핵심이 되는 ‘근로의 대가’에 대한 논의를 하기 전에 앞서 제2장에서는 임금 일반론인 임금에 관한 본질, 임금 관련 법규정, 「근로기준법」 상 임금 보호의 가치에 관한 관점을 살펴보고자 한다. 이를 위해 ① 임금의 법적 성격에 관한 그간의 이론적 논의를 소개하여 임금의 본질을 밝히고, ② 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금 관련 법규정을 분설한 뒤 「근로기준법」 상 특정 급여 산출을 위한 도구적 개념인 평균임금·통상임금과 임금의 개념이 구분되는지 여부를 살펴본 후 ③ 「근로기준법」 상 임금과 「근로기준법」 외에 기간제법 등 노동관계법에서의 임금과의 관계 그리고 ‘근로의 대가’를 전제로 하지 않는 민법·사회보장법상 보수와의 비교를 통해 제2장에서 ‘근로의 대가’의 의미를 파악함에 있어 법정안정성과 합목적성 중 어느 것이 보다 중시되는 것이 합리적인지를 밝힌다.

제3장에서는 ‘근로의 대가’의 의미와 판단 요건 그리고 판단 방법을 명확히 확정하기 위해 ‘근로의 대가’에 관한 판례와 학설을 살펴보고 판례의 일관되지 못한 태도를 비판하며 다양한 학설이 제기된 점을 고려하여 ‘근로의 대가’에 관한 판례를 먼저 분석한 뒤 다양한 학설을 소개하고 이를 분석하여 ‘근로의 대가’에 관한 쟁점별로 견해를 밝힌다. ① 근로의 대가에 관한 판례를 분석하기 위해 i) 근로의 대가의 판단 지표에⁹⁾ 관한 종래 판례의 변화 과정을 살펴보고, 다양한 금품에 관한 임금성 판결에 대한 검토는 그간 많이 이루어진 점을 고려하여 ii) 최근 판결 중 임금성에 관한 많은 논란이 되었고 제4장에서 논의할 경영성과급의 임금성 판단과 관련하여 유의미성을 가지는 판결인 ‘개인성과급·공공기관 경영평가성과급·복지포인트 임금성 판결’을 중심으로 법원의 판결을 살펴본다. 이를 바탕으로 ② 근로에 대가에 관한 학설과 관련하여 최근 제기된 근로의 대가에 관한 학계의 다양한 견해를 소개하고 유형화하여 각 견해별 세부적인 차이를 파악하여 쟁점을 명확히 하도록 한다. ③ 이후 쟁점을 중심으로 ‘근로의 대가’의 의미, 판단 요건(요소)과 판단 방법에 관한 견해를 제시한다.

9) 판례는 근로의 대가를 판단함에 있어 판단 기준이 되는 사항이 요건인지 아니면 요소인지를 밝히고 있지 아니한바, 본 연구에서는 판례의 판단 기준이 되는 사항을 판단 지표라고 표현하도록 한다.



제4장에서는 본 연구의 핵심 주제인 경영성과급의 임금성을 판단하기 위해 경영성과의 배분과 경영성과급의 임금성에 관한 다양한 견해와 판결을 검토하고 비교법적 검토를 통해 임금성에 관한 분쟁을 해결할 방법을 모색한다. 이를 위해 ① 성과배분제를 간략히 소개하고, 현재 쟁송 중인 경영성과급의 의미와 특징 그리고 경영성과급의 연혁과 도입배경에 대해 살펴본다. ② 경영성과급의 임금성 인정 여부와 관련한 학계의 상반된 견해를 주요 쟁점별로 살펴본 후 이를 검토하여 경영성과급의 임금성 여부에 관한 견해를 제시한다. 또한 ③ 경영성과급의 임금성과 관련하여 유의미성을 가지는 최근 ‘개인성과급·공공기관 경영평가성과급·복지포인트 임금성 판결’과 앞서 제시한 경영성과급의 임금성 여부에 관한 견해와의 논리적 일관성을 밝힌 후 최근 경영성과급 임금성 관련 하급심 판결을 유형화 한 뒤 유사하거나 동일한 사실관계하에 있음에도 불구하고 상이한 결론을 내린 대표 사건을 비교분석하여 일관된 결론을 내리지 못하고 있는 하급심 판결의 문제점을 검토한다. ④ 일본, 미국, 독일의 임금 관련 법제도(개념과 요건) 및 경영성과급의 임금성 인정 여부를 검토하여 경영성과급의 임금성이 인정되는 것이 보편타당한지를 검토한 후, 일본, 미국, 독일에서 임금성 관련 논란이 제기되지 않거나 최소화하고 있는 방안을 살펴 비교법적 검토를 통해 임금성에 관한 분쟁을 근원적으로 해결할 수 있는 방법에 대해 고찰해본다.

마지막으로 제5장에서는 본고에서 마지막으로 제4장은 본고에서 논의된 내용을 요약·정리하면서 우리법 체계 내에서 경영성과급의 임금성과 관련한 논쟁을 해결하기 위한 입법적 제언을 첨언한다.



제2장 임금에 대한 일반적 논의

제1절 임금의 법적 성격

I. 임금의 법적 성격에 대한 검토 필요성

임금의 법적 성격에 관한 문제는 주로 일본에서 파업기간 중 임금청구권 및 임금공제의 범위와 관련하여 활발히 논의됐다.¹⁰⁾ 이러한 일본의 임금의 법적 성격 관한 논의는 우리나라 국내 학계에 수용되어 소개되었고, 파업기간 중 임금공제와 관련한 우리나라 대법원 판결에도 상당한 영향을 주었다.¹¹⁾ 그러나 1995년 대법원이¹²⁾ 전원합의체 판결을 통해 파업기간 중 임금공제에 대한 문제에 대한 입장을 명확히 하면서 논의의 실익이 크지 않게 되었고, 현재 우리나라에서의 독자적인 임금의 법적 성격에 관한 논의가 활성화되었다고 보기는 어렵다.

그러나, 임금의 법적 성격을 어떻게 파악하는지는 임금의 본질과 관련될 뿐만 아니라 임금법제의 해석과 적용 및 임금성 인정 범위나 방법(입증책임의 전환)에도 영향을 줄 수 있다.¹³⁾ 따라서 「근로기준법」 상 임금의 개념을 살펴보기 전에 앞서 임금의 법적 성격에 대한 그간의 이론적 논의를 살펴볼 필요가 있다. 따라서 이하에서는 임금의 법적 성격에 관한 대표적인 학설인 ‘노동대가설’과 ‘노동력대가설’을 소개한 후¹⁴⁾

10) 하경효, 「임금법제론」, 신조사, 2013, 11면

11) 이정, 앞의 논문, 146면

12) 대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결

13) 하경효, 「임금법제론」, 신조사, 2013, 11면

14) ‘임금이분설’과 ‘의사해석설’도 임금의 법적 성격에 관한 이론으로 설명하기도 하나(이정, 앞의 논문, 146면 이하 참조) 엄격하게 분류한다면 임금이분설은 노동력대가설을 구체화 한 것으로 사실상 다른 학설로 보기 어렵고, 의사해석설은 임금의 법적 성격에 관한 학설이기보다는 쟁의행위 기간 중 임금 청구권의 범위에 관한 학설이기 때문에 임금의 법적 성격 학설로 소개하지 않되 임금이분설은 대법원 판결의 변화 검토 시 살펴보도록 한다.



우리나라에서 독자적으로 제기되었던 ‘근로관계보상설’도 살펴본다. 더불어 임금이분설을 폐기한 우리나라 대법원이 임금의 법적 성격에 관해 어떠한 입장을 취하고 있는지를 살핀 후 임금의 법적 성격에 관한 견해를 제시하도록 한다.

Ⅱ. 임금의 법적 성격에 관한 학설

1. 노동대가설

노동대가설(근로대가설)은 근로계약을 「민법」 제655조(고용의 의의)상 고용계약과 같이 ‘근로자의 근로제공’과 ‘사용자의 임금지급’을 ‘교환계약’으로 보는 것을 전제로 한다.¹⁵⁾ 즉, ‘근로제공’과 ‘임금’ 간 쌍무적 관련성을 바탕으로 구체적인 근로제공에 대한 대가가 임금에 해당하며, 노동력의 처분을 사용자에게 맡기는 것은 근로계약의 이행 과정에 불과하기 때문에¹⁶⁾ 임금의 범위를 법문과 같이 제한적으로 해석하여 법적안정성에 보다 가치를 두게 된다.

따라서 노동대가설은 근로계약상 임금청구권이 근로자에게 발생한다고 보기 위해서는 근로자와 사용자의 합의에 의한 근로자의 ‘구체적인 근로’가 현실적으로 선제공되어야 한다(임금의 후불성)고 보며, 현실적으로 근로 제공과 관련 없는 금품은 임금에 해당하지 않는다고 본다.¹⁷⁾ 일본에서 이 학설을 대표하는 판결은 ‘明星電氣事件’이며,¹⁸⁾ 해당 사건에서 판례는 아래와 같이 판시하였다.

원고들은 우선 노동임금은 구체적 노동에 대한 대가가 아니고 근로자가 노동력을 사용자의 지배에 맡기는 것에 대한 대가이며, 즉 사용자의 처분권 하에 노동력이 놓여 있다는 사실에 의하여 임금청구권이 발생한다고 하는 견해에 입각하여,

15) 김상률, 「임금의 개념과 제도상 문제점에 관한 연구」, 박사학위 논문, 경북대학교, 2011, 38면.

16) 박지순·이진규, 앞의 논문, 171면

17) 문무기·윤문화·이철수·박은정, 『임금제도 개편을 위한 노동법적 과제』, 한국노동연구원, 2006, 34-35면 참조; 이정, 위의 논문, 146-147면 참조

18) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 『「근로기준법」 주해 I (제2판)』, 박영사, 2020, 226면.; 문무기외 3명, 앞의 책, 3면; 이정, 앞의 논문, 146-147면



본 건에서 원고들의 노동력은 회사의 지휘명령 하에 놓여 있기 때문에 임금청구권이 발생하였다고 주장한다. 그러나 근로계약은 민법의 고용계약보다 발전하고 노동법에 의하여 각종의 수정은 가해졌지만, 고용에 있어서의 ‘노무’에 대한 ‘보수’라고 하는 쌍무유상계약으로서의 기본적 성격은 근로계약에 있어서 ‘근로’에 대한 ‘임금’으로 승계되었다고 말할 수 있다. 따라서 근로계약의 이행으로서 구체적 근로가 있을 때 비로소 임금청구권이 발생하는 것이고, 노동력을 사용자에게 맡기는 것은 계약이행의 한 과정으로 취해진 것에 지나지 않는다고 해석하는 것이 바람직하다.¹⁹⁾

2. 노동력대가설

노동력대가설(근로관계대가설)은 근로가 종속노동이라는 것을 전제로 한다. 근로계약은 구체적인 근로제공 그 자체를 약속한 것이 아니라 일정한 조건하에 노동력의 처분을 사용자에게 맡긴 계약으로 본다.²⁰⁾ 즉, 임금이란 근로자가 자신의 추상적인 노동력을 사용자의 처분에 맡긴 것에 대한 대가로 보는 견해이다.²¹⁾ 구체적 노동에 대응하지 않는 부분도 단체협약이나 취업규칙에 지급조건이 명확히 규정되고 사용자의 지급의무가 발생한다면 근로의 대가로 인정하여야 한다고²²⁾ 보기 때문에 임금의 범위를 넓게 해석하여 근로자 보호라는 합목적성에 보다 가치를 두게 된다.

따라서 노동력대가설은 근로계약상의 임금청구권이 근로자에게 발생한다고 보기 위해서는 근로자가 근로계약에 따라 자신의 노동력을 처분 가능한 상태로 놔두면 되고, 설령 사용자가 이를 사용하지 않거나 사용할 수 없어서 현실적으로 근로 제공이 이루어지지 않더라도 근로자에게 귀책사유가 없는 한 근로자의 임금청구권 발생에는 영향이 없다고 본다. 노동력대가설을 지지했던 대표적인 판결로는 일본의 ‘國鐵室蘭棧橋事件’을 들 수 있고²³⁾ 해당 사건에서 판례는 아래와 같이 판시하였다.

19) 前橋地裁 1963. 11. 14. 判決(明星電氣附勞加民金集請求事件, 勞民集(14권 6호), 1419면)[문무기의 3명, 앞의 책, 35면 재인용]

20) 이정, 앞의 논문, 147면.

21) 김상률, 앞의 논문, 39면.

22) 박지순·이진규, 앞의 논문, 171면

23) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 226면 참조; 문무기의 3명, 앞의 책, 36면 참조; 이정, 앞의 논문, 147면 참조



“원래 근로계약이란 피용자가 그 노동력을 일정기간 사용자의 처분에 위임하고 사용자의 지휘에 좇아 근로를 제공할 것을 약정하고 사용자는 노동력의 대가로서 임금을 피용자에게 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이므로 임금청구권은 피용자가 사용자의 지배권 내에 들어가고 그 노동력을 사용자의 처분에 위임하는 것, 즉 직장편입에 의하여 발생한다고 해석하여야 하며, 일단 노동력이 직장에 편입된 이상 피용자가 현실적으로 채무의 본질에 좇아 노무에 종사하지 않더라도 그것이 피용자의 귀책사유에 해당하는 경우를 제외하고는 임금청구권을 상실하지 않는다.”²⁴⁾

3. 근로관계보상설

근로관계보상설은 앞서 살펴본 임금의 법적 성격에 대한 종래 학설을 비판하며 임금의 본질에 대해 밝히고자 우리나라에서 독자적으로 제기된 학설이다. 근로관계보상설에 의하면 근로자는 사용자와의 근로계약에 기하여 노무제공의 의무를 부담하게 되고 임금은 이러한 의무를 부담하는 관계를 유지하는 것에 대한 보상(근로제공의무 뿐만 아니라 충실의무에 대한 대가)으로서 지급되는 것으로 파악한다.

따라서 근로관계보상설은 근로관계의 유지를 임금채권의 발생 근거로 보기 때문에 임금청구권의 발생 시기를 ‘근로관계의 성립 시점’ 다시 말해 ‘근로자와 사용자간 근로계약 체결에 관한 의사표시의 합치가 이루어진 시점’으로 본다.²⁵⁾

4. 각 학설에 대한 검토

우선 노동대가설은 임금의 본질을 근로의 대가로 보기 때문에 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호상 임금의 정의 규정에 가장 부합하며 쌍무유상계약인 근로계약에 따라 노무급부에 대한 반대급부로서 임금의 본질을 파악할 수 있어 우리나라 법규정과 근로계약의 법적 성격에 가장 부합한다고 볼 수 있다. 그러나 노동대가설은 근로의 제공에 대한 대가로 지급되는 금품만을 임금으로 보기 때문에 노동대가설에 따르면 유

24) 札幌地裁室蘭支部 1964. 4. 8. 判決(國鐵室蘭棧橋事件, 勞民集, 15권 2호, 232면)

25) 이선신, 「임금의 유연성 제고에 관한 법리 연구」, 박사학위 논문, 고려대학교, 2010. 32면 이하



급주휴수당, 휴업수당 등 근로 제공이 없음에도 지급되는 각종 수당들을 임금으로 볼 수 없어 임금의 범위가 지나치게 협소하게 해석된다는 비판이 제기된다.²⁶⁾ 또한 노동대가설은 임금의 후불성을 전제로 하나 일본의 경우 일본 민법²⁷⁾의 법문에 명확하게 약속된 ‘노동을 종료한 후 보수를 지급한다’는 문구를 명시하고 있어 임금의 후불성에 대한 법적 근거가 있는 반면 우리나라 민법은²⁸⁾ ‘보수는 약정한 시기에 지급한다’고 규정하고 있을 뿐 처음부터 보수를 후불로 지급해야 한다고 규정하고 있지 않고 있어 우리나라에서는 법해석 측면에서 보더라도 임금의 후불성을 전제로 한 노동대가설을 적용하기 어렵다는 비판도 제기된다.²⁹⁾

반면 노동력대가설은 구체적인 근로의 제공과 관련이 없는 휴업수당, 가족수당, 물가수당 등 각종의 수당에 대해서도 임금성을 긍정할 수 있기 때문에 임금의 범위를 지나치게 협소하게 보는 노동대가설의 문제점을 극복할 수 있고, 현실적인 근로 제공이 없는 대기시간을 근로시간에 포함하여 임금청구권을 인정하는 것이 당연해진다는 점과 조업 장애 시 사용자에게 임금위험을 부담하게 하는 원칙을 설명함에도 유용하다는 장점이 있다. 그러나 노동력이라는 경제학상의 개념을 인격권이 전제된 노동법에서 사용하는 것은 바람직하지 않고 오늘날 스마트워크(원격근무·재택근무 등)과 같이 근로자가 자신의 노동력을 ‘사용자의 처분 가능한 상태’로 둔 것으로 볼 수 있는지 여부가 의문시 되는 새로운 근무형태와 관련하여 무리없이 설명에 한계가 있다는 비판이 제기된다.³⁰⁾

근로관계보상설은 최근 사용자의 급부 종류와 내용에 비추어 근로의 대가라고 보기 어려운 성질의 급부가 적지 않은데 이들 급부를 모두 임금에 포섭시킬 수 있다는 장점이 있다. 그러나 ‘임금’과 구분되는 ‘보상’이라는 보다 포괄적 의미의 용어³¹⁾를 사

26) 하경효, 앞의 책, 12면

27) 일본 민법 제624조(보수의 지급시기) ① 노동자는 약정한 노동을 종료한 후가 아니면 보수를 청구할 수 없다.

28) 우리나라 민법 제656조(보수액과 그 지급시기) ② 보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체없이 지급하여야 한다.

29) 이선신, 앞의 논문, 21면

30) 하경효, 앞의 책, 12-13면

31) 이선신, 앞의 논문, 33면



용하면서 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중 임금과 임금이 아닌 급부에 대한 구분이 어렵고 자칫 근로의 대가와 무관하게 사용자가 지급하는 모든 금품이 임금 범위에 포함되는 것으로 이해될 위험을 배제하기 어렵다는 비판이 제기된다.³²⁾

Ⅲ. 우리나라 판례³³⁾

1. 임금 이분설의 폐기

앞서 본 바와 같이 일본의 학설에 기해 우리나라에서도 임금은 근로의 대가로서 근로자가 근로계약상의 근로를 제공하는 것에 대한 보수를 의미하므로 현실적 근로제공을 전제로 하지 않고 근로자의 지위에 기해 발생하는 생활보장적 성격의 임금의 개념을 인정할 것인가에 대하여 논란이 있었다. 대법원은 한때 쟁의행위 기간 동안의 임금지급청구 문제와 관련하여 일본에서 노동력대가설을 보다 구체화 시키면서 등장한 임금이분설을 취하기도 하였다.

“쟁의행위로 인하여 사용자에게 근로를 제공하지 아니한 근로자는 무노동무임금의 원칙에 따라 일반적으로는 근로의 대가인 임금을 청구할 수 없는 것이지만, 임금 중 사실상의 근로제공에 대하여 교환적으로 지급받는 것이 아니라, 근로자로서의 지위 자체에 기하여 지급받는 생활보장적 부분으로서, 당해 근로계약의 해석상 사실상 근로를 제공하였는지의 여부와 관계없이 지급받도록 되어 있는 임금에 관하여는 위와 같은 무노동무임금의 원칙이 적용되지 않는다고 볼 것인 바, 어느 임금이 무노동무임금의 원칙이 적용되지 않는 생활보장적 임금에 해당되는지의 여부는, 당해 임금의 명목과는 관계없이, 단체협약이나 취업규칙 등에서 결근·지각·조퇴 등으로 근로를 제공하지 아니한 경우에 당해 임금을 감액하도록 규정하고 있는지의 여부 또는 그와 같이 규정된 바는 없더라도 종래의 관행이 그와 같은 경우에 당해 임금을 감액하여 왔는지의 여부 등을 참작하여 판단하여야 한다.”³⁴⁾

그런데 대법원은 1995년 ‘삼척군 의료보험조합 임금청구 소송 사건(이하 ‘삼척군의

32) 하경효, 앞의 책, 14-15면

33) 김상률, 앞의 논문, 36-37면.

34) 대법원 1992. 6. 23, 선고 92다11466 판결.



료보험조합사건'이라 한다.)'에서 전원합의체 판결³⁵⁾을 통해 근로의 대가를 엄격하게 파악하며 기존에 임금이분설을 취하던 판례의 입장을 전면 부정하며 무노동 무임금 원칙을 적용해야 한다고 판시하였다. 대법원은 모든 임금은 근로의 대가로서 '근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수'를 의미하기 때문에 현실에서 근로제공 없이 근로자로서의 지위에 기해 발생하는 생활보장적 성격의 임금이란 있을 수 없고, 우리나라의 법제상 임금을 사실상 근로를 제공한 대가로 받는 교환적 성격의 부분과 근로자로서의 지위에 기해 받는 생활보장적 성격의 부분으로 나눌 근거가 없다고 판시하여 그간의 임금이분설에 관한 논의를 일단락 짓고 임금일원론으로 판례의 입장을 변경하였다.

“모든 임금은 근로의 대가로서 '근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수'를 의미하므로 현실의 근로 제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생한다는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없고, 또한 우리 현행법상 임금을 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 2분할 아무런 법적 근거도 없다. 뿐만 아니라 임금의 지급 실태를 보더라도 임금은 기본적으로 근로자가 생활하는 데 필요한 생계비와 기업의 지불능력과의 상관관계에 따라 형성되는데 임금을 지불항목이나 성질에 따라 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 현실의 근로 제공과는 무관하게 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 나누고(이른바 임금2분설) 이에 따라 법적 취급을 달리하는 것이 반드시 타당하다고 할 수도 없고, 실제로 현실의 임금 항목 모두를 교환적 부분과 생활보장적 부분으로 준별하는 것은 경우에 따라 불가능할 수 있으며, 임금2분설에서 전형적으로 생활보장적 임금이라고 설명하는 가족수당, 주택수당 등도 그 지급 내용을 보면 그것이 근로시간에 직접 또는 비례적으로 대응하지 않는다는 의미에서 근로 제공과의 밀접도가 약하기는 하지만 실질적으로는 근로자가 사용자가 의도하는 근로를 제공한 것에 대하여 그 대가로서 지급되는 것이지만 단순히 근로자로서의 지위를 보유하고 있다는 점에 근거하여 지급한다고 할 수 없으며, 이러한 수당 등을 지급하게 된 것이 현실의 근로 제공과는 무관하게 단순히 근로자의 생활이나 지위를 보장하기 위한 것이라고 할 수도 없으므로, 이러한 수당 등을 현실적인 근로 제공의 대가가 아닌 것으로 보는 것은 임금의 지급 현실을 외면한 단순한 의제에 불과하다.”³⁶⁾

35) 대법원 1995. 12. 21. 선고, 94다26721 전원합의체 판결



2. 법적 성격에 관한 대법원 전원합의체 판결의 입장에 대한 견해 대립

앞서 살펴본 바와 같이 임금이분설을 폐기하고 임금일원론을 취한 전원합의체 판결 이후 대법원이 노동대가설 또는 노동력대가설 중 어느 견해를 취하고 있는지가 명확하지 않아 학계에서는 이를 규명하여 보고자 하는 노력이 있었다.³⁷⁾ 대법원 전원합의체 판결을 ① ‘노동대가설’을 취하고 있다고 보고 근로의 대가만이 임금 해당성의 판단기준이 된다는 의미로 해석하는 견해³⁸⁾, ② 1995년 전원합의체 판결 문구에 따라 ‘계약의사를 중심’으로 판단하되 ‘노동대가설’을 보충적으로 따른다는 견해³⁹⁾, ③ 대법원이 전원합의체 판결 전후 일관되게 임금을 “근로자가 자신의 노동력을 사용자의 지휘·처분 하에 두고 제공한 근로에 대한 대가”라고 판시하고 있기 때문에 노동력대가설을 취하고 있다는 견해⁴⁰⁾, ④ ‘노동대가설’의 입장인지 아니면 ‘노동력대가설’의 입장인지 분명하지도 않다는 견해⁴¹⁾ 등 다양한 견해가 제기되었다.

3. 검토

임금이분설을 폐기한 대법원의 삼척군의료보험조합사건 전원합의체 판결은 2013년 대법원의 갑을오토텍 통상임금 사건 전원합의체 판결에도 참조 판례로 인용되면서 통상임금의 외연을 넓히는 이론적 근거가 되기도 하였다. 이로 인해 대법원이 노동력대가설을 취하고 있는 것이 아니냐고도 볼 수 있지만, 대법원은⁴²⁾ “근로의 임금청구권

36) 대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결, 대법원 1996.10.25. 선고 96다5346 판결; 이외에 대법원 1996. 2. 9. 선고 93다4057 판결, 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결, 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다26561 판결, 대법원 1997. 3.25. 선고 96다723 판결 등도 같은 취지를 밝히고 있다.

37) 문무기 외 3인, 앞의 책, 38면

38) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 228면; 김영문·이상윤·이정, 『임금개념과 평균임금·통상임금의 산정범위』, 법문사, 2004. 23면,

39) 김유성, 「노동법 I」, 77면; 이정, 앞의 논문, 151면

40) 이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 「법제논단(2014년 4월호)」, 법제처, 2014, 9면.

41) 문무기, 앞의 책, 40면, 이선신, 앞의 논문, 20면.

42) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000다60890, 60906 판결



은 특별한 약정이나 관습이 없으면 근로를 제공함으로써 비로소 발생하는 것이고 근로자가 근로제공을 하지 않은 이상 그 대가관계인 임금청구권을 갖지 못한다”라고 판시하며 임금청구권의 성질에 대해 근로제공을 전제로 한다는 명확한 입장을 취한바 있는 점, 임금을 노동대가설로 파악하는 이상 모든 임금은 근로제공에 대한 교환적 성격의 반대급부이므로 임금에 해당하는 금품 중에는 별도의 보장적 부분이 인정될 수 없어 노동대가설이 대법원의 임금일원론에 부합한 해석이라는 점을 고려하면⁴³⁾ 법원이 노동대가설을 취하고 있다고 보는 견해가 보다 타당하다.

IV. 소결

오늘날 임금의 법적 성격에 관한 이론적 논의만을 가지고 연역적 방법에 따라 사용자가 근로자에게 지급하는 다양한 급부가 임금인지 아닌지를 결정하는 것은 어려운 문제이다. 앞에서 살펴본 바와 같이 임금의 본질에 관한 기존의 학설들은 부분적으로는 타당성을 갖지만 동시에 논리적 취약점을 가지고 있어서 임금의 본질을 모순 없게 충분하게 설명하고 있지 못하다. 따라서 임금의 법적 성격에 관한 상기 견해 중 어느 하나를 선택한다고 하더라도 그 학설이 예외 없이 사용자가 근로자에게 지급하는 각종 급부의 임금성 여부를 모두 판단해줄 수는 없다.

다만, 이러한 임금의 법적 성격에 대한 이론적 논의는 결국 임금의 범위를 넓게 볼 것인지 아니면 좁게 볼 것인지와 관련되고, 법적안정성과 합목적성 중 어느 것에 더 가치를 둘 것인지와 관련되기 때문에 임금의 법적 성격은 결국 임금의 개념에 대한 이해 태도와 불과분의 관계에 있게 되기 때문에 임금성에 대한 연구를 함에 있어 반드시 선행 검토되어야 하며 논의의 실익이 있다.

위와 같은 의미로서 임금의 법적 성격을 구분지어 본다면 i) 우리 「근로기준법」은 제2조 제1항 제5호 정의 규정에 임금을 “근로의 대가”라고 명확히 법상 규정하고 있는 점, ii) 대법원 전원합의체 판결이 임금일원론을 취하면서 근로의 대가라는 표현을 사용한 점, iii) 쌍무유상계약인 근로계약에 따라 노무급부에 대한 반대급부로서 임금이

43) 박지순·이진규, 앞의 논문, 172면



지급되는 것이고 임금청구를 위해서는 근로제공이 전제되어야 한다는 점, iv) 근로자의 근로제공이 없을 때 사용자의 귀책사유에 의한 이행불능이 인정되는 한도에서만 임금청구권이 발생한다는 점,⁴⁴⁾ v) 노동력관계설에 따르면 임금과 비임금을 구분할 필요가 없어 임금성이 지나치게 확장될 수 있다는 점, vi) 근로제공 없이 임금을 대신하는 주휴수당, 휴업수당 등의 급여는 법률상 근거가 있는 예외적인 경우에만 지급된다는 점을 고려한다면⁴⁵⁾ 임금의 법적 성격은 현실적인 노무급부에 대한 반대급부로서 파악하는 노동대가설이 우리 법제하에서 그간의 법원의 판결을 고려하면 보다 타당하다.

제2절 근로기준법상 임금의 개념

I. 임금 관련 법규정에 관한 체계적 검토 필요성

근로계약은 일종의 채권계약으로 근로자는 근로제공의무를 부담하고 사용자는 이에 대한 반대급부로서 임금을 지급한다. 따라서 무엇이 임금인지는 원칙적으로 당사자의 계약내용 형성의 자유에 의하여 당사자 간 의사표시의 합치에 따라 정해지게 되나, 근로관계 종속성으로 인해 개별 근로계약내용 형성에 있어 실질적 제약이 있기 때문에 이를 보충하기 위해 근로조건의 핵심인 임금에 대해 단체교섭을 하여 집단적 의사표시의 합치에 의해 임금에 관한 단체협약을 체결하게 된다. 위와 같은 이유로 임금을 법률로 정하는 것은 오히려 예외적이라고 할 수 있다.⁴⁶⁾

그러나, 우리나라 법제는 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호에서 임금에 관한 추상적 정의 규정을 두고 있고 이러한 추상적 임금 개념을 정점으로 특정 사유 발생 시 지급할 급여금의 산출 기초가 되는 평균임금(「근로기준법」 제2조 제1항 제6호 및

44) 현대 대부분의 일본학자가 취하는 견해[노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 229면]

45) 이수정·박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 「노동법포럼(제37호)」, 노동법이론실무학회, 2022. 197면

46) 김영문, “임금개념과 평균임금·통상임금의 산정범위”, 「기업법연구(제18권 제2호)」, 한국기업법학회, 2004. 45면



동법 시행령 제2조)과 통상임금(「근로기준법」 시행령 제6조)에 대해 각각 별도로 규정하고 있다. 즉, 당사자의 의사에 따라 결정될 임금의 개념을 입법자의 요청에 따라 법률로 규정하여 제한하고 있다.

또한 「근로기준법」 및 동법 시행령은 평균임금과 통상임금에 관한 법규정을 두고 있는데 후에서 살펴보듯이 평균임금성과 통상임금성은 임금과 같이 개념적 문제는 아니지만 근로자의 실질적인 편익 실현을 위해 평균임금성과 통상임금성이 인정되는 것은 중요한 문제가 된다. 따라서 임금, 평균임금, 통상임금의 관계를 어떻게 규정할 지에 따라 임금성은 개념적인 문제를 넘어 도구적 개념인 평균임금과 통상임금 산출에도 예기치 못한 결과를 초래할 수 있어 「근로기준법」상 임금의 범위를 어떻게 볼 것인지에 대한 방법론을 논하기 위해 평균임금·통상임금과 「근로기준법」상 임금이 법상 어떻게 규정되어 있고 각 개념이 구분되는지를 살펴본다.⁴⁷⁾

Ⅱ. 「근로기준법」상 임금

1. 「근로기준법」상 임금 정의 규정

「근로기준법」 제2조 제1항 제5호는 임금을 정의함에 있어 “임금이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.”라고 규정하고 있다. 이 조항에 따르면 근로관계에 의해 근로자가 수령하는 금품이 「근로기준법」상 임금에 해당하기 위해서는 ① 지급 주체가 사용자이어야 하고, ② 근로에 따른 대가로 지급되어야 하며, ③ 지급 명칭은 불문하지만, ④ 금품의 형태로 지급되어야 한다.

2. 임금 개념의 구성

(1) 사용자가 근로자에게 지급

사용자가 지급하는 금품이 임금이 되기 위해서는 근로관계 당사자 사이에 지급되

47) 임상민, “성과상여금의 (평균)임금성”, 「사법(55호)」, 사법발전재단, 2020, 1101, 1134면 참조



는 것이어야 한다. 따라서 금품의 지급과 수령 주체가 근로관계 당사자인 「근로기준법」 제2조 제1항의 사용자(제2호) 및 근로자(제1호) 해당하지 않으면 해당 금품은 임금이라고 볼 수 없다.

임금의 지급 주체는 사용자여야 하며 사용자가 아닌 제3자가 근로자에게 지급한 금품은 이를 「근로기준법」상 임금이라 할 수 없다. 따라서 i) 호텔이나 식당 등에서 고객이 지급한 봉사료는 사용자가 지급하는 것이 아닌 제3자가 지급하는 것으로 사용자가 고객으로부터 봉사료를 징구하여 배분하는 것이⁴⁸⁾ 아닌 이상 임금으로 보지 않는 것이 원칙이다. 또한 ii) 「근로복지기본법」에 따라 이를 설치한 사업주와는 별개로 법인격이 부여되어 독립된 정관과 기관에 의해 설치·운영되는 법인인 사내근로복지기금이 있고 동 기금이 목적사업을 통해 근로자에게 제공한 급부도 지급 주체가 사용자가 아니기 때문에 임금으로 볼 수 없다.⁴⁹⁾ 더불어 iii) 각종 사회보험제도에 따라 지급되는 보험급여나 지원금도 사용자가 지급하는 것이 아니므로 임금에 해당하지 않는다.⁵⁰⁾ 다만, 근로자가 부담하여야 할 보험료를 사용자가 납부하는 경우에는 해당 금품이 근로자에게 직접 지급되지 아니하더라도 임금으로 볼 수 있다.⁵¹⁾

임금 수령 주체는 근로자여야 하며, 수령 주체가 「근로기준법」상 사용종속관계⁵²⁾ 하에서의 근로자로 인정될 수 없는 경우에는 임금이라고 할 수 없다. 따라서 업무집행권을 가진 등기이사나⁵³⁾ 사용종속관계가 없거나 인적 종속성 없이 경제적 종속성만 인정될 수 있는 보험설계사, 학습지교사 등에게 지급되는 보수는 「근로기준법」상 임금이라고 볼 수 없다.

48) 대법원 1992. 4. 28 선고 91누8104 판결 : 사용자가 고객으로부터 대금의 일정비율을 봉사료 명목으로 일률적으로 받아 모아두었다가 정기적으로 전체 근로자에게 총액을 균등분배하는 경우는 명칭만 봉사료일 뿐이고 실질적으로는 영업에 따른 판매대금의 일부에 해당하는 것으로 그 자체가 임금에 해당된다.

49) 2020-06-02, 퇴직연금복지과-2379

50) 대법원 1994. 7. 29. 선고 92다30801 판결

51) 하경효, 앞의 책, 49면

52) 인적종속성이 인정되어야 하며 경제적 종속성만 인정되는 경우 「근로기준법」상 근로자로 볼 수 없다.

53) 김유성, 앞의 책, 76면



(2) 근로의 대가

근로의 대가 즉, 근로제공에 대한 대가는 임금의 개념을 구성하는 가장 핵심 개념이 된다.⁵⁴⁾ 설사 사용자가 근로자에게 금품을 지급한다고 하더라도 근로의 대가로 지급한 것에 대해서만 임금성이 인정되기 때문에 근로의 대가가 아닌 i) 근로제공과 관련 없이 특수한 조건이나 환경에서 직무를 수행함으로 인해 추가적으로 소요되는 비용을 변상하기 위해 지급한 금품(실비변상적 급부)이나 ii) 사용자가 지급의무 없이 은혜적으로 지급하는 금품(은혜적 급부)⁵⁵⁾ iii) 사용자의 지급의무가 있더라도 돌발적인 사유에 따라 지급되는 급여(임의적 급부)⁵⁶⁾ iv) 근로자가 순수하게 복리후생시설을 이용한 그 자체는 원칙적으로 임금이라 말하기 어렵다.⁵⁷⁾ 임금의 개념을 구성하는 핵심인 근로의 대가의 의미와 판단 요건에 대한 구체적인 사항은 이하 ‘제3장 임금 판단의 핵심 요건인 근로대가성’에서 자세히 살펴본다.

(3) 명칭 불문

임금성 여부 결정의 핵심은 근로의 대가로 지급되는지 여부이다. 따라서 사용자가 지급하는 금품의 실질적 성격이 아닌 명칭만을 기준으로 임금성 여부가 달라져서는 아니된다. 즉, 복리후생비나 여비 등의 명칭으로 지급되었다고 하여 임금성이 부정된다고 단정할 수 없으며, 당사자의 의사 등 제반사정을 살펴보고 그것이 실질적으로는 근로자의 근로제공에 대한 반대급부로서 지급된 것이라면 「근로기준법」상 임금으로 보아야 한다.⁵⁸⁾

(4) 일체의 금품

임금은 금품이어야 한다. 임금으로 지급되는 금품은 대체로 금전으로 지급되는 것이 일반적일 것이나, 상품권 등 유가증권뿐만 아니라 현물이나 시설의 제공 등 이익을

54) 하경효, 앞의 책, 41면; 박은규, 앞의 논문, 77면

55) 박지순·이진규, 앞의 논문, 177면

56) 김형배, 앞의 책, 416면

57) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 251면

58) 하경효, 앞의 책, 50-51면



제공하는 것도 모두 포함된다고 보는 것이 타당하다. 이와 관련하여 「근로기준법」 제43조 제1항에서 임금의 통화불 원칙을 규정하고 있어 통화로 지급되지 않는 것은 임금으로 볼 수 없는지에 관한 문제가 제기되지만 「근로기준법」 제43조 제1항은 적법한 임금의 지급 효과가 발생하였는지 여부를 판단함에 있어서만 적용되며, 통화 이외의 다른 지급 수단이 사용되었다고 하여 임금에서 제외된다고 볼 수 없다.⁵⁹⁾

Ⅲ. 「근로기준법」 상 평균임금·통상임금

1. 검토 필요성

평균임금은 법령이 정하는 산정 사유 발생을 전후하여 근로자가 통상적인 생활을 유지하도록 하는데 산출의 목적이 있어 사후적 개념인 반면, 통상임금은 임의의 근로를 제공하기 이전에 연장근로 등에 대한 가산임금을 산정할 수 있도록 함으로써 연장근로 등에 대한 의사결정을 가능하게 하려는데 산출의 목적이 있어 사전적 개념이다. 즉, 평균임금과 통상임금은 여러 가지 특정 사유가 발생하는 경우 적용할 급여금의 산출을 위한 도구적 개념이다.⁶⁰⁾ 따라서 평균임금 및 통상임금은 본질적으로 개념상 문제인 임금과는 다르게 실제적인 편익상의 문제(쟁송의 대상)가 된다.⁶¹⁾

일본과 같이 평균임금·통상임금의 각 산출 목적에 맞게 기간 등을 고려하여 임금의 일부를 제외하는 별도의 법규정을 두고 있는 경우 임금성을 넓게 인정하더라도 평균임금·통상임금은 법규정에 의거 제한이 되기 때문에 임금성을 넓게 인정하더라도 편익 실현을 위한 쟁송에 미치는 영향이 작을 수 있지만 임금과 평균임금·통상임금이 일치할 경우 임금은 단순히 개념상의 문제를 넘어서 편익상의 문제(쟁송의 대상)가 되며 임금성 범위를 지나치게 넓게 해석할 경우 평균임금·통상임금산정 취지에 부합하지 않은 결과가 도출될 수 있다. 따라서 임금의 개념(요건)과 판단방법을 정립함에 앞서 우리나라 법제상 임금과 평균임금·통상임금 간의 관계(준별 가능 여부)에 대해 살

59) 사법연수원, 「해고와 임금」, 2016, 99면

60) 김형배, 앞의 책, 410면

61) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 278면



떠볼 실익이 있다.

2. 평균임금과 통상임금 관련 법령

(1) 평균임금

「근로기준법」은 아래와 같이 제2조 제1항 제6호에서 평균임금의 정의 규정을 두고 있으며, 3개월 동안에 지급된 임금총액을 그 기간의 총일 수 나눈 금액을 말한다고 규정하고 있으나 대법원은 3개월을 초과하여 지급하는 임금의 경우에도 평균임금 산정 시 임금총액에 산입하고 있다. 다만, 동법 시행령 제2조 제2항에서는 임금성이 인정되더라도 임시로 지급된 임금 및 수당은 평균임금 산정 시 임금의 총액에 포함하지 않도록 규정하고 있다.

「근로기준법」 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

6. “평균임금”이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.

「근로기준법」 시행령 제2조(평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금)

① 「근로기준법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호에 따른 평균임금 산정 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간이 있는 경우에는 그 기간과 그 기간 중에 지급된 임금은 평균임금 산정기준이 되는 기간과 임금의 총액에서 각각 뺀다.

<1.~8. 생략>

②법 제2조제1항제6호에 따른 임금의 총액을 계산할 때에는 임시로 지급된 임금 및 수당과 통화 외의 것으로 지급된 임금을 포함하지 아니한다. 다만, 고용노동부장관이 정하는 것은 그러하지 아니하다.

평균임금은 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조, 제13조에 따라 퇴직금과 확정급여형 퇴직연금, 「근로기준법」 제46조에 따라 휴업수당, 동법 제60조 제5항에 따라 연차휴가수당, 「근로기준법」 제79조, 제79조, 제80조, 제82조, 제83조, 제84조에 따라 휴업·



장해·유족보상과 장례비, 일시보상, 「산업재해보상보험법」 제36조, 제52조, 제57조, 제62조, 제67조, 제71조, 제74조에 따라 휴업·장해·유족급여, 상해보상연금, 장의비, 직업훈련수당 등 보험급여 등의 지급기준이 된다.

(2) 통상임금

통상임금은 「근로기준법」에 정의 규정을 두고 있지 않고, 동법 시행령 제6조 제1항에 정의 규정을 두고 있다. 대법원은 2013년 전원합의체 판결을 통해 ‘소정근로의 대가, 정기성, 일률성, 고정성’이 통상임금의 인정을 위한 판단 요건임을 명확하였다.⁶²⁾

「근로기준법」 시행령 제6조(통상임금) ①법과 이 영에서 “통상임금”이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

②제1항에 따른 통상임금을 시간급 금액으로 산정할 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정된 금액으로 한다.

통상임금은 「근로기준법」 제2조 제2항에 따라 평균임금의 최저한도, 「근로기준법」 제26조에 따라 해고예고수당, 「근로기준법」 제46조에 따라 휴업수당의 최고한도, 「근로기준법」 제55조에 따라 유급주휴일, 「근로기준법」 제60조 제5항에 따라 연차유급휴가수당, 「근로기준법」 제74조 제4항에 따라 출산전후휴가수당 등의 지급기준이 된다.

(3) 검토

평균임금 및 통상임금에 관한 「근로기준법」 및 동법 시행령 그리고 대법원 전원합의체 판결을 살펴본 결과 임금 중 ‘소정근로의 대가, 정기성, 일률성, 고정성’ 요건을 충족하지 않은 경우는 통상임금성이 배제될 수 있어 임금성이 넓게 인정되더라도 산정 취지에 부합한 결과를 도출할 수 있을 것으로 보이나, 평균임금의 경우 임시로

62) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결



지급된 임금 및 수당과 통화를 제외하고는 임금성이 인정될 경우 평균임금 산정 시 모두 산입하는 것으로 규정되어 있다.

3. 평균임금·통상임금과 임금의 구분 가능성

(1) 현행 법제 하에서 구분 가능한지 여부에 대한 견해

우선 통상임금의 경우 임금성이 인정된다고 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 대법원이 판시한 통상임금의 요건인 ‘고정성’과 ‘소정근로의 대가’에 해당되지 않을 경우 통상임금에 산입될 수 없다. 따라서 임금성과 통상임금의 개념은 구분될 수밖에 없고 이를 부정하는 견해를 취하는 경우는 없는 것으로 보인다. 그렇다면 평균임금도 통상임금과 마찬가지로 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금과 구분이 가능한지에 대해 살펴보면 아래와 같이 견해가 나뉜다.

「근로기준법」 제2조 제1항 제6호의 평균임금에 산입될 임금총액 상 임금의 요건(이하 ‘평균임금의 요건’이라 한다)과 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금의 요건에 대해 ① 구분가능설은 i) 「근로기준법」 시행령 제2조 제2항에서 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’ 등을 평균임금에서 제외한다고 규정하고 있는 점 ii) 평균임금의 목적이 통상적인 생활임금을 유지하도록 하는것에 있다는 점, iii) 부당해고 시 임금상당액 청구, 기간제 근로자 등의 차별, 쟁의행위 기간 중 임금 산정과 같이 평균임금성이 문제되지 않고 임금성만 문제되는 경우 등이 있는 점, iii) 평균임금은 근로자의 통상적인 생활을 유지하는 것에 목적이 있어 그러한 목적에 부합하지 아니한 「근로기준법」 상 임금을 평균임금 산출 시 배제하는 것인 합리적이라는 점 등을 이유로 구분이 필요하다고 보며, 현행 법제상으로도 가능하다고 본다. 이러한 이유로 추후 살펴볼 근로의 대가에 관한 판단지표 중 계속성·정기성이나 지급액의 사전확정성 여부는 임금성 지표가 아닌 평균임금성 지표가 되어야 한다고 본다.⁶³⁾

반면 ② 구분불가설은 i) 평균임금은 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 말한다 고 규정되어 있어 임금은 모두 평균임금 산정에 포함되는 점, ii) 비록 「근로기준

63) 임상민, 앞의 논문, 1101-1105면



법」 시행령 제2조 제2항이 ‘임시로 지급된 임금 및 수당과 통화 외의 것으로 지급된 임금’을 평균임금에서 제외한다고 명시되어 있지만 우리나라는 일본과 달리 3개월을 초과하는 기간을 단위로 지급되는 임금을 평균임금에서 제외하고 있지 않아 평균임금의 요건과 임금성의 요건이 다르다고 보기 어려워 구분이 불가하다고 본다.⁶⁴⁾

(2) 판례의 태도

법원은 평균임금이 아닌 임금성만 문제되는 사안(쟁의행위 시 무노동 무임금 적용, 부당해고시 임금상당액 지급)에서도⁶⁵⁾ ‘계속성·정기성’을 판단요소로 삼고 있어 임금성 요건과 평균임금 요건을 별도로 구분하지 않는 구분불가설을 취하고 있는 것으로 보인다.

각 상여금은 단체협약에 의하여 정하여진 시기에 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있으므로 근로의 대가로서의 임금에 해당하고, 쟁의행위 기간 중에는 임금이 지급되지 아니하는 것이 원칙이므로 사용자는 각 상여금의 산정 기간 내에 있는 태업시간에 상응하는 상여금 역시 원고들에게 지급할 의무가 없다고 본 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상여금에 관한 무노동 무임금 원칙 및 노동관행에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 등의 위법이 없다.⁶⁶⁾

사용자의 부당한 해고처분이 무효이거나 취소된 때에는 그동안 피해고자의 근로자로서의 지위는 계속되고 있었던 것이 되고, 근로자가 그간 근로의 제공을 하지 못한 것은 사용자의 귀책사유로 인한 것이라 할 것이니 근로자는 민법 제538조제1항에 의하여 계속 근로하였을 경우에 받을 수 있는 임금 전부의 지급을 청구할 수 있는바, 여기에서 근로자가 지급을 청구할 수 있는 임금은 「근로기준법」 제2조에서 규정하는 임금을 의미하므로, 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금원으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있다면 그 명칭 여하를 불문하고 모두 이에 포함되며, 반드시 통

64) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 278면

65) 기간제 차별은 임금성 외에도 다른 근로조건의 차별도 금하고 있어 임금성만 문제되는 사안이라고 볼 수 없어 제외함

66) 대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다39946 판결



상임금으로 국한되는 것은 아니다.⁶⁷⁾

(3) 검토

평균임금이 통상의 생활을 보장하기 위한 실생활임금이라는 점과 이러한 취지를 「근로기준법」 시행령 제2조 제2항에서 수용하여 평균임금 산정 시 특별히 임시로 지급되는 임금과 수당을 제외하도록 하는 규정 두고 있는 점(단, 시행령 제2조 제2항이 평균임금과 임금을 구분하기 위한 취지로 규정된 조항이라고 보기는 어렵고 실생활임금이라는 평균임금의 취지만을 고려한 조항이라고 보임)을 고려하면 임금성이 인정된다고 하더라도 평균임금에 산입하지 않는 것이 적합하지 않은 임금이 있을 수밖에 없다.

평균임금은 근로제공에 대한 대가로 지급되어야 할 임금과 같은 목적물이 아니라 특정 상황에서 지급액을 산출하기 위한 도구적인 개념이다. 법원이⁶⁸⁾ 개별 사안별로 「근로기준법」 및 동법 시행령에 따라 산출될 평균임금이라고 하더라도 평균임금의 취지에 맞는지를 고려(현저하게 적거나 많게 산정된 경우에 평균임금 기간과 임금에서 제외)하여 평균임금 산출 시 해당 기간과 해당 기간 중 지급된 임금을 제외하고 있는 것과 같이, 임금성(평균임금에 산입할 임금총액에 산입)이 인정되는 수당을 포함하여 산출한 수준이 통상적인 생활임금을 반영하지 못하고 있다면 해당 금품은 평균임금 산정 시 임금 총액에서 제외해야 하는 것이 타당하며 「근로기준법」 시행령 제2조에서 이러한 취지를 반영하고 있는바, 임금성 판단 요건과 평균임금 판단 요건은 구분될 수 있다고 보는 것이 보다 타당하다.

IV. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 「근로기준법」은 제2조 제1항 제4호의 근로계약의 정의에 따라 임금의 의미를 도출하여 해석할 수 있음에도 불구하고 특별히 제5호에서 임금에

67) 대법원 2012. 2. 9 선고 2011다20034 판결

68) 대법원 2009.5.28. 선고 2006다17287 판결; 대법원 2020.6.25. 선고 2018다292418 판결



관한 정의를 규정하고 있다. 이러한 임금의 정의 규정은 1953년 「근로기준법」 제정(법률 제286호, 1953. 5. 10, 제정) 당시의 정의 규정과 실질적인 차이가 없음에도⁶⁹⁾ 불구하고 법이 제정된 과거부터 수십년이 지난 현재까지도 사용자가 근로자에게 지급한 각종 수당과 복리후생비의 임금성에 대해 끊임없는 논의와 분쟁이 지속되고 있다. 이는 앞서 살펴본 바와 같이 그간 추상적인 임금 관련 정의 규정에만 근거해 ‘근로의 대가’의 의미에 대한 구체적인 고찰 없이 개별 사안 별로 임금성 여부를 판단해왔기 때문일 것이다.

물론 다양한 명칭의 수당과 복리후생의 임금성을 밝히는 것은 쉬운 문제가 아니다.⁷⁰⁾ 그러나 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 규정은 임금과 임금 이외의 급여를 확정하는 기준이 되는 규정이자 「근로기준법」 및 노동관계법상 임금과 관련한 다양한 규정의 적용 여부를 결정함에 있어 가장 먼저 통과되어야 하는 관문이다. 비록 추상적 규정이라고 하더라도 입법자가 임금에 대해 별도의 정의 규정을 명시적으로 두고 이를 준수하도록 한 이상 임금성이 인정되기 위해서는 법문의 구성 요건을 반드시 충족하여야 하며 이러한 법문에 충실하게 해석하여야 한다.

「근로기준법」 제2조 제1항 제5호상 임금의 개념을 정리하면 ① 「근로기준법」상 사용자가 「근로기준법」상 근로자에게 지급하여야 하며, ② 외견상 명칭보다는 그 실질적인 성격이 임금에 해당하여야 하며, ③ 지급 형태는 금전, 유가증권, 현물 등 통화 이외의 지급수단도 포함되나, ④ 반드시 ‘근로의 대가’라는 것이 전제되어야 하기 때문에 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이라고 하더라도 ‘근로의 대가’를 충족하지 못한다면 임금성이 인정될 수 없음을 확인할 수 있었다. 따라서 법치주의에 따라 임금성을 판단함에 있어서는 입법자의 의사를 존중하여 “근로의 대가”를 전제로 임금성 여부를 판단하고 해석하여야 한다.

69) 실제 근로의 대상이 대가로 변경된 것 외에는 차이가 없음

「근로기준법」 제정 당시 임금 정의 규정	현행 「근로기준법」 상 임금 정의 규정
본법에서 임금이라 함은 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 임금, 봉급 기타 여하한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.	“임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.

70) 이달휴, 앞의 논문, 9면.



한편, 종래 임금에 관한 논의는 임금 그 자체보다는 평균임금·통상임금을 중심으로 이루어졌고 2013년 대법원은 전원합의체 판결을 통해 통상임금의 외연을 넓히면서도 그 요건을 명확히 하였지만, 임금의 개념(요건)과 판단 방법에 대해서까지 명확한 입장을 밝혔다고 보기는 어렵다. 특히 평균임금성과 임금성을 별도로 준별하고 있는지도 불분명하다. 「근로기준법」 및 동법 시행령은 임금 정의 규정과 별도로 평균임금·통상임금을 법령에 규정하고 있는데 평균임금과 통상임금은 특정 급여 산출을 위한 도구적 개념으로 각 목적에 맞게 산출되어야 한다. 따라서 임금·평균임금·통상임금의 요건 및 범위는 개념적으로 일치될 수는 없다. 다만, 평균임금의 경우 앞서 살펴보았듯이 우리 법제는 임시로 지급된다는 제한 조건 외에 ‘임금’과 ‘평균임금 산정 시 임금 총액에서의 임금’을 명확히 구분하지 않고 있다. 이로 인해 「근로기준법」상 임금의 개념(요건) 및 판단방법의 정립은 「근로기준법」상 평균임금을 기본개념으로 활용하고 있는 「근로기준법」 및 다른 법령에도 영향을 미칠 수밖에 없다. 결론적으로 임금, 평균임금·통상임금에 관한 우리나라의 법령 간의 관계를 고려하면 임금의 개념(요건)과 판단방법을 정립함에 있어 법적안정성과 합목적성의 적절한 균형이 더욱 요구된다.

제3절 임금 관련 법제의 구조와 비교

I. 임금 관련 법제 구조와 각 법령간 비교 필요성

2003년 ILO⁷¹⁾의 협약 및 권고의 적용에 관한 전문가 위원회는⁷²⁾ “Protection of wages” 보고서에서 전 세계적으로 임금 총액에 변함이 없으면서 임금의 개념에서 벗어나는 복지 혜택이나 수당을 도입하는 ‘비임금화(desalarization) 정책’으로 인해 각국의 법제하에서 임금으로서 법적인 보호를 받고 있는 임금의 개념이 상실될 정도에 이르렀다는 문제점을 지적하면서도 비임금화 정책이 ILO 제95호 협약 제1조의 임금

71) International Labour Organization

72) the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations



의 정의 규정의⁷³⁾ 취지에 반하는 것은 아니지만, 비임금적 성격의 수당이 제95조 협약을 적용함에 있어 임금의 관한 법적 보호의 범위 내에서 포괄될 수 있도록 하는 조치를 취해줄 것을 요구한바 있다. 이러한 ILO의 입장에서 알 수 있듯이 임금의 개념과 범위는 임금에 관한 법적 보호와 밀접한 관련성을 가진다.⁷⁴⁾

현행 임금에 관한 법제를 살펴보면 「근로기준법」과 노동관계법인 「최저임금법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「임금채권보장법」, 「근로자퇴직급여 보장법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등 다양한 법령에서 임금에 관한 특별한 보호를 위해 임금에 관련 법규정을 두고 있다. 한편 민법은 임금청구권과 관련하여 가장 기초가 되는 법률로⁷⁵⁾ 임금에 상응하는 개념으로 ‘보수’라는 개념을 법상 규정하고 있다. 참고로 사회보험법에서도 보험료 징수의 기준으로 ‘보수’라는 개념을 법상 규정하고 있으며 사회보장법상 보수는 다시 소득세법 상 과세의 기준이 되는 ‘근로소득’이라는 개념을 통해 구체화 된다.

「근로기준법」상 임금의 개념에 관한 법체계적 해석을 위해 노동관계법 상 임금 관련 법 규정을 정리하고, 임금과 다른 용어인 보수·근로소득에 대해 민법, 사회보장법, 소득세법 상 법 규정을 정리한 후 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금과 유기적인 관계를 밝혀보도록 한다. 이를 통해 법체계적으로 사용자가 지급하는 금품을 근로의 대가인 ‘임금’과 근로의 대가와 무관한 ‘임금 외의 금품(비임금)’으로 구분할

73) 제95호 임금보호 협약(1949년)

제1조 이 협약에서 임금이라 함은 명칭 또는 계산방법의 여하를 불문하고 금전으로 평가할 수 있고, 쌍방의 합의나 국내의 법령으로 정해진 보수 또는 소득으로, 완성되었거나 앞으로 완성될 일 또는 제공되었거나 앞으로 제공될 용역에 관하여 사용자가 문서 또는 구두에 의한 고용계약에 의거하여 근로자에게 지불하는 것을 말한다.

임금보호협약의 주요 내용 금전으로 지불되어야 할 임금은 법정화폐로 지불되어야 함. 수표를 통한 임금지급은 특수한 사정이 있을 때에 한하여 가능 부분적인 현물지급은 그것이 관례이거나 바람직한 상황 혹은 근로자나 그 가족의개인적인 용도·이익을 위하여 적합한 경우일 때 가능 임금은 통상 해당 근로자에게 직접 지불되어야 하며, 근로자가 사업장내 매점 사용을 강요받지 않고 자신의 임금을 자유롭게 처분할 수 있는 자유를 보장하여야 함 이 협약은 임금에서의 공제가 허락되는 범위를 규정·제한. 임금은 근로자 및 그 가족의 생활에 필요하다고 인정되는 한도에서, 차압 또는 양도에 대하여 보호를 받아야 함. 기업의 파산 혹은 사법상의 청산의 경우에 임금은 우선적 채권으로 취급되어야 함[고용노동부 국제기구담당관실, ILO 주요 협약(2012), 139.]

74) 문무기의 3명, 앞의 책, 29면

75) 하경효, 앞의 책, 33면



필요성이 있는지를 밝힌다.

Ⅱ. 노동관계법 상 임금 관련 규정

1. 「근로기준법」 상 임금 관련 규정

「근로기준법」상의 임금보호규정은 임금지급 보호 규정, 임금채권 보호 규정, 임금수준 보호 규정으로 나눌 수 있다.⁷⁶⁾

① 「근로기준법」 상 임금 지급에 관한 보호 규정으로는 제21조 전차금 상계 금지 규정(5백만원 이하 벌금), 제36조 퇴직시 금품청산의무 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 : 이를 강제하기 위해 제37조에서 금품청산의무 위반 시 지연이 자율 규정), 제43조 임금 지급시 직접불, 전액불, 통화불 매월 1회 이상의 일정기불의 원칙을 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 : 이를 강제하기 위해 제43조의 2 및 제43조의3에서 체불사업주 명단 공개와 임금 등 체불 자료의 제공 규정), 제45조 출산, 질병, 재해 등 비상시 임금 지급 규정(1천만원 이하 벌금) 등이 있다.

② 임금채권 보호 규정은 제38조 임금채권의 우선변제 규정, 제44조·제44조의2 도급사업에 대한 임금지급 및 건설업에서의 임금 지급 연대책임 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금), 제44조의3 하도급 근로자의 임금채권 확보 규정(건설업에서의 특례 규정), 제49조 임금의 시효 규정이 있다.⁷⁷⁾

③ 임금수준 보호 규정은 제46조 휴업수당 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금), 제47조 도급제근로자에 대한 일정액 임금 보장 의무 규정(500만원 이하 벌금), 제56조 연장·야간·휴일근로에 대한 임금 가산 지급률 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)이 있다.

76) 체계적 설명을 위해 임의로 분류하였다.

77) 김형배·박지순, 174면에 따르면 민법 제163조 제1호의 금료 채권과 시효가 동일하기 때문에 「근로기준법」 상 특별한 보호라고 보기는 어렵다.



2. 기타 노동관계법 상 임금 관련 규정

「근로기준법」 외에도 노동관계법 상 다수의 임금 관련 법 및 규정이 있으나, 대표적인 것은 「최저임금법」, 「임금채권보장법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「근로자퇴직급여 보장법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등이 있다.

① 최저임금제는 원래 「근로기준법」에 규정되어 있었으나, 1986. 12. 31 「최저임금법」이 제정되면서 대체되었다.⁷⁸⁾ 최저임금법 제4조 및 제5조는 최저임금의 결정 기준과 최저임금액을 규정하고 있고, 제6조는 최저임금 이상 지급의무와 위반 시 효력 그리고 귀책사유 있는 도급인의 수급인 소속 근로자에 대한 최저임금 준수의 연대책임의무를 규정(3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)하고 있다.

② IMF 이후 우리나라 경제가 불황에 빠져들면서 기업들의 대량도산사태와 대량실업이 발생하면서 1998. 2. 20 「임금채권보장법」이 제정되었다.⁷⁹⁾ 동법 제7조는 퇴직한 근로자에게 미지급된 「근로기준법」 제38조 2항 1호에 의한 임금(최종 3개월분) 및 「근로자퇴직급여보장법」 제12조제2항에 따른 퇴직급여(최종 3년간), 「근로기준법」 제46조에 따른 휴업수당(최종 3개월분), 「근로기준법」 제74조 제4항에 따른 출산전후휴가 기간 중 급여(최종 3개월분)를 국가가 사업주를 대신하여 지급을 보장(체불임금 등 대지급금 제도)하고 있다. 2021. 4. 13 법개정을 통해 재직근로자에 대해서도 체불임금의 대지급금 제도를 운영하고 있고, 동법 제7조의2에서 이를 규정하고 있다.

③ 고용에 있어서 남녀의 평등한 기회 및 대우를 보장하고, 모성을 보호하며, 직업능력을 개발함으로써 근로여성의 복지증진에 기여하기 위해 1987. 12. 4 남녀고용평등법이 제정되었다. 현행 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제8조는 남녀의 동일 가치 노동에 대해 동일한 임금 지급 의무를 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)하고 있다.

④ 「근로기준법」에 따라 일시금 위주로 운영되고 있는 퇴직금제도를 인구 고령화에 대응하여 퇴직연금제도로 전환할 수 있도록 2005. 1. 27 「근로자퇴직급여 보장

78) 김형배, 357면

79) 김형배, 411면



법」이 제정되었다. 동법 제4조는 제1항은 퇴직급여제도의 설정에 관한 규정이며, 제2항은 퇴직급여제도 차등설정 금지에 관한 규정(2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)이며 제8조는 퇴직금제도의 설정에 관한 규정이며 제9조제1항·제17조제2항·제20조제5항은 퇴직금 또는 확정급여형퇴직급여를 퇴직 후 14일 이내 지급하도록 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금)하고 있으며, 제23조의7은 연 1회 확정기여형퇴직금제도의 사용자부담금을 납입하도록 규정(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금)하고 있으며, 제12조는 퇴직급여 등의 우선변제에 관해 규정하고 있다.

⑤ 기간제근로자, 단시간근로자 등 비정규직 근로자가 급격히 증가하고 이들 근로자에 대한 차별적 처우와 남용행위가 사회적 문제로 대두됨에 따라, 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 사용자의 남용행위를 규제함으로써 이들 근로자의 근로조건을 보호하고 노동시장의 건전한 발전을 도모하고자 2006. 12. 21 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘기간제법’이라 한다.)」이 제정되었다. 동법 제2조 제3호는 금지되는 차별적 처우와 관련하여 제정 당시에는 “임금 그 밖의 근로조건 등”을 차별 시정의 대상으로 규정하고 있었으나, 2013. 3. 22 법 개정을 통해 기존에 차별 시정 대상을 각호로 구체화·세분화하여 법률에 명시하였다.⁸⁰⁾ 기간제법 제8조에 따라 차별적 처우는 금지되며, 또한 계속되는 차별적 처우에 대해서는 제척기간의 기산일을 ‘차별적 처우가 있는 날’이 아닌 ‘종료일’로 보고 있는데 차별적 처우 중 임금에 해당하는지 임금외 근로조건에 해당하는지에 따라 시정신청기간과 밀접한 관련성을 가지게 되어 임금성 여부를 판단할 실익이 있다. ⁸¹⁾제9조

80) 법 개정의 취지 및 기간제법 제2조 제3호 가~목간의 관계를 살펴보면 나목 또는 다목에 해당되는 상여금 성과급은 임금이 아니기 때문에 분리하여 적시한 것이 아님을 알 수 있음

기간제법 제정 당시 차별적 처우 관련 규정	개정 기간제법상 차별적 처우 관련 규정
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 3. “차별적 처우”라 함은 임금 그 밖의 근로조건 등에 있어서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 3. “차별적 처우”라 함은 다음 각 목의 사항에 있어서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다. 가. 「근로기준법」 제2조제1항제5호에 따른 임금 나. 정기상여금, 명절상여금 등 정기적으로 지급되는 상여금 다. 경영성과에 따른 성과급 라. 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항



에 따라 차별적 처우를 받은 기간제근로자 또는 단시간 근로자는 차별적 처우에 대한 시정을 노동위원회에 신청할 수 있고, 제13조에 따라 노동위원회는 차별적 행위의 중지, 임금 등 근로조건 개선 또는 적절한 배상(3배 이내)을 명할 수 있도록 있으며 고용노동부장관도 시정을 요구할 수 있다. 기간제법 제24조에 따라 고용노동부 장관은 정당한 이유 없이 확정된 시정명령을 따르지 않는 자에게 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

3. 검토

「근로기준법」과 다르게 노동관계법에서는 임금에 관해 별도의 정의 규정을 두고 있지 않다. 그러면서도 다수의 노동관계법에서 법상 다양한 목적을 달성하기 위해 법문에 ‘임금’의 용어를 사용하고 있다. 이는 「근로기준법」상 임금의 개념을 준용하여 법을 적용하고 해석하고 있기 때문으로 보인다.⁸²⁾ 물론 「근로기준법」 등 노동관계법상 ‘임금’에 관해 각 법령에서 달성하고자 하는 목적에 따라 ‘임금’ 개념과 범위에서 세부적인 차이가 존재할 수는 있다고 하더라도 실무상으로는 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금에 해당한다면 동법 뿐만 아니라 다른 노동관계법상 임금에 관한 특별한 법적 보호를 받을 수 있고 해당 보호 규정을 위반하는 경우 강행규정 위반을 이유로 당사자 간의 임금에 관한 약정이 무효가 될 뿐만 아니라 「근로기준법」을 위반한 사용자 등에게 처벌규정이 적용될 수도 있다. 즉, 임금은 범죄구성요건의 요소로서의 의의도 가지고 있다.⁸³⁾

이러한 이유로 사용자가 근로자에게 지급하는 급부를 중 ‘근로의 대가’로 보아 임금성을 인정하기 위해서는 법정안정성을 반드시 고려하여 임금의 개념(요건)과 판단 방법을 명확히 정립하여야 한다.

81) 박종희·강선희, “비정규근로자에 대한 차별시정제도의 현황과 몇 가지 쟁점에 대한 검토”, 「산업관계연구(제22권 제2호)」, 한국고용노사관계학회, 2012. 104면

82) 앞서 본 평균임금과 임금의 구별처럼 일부 차이가 날 수는 있더라도 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금이 임금 관련 법규정을 적용하는 기준이자 관문의 역할을 하게 될 것이다.

83) 이수정·박지순, 앞의 논문, 198면



Ⅲ. 임금과 구별되는 개념으로서 보수 등 관련 법제

1. 민법상 보수 관련 규정

현행 민법에는 임금의 개념을 명시적으로 규정한 조항⁸⁴⁾은 없다. 다만, 민법은 근로계약 상 ‘임금’에 대응하는 고용계약 상 ‘보수’에 대해 아래와 같은 조항을 규정하고 있다. 민법 상 사용자의 보수지급은 고용계약의 본질적인 내용으로 노무자는 노무 제공의 대가로 사용자에게 보수의 지급청구에 관한 권리를 가진다.

보수는 금전으로 지급함이 원칙이나, 금전 이외의 것으로 보수를 지급하기로 약정한 때에는 그 약정에 따라 지급되며, 특별한 약정이 없는 때에는 관습에 의해 지급된다. 보수는 후급을 원칙으로 하나 약정한 시기에 지급되어야 한다. 약정이 없더라도 관습에 의한 시기에 지급되어야 하며, 약정과 관습이 없더라도 노무를 종료한 후에는 지체없이 지급되어야 한다.⁸⁵⁾

제655조(고용의 의의) 고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

제656조(보수액과 그 지급시기) ①보수 또는 보수액의 약정이 없는 때에는 관습에 의하여 지급하여야 한다.

②보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체없이 지급하여야 한다.

2. 사회보장법상 보수(소득세법상 근로소득) 관련 규정

2011. 1. 1부터 사회보험료가 통합징수되게 됨에 따라 고용보험 및 산업재해보상보

84) 민법 제164조가 1년의 단기소멸시효에 대해 규정하면서 “연예인의 임금”을 규정하고 있는데 연예인은 일반적으로 사용종속성을 가지는 근로자에 해당하지 않는다. 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호는 사용자가 근로의 대가로 사용종속성을 가지는 근로자에게 지급하는 것을 임금으로 본다. 따라서 민법 제164조의 임금과 「근로기준법」 제2조 정의 상 임금은 단언된 동일할 뿐 비교대상이 된다고 보기 어렵다.

85) 양재현, 「민법상 고용계약에 관한 연구」, 박사학위 논문, 숭실대학교, 2010, 91면 참조



험은 기존에 보험료 부과기준을 「근로기준법」상 임금에서 4대 사회보험의 공통 기준인 보수(소득세 부과대상인 근로소득)으로 변경하였다.

「국민건강보험법」 제70조 제3항은 ‘보수’라는 용어를 사용하고 있고 「국민연금법」은 ‘소득’이라는 용어를 사용하는데 양자의 개념은 일부 상이하지만 공통적으로 소득세법에 따른 비과세근로소득 등을 보수와 소득에서 제외하고 있다.

「소득세법」 제20조의 근로소득에서 소득세법 제12조 비과세소득을 제외한 금액을 말한다. 근로소득에는 임금으로 보기 어려운 항목들도 포함되며 제외되는 비과세 소득 중 임금성이 인정되는 대표적인 예시는 식대(월 10만원 한도)⁸⁶⁾, 벽지수당(월 20만원 한도), 자가운전보조금(월 20만원 한도), 월정액급여가 낮은(월 210만원) 생산직 근로자 등의 연장근로·야간근로·휴일근로수당(연 240만원 한도) 등이 있다.

고용보험법 제2조(정의)

5. “보수”란 「소득세법」 제20조에 따른 근로소득에서 대통령령으로 정하는 금품을 뺀 금액을 말한다. 다만, 휴직이나 그 밖에 이와 비슷한 상태에 있는 기간 중에 사업주 외의 자로부터 지급받는 금품 중 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금품은 보수로 본다.

고용보험법 시행령 제1조의2(보수에서 제외되는 금품) 「고용보험법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호 본문에서 “대통령령으로 정하는 금품”이란 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 근로소득을 말한다.

고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제2조(정의)

3. “보수”란 「소득세법」 제20조에 따른 근로소득에서 대통령령으로 정하는 금품을 뺀 금액을 말한다. 다만, 제13조제1항제1호에 따른 고용보험료를 징수하는 경우에는 근로자가 휴직이나 그 밖에 이와 비슷한 상태에 있는 기간 중에 사업주 외의 자로부터 지급받는 금품 중 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금품은 보수로 본다.

고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제2조의2(보수에서 제외되는 금품) 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3호 본문에서 “대통령령으로 정하는 금품”이란 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 근로소득을 말한다.

86) 2023. 1. 1부터 식대 한도 20만원으로 한도 증액



국민건강보험법 제70조(보수월액) ① 제69조제4항제1호에 따른 직장가입자의 보수월액은 직장가입자가 지급받는 보수를 기준으로 하여 산정한다.

② 휴직이나 그 밖의 사유로 보수의 전부 또는 일부가 지급되지 아니하는 가입자(이하 “휴직자등”이라 한다)의 보수월액보험료는 해당 사유가 생기기 전 달의 보수월액을 기준으로 산정한다.

③ 제1항에 따른 보수는 근로자등이 근로를 제공하고 사용자·국가 또는 지방자치단체로부터 지급받는 금품(실비변상적인 성격을 갖는 금품은 제외한다)으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 이 경우 보수 관련 자료가 없거나 불명확한 경우 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하면 보건복지부장관이 정하여 고시하는 금액을 보수로 본다.

④ 제1항에 따른 보수월액의 산정 및 보수가 지급되지 아니하는 사용자의 보수월액의 산정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

국민연금법 제3조(정의 등) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “소득”이란 일정한 기간 근로를 제공하여 얻은 수입에서 대통령령으로 정하는 비과세소득을 제외한 금액 또는 사업 및 자산을 운영하여 얻는 수입에서 필요경비를 제외한 금액을 말한다.

국민연금법 시행령 제3조(소득의 범위) ① 사업장가입자나 국민연금에 가입된 사업장에 종사하는 임의계속가입자(생략)의 법 제3조제1항제3호에 따른 소득의 범위는 다음 각 호와 같다.

2. 근로자의 경우: 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득에서 같은 법 제12조제3호에 따른 비과세 근로소득(같은 호 거목 및 같은 법 시행령 제16조제1항제1호에 따라 원양어업 선박이나 국외등을 항행하는 선박에서 근로를 제공하고 받는 월 300만원 이내의 금액은 제외하고, 「조세특례제한법」 제18조의2에 따라 과세하지 않는 금액은 포함한다)을 뺀 소득

소득세법 제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

1. 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여

소득세법 제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

3. 근로소득과 퇴직소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득자. 대통령령으로 정하는 실비변상적(實費辨償的) 성질의 급여



다. 생산직 및 그 관련 직에 종사하는 근로자로서 급여 수준 및 직종 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 근로자가 대통령령으로 정하는 연장근로·야간근로 또는 휴일근로를 하여 받는 급여

러. 대통령령으로 정하는 식사 또는 식사대

며. 근로자 또는 그 배우자의 출산이나 6세 이하 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 받는 급여로서 월 10만원 이내의 금액

저. 대통령령으로 정하는 복리후생적 성질의 급여

IV. 「근로기준법」 상 임금과의 비교

1. 민법상 ‘보수’의 의미와 「근로기준법」 상 임금과의 비교

민법상 고용계약에 따른 보수는 근로계약에 따른 임금청구권의 기초가 되는데 i) 「근로기준법」 상 근로계약은 그 이념이나 규제 내용의 면에서 민법상의 고용계약을 대폭 수정하고 있지만, 민법상의 고용계약도 종속성을 전제로 하는 계약개념으로서 양자 사이에 본질적인 차이가 없다는 구별 부정설과,⁸⁷⁾ ii) 근로계약은 민법상 고용계약에서 그 법형식과 실체 사이의 모순인 종속성을 극복하기 위하여 등장한 것으로 그 성립과정이 다르고, 근로계약의 개념 구성은 근로자의 생존권 보장이라는 기본 이념의 실현에 있으므로 양 계약의 이론적인 출발점이 다르다는 것, 그 규제 내용으로 고용관계에서 사실로 존재하는 신분적·조직적 요소를 근로계약에서는 법적 계기로 받아들여 사회법적 규제를 가하고 있다는 것 등을 근거로 구별해야 한다는 구별 긍정설이 제기된다.⁸⁸⁾ 후자인 구별 긍정설이 다수설이다.⁸⁹⁾

근로계약은 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 그 대가를 얻는 법률관계로 민법상의 고용계약에 그 법적 기초를 두고 있고 근로계약과 고용계약은 모두 쌍무적 견련관계를 전제로 한다. 그러나 민법상 고용계약은 계약의 자유에 기초하고 있어 실질

87) 이병태, 「최신노동법」(제8전정판), 중앙경제, 2008, 585면 : 구별부정설도 민법이 대등 당사자간의 계약을 규율하는 것에 비해 「근로기준법」이 근로자의 생존 보호를 목적으로 하고 있다는 이념적 차이는 인정한다.

88) 김유성, 「노동법 I」, 법문사, 2005, 55-56면

89) 김형배, 「노동법(27판)」, 33면, 임종률, 「노동법(제18판)」, 박영사, 2019, 355면



적인 평등관계가 성립될 수 없고, 근로자 보호를 위해 특별법이라 할 수 있는 「근로기준법」 등 노동관계법이 등장하게 된 것이고 이러한 규제하에 있는 것이 근로계약이다. 즉, 고용계약 그 자체로는 근로관계를 규율하는데 일정한 결함을 가지고 있고, 이를 계약법리의 수정과 「근로기준법」 등 노동관계법 상 강행법률을 통해 근로계약으로 보완하고 있는 것이다.⁹⁰⁾

근로계약상 임금도 고용계약상 보수에 법적 기초를 두고 있고 양자 모두 쌍무적 관련관계 하에서의 대가로서 성질을 가진다는 공통점은 있다. 다만, 「근로기준법」 상 임금이 가지는 강행규정의 성격상 임금의 범위는 확정되어야 하기 때문에 민법 상 보수와 구별되는 「근로기준법」 상 임금의 개념이 별도로 「근로기준법」에 정의되어 있고, 동법 제2조 정의에 따라 ‘근로의 대가’라는 요건이 충족되어야 하는 「근로기준법」 상 ‘임금’의 범위와 ‘근로의 대가’라는 요건을 요하지 않는 민법 상 ‘보수’의 범위는 구분된다.

따라서 민법에 바탕을 둔 「근로기준법」 상 임금은 채권계약의 성질을 가지기 때문에 대가적 교환관계에 있다고 볼 수 있으나,⁹¹⁾ 민법 상 보수가 당사자의 계약 자유의 원칙에 의거 주관적 합의에 따라 결정된 급부의 지급인 반면, 「근로기준법」 상 임금은 민법 상 보수에 법적 기초를 두면서도 노동관계법 상 강행규정성 하에서 사용종속관계인 근로계약에 따라 근로의 대가로서 지급되는 것으로 사용자가 근로자에게 지급하는 급부 중 ‘근로의 대가’로 볼 수 없어 비임금으로 지급되는 것(경영성과급이 근로의 대가가 없어 임금이 아닌 경우)이라도 민법상 보수에는 해당될 수 있다. 즉, 민법 상 보수가 「근로기준법」 상 임금보다 더 광의의 개념이라 할 수 있다. 또한 위와 같이 고용계약에서 ‘보수’는 그 범위에 대하여 당사자간의 합의에 따라 결정되지만, 법정책 상 근로자보호라는 목적을 실현해야 하는 근로기준법의 성격을 고려하면 근로기준법은 특별히 당사자의 합의 여부와 무관하게 보호대상으로서의 임금의 범위를 명확히 하기 위해 임금의 개념과 기준을 독립적으로 정의한 것이라고 볼 수 있다.⁹²⁾

90) 김형배·박지순, 「노동법 강의(제11판)」, 신조사, 2022, 3-4면

91) 박은규, 앞의 논문, 33면.

92) 이수정·박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 「노동법포럼(제37호)」, 노동법이



2. 사회보험법상 ‘보수’의 의미와 「근로기준법」 상 임금과의 비교

사회보험법 상 보수는 ‘세법 상 과세소득과 비과세 소득’을 기반으로 산출된다. 소득세법은 근로소득세를 부과하기 위해 설정된 조세정책적 관점에서 근로소득을 정의한다. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제13조 제1항 제1호에 따라 고용보험료를 징수하는 경우에는 근로자가 휴직이나 그 밖에 이와 준하는 상태에 있는 기간 중에 ‘사업주 외의 자’로부터 지급받는 금품 중 고용노동부장관이 고시하는 금품을 보수로 본다고 명시하고 있는데 이 규정은 입법 정책에 따라 동법상 보수의 개념이 근로기준법상 임금보다 상당한 개방성을 가지고 있음을 보여준다.⁹³⁾

따라서 사회보험법 상 보수·소득 및 소득세법 상 근로소득은 「근로기준법」 상 임금과 상호 일치하지 않으며 직접적인 관련성이 없다. 근로기준법 상 임금은 고용계약 또는 근로계약의 반대급부로서 임금의 보호 목적과 기능을 고려하여 그 범위와 대상을 제한하거나 특정할 수 있다. 이러한 이유로 경영성과급 등 사용자가 근로자에게 지급하는 특정 금품에 대해 근로의 대가가 아니라고 보아 「근로기준법」 상 임금성을 제한하더라도 보수·소득·근로소득에는 포함될 수 있는 것이다.

V. 소결

민법 제8절 고용(계약)의 보수는 근로계약 상 임금청구권의 기초가 된다. 이에 따라 「근로기준법」 상 제2조 제1항 제5호의 임금은 대가적 교환관계라는 채권계약으로서의 성질을 진다. 다만, 앞서 살펴본 바와 같이 계약 자유의 원칙에 따라 보호되는 민법의 고용계약상 보수와 다르게 「근로기준법」 상 임금은 강행규정성을 가지기 때문에 더 협의의 개념이며 그 범위를 제한 할 수 있다. 다만, 앞서 살펴본 바와 같이 각 정책적 목표에 따라 상당한 개방성을 가지는 사회보험법 상 보수·소득 및 소득세법상 근로소득과는 상관관계가 있다고 보기는 어렵다.

론실무학회, 2022, 198-199면

93) 이수정·박지순, 앞의 논문, 213면



노동관계법에서는 임금에 관해 별도의 정의 규정을 두고 있지 않기 때문에 「근로기준법」상 임금의 개념을 준용하여 해석하고 있다. 따라서 임금에 해당한다면 「근로기준법」 뿐만 아니라 다른 노동관계법상 임금에 관한 특별한 법적 보호를 받을 수 있고 해당 보호 규정을 위반하는 경우 강행규정 위반을 이유로 당사자 간의 임금에 관한 약정이 무효가 될 뿐만 아니라 사용자에게 처벌규정이 적용될 수도 있다. 사용자가 근로자에게 지급하는 급부로 법상 보호필요성이 있다는 이유만으로 강행법규에 의해 특별한 보호를 받고 있는 「근로기준법」 상 임금의 개념과 범위를 법적 근거도 없이 지나치게 확대하여 해석하는 것은 경계해야 하며, 법적안정성을 위해서라도 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 ‘임금의 개념’을 법문에 충실하게 해석할 필요가 있다.



제3장 임금 판단의 핵심 요건인 근로대가성

제1절 서설

그간 근로의 대가에 대한 현행 법원의 판결은 ‘근로의 대가’의 의미를 엄밀하게 분석하고 이를 확정하는 개념적 징표에 의하여 판단하는 것이 아니라, 문제가 된 급여의 규정의 취지나 성격에 비추어 임금성을 각 사안별로 개별적으로 판단하고 해석하는 유연한 해석방법을 취하여 왔다.⁹⁴⁾

이러한 판단 방법에 대해 임금의 추상적 법률만을 기준으로 그 운영실태를 고려하여 판단하는 것은 쉽지 않은 문제이기에 판례와 같은 판단 방법이 오히려 효율적이고 명확할 수 있다는 견해가 제기될 수 있지만, 이러한 판례의 판단 방법에 대해 ‘근로의 대가’의 본질에 대한 명확한 규명이 선행되고 이후 판단 구조가 명확히 적립되지 않는다면 사건을 담당하는 법원의 판단 경향에 따라 임금성이 지나치게 넓어지거나 지나치게 좁아지는 문제를 야기할 수 있어⁹⁵⁾ 앞서 살펴본 바와 같이 명확성을 전제로 하는 죄형법정주의에 반할 여지가 있고, 예측가능성 저하에 따른 불확실성이 증가되며, 개별 사안별로 형평성의 문제가 발생할 수 있다.⁹⁶⁾

이러한 이유로 학계에서는 임금성에 관한 법원의 판단 방식(유형론적 해석방식)에 많은 비판을 제기하며 임금성의 판단 요건 및 판단 방식에 대해 다양한 해석론이 제기되었다.⁹⁷⁾ 따라서 이하에서는 i) 그간 근로의 대가’의 의미와 판단 요건에 관한 판례의 태도를 살펴본 후, ii) 대법원 판결에 대한 비판적 견해를 바탕으로 ‘근로의 대가의 의미 및 판단요건’에 대해 제기된 학계의 다양한 해석론을 유형화하여 쟁점을 도출하고, iii) ‘근로의 대가’의 의미와 판단 요건에 대한 나름의 견해를 제기하고자 한다.

94) 박지순·이진규, 앞의 논문, 173면

95) 박은규, 앞의 논문, 84면

96) 박지순·이진규, 앞의 논문, 173면

97) 이에 대해서는 제3절에서 후술하도록 한다.



제2절 근로대가성에 대한 판례의 변화

I. 기존 판례의 태도

1. 임금성 관련 판례 법리

(1) 임금성 판단 법리를 최초로 제시한 판결

대법원은 대한석탄공사 사건⁹⁸⁾에서 식대보조비, 연료보조비, 체력단련비, 가족수당 등 복리후생적 수당이 (평균)임금성에 해당되는지를 판단하면서 “평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에는 ① 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, ② 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고, ③ 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함되는 것이다.”라고 판시하며 임금성 판단 법리를 최초로 제시하였다.⁹⁹⁾

위 판례에 따라 임금성 인정을 위한 3개의 필수적인 판단 지표(모두 충족)를 도출해보면 “임금성 판단 지표”는 아래와 같으며, 이후 복리후생적 수당뿐만 아니라 다른 급여의 임금성이 문제된 다수의 사건에서 해당 법리가 그대로 적용되었다.

<임금성 판단 지표>

- ① 근로의 대상(대가)
 - ② 계속적·정기적 지급(계속성·정기성)
 - ③ 사용자의 지급의무(지급의무성)
-

98) 대법원 1990. 12. 7. 선고 90다카19647 판결

99) 김홍영, “지난 20년간 임금 법제의 해석과 입법의 동향”, 『노동법연구(제26호)』, 서울대노동법연구회, 2009, 75면; 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 99면



(2) 근로제공 관련성을 최초로 구체화한 판결

대법원은 1995년 영화진흥공사 자가운전보조비 사건(이하 ‘영화진흥공사 사건’이라 한다)¹⁰⁰⁾에서 임금성을 판단하면서, ‘① 근로의 대상’과 관련하여 “금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 그 금품지급의무의 발생이 ‘근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것(이하 ‘근로제공 관련성’이라 한다)¹⁰¹⁾’으로 볼 수 있어야 할 것이고, 이러한 관련 없이 그 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 그 금품의 지급이 단체협약·취업규칙·근로계약 등이나 사용자의 방침 등에 의하여 이루어진 것이라 하더라도 그러한 금품은 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다 할 것이다”라고 판시하여 위 “①근로의 대상”의 의미를 ‘근로제공 관련성’으로 구체화 시키고 임금성 판단에 있어 “근로제공 관련성”을 ‘계속성·정기성’ 및 ‘지급의무성’보다 핵심적인 요소로 강조하였다.

<임금성 판단 지표>

- ① 금품지급의무 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 밀접하게 관련된 것
 - ② 계속적·정기적 지급(계속성·정기성)
 - ③ 사용자의 지급의무(지급의무성)
-

다만, 상기 대법원 판결의 의미와 관련하여 “① 근로제공 관련성”은 「근로기준법」의 임금의 정의 조항에서 ‘근로의 대가’의 의미를 설명한 것으로 뒤의 2가지의 지표(“② 계속적·정기적 지급”과 “③ 사용자의 지급의무”)와는 성질을 달리할 뿐만 아니라 더 상위의 개념으로 보았다고 해석하는 견해와 “① 근로의 대상”은 임금의 요건인 근로의 대가가 아닌 “근로제공과의 직접적 관련성”이라고 보아 ①~③은 모두 임금성을 판단하는 지표이며 상하 개념이 아닌 병렬적 개념이고 법원은 3가지 판단지표를

100) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94다55934 판결 : 일정 지급 이상의 직원 중 자기차량을 보유하여 운전한 자에 한하여 지급하는 자가운전보조비의 임금성 사건

101) 기술의 편의를 위해 근로제공 관련성이라고 하였다.



모두 충족하는 경우 임금성이 인정한다고 보았다고 해석하는 견해가 제기되었다.¹⁰²⁾

(3) 이후 임금성 관련 판례의 태도

이후 대법원은 일부 판결에서는 ‘영화진흥공사 판결’과 동일한 법리를 제기하기도 하였으나¹⁰³⁾, 이와 다르게 다수의 판결에서 근로제공 관련성에 대한 별도 판단 없이 ② 계속성·정기성, ③ 지급의무성만 인정되면 임금성을 인정한 판결도 확인된다.¹⁰⁴⁾ 이러한 대법원의 ‘근로의 대가’에 대한 일관되지 않은 기준을 적용한 판결로 인해 대법원이 상기 ‘영화진흥공사 판결’ 이후 임금성을 인정함에 있어 ‘근로제공 관련성’을 다른 판단 지표와 다르게 필수적이고 핵심적인 요건으로 본 것인지가 명확하지 않게 되었다.

다만, 최근 임금성에 관한 다양한 사건에 대한 판결이 종래 대법원 판결 중 어떠한 판결을 참조 판결로 인용하고 있는지를 살펴보면 ‘근로제공 관련성’ 지표를 다른 두 개의 지표보다 주된 판단 지표로 삼는 듯한 태도를 보이는 판결은 다수가 영화진흥공사 사건 판결을 참조 판결로 삼고 있다.

참고로 일부 대법원 판례 중에는 “일률성”을 별도 지표로 제시한 것도 있으나¹⁰⁵⁾, 이에 대해 일률성 지표는 통상임금성을 판단할 때 사용되는 기준이어서 임금성 판단

102) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 100-101면 : 심재진은 ‘임종률, 김형배, 이승렬, 김홍영’이 전자의 견해를 ‘문무기·윤문희·이철수·박은정, 문종철, 김영문, 김정환’이 후자의 견해를 취한다고 본다.

103) 박종희, 앞의 논문, 227면(대법원 1996.5.14. 선고 95다19256 판결; 대법원 1999.5.12. 선고 97다5015 판결 등).

104) 박종희, 앞의 논문, 227면(대법원 2001.10.23. 선고 2001다53950 판결; 대법원 2011.06.10. 선고 2010두19461 판결; 대법원 2018.10.12. 선고 2015두36157 판결; 대법원 2018.12.13. 선고 2018다231536 판결. 이러한 판단기준을 제시한 것은 위 94다55934 판결 이전에도 있었다(예컨대 대법원 1990.12.7. 선고 90다카19647 판결 등) 그리고 이는 대법원의 전원합의체로 명확하게 정리된 입장도 아니며, 사안별로는 여전히 94다55934 판결방식에 따라 판단한 경우도 있다(대법원 2011.7.14. 선고 2011다23149 판결 등).

105) 심재진 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 100면(일률성을 요구하는 판결들은 주로 가족수당의 임금성을 판단하는 경우로 한정되어 있다고 보고 있음) : 대법원 1991. 2. 12. 선고 90다15952 판결; 대법원 2002. 10. 17. 선고 2002다8025 전원합의체 판결 ; 대법원 2005. 9. 9. 선고 2004다141217; 대법원 2005. 10. 13. 선고 2004다13762 판결 ; 대법원 2011. 6. 10. 선고 2010두19461 판결



에서 지표로 삼는 것은 타당하지 않다는 비판이 제기되며 학계의 거의 공통된 견해이다.¹⁰⁶⁾

[표 1] 종래 임금성 관련 대법원 판결의 변화

구분	요건	주요 내용	참조 판결
초기	근로의 대상 지급의무성 계속성·정기성	평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에는 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, <u>근로자에게 계속적, 정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있으면</u> 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함되는 것이다.(대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카23868 판결 등 다수)	-
변화	(필수)근로제공 관련성 (부수)지급의무성 (부수)계속성·정기성	임금에 해당하려면 먼저 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것이어야 하므로 비록 그 금품이 계속적, 정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다. 여기서 어떤 금품이 근로의 대상으로 지급된 것이냐를 판단함에 있어서는 그 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 할 것이고, 이러한 관련 없이 그 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 경우에는 그 금품의 지급이 단체협약 취업규칙 근로계약 등이나 사용자의 방침 등에 의하여 이루어진 것이라 하더라도 그러한 금품은 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다 할 것이다.(대법원 1995. 5. 12, 선고 94다55934 판결: 영화진흥공사 판결 등 다수)	복지포인트 (2019년~) 사기업 경영성과급 (2020년~)
이후	지급의무성(노동관행) 계속성·정기성 ※근로제공 관련성 요하지 않음	평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에는 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 지급하는 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것은 그 명칭 여하를 불문하고 모두 포함된다.(대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결 : 한일시멘트 판결 등 다수)	공공기관 경영평가 성과급 (2018~)

106) 심재진 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 100면(동일한 취지로 ; 문무기외 3명, 앞의 보고서, 10면; 김정환, 앞의 논문, 22면, 임상민, 앞의 논문, 11면)



(4) 종래 판례의 태도에 대한 검토

종래 판례의 태도가 명확하다고 볼 수는 없으나 ‘근로의 대가’를 판단함에 있어 주로 하기 3개의 객관적 판단 지표를 살피면서도 원칙적으로 각각의 객관적 판단 요소는 동등한 가치를 가지면서도 개별 사안에 따라 그 비중과 정도에 차이를 두었기 때문에 객관적 판단 지표 중 어느 하나가 결여되었다라든 다른 지표를 통해 근로의 대가성을 인정할 수 있다고 보이는 경우 ‘근로의 대가’가 있다고 보아 임금성을 인정하는 유형론적 해석방법으로 판단해온 것으로 보인다.¹⁰⁷⁾

물론 앞서 살펴본 바와 같이 일부 판결이 근로제공 관련성을 다른 두 개의 요소보다 보다 강조한바는 있으나, 이후에도 법원에서 이러한 판단 구조를 통일적으로 적용하지 않은 점, 근로제공 관련성 지표를 필수적 요건으로 보았던 판결의 입장에 변화가 있는 것이라면 대법원 전원합의체 판결 등에서 다루어졌어야 했으나 그렇지 않은 점 등을 고려하면 종래의 판결의 변화는 임금성에 관한 명확한 개념 정립과 범위를 설정하기 위해 심도 있는 논의를 통해 도출된 것으로 보기는 어렵다.

다만, 종래 판결은 하기 3개의 객관적 판단 지표를 (평균)임금성 판단 시 주로 판단 지표로 삼았고 개별 사건마다 필요에 따라 일부 지표를 다른 지표보다 강조해 왔다.

<법원의 ‘임금성’에 대한 3개의 객관적 판단 요소>

- ① 금품지급 의무 발생이 근로제공과 직접적 또는 밀접한 관련이 있을 것
 - ② 단체협약, 취업규칙, 근로계약, 노동관행에 따라 사용자의 지급의무가 있을 것
 - ③ 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되었을 것
-

107) 김영문·이상윤·이정, 앞의 책, 41-42면; 김희성·성대규, 성과배분으로서 경영성과금의 임금성에 대한 고찰, 「노동법포럼(제35호)」, 노동법이론실무학회, 2022, 17면; 박은규, 앞의 논문, 82-84면 참조,



II. 최근 판례의 태도

임금성 여부가 문제된 다양한 판례가 있으나, 이중 근로의 대가와 관련한 해석과 판단 기준이 될 수 있고 추후 제4장에서 논의할 경영성과급의 임금성과 관련하여 비교할만한 유의미한 판결은 ① 개인성과급의 임금성 판결, ② 공공기관 경영평가성과급의 임금성 판결, ③ 복지포인트의 임금성 판결이다.

1. 개인성과급의 임금성

(1) 개인성과급의 임금성 판결의 변화

개인성과급의 임금성에 대해서는 과거 금강제화 사건¹⁰⁸⁾에서 구두 판매 사원에게 지급한 포상금의 임금성을 인정한바 있으나, 동원증권 하건¹⁰⁹⁾에서는 영업직원의 실적에 따라 성과급과 관련하여 대법원이 “근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과급은 지급조건과 지급시기가 단체협약 등에 정하여져 있다고 하더라도 지급조건의 충족 여부는 근로자 개인의 실적에 따라 달라지는 것으로서 근로자의 근로제공 자체의 대상이라고 볼 수 없으므로 임금에 해당된다고 할 수 없다”라고 보아 개인성과급의 임금성을 부정하였다. 그러나, 근로자 개인의 실적은 근로제공과 직접적 또는 밀접하게 관련되는 것으로 볼 수 있어 임금성이 인정되어야 하며 이와 동일한 취지로 다수의 비판적인 견해가 제기되었다.¹¹⁰⁾ 이후 대법원은 한국산재의료원 사건¹¹¹⁾ 및 센트럴모터스 사건¹¹²⁾에서 개인실적에 따라 지급되는 의사의 진료성과급과 자동차 영업사원이 개별적으로 차를 판매하여 일정한 비율로 판매한 대수만큼 받는 인센티브에 대해 임금성을 인정하였다.

임금성을 인정한 위 3개의 판례는 모두 영화진흥공사 사건 판결¹¹³⁾에 따라 근로의

108) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000다18127 판결

109) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결

110) 김홍영, “성과급의 임금성 여부”, 『노동법연구(제17호)』, 서울대학교노동법연구회, 2004. 275-294면

111) 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다77514 판결

112) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결



대가와 관련하여 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있어야 한다고 보았다. 다만, 최근 대법원은¹¹⁴⁾ 정수기 등 가정용 기기에 대한 설치·사후관리 및 판매 등 업무를 수행하는 ‘엔지니어’인 정수기 수리기사에 판매수수료에 대해서도 임금성을 인정하면서도¹¹⁵⁾ 영화진흥공사 판결이 아닌 공공기관 경영성과급 판결을 참조 판례로 보았고 ‘근로제공 관련성’에 대해 판단하지 않았다.

[표 2] 개인성과급의 임금성 관련 판결

구분	임금성	주요 내용	사건번호 ¹¹⁶⁾
개인 성과급	부정 (개인포상금)	상품권판매는 구두류 제품판매를 주업으로 하는 피고가 역점을 두는 사업이므로 직원들이 상품권판매를 위하여 하는 영업활동은 결국 피고에 대하여 제공하는 근로의 일부로 판매실적 개인포상금 임금성인정	대법원 2000다18127 판결 (금강제화)
	부정 (성과급)	근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과급은 지급조건과 지급시기가 단체협약 등에 정하여져 있다고 하더라도 지급조건 충족 여부는 근로자 개인의 실적에 따라 달라지는 것으로서 근로 제공 자체의 대상이라고 볼 수 없어 임금 아님	대법원 2001다76328 판결 (동원증권)
	인정 (진료포상비)	의사의 실적을 판단하는 기준으로 삼은 진료와 특진, 협진 등의 업무는 매달 이를 수행하는 횟수에 차이는 있을지언정 그 자체는 의사 고유의 업무로서 병원을 운영하는 피고에게 제공된 근로의 일부로 임금임	대법원 2010다77514 판결 (한국산재의료원)
	인정 (차량판매 인센티브)	피고 회사가 인센티브(성과급) 지급규정이나 영업 프로모션 등으로 정한 지급기준과 지급시기에 따라 인센티브(성과급)를 지급하여 왔고, 차량판매는 피고 회사의 주업으로서 영업사원들이 차량판매를 위하여 하는 영업활동은 피고 회사에 대하여 제공하는 근로의 일부라 볼 수 있어 인센티브(성과급)는 근로의 대가로 지급되는 것으로 임금임	대법원 2011다23149 판결 (센트럴모터스)

113) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94다55934 판결

114) 대법원 2021. 11. 11. 선고 2020다273939 판결

115) 김희성·이준희, 앞의 논문, 253면



(2) 개인성과급의 임금성을 부정한 대표적인 판결

개인성과급의 임금성을 인정한 대표적인 대법원 판결인 센트럴모터스 사건 판례의 경우 임금 지급의 주요 사실관계와 판결 요지는 아래와 같다.¹¹⁷⁾

1) 주요 사실관계

자동차 수입판매사인 피고 센트럴모터스주식회사는 영업사원들에게 아래와 같이 인센티브를 지급하였고, 원고는 인센티브를 평균임금에 포함하여 퇴직금을 산정하고 기지급된 퇴직금과의 차액을 지급하라고 주장하였다.

3) 인센티브 지급규정

4.1. 영업사원 인센티브 지급

4.1.1. 지급기준

(1) 인센티브 지급률은 영업사원이 판매한 차량에 대해 다음 지급기준표에 의한다.

판매대수	인센티브 지급률	추가 인센티브
1대	0.8%	-
2대	1.0%	-
3대	1.7%	-
4대	1.8%	-
5대	1.9%	-
6대	2.0%	-
7대	2.0%	100만원
8대 이상	2.0%	100만원+50만원 (7대 초과분에 대해 대당 50만원 추가)

(2) 판매수당의 지급액은 차량 총 판매금액에 인센티브 지급률을 곱해 산정한다.

(3) 상기 인센티브 지급 외에 추가로 발생하는 영업 프로모션의 경우는 별도로 정하는 바에 의한다.

4.1.2. 지급일

판매수당의 지급은 당월 정산 후 익월 25일 급여와 함께 지급한다.

116) 가독성을 고려하여 판결일은 생략함

117) 임상민, 앞의 논문, 1122면



2) 대법원의 판결 요지

대법원은 영화진흥공사 사건 판결을 참조 판결로 제시하면서, 피고 회사가 인센티브 지급규정이나 영업 프로모션 등으로 정한 지급기준과 지급시기에 따라 인센티브를 지급해 왔고, 차량판매는 피고 회사의 주업으로서 영업사원들이 차량판매를 위해 하는 영업활동은 피고 회사에 제공하는 근로의 일부라 볼 수 있어 인센티브는 근로의 대가로 지급되는 것이라고 봐야 하며, 매월 정기적, 계속적으로 이뤄지는 인센티브의 지급이 개인근로자의 특수하고 우연한 사정에 의해 좌우되는 우발적, 일시적 급여라고 할 수 없고, 지급기준 등의 요건에 맞는 실적을 달성했다면 피고 회사로서는 그 실적에 따른 인센티브 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적 급부라 할 수도 없으며, 인센티브를 일률적으로 임금으로 보지 않을 경우 인센티브만으로 급여를 지급받기로 한 근로자는 근로를 제공하되 근로의 대상으로서의 임금은 없는 것이 되고 퇴직금도 전혀 받을 수 없게 되는 불합리한 결과가 초래될 것인 점 등에 비춰 보면, 이 사건 인센티브는 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 해당한다고 판단했다.

참고로 원심에서는 ‘팀성과급의 임금성’도 문제가 되었으나 원심은 “다만 피고가 지급하는 인센티브 중 팀별 목표 달성 여부에 따라 지급 여부가 정하여지는 팀 인센티브는 개인적으로 지급되는 것이 아니거나 은혜적인 급부에 불과하여 평균임금에 포함될 수 없다고 보아야 할 것이다.”¹¹⁸⁾ 라고 판결하여 ‘팀성과급의 임금성’을 부정하였다.

(3) 검토

개인성과급의 임금성과 관련하여 나뉘었던 법원의 판례는 개인성과급의 임금성을 인정하는 것으로 정리된 것으로 보인다.¹¹⁹⁾

개인성과급의 임금성과 관련하여 판례의 특징은 ① 금품지급 의무의 발생이 ‘근로 제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련’되어 있을 것을 중요한 판단요

118) 수원지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009나33003 판결

119) 노동법실무연구회(최은배 집필분), 앞의 책, 256면; 박지순·이진규, 앞의 논문, 187면; 김희성·이준희, 앞의 논문, 252면, 신동윤·성대규, 앞의 논문, 407면 및 190쪽 이하 등.



소로 삼았다는 것이며, ② 근로제공이 ‘해당 사업의 주된 목적이나 활동과 긴밀성이 있는지 여부’ 또는 ‘사업의 실적이나 성과로 직접 연결되는지 여부’를 고려하였다는 것이다.¹²⁰⁾ 즉, 판례는 성과급의 지급기준의 달성이 근로자의 본연의 근로제공을 통해 충족되고, 이 근로제공은 회사의 주요 활동의 일부분이라는 점을 근거로 근로제공 관련성이 있음을 명확히 하였다. ③ 지급 사유의 발생 자체가 불확실하다고 하더라도 취업규칙 등에 명시된 지급 기준을 충족하는 경우 성과 달성 후 금액이 산출이 되며 회사가 지급을 거절할 수 없는 것이면 지급의무성을 인정하였다.¹²¹⁾

개인성과급의 임금성을 부정한 판례가 지급 사유의 불확정성만을 주된 판단 기준으로 한 반면, 개인성과급의 임금성을 인정한 판결은 개인의 근로제공이 성과급 발생에 직접적인 영향을 주었는지를 주로 고려하여 임금성을 긍정하였다. 이러한 판례의 태도는 최저임금법 상 기본급 등 고정적 급여 지급 없이 도급제(또는 혼합)임금 형태도 인정되는 점을 고려하더라도 타당하다고 보인다. 이와 같은 성격의 개인성과급을 부진정 성과배분 또는 실적참가형 보수제도라고 할 수 있고 진정성과배분과는 구분된다.¹²²⁾

다만, 개인의 실적이 아닌 집단의 실적(팀성과급)을 기준으로 한다고 하여 임금성이 부정된다는¹²³⁾ 하급심 판례의 입장에는 동의하기 어렵다.¹²⁴⁾ 법원이 직접적인 관련성 외에도 밀접한 관련성을 근로의 대가를 판단하는 기준으로 삼고 있기 때문이다. 개인성과급은 물론 집단성과급도 근로제공 관련성이 인정될 수 있고 사용자의 지급의무성이 인정될 수 있다면 임금성을 부정할 이유는 없다.¹²⁵⁾

120) 김기선, “개인실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 280호)」, 중앙경제, 2014, 81면

121) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 104면

122) 김형배, 앞의 책, 2021, 1579면; 박지순·이진규, 앞의 논문, 187-188면

123) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012다48077 판결(PCA생명 장기성과급 임금성 사건)은 집단성과급의 임금성을 부정하였다.

124) 박지순·이진규, 앞의 논문, 188면에서 진정성과배분 중 임금성을 가진 진정성과배분과 임금보충(근로자 재산형성)적 성격의 진정 성과배분을 구분하고 있다. 이 견해를 기준으로 하급심 판결상 임금성이 부정되었던 센트럴모터스 사건의 팀성과급은 진정 성과배분에 해당되며 하급심 판결의 결과와 다르게 임금성이 인정되는 것이 타당하다고 보인다..

125) 김홍영, 앞의 논문(지난 20년간 임금 법제의 해석과 입법의 동향, 85면



2. 2018년 이후 공공기관 경영평가성과급의 임금성

(1) 공공기관 경영평가성과급의 판결

정부는 공공기관 운영에 관한 법률 제48조(경영실적평가)에 따라 매년 공공기관에 대해 경영실적평가를 하고 기획재정부는 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침 및 예산집행지침’에 따라 경영평가성과급을 각 공공기관의 예산으로 편성한 후 확정된 기준에 따라 공공기관 경영평가성과급을 산정·지급하는 구체적인 방법을 제시하고 있다. 공공기관은 이를 단체협약이나 취업규칙에 반영하여(경영실적 평가 결과에 따른 경영평가성과급의 지급 시기, 산정 방법, 지급 조건 등을 구체적으로 정하고 있음) 소속 직원들에게 정부경영평가성과급을 지급한다. 정부의 경영평가결과 ‘D등급’을 받는 기관에 소속된 직원들은 경영평가성과급이 지급되지 않기 때문에 그간 고용노동부 등은 지급 여부 자체가 불확정적이라고 보아 임금성을 부정해왔다.¹²⁶⁾ 그러나, 2018년부터 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 긍정하는 다수의 판결이 있었다. 그 대표적인 사례로는 대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결(한국감정원), 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결(한국공항공사), 대법원 2018. 12. 28. 선고 2018다219123 판결(한국산업인력공단), 대법원 2018. 12. 28. 선고 2016다239680 판결(주택도시보증공사) 등이 있으며, 모두 임금성(평균임금성)을 인정하였다¹²⁷⁾.

상기 공공기관 집단성과상여금에 대하여 (평균)임금성을 인정한 판결들에는 다음과 같은 특징이 있다. ① 대법원이 최초로 집단성과급의 임금성을 정면으로 인정하였다. ② 지급기준(지급대상, 지급조건)이 정해져 있다는 사정만으로 평가 결과에 따라 지급

126) 2008. 6. 18, 근로조건지도과-2108 : 일반적으로 성과 상여금이 목표 달성 또는 경영 이익의 발생 여부에 따라 지급 기준·시기·금액이 확정되는 경우에는 이익의 공유 또는 성과의 배당 성격을 가지므로 근로의 대가성이 인정되지 않으나, 취업규칙·단체협약·근로계약서 등에 성과급의 지급 조건·시기·금액 등이 사전에 정해져 있거나, 전 근로자에게 관행적으로 지급해 사회 통념상 근로자가 당연히 지급받을 수 있다는 기대를 갖고 있는 경우에는 임금에 해당한다 할 것입니다. 귀 질의상의 인센티브 성과급은 귀 기관의 취업규칙 등 자체 규정에 정해진 지급 조건에 따라 계속적·정기적으로 지급해 지급 의무가 설정돼 있는 것이 아니라 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 정부 산하 기관 경영 실적 평가 결과에 따라 비로소 그 지급 여부 및 지급액이 결정되고, 「정부산하기관 예산관리기준」에 의해 편성된 정부 예산에 따라 지급하는 것으로 정부의 예산 반영이 이뤄지지 않은 경우에는 인센티브 성과급의 지급 의무가 예정돼 있다고 보기는 어렵다 할 것입니다.

127) 임상민, 앞의 논문, 1120면



액이 ‘0’원이 될 수 있더라도(지급 여부가 달라지더라도) 임금성을 인정하였다.¹²⁸⁾

(2) 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 최초로 인정한 판례

정부 경영평가성과급의 임금성에 관한 최초 대법원 판례인 한국감정원 사건 판결¹²⁹⁾의 경우 임금 지급의 주요 사실관계와 판결 요지는 아래와 같다.

1) 주요 사실관계

한국감정원의 2008년 내부경영평가편람상 성과상여금의 적용대상, 지급시기, 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 직원별 차등지급률을 산정하는 방법, 지급대상과 기준 등이 구체적으로 명시되어 있었고, 2013년부터는 기관이 최하위 평가를 받은 경우 성과급이 지급되지 않아 최저지급률은 보장되지 않았다. 참고로 전체공공기관 수 대비 전년도 경영평가의 결과로 인해 D등급(미흡)을 받은 공공기관은 연도별로 2013년 19개(17.1%), 2014년 30개(25.6%), 2015년 15개(12.9%), 2016년 13개(11.2%), 2017년 17개(14.3%), 2018년 7개(5.7%), 2019년 17개(13.3%)이다.¹³⁰⁾

한국감정원은 위와 같이 매년 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 보수규정과 내부경영평가편람에서 정한 기준과 계산방식에 따라 잔여 성과상여금을 산정하여 소속 직원들에게 지급하고 퇴직금을 지급할 때에도 위와 같이 지급한 성과상여금을 모두 포함하여 평균임금을 산정하였다. 업무상 재해로 사망한 한국감정원 소속 근로자의 유족이 산업재해보상보험법상 급여의 기준이 되는 평균임금에 경영평가성과급이 포함되어야 한다고 주장하면서 근로복지공단에 평균임금의 정정을 청구하였으나 인정되지 않았고, 법원에 근로복지공단을 상대로 평균임금정정 불승인 및 보험급여차액 부지급 처분 취소소송을 제기하였다.

2) 대법원의 판결 요지

대법원은 정부 경영평가성과급의 임금성을 긍정하며 근로제공 관련성에 대한 판단

128) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 113면

129) 임상민, 앞의 논문, 1122면

130) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 98면



없이 “경영평가성과급이 계속적·정기적으로 지급되고 지급대상, 지급조건 등이 확정되어 있어 사용자에게 지급의무가 있다면, 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지므로 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 포함된다고 보아야 한다. 경영실적평가 결과에 따라 그 지급 여부나 지급률이 달라질 수 있다고 하더라도 그러한 이유만으로 경영평가성과급이 근로의 대가로 지급된 것이 아니라고 볼 수 없다.”고 판결하여 ‘지급형태의 계속성·정기성’과 ‘사용자의 지급의무성’만을 판단기준으로 삼아 임금성을 긍정하였다.

기타 공공기관의 경영평가성과급이 i) 공공기관운영법에 근거한 것이고, 기획재정부장관의 경영평가결과 지급되는 것으로 지급이 확실시 되는 점, ii) 전년도 근무성적을 평가하여 지급되는 것이고, 공공기관의 경영평가성과급 중 일부는 이미 지급되고(매년 2월), 잔여성과급으로 지급되는 점(7월 지급), iii) 정부의 경영평가지급기준에 따라 이미 예산 등이 확보되어 있고, 기관 자체의 급여규정 등에서 이를 확인하는 것에 불과한 점 등을 들어 근로의 대가인 임금에 해당하는 것(판례는 이를 ‘지급의무가 있음을 전제’로 라고 함)이고, 계속적·정기적으로 일률적으로 지급되고 있음을 근거로 임금성을 긍정하고 있다.¹³¹⁾

(3) 검토

대법원은 종래 판결¹³²⁾에서 경영성과급은 근로제공과는 직접 또는 밀접한 관련이 없는 요소에 의하여 결정된다는 것을 이유로 임금성을 부인해 왔다. 반면 공공기관의 경영평가성과급의 임금성을 인정한 대법원 판결은 근로의 대가인 근로제공 관련성을 핵심 쟁점으로 보지 않았고, 지급의무성과 계속성·정기성을 판단 지표로 삼았다. 이는 법원 판결의 일관성 및 법적 안정성 확보 측면 문제가 있는 판결이라고 보인다.¹³³⁾

또한 대법원은 통상임금성 판단기준인 고정성과 관련된 요소를 임금성 판단 지표

131) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성). 89면 이하 참조

132) 대법원 1998. 1. 20. 선고 97다18936 판결), 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다77514 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결

133) 유성재, 앞의 글, 33면



로 삼기까지 하였는데 이는 타당하지 않다. 실제 공공기관의 경영평가성과급의 임금성에 관한 하급심 판결 중에는(주택도시보증공사)¹³⁴⁾ “일률성”에서 더 나아가 “소정근로의 대가”라는 표현을 평균임금성 판단 시 사용한 경우도 있고 대법원도 통상임금성의 고정성 판단 요소인 ‘실제 근무일수에 따라 일할 계산하여 지급된 점’과 경영평가성과급이 ‘평가대상 기간에 재직한 직원에 대하여 지급된 점’을 이유로 근로 대가성(임금성)을 인정하였다. 다투었던 사안이 평균임금에 대한 것임을 감안하면 경영평가성과급의 지급 실태와 평균임금 제도의 취지 등을 고려하여 판결한 것은 타당하나 이는 임금성을 판단하는 기준이 아니라 평균임금의 판단 기준으로 임금성 판단 시 고려되어야 할 사항은 아니다. 그간 임금의 개념 다시 말해 근로의 대가의 의미를 명확히 하지 않은채 유형론적인 판단을 하여 내재되었던 문제를 법원 스스로가 해당 판결에서 여실히 드러낸 것이다.

다만, ‘지급의무성’을 인정한 대법원의 판결은 합리적이라고 보인다. 지급의무성은 통상임금의 고정성과 다르게 최저지급률 유무가 판단 기준이 아니다. 즉, 지급 여부에 따라 판단하는 것이 아니라 단체협약, 취업규칙, 근로계약 또는 노동관행 등 법원으로 해석될 수 있는 근거상 지급기준(지급 대상, 지급 조건 : 지급액이나 지급률이 특정될 수 있어야 함)이 구체적으로 정해져 있고 그 지급기준에 따라 사용자의 지급의무를 인정할 수 있다면 사용자의 지급의무성이 인정되는 것이다. 따라서 대법원 판결과 마찬가지로 실제 산출된 지급액이 설사 ‘0원’이 된다고 하더라도 ‘사용자의 지급의무성’을 부정할 필요는 없다. 즉, 2012년부터 최하위 평가를 받은 경우 최저지급률이 없어 지급액이 ‘0원’이 될 수도 있다는 사정이 있더라도 지급의무성이 부정되는 것이 아니라 지급의무성은 인정되지만 단지 그 산정 결과가 ‘0원’일 뿐이라고 보는 것이 더 타당하다. 즉, 정부 경영평가 결과가 산출되면 그 즉시 금액을 ‘0’원으로 산출할 수 있다는 것은 취업규칙 등 법원에 따른 지급조건이 충분히 구체적이라고 볼 수 있고 그 결

134) 서울고등법원 2016. 6. 29. 선고 2015나2054828 판결 : 위 경영평가성과급은 근로자 개인의 근무에 대한 평가가 아니라 정부가 각 공공기관의 경영목표 및 경영실적, 기관장 경영계획서를 평가하여 그 결과에 따라 지급률이 결정되는 것으로서 근로자 개인의 소정근로의 대가로 볼 수 없으니 평균임금에 포함시켜서는 안 된다고 주장한다. 그러나 경영평가성과급이 보수규정에 의하여 피고에 지급의무가 지워져 있고, 피고의 모든 근로자 또는 일정한 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 지급되어 왔음은 앞서 본 바와 같거나 앞서 든 증거들에 의하여 인정할 수 있으므로 이는 소정근로의 대가로서 평균임금에 해당한다고 할 것이다.



과 지급액(지급률)이 ‘0원’으로 산출될 수 있는 것일 뿐 이러한 이유로 공공기관 경영평가성과급 판례가 ‘사용자의 지급의무’를 부정하지 않은 것은 충분히 합리적인 이유가 있다고 보인다.

근로계약이란 근로의 제공과 임금의 지급이 상호 견련관계에 있는 쌍무계약인 바¹³⁵⁾, 사용자가 근로자에게 지급한 금품이 ‘근로의 대가’로서 임금에 해당하기 위해서는, 해당 금품과 근로자가 제공한 근로 간에 쌍무적 견련성을 가져야 한다.¹³⁶⁾ 또한 앞서 살펴본 바와 같이 「근로기준법」 상 ‘근로의 대가’를 규정하고 있는 이상 입법자의 의사에 따라 법을 해석하는 자는 금품 지급과 근로제공에 따른 대가가 관련성이 있는지를 반드시 판단하여야 한다. 다시 말해, 임금의 개념을 근로제공에 따른 반대급부로 본다면 ‘근로의 대가’를 판단하는 지표에 ‘근로제공 관련성’이 포함되어야 하고, 나아가 선행적 판단 지표로 삼아야 한다.

따라서 대법원이 공공기관 경영평가성과급 판결을 통해 사용자의 지급의무성에 대해 개인성과급의 임금성 판결과 같이 지급 여부의 불확실성이 아닌 지급 근거의 유무(임금청구권일 인정할 수 있을 정도)를 기준으로 판단한 것은 타당하나, 근로의 대가에 대한 주된 판단지표인 ‘근로제공 관련성’에 대한 판단을 회피하고¹³⁷⁾, 통상임금의 판단 기준인 ‘일할 및 재직자 여부’, ‘소정근로의 대가’를 임금성 판단기준으로 삼은 것과 평균임금의 취지(통상적인 실생활임금)와 평균임금성을 긍정하는 요소가 되는 ‘지급형태의 계속성·정기성’을 임금성 판단기준으로 삼은 것은 타당하지 않다.

3. 복지포인트의 임금성

(1) 복지포인트의 임금성 판결의 변화

선택적 복지제도 중 하나로 근로자가 사용자로부터 지급받는 ‘복지포인트’는 「근로복지기본법」 등에 따라 기업복지체계 구축방안으로 도입된 제도라는 특징이 있다.

135) 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 「노동법률(통권 343호)」, 중앙경제, 2019, 37면

136) 하경효, 앞의 책, 42면

137) 박지순·이진규, 앞의 논문, 198면; 김희성·이준희, 앞의 논문, 255면



근로자의 근로제공 관련성이 인정되어 임금(통상임금)에 해당할 수 있는 것인지가 다수의 사전에서 문제되었고, 종래 하급심의 입장도 나뉘고 있었다.¹³⁸⁾

그러나, 2019년 8월 서울의료원의 복지포인트의 임금성에 대해 대법원이 전원합의체 판결로 부정한 이후 복지포인트의 임금성을 부정하는 다수의 판결이 이어졌다. 그 대표적인 사례로는 대법원 2019. 9. 9. 선고 2017다230079 판결, 대법원 2019. 9. 10. 선고 2015다30886·30893 판결, 대법원 2019. 11. 28. 선고 2019다261084 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2017다247602 판결, 대법원 2021. 6. 3. 선고 2015두49481 판결, 대법원 2021. 8. 26. 선고 2017다269145 판결 등이 있으며, 상기 판결 모두 임금성(통상임금)을 부정하였다.

(2) 복지포인트의 임금성을 최초로 부정한 판결

복지포인트의 임금성에 관한 최초 대법원 판결인 서울의료원 사건¹³⁹⁾의 경우 주요 사실관계와 대법원 판결의 요지는 아래와 같다.

1) 주요 사실관계

피고인 서울의료원은 2008년경부터 ‘선택적 복지제도 운영지침’에 따라 ‘선택적 복지제도’를 시행해왔다. 피고는 소속 직원인 원고들에게 전년도 말일 재직자를 기준으로 전직원에게 일률적으로 부여하는 ‘공통포인트’와 근속연수에 따라 차등 부여하는 ‘근속포인트’를 당해연도 1월 1일에 배정하였고, 1월(상반기)과 7월(하반기)에 균등하게 분할 지급하였다. 2012년까지는 상반기 신규입사자에게는 7월에 배정액의 반액을 하반기 입사자에게는 익년 1월에 반액을 각각 지급하였으나, 2013년 이후에는 12월 입사자를 제외하고는 근무기간을 일할 계산하여 배정 지급하였다.

직원들이 복지포인트를 사용 방법은 피고 전용 온라인 쇼핑사이트인 인터넷북리후생관에서 물건을 구매하거나, 인터넷북리후생관과 복지가맹업체 등에서 복지카드로 물건을 우선 구매하고 복지포인트 사용신청을 하여 피고로부터 상당액의 돈을 현금받

138) 임미나, 연합뉴스, 2016. 2. 2 기사, "복지포인트도 통상임금"...법원, 잇따라 인정 판결

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20160201202700004?input=1195m>

139) 대법원 2019.8.22. 선고 2016다48785 판결



는 것이다. 복지포인트는 매년 12월 20일까지 사용하지 못한 경우 소멸되고, 사용항목도 제한되어 있다.

원고들은 복지포인트를 통상임금에 포함시켜 계산한 연장근로수당 등 법정수당과 기지급 연장근로수당 등 법정수당의 차액을 지급하라고 주장하였다.

참고로 1심¹⁴⁰⁾ 및 2심¹⁴¹⁾ 법원은 복지포인트의 임금성(통상임금)을 긍정하였으나, 대법원은 전원합의체 판결을 통해 복지포인트의 임금성을 부정하고 원심을 파기 환송하였다.

2) 대법원의 판결 요지¹⁴²⁾

i) 다수의견¹⁴³⁾은 임금성의 판단 기준을 “임금성을 긍정하기 위해서는 그 금품이 근로의 대가로 지급되는 것이어야 하고 그 금품이 계속적 정기적으로 지급된 것이라 하더라도 근로의 대가로 지급된 것으로 볼 수 없는 경우에는 임금에 해당하는 것으로 볼 수 없고 근로의 대가로 지급된 것인지 여부는 그 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 밀접하게 관련되어 있어야 한다고 한다”라며 ‘근로제공 관련성’을 임금성(근로의 대가)을 인정하기 위한 필수적인 요건으로 보았다.

특히, ‘복지포인트의 근거법이 되는 「근로복지기본법」 제3조 제1항은 근로복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있어 「근로복지기본법」상 기업근로복지를 구성하는 선택적 복지제도에 기초한 복지포인트는 임금과 같은 근로조건에서 제외된다고 보는 것이 입법자의 의사이자 타당한 규범 해석이라고 보았다.¹⁴⁴⁾ 더불어 근거법

140) 서울중앙지방법원 2016. 1. 14 선고 2013가합79776 판결

141) 서울고등법원 2016. 10. 12. 선고 2016나3364 판결

142) 근로의 대가로서 논점을 명확히 하기 위해 임금성 판단 부분만 요지를 인용하도록 한다.

143) 다수의견은 대법원장 김명수, 대법관 조희대 대법관 권순일 대법관 이기택 대법관 안철상 대법관 민유숙 대법관 이동원 대법관 노정희의 의견임

144) 판결문 발췌 : 복지포인트의 전제가 되는 선택적 복지제도는 「근로복지기본법」에서 정한 제도이다. 「근로복지기본법」은 제3장 ‘기업근로복지’ 중 제3절에서 선택적 복지제도를 규율하고 있다. 그런데 「근로복지기본법」은 제1조에서 “근로복지정책의 수립 및 복지사업의 수행에 필요한 사항을 규정함으로써 근로자의 삶의 질을 향상시키고 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다.”라고 규정하고, 특히 제3조제1항은 “근로복지(임금·근로시간 등 기본적인 근로조건은 제외한다. 이하 같다)정책은 근로자의 경제·사회활동의 참여기회 확대 …”라고 규정하여 근로복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있다.



령 외에도, 선택적 복지제도의 연혁과 우리 법제와 실무에서의 도입배경, 노동현장에서의 복지포인트에 대한 인식, 사용 용도·사용 기한·양도 가능성의 제한, 복지포인트 배정 이후의 지급 절차와의 관계, 「근로기준법」의 규정 관계, 선택적 근로복지제도 활성화 등'을 이유로 복지포인트의 임금성을 부정하였다.

ii) 별개의견¹⁴⁵⁾은 「근로기준법」은 임금을 '사용자가 근로자에게 지급하는 일체의 금품'이라고 포괄적으로 정의하고 있으므로, 복리후생적 성격이 있다고 하여 일률적으로 임금이라는 성격이 배제되는 것은 아니며 '복지'라는 명칭으로 인해 임금성 여부를 판단하는데 장애가 되지 않는다고 보았다.

iii) 반대의견¹⁴⁶⁾은 어떤 금품이 임금으로 볼 수 있기 위해서는 그 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접·밀접하게 관련되어 있을 것을 요하나, 「근로기준법」의 규정 내용 및 근로자보호라는 입법취지를 고려해 볼 때 근로계약에 따라 근로를 제공하고 사용자로부터 지급받는 금품은 실비변상적이라거나 은혜적인 금품이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 근로제공과 직접 혹은 밀접하게 관련된 것으로 이해되어야 한다며 사용자가 근로자에게 금품을 계속적·정기적으로 지급하고, 지급에 관하여 단체협약이나 취업규칙 등에 근거하여 사용자에게 의무가 지워져 있다면 실비변상적이라거나 은혜적인 금품으로 볼 수 없는 이상 임금으로 보았다.

특히 반대의견은 다수의견이 「근로복지기본법」을 복지포인트의 근거법령으로 보아 법문을 근거로 복지포인트의 임금성을 부정하는 견해에 대해 「근로복지기본법」이 복지포인트의 임금성을 배제하려는 입법 의도나 목적을 가지고 있지 않고 「근로기준법」의 해석·적용을 통해 복지포인트의 임금성 해석·적용하여야 한다고 보았다.¹⁴⁷⁾

결국 「근로복지기본법」상 기업근로복지를 구성하는 선택적 복지제도에 기초한 복지포인트는 임금과 같은 근로조건에서 제외된다고 보는 것이 타당한 규범 해석이다.

물론 「근로기준법」의 관점에서 복지포인트가 임금인지 여부가 판단되어야 한다는 논의는 타당하다. 하지만 복지포인트의 임금성 여부를 판단할 때 관련 법률의 규정 역시 충분히 고려하여 규범조화적으로 판단함이 타당하다. 위와 같은 「근로복지기본법」의 규정 내용에서 알 수 있는 선택적 복지제도에 대한 입법자의 기본적인 규율 내용은 복지포인트가 임금이 아니라는 점에 기초하고 있음은 분명하고, 이는 임금성을 긍정하기 어려운 중요한 사정이다.

145) 별개의견은 대법관 김재형의 의견임

146) 반대의견은 대법관 박상옥, 대법관 박정화, 대법관 김선수, 대법관 김상환의 의견임

147) 판결문 발췌 복지포인트가 임금에 해당하는지는 「근로기준법」의 관점에서 그 실질에 비추어 임금으로 보호할 필요성이 있는지를 고려해서 판단하여야 한다. 노동법의 규율은 그



(3) 검토

대법원이 종래 엇갈린 하급심 판결을 전원합의체 판결을 통해 복지포인트의 임금성 여부에 대한 명확한 결론을 내렸고 이를 통해 법정안정성에 기여하였다는 것에도 의미가 있지만, 대법원이 전원합의체 판결을 통해 임금성과 관련한 판단 기준으로 ‘근로제공 관련성’을 명확하게 제시하였다는 것에 의미가 있다. 그간 대법원은 1999년 한국도로공사 전원합의체 판결¹⁴⁸⁾을 통해 ‘근로제공 관련성’을 임금 판단 기준으로 제시한 이후에도 대법원 소부가 2018년 공공기관 경영평가성과급 판결에서 ‘근로제공 관련성’에 대해 직접 판단하지 않고 ‘사용자의 지급의무성’과 ‘계속성·정기성’ 만을 가지고 임금성을 판단하였기 때문에 2018년 이후 가장 최근의 전원합의체 판결이라는 점에서 임금성 여부가 문제되고 있는 사안에 대한 그 해석과 판단의 기준이 될 수 있어 그 의미가 크다.¹⁴⁹⁾

보다 자세히 살펴보면 대법원 전원합의체 판결을 통해 i) 다수의견, 별개의견, 반대의견 모두 근로의 대가로서 임금성 판단기준을 실시하고 있어 임금성 판단에 대해 유형론적 접근이 아닌 본질적 접근을 하고 있음을 알 수 있고,¹⁵⁰⁾ ii) 다수의견과 반대의견이 임금성을 판단함에 있어 근로대가성 및 근로제공과의 직접적 관련성을 강조한 영화

실질에 따라 해석·적용되어야 함이 대원칙이다. 특히 임금에 해당하는지 여부가 한계선상에 있는 급여 항목의 경우 그 실질을 규명하여 법적 판단을 내리는 것이 중요하다. 다수의견이 들고 있는 「근로복지기본법」의 규정은 「근로복지기본법」이 정책적으로 규율하고자 하는 대상을 정한 것에 불과할 뿐, 개별 기업에서 시행하고 있는 선택적 복지제도의 내용을 이루는 복지포인트를 임금으로 평가할 수 있는지 여부까지 규율하고자 하는 입법 의도나 목적을 가지고 있다고 할 수 없다. 그리고 「근로복지기본법」의 규정이 「근로기준법」상 임금에 해당하는지 여부에 대한 해석 기준의 적용을 부정하고자 하는 입법 취지를 가지고 있다고 보기도 어렵다. 따라서 「근로복지기본법」의 규정이 복지포인트가 「근로기준법」상 임금이 아니라는 점에 기초하고 있다고 해석하거나, 이를 들어 임금성을 긍정하기 어렵다는 결론을 도출하는 것은 타당하지 않다. 오히려 「근로복지기본법」의 규정내용을 강조하는 다수의견은 「근로기준법」의 해석·적용 문제를 「근로복지기본법」의 해석·적용 문제로 사실상 치환하는 결과가 되어 부당하다.

148) 대법원 1999. 5. 12. 선고 97다5015 판결 : 근로자에게 지급되는 금품이 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함될 수 있으려면 그 명칭의 여하를 불문하고, 또 그 금품의 지급이 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등이나 사용자의 방침 등에 의하여 이루어진 것이라 하더라도 그 지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 있는 것, 즉 근로의 대상(대상)으로 지급된 것으로 볼 수 있어야 한다.

149) 한광수·김희성, 「복지포인트의 임금해당성」, 「노동법논총(제48집)」, 2020, 110면.

150) 한광수·김희성, 앞의 논문, 81면



진흥공사 자가운전보조비 임금성 사건을 실시하고 있어 ‘근로제공 관련성’이 근로의 대가를 판단하는 기준임이 명확해졌고 iii) 다수의견이 ‘사용자의 지급의무성’과 ‘계속성·정기성’이 인정되더라도 ‘근로제공 관련성’이 인정되지 않을 경우 임금성이 부정된다고 보아 판단 지표 간에 우위를 명확히 하였으며, iv) 반대의견이 「근로기준법」상 임금성 판단 기준으로 근로제공과의 관련성 여부, 지급의 계속성·정기성 여부, 사용자의 지급의무 유무를 인정하면서도 ‘사용자의 지급의무성’과 ‘계속성·정기성’이 인정되는 경우 오히려 ‘근로제공 관련성’을 추정하는 견해를 취하고 있어(소극적 배제방식), 대법원 전원합의체 판결(다수의견)이 ‘사용자의 지급의무성’과 ‘계속성·정기성’ 판단을 통해 ‘근로제공 관련성’을 추정될 수 없고 ‘근로제공 관련성’이 별도로 인정되어야 ‘근로의 대가’로 인정할 수 있다는 견해를 취하고 있음(적극적 포섭방식)을 확인할 수 있다.¹⁵¹⁾

2018년 공공기관 경영평가성과급 판결에도 불구하고 후술할 최근 민간기업 경영성과급의 임금성 관련 하급심에서 ‘근로제공 관련성’이 임금성 판단의 기준으로 명확히 설치되고 있는 것은 상기 2019년 8월 복지포인트 임금성 관련 대법원 전원합의체 판결의 영향임을 배제할 수 없다고 보인다.

다만, 다수의견은 복지포인트의 임금성을 판단함에 있어 지급형태의 특수성(사용용도·사용 기한·양도 가능성의 제한, 복지포인트 배정 이후의 지급 절차와의 관계) 외에 복지포인트의 근거 법령, 연혁과 도입배경, 당사자들의 인식, 제도의 활성화 등을 임금성 부정의 이유로 설치하였다. 이러한 다수의견의 태도가 임금성이 문제되는 다른 급부에서도 판단의 근거가 될 수 있는지에 대해서는 명확하지 않다.

III. 소결

임금성 즉, 근로의 대가의 의미에 대한 대법원의 판결을 과거부터 최근까지 정리해

151) 박종희, 227면-228면 : 박종희 교수는 다수의견과 같이 금품지급발생의무가 근로제공과 직접적 혹은 밀접하게 관련되는 경우라는 적극적 표지를 갖춘 경우 임금으로 인정하는 입장을 취한다면 임금으로 판단되는 범위가 다소 좁아지게 되기 때문에 이러한 판단 방식을 ‘적극적 포섭방식’이라고 설명하고 있고, 이에 반해 반대의견과 같이 계속적 정기적으로 지급되고 지급의무가 근거지워져 있다면 임금으로 간주하고 다른 부가적 판단기준을 덧붙이지 않는다면 임금인정 범위가 넓어질 수 있어 이러한 판단 방식을 ‘소극적 배제방식’이라고 하였다.



보았다. 앞서 살펴본 바와 같이 종래 법원이 ‘근로의 대가’의 의미를 규정하는 것에 대해 통일적인 견해를 취하였다고 보기는 어렵다. 특히 ‘근로의 대가’의 의미와 ‘근로 제공 관련성’과 다른 객관적 요건과의 관계에 대해 보다 깊은 고민이 있었던 것은 2018년 12월 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정한 판결 이후부터라고 보인다. 더불어 2019년 8월 복지포인트의 임금성 관련 대법원 전원합의체 판결이 있었지만, 대법원이 ‘근로의 대가’에 대해 명확한 요건과 판단 구조를 정립하고자 하였는지도 의문이다. 복지포인트 임금성에 대해 “임금 판단기준의 회귀성에 관한 비판적 검토”가¹⁵²⁾ 제기되는 것도 유사한 이유라고 보인다.

대법원이 2013년 전원합의체 판결을 통해 통상임금성 개념을 명확히 하고 통상임금성의 범위를 넓혀왔듯이, 개인성과급의 임금성과 집단성과급이라고 할 수 있는 공공기관의 경영평가성과급의 임금성을 인정하며 임금성의 범위를 넓히고 있지만¹⁵³⁾ 이 과정에서 통상임금과는 다르게 임금의 개념을 명확히 하고자하였고 그 결과 임금성의 범위가 확장되었다고 보이지 않는다.¹⁵⁴⁾

이로 인해 하기 제4장에서 살펴볼 경영성과급의 임금성에 대한 논란이 더욱 가중되고 있다. 향후 대법원이 경영성과급의 임금성에 관한 판결을 함에 있어 그 선행이 되는 ‘근로의 대가’의 개념과 판단 기준을 명확히 할 것이라고 기대된다. 더불어 앞서 살펴본 최근 판례 중 ① 개인성과급의 임금성(지급 여부 불확실성), ② 공공기관 경영평가성과급의 임금성(집단성과급, 외부적 요인), ③ 복지포인트의 임금성(「근로복지기본법」에 따른 기업복지체계, 연혁과 도입배경) 판결은 제4장에서 살펴볼 경영성과급의 임금성 여부를 밝힘에 있어서 논리적인 연관성을 가지며 경영성과급의 임금성 여부에 관해 어떠한 견해를 취하더라도 상기 3개의 판결과 관련되어 상호 모순되지 않은 논거가 제시되어야 한다.

152) 박종희, 앞의 논문, 227-228면.

153) 같은 취지로 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 89면 이하 참조 단, 권혁 교수는 실무상 임금의 범위가 확대되고 있다는 견해에 반대한다.(권혁, 앞의 논문, 196면 참조)

154) 다만, 복지포인트 임금성에 관한 대법원 전원합의체 판결상 반대의견을 통해서 우리 대법원이 사용자가 근로자에게 지급하는 급부에 대해 ‘근로제공 관련성’에 대한 판단 없이 ‘지급 의무’ 등의 판단지표가 인정되었다는 것을 이유로 ‘근로의 대가’로 추정할 수는 없다는 입장을 취하고 있음은 명확해졌다.



제3절 임금성 판단의 핵심 요건인 근로의 대가

I. 근로의 대가에 대한 다양한 해석론

학계에서는 ‘임금’의 개념과 범위를 명확히 정립하고 확정하기 위해 유형론적 해석 방법을 취하는 판례의 태도를 비판하며, ‘근로의 대가’를 판단하기 위한 요건에 대해 아래와 같은 다양한 견해가 제기되고 있다. 대부분의 견해는 ‘근로의 대가’를 해석함에 있어 ‘임금이 근로계약 상 근로제공의무와의 관계에서 쌍무적 관련성을 가진다.’는 법 논리를 부정하지 않는다.¹⁵⁵⁾ 즉, 다양한 해석론에도 불구하고 학계의 다수설은 근로계약은 민법상 쌍무계약(민법 제655조)이고, 근로관계는 근로제공과 임금지급의 교환을 목적으로 하는 채권관계라는 기본구조를 바탕으로 하며¹⁵⁶⁾ 이러한 논리적 구조 하에서 임금이란 근로계약 하에서 근로제공에 대한 반대급부로 지급되는 금품이기 때문에 근로제공과 임금지급은 쌍무적 관련관계에 있음을 인정하고 있다.

그럼에도 불구하고 각 해석론이 ‘근로의 대가’를 판단함에 있어 상호 다른 요건을 제시하고 있는 이유는 결국 i) 임금에 관한 개념의 정립과 범위의 확정에서 임금의 법적 성격과 법문에 충실하게 해석할 것인지 아니면 ii) 임금의 보호필요성에 보다 중점을 두어 해석할 것인지에 대한 견해의 차이로 인한 것으로 보인다.

II. 학설의 태도

아래에서 살펴볼 다양한 해석론은 근로의 대가를 인정하기 위한 요건과 판단지표 간의 관계 및 판단 구조 등 쟁점에 따라 견해가 나뉘지만, 크게는 ① ‘근로제공 관련

155) 김형배, 노동법(제27판), 박영사, 2021, 399면; 하경효, 임금법제론, 신조사, 2013, 41면 이하; 김유성, 앞의 책; 임종률 앞의 책; 문무기외 3명, 앞의 보고서, 7면; 박종희, 앞의 논문, 228면; 임상민, 앞의 논문, 1097면; 박지순 이진규, 앞의 논문, 174면; 권혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼」 제28호, 노동법이론실무학회, 2019, 199면; 한광수·김희성, 앞의 논문, 84면; 이선신, ‘「근로기준법」상 임금정의규정의 합리적 해석방안」 「노동법학」 제46호, 2013, 140면; 박은규, 앞의 논문, 33면

156) 김형배·박지순, 앞의 책, 102면; 박지순 이진규 앞의 글, 174면



성'을 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해와 ② 사용자의 '지급의무성'을 중심으로 근로의 대가를 추정하려는 견해로 나누어 볼 수 있다.

1. '근로제공 관련성' 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해¹⁵⁷⁾

이 견해를 취하는 학자들은 법문상 '근로의 대가'라고 정의되어 있는 점과 "근로계약 상 근로제공의무와의 관계에서 쌍무적 견련성"이라는 임금의 본래적 성격에 주안점을 두고 법원의 주된 3가지 객관적 판단지표 중 영화진흥공사 사건 판결에서 제시된 지표인 '근로제공 관련성(금품 지급과 근로제공간에 직접 또는 밀접한 관련성)'을 필수 요건(적극적 지표, 주된 요소)으로 인정하여 이를 중심으로 '근로의 대가'를 판단하여 법정안정성을 중시한다. 판단 방법으로 판단 요건(적극적 지표, 주된 요소)과 요소(소극적 지표, 보충적 요소)를 구분하며 판단 지표간에 우위성을 인정한다. 이 견해를 취하는 주요 학자간에도 '근로의 대가'에 대한 판단방법'에 있어 세부적인 견해의 차이가 있으며, 이를 구분해 보면 아래와 같다.

(1) 근로제공 관련성을 필수 요건으로 보는 견해

이 견해는 법원 및 학계가 '근로의 대가'에 대한 핵심 요건에 대해 의미를 엄밀하게 분석하고 확정하지 않은 채 개별 사안별 유연한 해석방법을 취하고 있는 것을 비판하면서 '임금의 개념'과 '근로의 대가의 판단방법'에 관한 견해를 제시한다.

임금의 개념에 대해 '임금이란 일반적으로 근로계약상 합의에 따라 근로자가 이미 제공하였거나 제공하게 될 근로에 대한 반대급부를 의미한다'라고 본다. 임금성이 인정되기 위해서는 i) 보수는 근로제공과 견련관계에 있어야 하며, ii) 상호견련성은 근로관계를 근거로 해야 하는데 이러한 두 개의 표지를 「근로기준법」에서는 '근로의 대가'로 정의하며 판례는 이를 근로제공 관련성(근로제공과의 직접 또는 밀접한 관련성)이라고 보고 있다고 한다.¹⁵⁸⁾

157) 하경효, 앞의 책; 박지순·이진규, 앞의 논문, 173면 이하; 권혁, 앞의 논문, 193면 이하; 김희성·성대규, 앞의 논문, 4면 이하; 김도한, "경영성과급의 임금성", 「중앙법학」 제24집 제1호, 중앙법학회, 2022, 139면; 심재진, 앞의 논문, ; 유성재 앞의 글, 32면 이하; 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 193면 이하; 임상민, 앞의 논문, 참조



근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어서는 판단 요건(기준)과 판단 요소를 나누어 접근할 필요가 있다고 본다. ‘근로의 대가’로 인정하기 위한 주된 판단 요건(구성요건)을 근로제공 관련성이라고 본다. 따라서 지급의무 존부, 지급근거 및 금액, 지급목적 및 산정방법에 대한 구체적 합의 존재 등은 부차적인 ‘판단 요소’에 불과하기 때문에 이러한 판단 요소는 개별 사안마다 필요에 따라 적용해야 한다고 보며¹⁵⁹⁾ 지급의무의 존부, 계속성·정기성 만으로 근로대가성을 단정할 수 없다고 본다.¹⁶⁰⁾

판단지표간 관계	주된 판단 요건	부차적 판단 요소
판단요건과 판단 요소를 구별 (→우위성 인정 추정 불가능)	근로제공 관련성 (구성요건)	지급의무 존부, 지급근거 및 금액, 지급목적 및 산정방법에 대한 구체적 합의 존재 등은 개별 사안마다 필요에 따라 적용 지급의무의 존부, 계속성·정기성만으로 근로대가성을 단정할 수 없음

(2) 주된 요소(근로제공 관련성)와 보충적 요소를 통한 추정을 인정하는 견해

이 견해는 법원이 그간 ‘근로의 대가’를 판단함에 있어 근로와의 직접적 또는 밀접한 관련성이 있는지에 대한 판단을 하거나, ‘계속성·정기성’, ‘지급의무의 존재’라는 유형적 판단을 통해 판단하는 이원적 방법을 취하였지만, 2019년 복지포인트에 관한 대법원 전원합의체 판결 이후 근로와의 직접적 또는 밀접한 관련성이 있는지를 ‘근로의 대가’로 보는 입장을 취하였다며 ‘임금의 개념’과 ‘근로의 대가에 관한 판단방법(판단구조)’에 관한 견해를 제시한다.¹⁶¹⁾

임금의 개념(근로의 대가)에 대해 사용자가 근로자에게 지급한 금품이 근로자가 이미 제공했거나 제공하게 될 근로에 대한 반대급부로 지급되었다는 것을 의미한다고

158) 박지순·이진규, 앞의 논문, 174면

159) 박지순·이진규, 앞의 논문, 173면

160) 박지순·이진규, 앞의 논문, 182면

161) 김희성·성대규, 앞의 논문, 8면



본다.¹⁶²⁾

근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 ① 1차로 근로제공관계와 쌍무적 견련관계에 있는 근로의 대가성을 인정할 수 있는지를 중심으로 근로제공 관련성을 판단(주요소) 하되, 주요소인 ‘근로의 대가’를 판단함에 있어 해당 금품의 지급 목적, 산정방법과 지급방법의 실질적인 모습, 당사자 사이의 합의의 목적과 내용 등에 대한 해석과 판단이 전제되어야 한다고 본다. ② 근로 대가성 판단을 통해서도 근로 대가성 인정 여부의 확정이 곤란할 경우에는, 2차로 해당 금품의 지급이 계속적, 정기적, 일률적으로 이루어지고 사용자에게 지급의무가 인정되는지 여부를 보충적, 부가적으로 판단하여 근로 대가성을 ‘간주’하게 된다고 본다.¹⁶³⁾

앞서 (1) 근로제공 관련성을 필수 요건으로 보는 견해와 비슷한 견해라고도 볼 수 있으나, 근로제공 관련성이 판단이 불분명한 경우 계속성·정기성, 일률성, 지급의무성을 통해 근로제공 관련성을 간주할 수 있다고 보고 있다는 점에 차이가 있다.

판단지표간 관계	주요소	보충적요소
주요소 보충적 요소 (→우위성 인정 추정 가능)	1차 판단 : 근로의 대가(근로제공 관련성) 판단 시 고려사항 : 금품의 지급 목적, 산정방법과 지급방법의 실질적인 모습, 당사자 사이의 합의의 목적과 내용 등에 대한 해석과 판단	1차 판단이 곤란하거나 불분명한 경우 계속성·정기성, 일률성, 지급의무성 →근로대가성 간주

(3) ‘지급의무발생’과 ‘근로제공’과의 직접·밀접적 관련성 유무라는 견해

이 견해는 일부 해석론상 법원이 임금의 개념 범위를 확대하고 있다는 견해(임금 개념 확대론)를 비판하며 그간 법원의 해석론은 법문에 충실하게 ‘근로의 대가’에 관한 일관된 입장을 취해왔으며 ‘임금의 개념’과 ‘근로의 대가에 관한 판단방법’에 관한

162) 김희성·이준희, 앞의 논문, 245면

163) 김희성·이준희, 앞의 논문, 245면 및 275면



견해를 제시한다.¹⁶⁴⁾

임금의 개념에 대해 임금은 ‘근로’라는 법적 사실과 ‘대가적 관계’에 놓이는 금품으로서, ‘근로’에 대한 대가여야 하며, 이는 근로가 영향을 미쳐 초래되는 ‘결과’에 대한 대가(추가적인 조건)와는 개념상 구별되어야 한다고 본다.¹⁶⁵⁾

근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 적극적 지표와 소극적 지표를 나누며 그 근거로 대법원(영화진흥공사 사건¹⁶⁶⁾)의 판결을 제시한다. i) 적극적 지표로 「‘해당 금품의 지급의무 발생’과 ‘근로제공’과의 직접·밀접 관련성」을 ii) 소극적 지표로 「‘지급의무 발생의 우연성’」을 제시한다. 소극적 지표와 관련하여 근로의 대가가 가지는 개념적 속성상 ‘근로의 제공’이라는 금부목적 사실이 존재하면 곧 확정적으로 대가의 지급의무가 발생되며, 그 외에 일정한 요건이나 사정을 조건으로 될 수 없기 때문에 지급의무의 발생이 개별 근로자의 특수하고 우연한 사정(추가적인 조건)에 의하여 좌우되는 경우 ‘근로의 대가’로 볼 수 없다고 본다.

참고로 적극적 지표 판단 시 판례가 제시한 객관적 지표 중 하나인 금품 지급의 ‘계속성·정기성’은 중요하지 않다고 보나, 평균임금이 해당 근로자의 평균적인 생활임금성을 징표하는데 기여하는 임금이어야 한다는 점을 고려하면 평균임금의 산입대상으로서 임금총액 산정에 있어 유의미한 요건으로 평가할 수 있다고 본다.¹⁶⁷⁾

판단지표간 관계	적극적 지표	소극적 지표
적극적 지표 소극적 지표 (→우위성 인정 추정 불가능)	근로의 제공과 — 지급의무 발생간 <직접·밀접 관련성 존재>	지급의무 발생의 우연성 (추가적인 조건 충족) ※계속성·정기성 평균임금 요건

164) 권혁, 앞의 논문, 196면

165) 권혁, 앞의 논문, 196~197면

166) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94다55934 판결

167) 권혁, 앞의 논문, 197-198면



2. ‘지급의무성’을 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해¹⁶⁸⁾

이 견해도 앞서 살펴본 바와 같이 「근로기준법」 상 임금의 정의 규정(근로의 대가)과 본래적 성격(근로계약상 근로제공의무와의 관계에서 쌍무적 전연성)을 가진다는 것을 고려하여 임금성을 인정함에 있어 ‘근로의 대상’일 것을 요구하고 있는 것은 앞서 ‘II.1. 근로 제공 관련성’ 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해와 동일하다. 그러나, 이 견해를 취하는 학자들은 ‘근로의 대상’의 의미에 대해 구체적인 해석을 하지 않거나, ‘근로의 대상’의 의미를 ‘근로제공 관련성’으로 보지 않거나 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중 지급의무성이 인정될 경우 ‘근로의 대가’를 인정하여 임금성의 범위를 넓게 보고자 한다.

이 견해를 취하는 학자들은 ‘근로의 대가’ 여부를 판단함에 있어 ‘근로제공 관련성’을 별도로 요구하지 않기 때문에 임금성을 폭넓게 인정하고 있으며, ‘계속성·정기성’ 또는 ‘지급의무성’을 ‘임금성’ 인정을 위한 독립적인 필수적 판단요건(요소)로 보고 각 지표가 동시에 모두 충족되어야 ‘임금성’을 인정한다. 이 견해를 취하는 학자들도 근로의 대가에 관한 판단 방법(구조)’에 대해 세부적인 견해를 달리하는데 이를 구분해 보면 아래와 같다.

(1) ‘계속성·정기성’ 및 ‘지급의무성’ 인정시 근로대가성 추정하는 견해

이 견해는 대법원이 영화진흥공사 판결에서 임금성 인정 시 ‘계속성·정기성’ 또는 ‘지급의무성’ 외에 ‘근로제공 관련성’이라는 부가적인 요소를 요구하였음에도 이후 판결에서는 ‘계속성·정기성’ 또는 ‘지급의무성’만으로 임금성을 판단하였고, 최근 대법원의 복지포인트 판결에서 또다시 ‘근로제공 관련성’을 요구하면서 임금의 판단 기준이 회귀된 것인지에 대해 의문을 제기하며 판례의 일관되지 못한 입장을 비판한다.

임금의 개념(근로의 대가)과 관련하여 사용자에게 지급하는 모든 급여는 근로의 대가로 지급되는 것으로 보는 것이 원칙이며, 근로의 대가로 볼 수 없는 명백히 예외적인 경우만 임금에서 제외되는 것으로 보는 것이 타당하다고 보기 때문에 임금이란 근로 제공의 대가로 지급하기로 되어 있는 대가관계에 놓여져 있다는 관념적 요소만 인정되면 그것으로 충분하다고 본다.¹⁶⁹⁾

168) 박종희 앞의 논문, 232면 이하, 이선신, 앞의 논문, 박은규, 앞의 논문



근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 때문에 ① 당사자의 의사로도 확인할 수 없거나 객관적으로도 명확하지 않는 경우에 비로소 보충적인 관점에서 근로의 대가 여부를 판단하게 되는 것이며 ② 근로의 대가 판단방법에 있어 i) 근로관계가 계속적 채권관계에 있다는 속성을 감안하여 ‘계속성·정기성’이 인정되어야 하며, ii) 근로계약의 쌍무적 견련관계하에서 사용자의 지급의무가 인정되어야 한다고 보기 때문에 ‘지급의무성’이 인정되어야 한다고 본다. 따라서 두 요건이 충족되면 임금으로 간주하여야 하며, 근로제공 관련성이라는 부수적 판단요소를 ‘근로의 대가’의 의미를 정의함에 있어 가미하는 것은 적절치 않다고 본다.

이 견해는 특히 복지포인트에 관한 대법원 전원합의체 판결과 같이 ‘근로제공 관련성’을 적극적 표지(요건)으로 인정하는 것과 관련하여¹⁷⁰⁾ 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중에서 근로 제공에 대한 대가로 직접적이고 밀접한 부분과 덜 직접적이고 덜 밀접한 부분이라는 것은 불분명할 뿐만 아니라 자칫 외형만으로 판단할 경우 본질을 흐리게 하거나 오해할 여지가 크며, 설령 구분 짓는다고 하더라도 의미의 모호성 때문에 자의적 판단으로 법적 안정성을 해할 우려가 높다고 본다. 따라서 ‘근로제공 관련성’은 ‘근로의 대가’의 핵심 요건 또는 부수적 요소도 아니라고 보며, 입증책임 분배의 원칙에 따라 ‘계속성·정기성’ 또는 ‘지급의무성’만을 판단하여 임금성을 추정하면 되고¹⁷¹⁾ 임금성을 부정하기 위해서는 사용자가 수당이 근로의 대가로 지급되는 것이 아니라는 점을 증명해야 한다고 본다.¹⁷²⁾

판단지표간 관계	판단 요건으로 인정	판단 요건 제외
동등한 요건 (→우위성 불인정 추정 가능)	1차 : 근로의 대가에 대한 당사자 의사 해석 2차 : 당사자의 의사 해석이 불분명한 경우에만 ‘계속성·정기성’ 및 ‘지급의무성’으로 근로의 대가 성을 추정하여 임금으로 간주함	근로제공 관련성

169) 박종희, 앞의 논문, 232면

170) 박종희, 앞의 논문, 228면 : 적극적 포섭방식

171) 박종희, 앞의 논문, 228면 : 소극적 배제방식

172) 복지포인트의 임금성 상 쟁점이 되었던 ‘배정’에 대한 문제를 반박하기 위해 ‘근로자에게 처분권한’이 부여되었다는 것을 임금성의 추가적인 요건을 명시하고 있다.



(2) ‘근로제공 관련성’과 ‘지급의무성’을 임금성 요건으로 추정하는 견해

이 견해는 임금성과 평균임금성을 구분해야됨에도 불구하고 판례가 임금성과 평균임금성을 구분하지 않고 3가지의 주된 판단표지를 모두 요구하고 있음을 비판한다.¹⁷³⁾

임금의 개념에 대해 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호 법문과 대법원 판례를 고려하여 근로의 대가의 의미는 임금근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 경우로 보며¹⁷⁴⁾ 근로제공의무와 임금지급의무는 근로계약에 의하여 쌍무적으로 발생하는 의무이기 때문에 근로계약 등에 의한 지급의무가 있는 급부를 임금이라고 본다. 근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 ‘근로의 대가’의 의미를 ‘근로제공 관련성’으로 인정하고 있는 것은 앞서 ‘II. 1. ’근로제공 관련성’ 중심으로 근로의 대가를 판단하려는 견해’와 동일하나, 근로의 대가 추정 등 판단 방법에 있어서는 명확한 견해의 차이를 보인다.

근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 임금성 인정을 위한 요건은 ‘근로의 대가 (=근로제공 관련성)’와 ‘지급의무성’이라고 보아 두 개의 요건을 동등한 요건으로 본다.¹⁷⁵⁾ 다만, 근로계약 등에 의한 지급의무성과 관련하여 특별한 사정이 없는 이상 사용자가 근로자에게 임금의 금품을 지급할 이유나 동기가 없기 때문에 그 금품이 임금이 아니라는 점에 관해서는 사용자가 입증해야 한다고 본다.¹⁷⁶⁾ 또한 지급의무의 사전확정성과 지급사유(또는 지급액)의 사전확정성은 서로 다른 개념이라고 본다.¹⁷⁷⁾ 따라서 ‘근로제공 관련성’과 ‘지급의무성’ 인정 여부만을 기준으로 임금성을 판단하되, 평균임금성을 판단 시 임시로 지급되는 임금이나 우발적 사유로 지급되는 임금은 평균임금 산정시 제외되어야 하며 ‘지급사유의 사전확정성’과 ‘계속성·정기성’은 임시로 지급되는 임금인지를 판단하는 평균임금을 산정하기 위한 요

173) 동일한 취지(이섷별·권오성, 앞의 논문, 170면)

174) 임상민, 앞의 논문, 1098면

175) 임상민, 앞의 논문, 1097면에 따르면 권오성 교수(앞의 글, 66면)도 동일한 견해를 취하고 있다고 본다.

176) 임상민, 앞의 논문 1100면 참조; 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 앞의 책, 249면(단, 객관적 요소만을 고려요소로 하여 추정하여야 한다고 본다)

177) 임상민, 앞의 논문, 1104면;



소178)에 불과하기 때문에 임금성 판단 시 고려하지 않는다¹⁷⁹⁾

판단지표간 관계	판단 요건으로 인정	판단 요건 제외
동등한 요건 (→우위성 불인정 추정 가능)	근로의 대가(=근로제공 관련성) 지급의무성 (≠지급액 또는 지급사유의 사전확정성)	계속성·정기성 지급사유의 사전확정성 (→평균임금 인정 요건)

(3) ‘근로의 대가’를 추정하고 객관적·주관적 요소를 동시에 고려하는 견해

이 견해는 판례가 임금성을 판단함에 있어 획일화하는데 한계에 부딪힌 결과 여러 객관적 판단요소만을 기준으로 유형론적 접근방법을 취하고 있는 한계를 비판하며 ‘근로의 대가’ 판단을 통한 임금성 판단 시 객관적 요소와 주관적 요소를 종합적으로 고려한 접근이 필요하다고 본다.

근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 1단계로 근로의 대가가 명백한 경우인지를 살펴 근로의 대가가 명백하다면 임금성을 긍정한다. 2단계로 만약 근로의 대가가 명백하지 않다면 판례와 같이 임금 운용의 실질에 따라 객관적 판단요소(계속성·정기성 및 지급의무성)를 추출하여 근로의 대가성을 추정하고, 아울러 주관적 판단요소를 고려하여¹⁸⁰⁾ 유형론적 접근방법에 따라 근로의 대가 여부를 판단한다. 3단계로 객관적 판단요소와 주관적 판단요소를 모두 고려하고 유형론적 접근방법에 의해 종합적으로 판단했음에도 불구하고, 해당 금품이 근로의 대가에 따라 지급된 것으로 볼 수 없다면 근로의 대가로 보지 않고 임금성을 부정한다.¹⁸¹⁾

178) 임금에서 제외되는 임시로 지급되는 임금을 판단하는 요소로 둘 중 하나만 부인되면 임시로 지급되는 것으로 볼 수 없어 임금성이 긍정된다고 본다.

179) 임상민, 앞의 논문, 1103면

180) 객관적 판단요소가 추정이 되지 않는다고 하여 주관적 판단요소에 대한 고려 없이 임금성을 부정하지 않아야 한다고 본다.(박은규, 앞의 논문, 92면)

181) 박은규, 앞의 논문, 190-192면



판단지표간 관계	판단 요건	판단 요건 제외
편면적 판단 요소 ¹⁸²⁾ (→우위성 인정 추정 가능)	1단계 : 근로의 대가가 명백한지 → 임금성 긍정 2단계 : 종합적 접근→근로대가성(임금성) 긍정 • 객관적 판단요소(계속성·정기성 및 지급의무성)로 근로대가성 추정 + 주관적 판단 요소(생성배경/목적, 지급 경위, 당사자 인식/실태)를 아울러 고려하여 유형론적 접근방법에 따라 종합적 고려(객관적 판단요소 추정안되더라도 주관적 판단요소 종합하여 고려하여 판단) 3단계 : 위 단계 상 임금성 긍정되지 않는 경우에만 → 임금성 부정	근로제공 관련성

(4) 주관적 요소로 판단하되 사회통념에 따라 ‘근로의 대가’를 추정하는 견해

이 견해는 판례가 “근로의 대가”의 실질적 내용에 대한 적극적 판단 유보하여 그 의미가 불분명하며 계속성·정기성, 발생근거 있는 지급의무, 일률성 등 임금표지요소들이 ‘근로의 대가’와 어떤 연관관계를 가지고 있는지 즉, ‘근로의 대가성’과 별개의 의미요소인지 아니면 ‘근로의 대가성’의 의미요소인지가 체계상 불분명하다며 비판한다.

임금의 개념(근로의 대가)과 관련하여 근로의 대가란 ① 단체협약이나 취업규칙 급여규정 근로계약 또는 노동관행에 의한 ‘지급의무성’과 ② ‘근로관계 유지’에 대한 교환적 취지로의 ‘교환관계성’의 두 개의 요소로 구성된다고 본다. ‘지급의무성’은 사용자가 법적 의무로서 급여지급의무를 부담하는 것을 의미하며, ‘교환관계성’이란 사용자의 급여지급이 근로자와의 근로관계유지에 대한 교환적 취지(사회통념상 합리적인 범위 내에서 인정될 수 있는 보상적 취지로 등가성이나 엄격성을 요하지 않음)로 이루어진 것을 의미한다고 본다.¹⁸³⁾

근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 ‘근로의 대가’ 여부는 ① 주관적 요소를 중시하기 때문에 1단계로 ‘당사자의 의사(주관적 요소로 노사간의 의사를 확인할 수 있는

182) 계속성·정기성 및 지급의무성은 임금을 판단하는 표지로 기능하나 임금을 부정하는 경우에 필요충분조건이라고는 할 수 없어 편면적 판단요소로만 기능한다(박은규, 앞의 논문, 75면)

183) 이선신, 앞의 논문, 98-99면



근로계약 또는 단체협약 등)’에 의하여 판단하여야 하며, 2단계로 만약 당사자의 의사에 의하여 판단하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란할 경우에는 사용자가 명시적 또는 묵시적으로 지급의무 있음을 인정하는 ‘사용자의 지급의사(또는 동기)’를 참작하여 판단하여야 한다고 한다. 다만, 위 두 방법으로는 판단이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 ② 보충적으로 사회통념에 따라 판단할 수 있는데 사회적 통념상 근로의 대가는 사실상 추정된다고 보고 추정의 강화 내지 배척과 관련한 요소를 통해 ‘근로의 대가’인지 여부를 판단하여야 한다. 사실과 정황에 따라 지급의무성의 추정을 강화하거나 교환관계성의 추정을 강화할 수 있는 반면 임의적·은혜적 급여에 해당한다면 지급의무성의 추정을 배척하는 요소가 되며, 기업설비업무비에 해당한다면 교환관계성의 추정을 배척하는 요소가 된다고 본다. 특히, 근로의 대가 외의 표지 중에 계속성·정기성은 교환관계성과 지급의무성의 추정을 모두 강화하는 요소가 될 수 있다고 본다.¹⁸⁴⁾

앞서 (1) ‘계속성·정기성’ 또는 ‘지급의무성’ 인정시 근로대가성을 추정하는 견해와 비슷한 견해라고도 볼 수 있으나, 계속성·정기성을 개념적 징표가 될 수 없다고 보는 점에 차이가 있다.¹⁸⁵⁾

판단지표간 관계	판단 요건	판단 요건 제외
주관적 요소 사회통념 상 보충 (→우위성 불인정 추정 가능)	<근로의 대가> ① 주된 판단 기준 : 주관적 요소 중시하여 판단 1차 : 근로의 대가에 대한 당사자 의사 해석 2차 : 당사자의 의사 해석이 불분명한 경우에만 사용자의 지급의사(또는 동기)를 참작하여 판단 ② 보충적 판단 기준 : 사회통념에 따른 판단 원칙 : 대가성은 사실상 ‘추정’ 예외 : 대가성 추정 배척 또는 강화에 관한 요소 고려하여 판단 • 강화요소 : 사실과 정황, 계속성·정기성 • 배척요소 : 임의적·은혜적 급여, 기업설비업무비	근로제공 관련성 계속성·정기성

184) 단, 사용자가 특정 급여를 계속적·정기적으로 지급하였다고 하더라도 그러한 관행으로부터 사용자의 지급의무가 곧바로 발생한다고 볼 수는 없 때문에 계속성·정기성은 지급의무성보다 교환관계성 추정에 영향이 더 크다고 본다.(이선신, 앞의 논문, 109면)

185) 이선신, 앞의 논문, 108면



Ⅲ. 소결

위와 같이 근로의 대가의 개념과 판단방법(구조)에 대해 다양한 견해가 제기되고 있으며 위 견해들을 유형화하여 종합해보면 아래와 같은 특징이 있다. ① 근로제공 관련성을 중심으로 판단하는 견해는 법원이 그간 객관적 판단 지표로 삼았던 지표 간에 우위성을 인정하며 근로제공 관련성이 인정되지 않는 이상 다른 지표를 통해 근로의 대가를 추정하지 아니하기 때문에 논리적으로 임금의 범위를 좁게 해석하게 된다. ② 반면 지급의무성을 중심으로 판단하는 견해는 법원이 그간 객관적 판단지표로 삼았던 지표 간에 우위성을 인정하지 않으며 사용자가 근로자에게 지급하는 금품의 근로의 대가로 추정하고 임금성이 아니라는 입증은 사용자가 하여야 한다고 보아 오히려 임금성 부정에 대한 입증은 사용자가 하여야 한다고 본다.

[표 3] 근로의 대가 관련 견해 유형화

판단지표 추정	근로제공 관련성 중심으로 판단		지급의무성 중심으로 판단	
	우위성 인정	우위성 불인정	우위성 인정	우위성 불인정
불가	1-(1)견해 (추정 불가) 1-(3)견해 지급의무 우연성 (소극적 요소)	-	-	-
가능 (입증책임 전환)	1-(2)견해 (보충적 추정, 단, 입증책임 전환은 불인정)	-	2-(3) 견해 (편면적 판단)	2-(1) 견해 (+계속성·정기성) 2-(2)견해 (+근로제공 관련성) 2-(4) 견해 (+교환관계성)

또한 ‘근로의 대가’에 관한 다양한 견해에 대한 분석을 통해 아래와 같은 사항이 근로의 대가의 개념과 판단방법을 정립함에 있어 쟁점이 됨을 확인할 수 있다. ① 근로의 대가의 개념을 정립함에 있어 쟁점이 되는 것은 1) 근로제공 관련성이라는 요건



이 필요한 것인지 여부 2) 지급의무의 불확실성이 지급 여부의 불확실성인지 아니면 지급액(지급률)의 불확실성까지도 의미하는 것인지 여부, 3) 법원이 객관적 판단지표로 삼았던 계속성·정기성도 근로의 대가의 개념에 포함될 수 있는지 여부이며, ② 근로의 대가의 판단방법(구조)에 있어 쟁점이 되는 것은 1) 각 판단 요건(지표)간 우위성이 인정되는지 여부와 2) 지급의무성이 인정될 경우 다른 객관적 판단 지표를 통해 근로의 대가를 추정하는 것이 합리적인지 여부라는 것을 도출할 수 있었다. 이하 ‘제4절 근로의 대가의 의미와 판단 방법’에서는 위 쟁점을 중심으로 살펴보도록 한다.

제4절 근로의 대가의 의미와 판단방법

I. 쟁점 검토의 방향성

위에서 살펴본 바와 같이 근로제공 관련성, 지급의무성, 계속성·정기성의 각각의 의미와 이를 근로의 대가의 판단지표로 볼 수 있는지를 살펴보고 지표 간 우위성 인정 여부와 사용자가 근로자에게 지급한 금품이라는 이유로 또는 근로의 대가가 아닌 다른 판단요소가 충족되었다는 이유로 근로의 대가를 추정할 수 있는지 순으로 살펴본다. 다만, 근로의 대가를 부정하는 요소가 되는 불확실성(불확정성)에 대해서는 근로제공 관련성 측면에서의 발생의 불확실성과 지급의무성 측면에서 지급의 불확실성을 나누어서 살펴보는 것이 타당하나 쟁점 간 혼재가 되지 않도록 지급의무성에서 검토하도록 한다.

II. 근로의 대가 판단 지표와 그 의미

1. 근로제공 관련성

(1) 근로제공 관련성의 의미

법원은 ‘근로제공 관련성’ 상 ‘관련성 정도’에 관해 ‘직접 관련성 또는 밀접한 관련



성'이라고 보고 있는데, 법원 판결과 다르게 '간접적 관련성'이 있는 금품까지 근로의 대가라고 보아야 할 것인가의 문제이다.

이에 대해 i) 임금의 법적 성격상 현실적인 근로제공을 전제로한 대가로서 간접적 관련성까지 포함하는 것은 본래적 성질에 부합한다고 보기 어려운 점, ii) 「근로기준법」 상 임금은 민법상 보수와 다르게 노동관계법 상 특별한 보호를 받고 강행규정성을 가지며 보호 법령에 대한 위반 시 사용자가 처벌될 수도 있어 합목적성과 법정안정성 사이에서 법익의 균형이 요구되는 점, iii) 임금성과 관련한 논란이 있었던 개인성과급의 임금성 판결 시 '근로제공과 직접 또는 밀접한 관련성'이 임금성 인정의 주요 논거가 되었는바 근로제공 관련성이 반드시 임금의 범위를 좁게 해석하려는 견해라고 보기도 어려운 점 등을 고려한다면 법원과 같이 '관련성'의 의미를 '직접 또는 밀접'으로 제한하여 파악하는 것이 타당하다.

직접 또는 밀접 관련성의 의미는 사전적으로 해석될 수 있으며 '직접'은 근로제공이 최종적 원인 내지 조건이 되어 금품 제공이 이루어지는 상태로서 다른 매개 원인 내지 조건이 없는 상태, '밀접'은 여러 원인 내지 조건 중 근로제공이 금품 지급의 주된 원인 내지 조건이 되는 상태로 해석할 수 있다.¹⁸⁶⁾

(2) 근로제공 관련성 필요 여부

'근로의 대가'를 개념(요건)으로 근로제공 관련성을 요하지 않는다는 견해는 '사용자가 지급하는 모든 금품을 특별한 예외가 없는 이상 근로의 대가'로 보는 것을 전제로 하고¹⁸⁷⁾ 관련성의 의미가 모호하다는 비판을 제기한다. 근로자에게 지급되는 임금에 대한 보호 범위를 넓히고자 하는 취지 하에서는 일응 타당한 면이 있으나, 아래와 같은 이유로 근로제공 관련성은 근로의 대가의 개념(요건)의 핵심적 지표가 되어야 한다.

그러나, 임금 일반론에서 살펴본바와 같이 i) 임금의 법적 성질 상 쌍무계약인 근

186) 직접은 중간에 제3자내 매개물 없이 바로 연결되는 관계를 의미하며 밀접은 아주 가깝게 맞닿아 있음. 또는 그런 관계에 있음을 의미함(국립국어원 표준국어 대사전 참조)(김희성 성대규, 앞의 논문, 6면)

187) 박종희, 앞의 논문, 228면



로계약에 따라 근로제공에 대한 대가로서 관련성을 가져야 한다는 점(노동대가설), ii) 근로제공 관련성이 필요하지 않다는 견해도 임금의 민법 상 쌍무계약에 바탕을 둔 근로계약 하에서 근로제공에 대한 반대급부로 지급되는 금품이며, 근로자의 근로제공의무와 사용자의 임금지급의무는 쌍무적 관련관계에 있다는 점을 부정하지 않는 점, iii) 우리나라 「근로기준법」은 임금의 개념을 법제화하고 있어 입법자의 의사에 따라 ‘근로의 대가’를 중심으로 판단하여야 하여야 한다는 점, iv) 근로제공을 전제로 하지 않고 사용자가 임의로 지급하는 금품은 임금의 본래적 속성 상 임금으로 볼 수 없기 때문에 근로의 대가의 개념을 논함에 있어 근로제공 관련성을 전제로 해야 하는 것은 당연한 점을 고려하면 근로제공 관련성은 ‘근로의 대가’의 개념을 구성하는 핵심적 지표이자 필수적 판단 요건으로 보아야 한다.

참고로 ‘관련성’은 정도의 개념이기 때문에 의미상 모호한 부분이 있을 수 있고 이로 인해 오히려 법적안정성을 해칠 우려가 있다고도 볼 수는 있지만 ‘관련성’의 의미에 대해 밝히지 않는다면 ‘관련성’을 부정하려는 입장에서도 판단의 기준이 없게 된다는 점, iii) ‘관련성’이 ‘근로(제공)’와 ‘대가’를 연결하는 가장 중요한 개념이기 때문에 이에 대한 의미를 명확히 정립하는 것이 근로자에게도 예측가능성을 높일 수 있다는 점, iv) 덜 직접적이고 덜 밀접한 부분에 대한 판단이 용이하지 않은 것은 맞지만 계속성 및 정기성도 단 한번의 예외라도 인정한다면 이 또한 정도의 개념이기 때문에 모호성은 여전히 내재되어 있는 점 등을 고려하면 ‘근로제공 관련성’은 근로의 대가의 개념을 구성하는 요건이 된다.

2. 지급의무성

(1) 지급의무성의 의미

지급의무성의 의미에 대해 사용자의 지급의무에 대한 존부라고 보아 단체협약, 취업규칙, 근로계약에 따른 법원(法源)을 의미한다고 보는 것에 다수의 견해가 일치한다. 다만, 근로의 대가성을 부정하는 불확실성(불확정성)의 의미 및 노동관행 인정여부에 따라 견해가 나뉜다.



1) 불확실성(불확정성)

근로의 대가와 관련하여 문제가 되는 것은 ‘불확실한(불확정적인) 금품’이다. 불확실성(불확정성)은 지급의무성에서만 문제가 되는 것은 아닌데 ① 근로제공 관련성 측면에서 발생 여부가 불확실한 금품과 ② 지급의무성 측면에서 지급이 불확정적인 금품을 나누어 살펴보는 것이 필요하다.

우선 ① 근로제공 관련성 측면에서 불확실성을 살펴보면 근로제공과 더불어 다른 요소가 개입되어야만 임금 발생되며(‘직접’ 관련성 없음) 더불어 근로제공이 아닌 다른 요소가 임금발생에 주된 요소가 된다면(‘밀접’ 관련성 없음) 이는 다른 요소의 개입으로 근로제공과 임금 발생간에 불확실성이 발생한 것으로 보아야 하며 근로제공 관련성이 부정된다고 보아야 한다.¹⁸⁸⁾ 참고로 ‘근로제공이 아닌 불확실한 조건 성취에 따라 지급의무가 발생된다면 지급의무성(지급의무의 확정성)과 배치되기 된다’고 보아야 이를 지급의무의 문제로 바라보는 견해가 제기되나¹⁸⁹⁾ 불확실한 조건 성취는 지급의무성이 아닌 근로제공과 지급의무 발생 사이의 관련성(근로제공 관련성) 측면에서의 불확정성을 의미한다고 해석하는 것이 보다 명확하다.

그 다음으로 ② 지급의무성 측면에서 불확정성을 살펴보면 ‘지급요건이 갖추어질 경우 회사가 지급을 거절할 수 없다’는 의미로 지급의무성을 파악하는 것이 타당하다.¹⁹⁰⁾ 즉, 지급의무성이 인정되기 위해서는 ‘지급 여부’가 확정되어야 기대권¹⁹¹⁾을 인정할 수 있으며 지급의무성(금품지급의무)은 근로자의 임금청구권(소송상 소구할 수 있는 권리)을 전제로 하여야 한다. 따라서 지급 자체에 대한 의무와 지급액에 대한 의무를 분리해서 판단하는 것은 타당하지 않다.¹⁹²⁾

188) 동일한 취지로 권혁, 앞의 논문. 202면 : 근로제공 관련성이 인정되기 위해서는 근로 제공이라는 급부 목적 사실 그 자체가 존재하면 확정적으로 대가지급의무가 발생하여야 한다고 보아야 하며, 근로제공이 이루어진 이후에 외부적 요인과 결합하여 발생한 결과와 연계된 금품은 근로제공 자체에 대한 대가가 아니라 격려나 분발 등 별도의 목적을 가진 금품이라고 본다.

189) 김희성·성대규, 앞의 논문, 6면

190) 심재진, 앞의 논문(공공기관 경영평가성과급의 임금성), 114면 다만, 이 견해는 지급을 거절할 수 없다는 의미가 임금청구권과 관련되어 지급액이 특정되어야 한다는 의미로 사용한 것으로 보이지는 않는다.

191) 김재훈, “성과급은 임금에 포함되는가?”, 「노동법률(통권 180호)」, 중앙경제, 2006. 45면

192) 최진수, 앞의 글, 113면; 김희성, 앞의 글, 57면



따라서 통상임금의 고정성과 같이 사전에 지급액이 확정될 필요는 없으나¹⁹³⁾ 지급 요건 내에서 근로제공과 관련한 조건 성취 결과에 따라 지급액이나 지급물을 산출할 수 있어야 사용자의 지급의무성을 인정할 수 있다고 보이며 근로제공과 관련된 조건이 성취된 후에도 지급액을 확정할 수 없다면 사용자의 전적인 재량에 따라 지급되는 임의의 불확정적인 금품으로 보아야 한다. 참고로 ‘지급의무 확정성’에 대해 단체협약이나 노사합의에 따라 지급 여부는 이미 확정된 것이라라는 견해가 있는데¹⁹⁴⁾ 단체협약이나 노사합의로 지급대상과 지급의 한도만 설정되고 구체적인 지급액에 대해 사용자가 재량권을 가지고 결정할 수 있다면 지급의무성이 인정된다고 보기는 어렵다. 법원에 의하여 해당 금품의 지급 요건 자체가 확정되지 않았다면 임금에 관한 특별한 법적 보호를 해야 할 범위도 확정하기 어렵고 이는 임의적으로 지급하는 금품에 해당하기 때문이다. 이러한 금품은 민법상 보수에 해당할 뿐이며 노동관계법 상 특별한 보호를 받는 임금이 될 수는 없다.

지급의무성이 인정되기 위해서는 사용자의 금품 지급의무 즉 근로자의 임금 청구권이 법적 근거를 바탕으로 인정될 수 있어야 한다. 사용자의 지급 의무가 법적 의무로 인정되기 위해서는 지급 대상 등 발생 조건에 관한 사항이 법원(法原)에 근거해야 할 것인바, 단체협약·취업규칙·근로계약 등에 명시되어 있거나, 노동관행에 따라 사용자의 지급의무가 인정될 수 있어야 한다. 법원도¹⁹⁵⁾ 이와 동일한 취지로 지급의무성을 해석하고 있다.

2) 노동관행

노동관행은 명시적인 법률의 규정이나 당사자의 합의와는 무관하게 ‘반복된 사실’에 대해 규범력을 부여하는 것으로 이를 인정함에 있어서는 엄격성이 요구된다.¹⁹⁶⁾ 법원은¹⁹⁷⁾ 기업의 내부에 존재하는 특정의 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고

193) 지급 여부의 확정성과 관련하여 사전확정성으로 해석할 경우에는 임금성 판단 시 적절하지 않다는 비판이 제기될 수 있으나(유성재, 앞의 글, 30면.; 이셋별·권혁, 앞의 논문, 164면) 본 연구에서 ‘지급 여부의 확정성’은 통상임금의 요건인 사전 확정성을 의미하는 것이 아니며 사전에 단체협약 또는 취업규칙 등의 법원에서 정한 발생 조건을 충족한 이후에 지급액 또는 지급물이 특정되어 임금청구권을 행사할 수 있는 확정성을 의미한다.

194) 권오성, 앞의 글, 67면

195) 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결; 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000다18127 판결 등

196) 김희성·성대규, 앞의 논문, 12-13면

197) 대법원 1995. 2. 14. 선고 94다21818 판결; 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결; 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701 판결; 대법원 2014. 2. 27. 선고 2011다109531 판결 등.



하기 위해서는 관행이 기업 사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나 구성원에 의해 일반적으로 아무도 이의를 제기하지 않고 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상 제도로써 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범 의식에 의해 지지되고 있어야 한다고 판시하고 있다.

따라서 사용자의 지급의무를 인정하는 근거 중 ‘노동관행’은 반복적 급부의 계속이라는 사실로부터 근로자가 향후 이와 동일한 급부를 사용자로부터 받게 된다는 신뢰를 한 경우에 이러한 신뢰는 관행을 기초로 보호될 수 있고, 임금청구권의 근거인 법원이 될 수 있다고 보아야 한다.¹⁹⁸⁾

(2) 지급의무성 필요 여부

지급의무성이 근로의 대가를 판단하는 지표가 되는지에 대해 i) ‘대가’는 급부간에 상호 의존적 관계를 의미하며¹⁹⁹⁾ ‘관련성’은 개념 상 상호간의 관계를 이어주는 개념이 되는데 이때 하나의 축이 ‘근로’라고 본다면 하나의 축은 ‘임금’이 되고 전자는 근로계약 상 근로제공의무를 의미하며 후자는 임금지급의무를 의미하는바 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 ‘근로의 대가’는 ‘법적 의무 발생’을 전제로 하는 개념이라는 점, ii) 법적 지급의무가 인정되지 않는다면 이는 사용자가 법적 의무 없이 임의로 지급하는 것(지급에 대한 재량권을 가지는 것)에 불과하여 근로의 대가로서 지급되는 것이라고 보기 어려운 점, iii) 쌍무적 관련성 상 사용자의 지급의무가 인정되지 않는다면 근로자가 대가를 청구하는 것에 대한 권리도 인정될 수 없다는 점²⁰⁰⁾ 등을 고려하면 ‘지급의무성’은 근로의 대가의 개념을 구성하는 요건이 된다고 보아야 한다.

3. 계속성·정기성

(1) 계속성·정기성의 의미

계속성이란 어떠한 금품의 지급이 1회에 그치는 것이 아니라 지속적으로 지급되고

198) 하경효, 앞의 책, 29면; 김희성·이진규, 앞의 논문, 246면

199) 이선신, 앞의 논문, 98면

200) 박종희, 앞의 논문, 236면



있다는 것을 말하고, 정기성이란 일정한 단위기간을 기준으로 하여 계속하여 반복적으로 지급되는 것을 말한다.²⁰¹⁾

(2) 계속성·정기성의 필요 여부

계속성·정기성을 근로의 대가의 판단지표로 볼 수 있는지와 관련하여 계속성·정기성은 i) 임금과 평균임금은 구분되는 개념으로 임금의 정의 규정인 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호상 계속성·정기성과 관련된 문구는 명확히 명시되어 있지 않지만²⁰²⁾ 「근로기준법」 시행령 제2조 제2항 상 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’은 평균임금에서 제외되도록 명시되어 있는바, 판례에서 임금성 판단 시 판단표지로 삼은 계속성·정기성은 근로의 대가 및 임금성과 관련된 개념이 아닌 평균임금과 관련된 개념이라고 보는 것이 법문 상 타당한 점²⁰³⁾ ii) 지급의무성을 ‘지급사유 발생의 불확정성’이 아닌 ‘법상 지급근거’로 본다면 계속성·정기성은 지급된 결과물에 불과하여 임금성 판단에서 의미가 없게 되는 점²⁰⁴⁾ ii) 만약 일부 미지급 사례가 있더라도 계속성·정기성을 인정할 수 있다고 본다면 계속성·정기성도 결국 정도의 문제가 되기 때문에 직접 또는 밀접성과 마찬가지로 모호한 개념이 된다는 것은 마찬가지라는 점 iii) 대법원 전원합의체 판결도²⁰⁵⁾ “금품이 계속적·정기적으로 지급된 것이라 하더라도 그것이 근로의 대상으로 지급된 것으로 볼 수 없다면 임금에 해당한다고 할 수 없다”라고 판시한바 있어 계속성·정기성은 근로의 대가나 임금성 개념을 이루는 요건이 아닌 하나의 요소에 불과하다고 보고 있는 점²⁰⁶⁾ 등을 고려하면 계속성·정기성은 근로의 대가의 개념을 구성하는 요건이 될 수 없다. 다수의 학자들도 계속성·정기성을 ‘근로의 대가’의 개념을 구성하는 요건으로 보고 있지 않다.²⁰⁷⁾

201) 하경효, 앞의 책, 44면 이하

202) 박은규, 앞의 논문, 81면

203) 임상민, 앞의 논문, 1101-1105면 참조

204) 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성“, 108면

205) 대법원 2019. 8. 22. 선고 2016다48785 판결

206) 이선신, “임금 유연성 제고에 관한 법리 연구“, 108면

207) 박지순·이진규, 앞의 논문, 181면; 권혁, 앞의 논문, 197면; 임상민, 앞의 논문, 1102면; 이선신, 앞의 논문, 108면; 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성“, 108면;



즉, 계속성·정기성은 외견으로 확인되는 지급 형태일 뿐으로 귀납적 방법에 따라 ‘지급의무성’을 긍정하는 하나의 판단 표지(요소)의 역할을 할 뿐이며 그 자체가 ‘근로의 대가’의 필수적 요건이 될 수는 없다. 실제 다수의 견해가 계속성·정기성은 평균임금의 판단 요건이지 ‘근로의 대가’의 판단 요건이 아니라고 보거나 부수적인 판단 요소에 불과하다고 보고 있다. 다만, 계속적·정기적으로 지급되었다면 지급의무성 인정하는 요소(특히, 지급근거가 명확하지 않은 경우 노동관행을 인정 여부를 검토함에 있어 중요한 판단 요소)가 될 수는 있다고 보인다.

Ⅲ. 근로의 대가 지표간 우위성 및 추정 가능 여부

1. 지표간의 관계

법원 및 학계는 대체로 근로제공 관련성을 근로의 대가를 인정하는 요건으로 인정할 경우 근로제공 관련성을 다른 판단지표보다 핵심 요건(주된 요소, 적극적 요소)으로 보고 있다. 근로의 대가의 개념을 구성하는 ‘판단 요건’과 ‘요건을 판단하기 위한 요소’를 구분하게 된다면 판단 요건과 요소간에 우위성이 인정되어야 하는 것은 당연하다. 근로의 대가로서의 판단 요건을 충족하지 못한다면 다른 판단 요소가 인정되더라도 근로의 대가로 인정될 수 없기 때문이다.

2. 근로의 대가에 대한 추정 가능 여부

추정을 통해 근로의 대가를 인정할지 여부는 법률안정성과 합목적성 중 무엇을 더 중시할 것인지에 따라 견해가 나뉠 수 있다. 이는 결국 증명책임의 부담을 누구에게 부담하게 할 것인지의 입증책임의 전환과도 연계될 수 있다.²⁰⁸⁾ 근로의 대가를 추정해야 한다는 견해는²⁰⁹⁾ 대체로 사용자가 근로자에게 지급하는 금품을 특별한 사정이

208) 박종희, 앞의 논문, 228면

209) 박종희, 앞의 논문, 228면(계속성·정기성 및 지급의무성으로 근로의 대가 추정); 임상민, 앞의 논문, 1098면(지급의무성만 추정되어 지급의무성에 대한 입증책임은 사용자가 부담); 박은규, 앞의 논문, 190-192면(객관적 요소인 계속성·정기성 및 지급의무성으로 근로의 대가 추정); 이선신, 논문, 109면(사회통념상 교환관계성과 지급의무성 추정)



없는 이상 근로의 대가로 보는 것이 타당하다는 것을 전제하고 있다.

그러나 i) 「근로기준법」 상 임금에 해당하게 될 경우 민법 상 보수와는 다르게 강행규정성을 가지며, 위반자에 대한 처벌 등이 수반되기 때문에 특별한 보호를 받게 되는바 법적안정성을 고려하여 임금의 범위를 확대하는 것은 신중할 필요가 있는 점, ii) 근로관계하에서 사용자가 지급하는 모든 금품을 ‘근로의 대가’로 본다면 임금의 정의 규정 상 ‘근로의 대가’라는 표현은 굳이 필요하지 않게 되며 이는 법문에 충실한 해석이 될 수 없다는 점, iii) 최저임금을 준수하는 범위 내에서 당사자간에 임금이 아닌 금품을 지급하는 것이 가능하며 당사자의 의사를 통해 근로의 대가가 명확하지 않고 객관적으로도 근로의 대가로 지급되는 것이 명확하지 않음에도 근로의 대가성을 추정한다는 것은 임금성을 지나치게 확대하는 것이 된다는 점, iv) 임금청구 시 입증책임은 근로자에게 있음에도 불구하고 ‘근로의 대가’ 부분에 대해서만 추정을 하여 입증책임을 전환하는 것은 타당하지 않다는 점, v) 근로의 대가의 개념에 기반하여 판단하는 것이 어렵다고 하여 근로의 대가를 추정한다면 본질에 대한 판단을 회피하는 것에 불과하다는 점, iv) 근로의 대가의 추정을 위한 요소는 그 자체가 목적이 아닌 수단이라고 보아야 함에도 ‘지급의무성’과 같은 근로의 대가의 요건을 추정을 위한 요소로 삼는 것은 요건과 요소(목적과 수단)를 명확히 구분하지 않은 것으로 타당하지 않다는 점 등을 고려한다면 근로의 대가는 추정이 아닌 본래의 개념에 대한 요건 그 자체를 판단하는 것이 보다 합리적인 방법이다.

법원도 최근 복지포인트 임금성에 관한 대법원 전원합의체 판결에서 사용자가 근로자에게 지급되는 것은 특별한 사정이 없는 이상 근로의 대가로 보아야 한다는 견해를 다수견해가 아닌 반대견해로 판시하였다. 이점을 고려하면 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 즉 지급의무성이 인정된다는 이유만으로 근로의 대가를 추정할 수는 없다는 것이 법원의 입장임이 명확하다고 보인다.

IV. 근로의 대가의 판단 방법

앞서 살펴본 바와 같이 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호 임금 정의 규정의 범문



에 충실한 해석, 쌍무적 견련관계에 있는 임금의 본래적 특성 등을 고려하면 근로제공 관련성과 지급의무성을 근로의 대가의 개념을 구성하는 요건으로 볼 수 있으나, 판례가 근로의 대가 판단 지표로 삼았던 계속성·정기성은 「근로기준법」 시행령 제2조 제2항의 평균임금의 개념을 구성하는 요건이라고 보아야 한다. 임금성을 부정하는 ‘불확실성’은 지급의무성 뿐만 아니라 근로제공 관련성에서도 문제가 된다. 근로제공 관련성이 인정되지 않아 금품의 발생이 불확실한 것과 법원이 인정되더라도 법원 상의 지급조건만으로는 임금청구권이 특정될 수 없어 지급의무가 불확정적인 것을 구분하여야 한다. 양자 모두 불확실성으로 인해 근로의 대가가 인정될 수 없다.

따라서 ‘근로제공 관련성’과 ‘지급의무성’으로 본다면 양자간에는 우위성이 인정될 수는 없으나, 근로의 대가를 구성하는 필요충분조건인 요건과 요건을 판단하기 위한 요소간에 우위성이 인정되는 것은 논리적으로 당연하다. 다만, 근로의 대가를 다른 요소를 통해 추정하는 것이 합리적인지는 결국 법정안정성과 합목적성 중 무엇을 중시할지에 따른 판단 방법의 문제일 뿐 근로의 대가의 개념을 정립하는 문제는 아니다. 따라서 양자의 방법은 선택의 문제라고도 볼 수 있으나, 우리 「근로기준법」이 임금의 개념을 법제화하였고 쌍무적 견련성을 가지는 근로제공의무와 관련된 임금지급의무는 본래적 속성 상 근로제공 관련성이 반드시 요구되어야 한다는 점, 「근로기준법」 상 임금에 관해 강행규정성을 부여하고 특별한 보호를 하고 있는 법제하에서 추정을 인정하는 것은 어렵다는 점 등을 고려하면 근로의 대가를 판단함에 있어 가장 합리적인 것은 그 개념을 구성하는 각각의 요건을 직접적으로 판단하여 근로대가성 해당 여부를 밝히는 것이다. 따라서 근로의 대가를 판단하는 방법은 아래와 같이 방법을 통해 판단할 수 있다.

첫째, 근로의 대가를 판단하기 위해서는 ‘근로제공 관련성’과 ‘지급의무성’ 요건이 모두 인정되어야 한다.

둘째, ‘근로제공 관련성’은 당사자 의사(지급 목적, 생성 배경), 해당 금품의 산정방법과 지급방법의 구체적인 실태 등을 통해 판단될 수 있다. 이 과정에서 금품 지급 의무 발생의 조건이 근로제공과 ‘직접’ 또는 ‘밀접’하게 관련되어 발생되는지 아니면 근로제공과 무관한 다른 조건의 성취를 통해 임금이 발생되는지를 살펴야 한다.



셋째, ‘지급의무성’은 단체협약·취업규칙 등 명시적인 법원 또는 반복지급과 구성원 신뢰에 바탕을 둔 노동관행 여부 및 산정방법과 지급방법의 구체적인 실태를 통해 판단될 수 있다. 이 과정에서 사용자에게 지급의무를 인정할 수 있는 지급조건이 법원에 특정되어 있는지(법원에 따른 지급 요건이 갖추어질 경우 사용자가 재량에 따라 지급 여부를 결정할 수 없도록 지급액이 특정될 수 있어야 함)를 살펴야 한다. 이 때 유의할 것은 법원에 근거한 지급 요건에 따라 산출된 지급액이 ‘0원’이 되더라도(평가 결과 낮은 등급을 받아 금액이 0원이 되더라도) 이는 지급 요건을 적용하여 산출된 결과로 지급 여부가 사용자의 재량에 있다고 볼 수 없기 때문에 지급의무성은 부정되지 않으며 지급 요건 적용에 따라 지급액이 ‘0’원으로 특정된 것으로 보아야 한다.

넷째, 위의 판단방법에 따라 근로의 대가 여부가 불분명할 경우 설사 계속적·정기적으로 지급되었더라도 임금성을 인정할 수 없으며 「근로기준법」 및 노동관계법 등 임금에 관한 규정이 아닌 「민법」상 보수에 관한 규정이 적용될 뿐이다.

[표 4] 근로의 대가 판단 방법



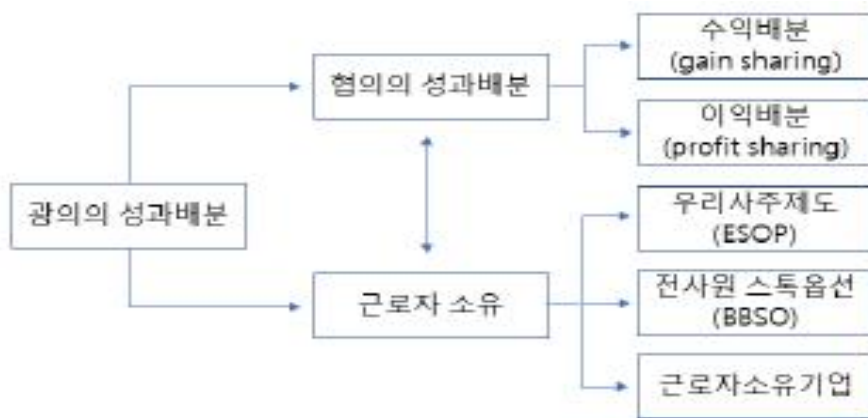
제4장 경영성과급의 임금성 판단

제1절 경영성과의 배분

I. 성과배분제의 의의

성과배분제는 기업, 사업부, 부서 등 집단의 성과에 연동해서 지급하는 집단성과급으로서, 성과배분제는 협의로는 이익배분(Profit sharing)이나 수익배분(Gain sharing)처럼 현금 성과배분을 지칭하지만, 경우에 따라 우리사주제도(ESOPs)나 전사원 대상 스톡옵션 등 근로자 소유(Employee ownership)를 포함하는 광의로 사용되기도 한다.²¹⁰⁾

[표 5] 성과배분의 의미²¹¹⁾



주 : 협의의 성과배분과 근로자 소유 사이의 쌍방향 화살표는 현금 대신 주식으로 (협의의) 성과배분을 하거나 (협의의) 성과배분금액으로 우리사주에 투자하는 등 두 제도가 밀접한 관련성이 있음을 의미. 근로자 소유기업은 우리사주조합 등이 50% 이상의 지분을 갖는 경우임.

210) 이장원·김동배·이상준, 「성과배분제도의 실태와 발전방안」, 한국노동연구원, 2020, 4면

211) 이장원·김동배·이상준, 위 보고서, 5면



협회의 성과배분제도에 대해 보다 구체적으로 살펴보면 성과를 산정하는 기준과 방법에 따라 근로자들이 경영에 참여하여 원가절감, 생산성 향상 등의 활동을 통해 조직성과의 향상을 도모하고 그 과실을 회사와 근로자가 함께 분배하는 수익배분제도(Gain sharing)와 일정기간 동안 발생한 기업이익을 사전에 정해지거나 그때 그때마다의 분배기준에 따라 근로자에게 나누어주는 이익배분제도(Profit sharing)로 크게 나뉘어진다. 이익배분제도는 근로자 참여를 반드시 필요로 하지 않고 시장상황 등 외부적인 요인까지 성과에 영향을 미친다는 점에서 수익배분제도와 구별된다. 성과배분제의 도입은 기업성과와 보상을 연계함으로써 기업과 근로자의 협력을 촉진하여 집단적 생산성 향상과 품질개선에 긍정적 효과가 기대된다. 또한 근로자에 대한 금전적 보상은 물론 경영참여 욕구를 충족시켜 기업의 경영목표와 근로자의 욕구를 통합하는 기능을 함으로써 노사안정에도 기여한다.²¹²⁾

성과배분제도는 2001년 제정된 「근로자복지기본법」에 법적 근거를 두고 있다. 「근로자복지기본법」 제20조 제1항은 사업주에게 초과 달성된 경영성과를 근로자에게 배분하도록 노력할 의무를 규정하였고, 현행 「근로복지기본법」 제84조도 동일한 내용으로 성과배분을 규정하고 있다. 이는 사업주로 하여금 근로자의 복지 향상을 위해 성과배분제도를 도입하도록 노력할 것을 규정한 것이라고 할 수 있다. 그리고 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제20조 제1항 제1호는 ‘생산성 향상과 성과배분’을 경영참가를 통한 협력적 노사관계를 근간으로 하는 노사협의회가 협의하여야 할 사항으로 규정하고 있다.²¹³⁾

7차년도(2017년) 사업체패널조사²¹⁴⁾에 따르면 표본조사대상기업인 62,601개소 중 성과배분제도²¹⁵⁾ 운영 비율은 19.4%로 나타나고 있다. 이중 사전에 정해진 성과배분 산정식을 보유한 비율은 64.1%로 나타나고 있다.²¹⁶⁾ 이를 통해 성과배분을 실시하는

212) 노동부, 성과배분제 도입 매뉴얼, 2001.1, 1면 참조[박지순·이진규, 앞의 논문, 182-183면 재인용]

213) 박지순·이진규, 앞의 논문, 182면

214) 사업체패널조사(Workplace Panel Survey:WPS)는 전국 사업체 중 농림어업 및 광업 등 일부 산업을 제외한 전 산업의 30인 이상 규모 사업체를 대표하도록 구성된 표본을 대상으로 2001년부터 격년마다 실시하는 패널조사임

215) 사업체패널조사의 성과배분제도에는 고정상여금을 포함하여 산출하고 있다.

216) 6~7차년도 사업체패널조사 기초분석보고서(한국의 사업체로 본 노동시장 현황), 한국노동연



다수의 기업은 성과배분을 제도화하여 운영하고 있음을 확인할 수 있다.

Ⅱ. 경영성과급의 의의

1. 경영학에서의 경영성과급

경영학에서의 임금은 인적자원에 대한 보상의 측면에서 기업이 종업원에게 지급하는 일체의 보상 내지 비용의 의미로 사용되는데, 크게 기본적 임금(직접적 임금)과 부가적 임금(간접적 임금)으로 나뉜다. 이 때 ‘기본적 임금’이란 근로의 대가 그 자체로 지급되는 기준임금과 수당을 의미하는 것으로서 ‘경제적 임금’에 해당한다. 다음으로 ‘부가적 임금’은 종업원과 기업이 이익공동체에 해당한다는 전제 하에 종업원이 경영성과에 대한 이익 배분에 참가함으로써 지급받는 ‘참여적 임금(배분참여급)’과 공동체주의의 규범에 따라 종업원이 직장을 삶의 공동체로 인식하게 하도록 하기 위한 혜택으로 지급받는 ‘사회적 임금(복리후생급)’으로 나뉜다. 이와 같이 경영학에서 기업이 종업원에게 지급하는 보상으로서의 임금을 기본적 경제적 임금, 참여적 임금(배분참여급), 사회적 임금(복리후생급)의 3가지로 분류하는 기준에 따르면, 「근로기준법」상의 임금 개념과 유사한 개념은 ‘기본적 임금’에 해당하며 기업의 경영성과에 대한 배분으로서의 경영성과급은 ‘참여적 임금’에 해당하는 것으로 볼 수 있다.²¹⁷⁾

2. 경영성과급의 특징

경영성과급은 전형적인 집단적 성과급으로 기업 내 조직 혹은 기업 전체가 달성한 성과 또는 이익을 기초로 이를 사용자가 근로자에게 배분하는 의미로 지급되기 때문에 경영성과급은 근로자 개인이 제공한 근로의 내용과 그 실적이 기업 내 조직 또는 기업전체가 달성한 성과 또는 이익에 어떤 영향을 끼쳤는지 판단하기 어렵다는 특징이 있다. 기업 내 부서 혹은 전체 기업이 달성한 이익에는 개별 근로자가 제공한 근로

구원, 2020, 78면

217) 박지순·이진규, 앞의 논문, 183-184면



와 그 실적뿐만 아니라 다양한 요소들이 영향을 미치기 때문이다.²¹⁸⁾

3. 경영성과급의 도입 연혁 및 도입 배경

경영성과급의 연혁을 미국의 성과배분제도를 중심으로 살펴보면 수익배분제(Gain sharing)은 1896년 미국의 Henry Towne에 의해 종업원에 대한 집단적인 보너스 제도(과실을 분배하기 위한 제도)로 도입되어 종업원들이 경영에 참여를 통한 생산비 절감 및 생산성 향상을 목표로 한다.²¹⁹⁾ 이익분배제(Profit sharing)의 경우 1980년대 미국경제가 어려워지자 조합원을 해고하지 않기 위한 대책으로 도입된 제도로 매출액이나 이익의 증대를 목표로 한다.²²⁰⁾ 수익배분제의 경우 종업원의 참여를 요소로 하는 반면 이익배분제는 종업원의 참여를 요소로 포함하고 있지 않기 때문에 이익분배제와 집단성과배분제는 임금성을 달리 볼 수 있다. 즉, 수익배분제의 경우 종업원 참여를 전제로 하여 종업원의 근로제공을 통한 절감비용을 배분하는 것으로 수익배분제는 근로제공과 성과배분간의 관련성이 이익배분제보다 더 밀접하다고 할 수 있다.

성과배분제도가 우리나라에서 본격적으로 도입된 배경은 1987년 이후 노동운동이

218) 김도한, 앞의 논문, 144면

219) 김동원·유구창, “집단성과배분제도”, 1면, 4면 참조

성과배분제도 유형	이익배분제	집단성과배분제
최초 연혁과 도입취지	1980년대 미국경제가 어려워지자 조합원을 해고하지 않기 위한 대책으로 도입	1896년 미국의 Henry Towne에 의해 종업원에 대한 집단적인 보너스 제도(과실을 분배하기 위한 제도)로 도입
종업원의 참여	참여를 전제로 하지 않음 종업원의 노력뿐만 아니라 여러 다른 요소(시장상황, 경쟁사의 전략, 경기부침 등)에 의해 목표 달성	참여를 전제로 함 종업원이 경영에 참가하여 원가절감, 생산성 향상 등의 활동을 하여 목표 달성
도입효과	이익배분제도는 사원들에게 노사가 공동운명 체임을 알리는 상징적인 효과는 있으나, 이익배분제도가 기업의 경영성과에 미치는 영향을 측정한 연구들에 의하면, 이익배분제도는 성과배분제도에 비하여 훨씬 미약한 효과를 가짐	

220) 이영면, 이익분배제에 대한 노사의 입장 변화 : 미국의 경험과 시사점, 「산업관계연구(제12권)」, 한국고용노사관계학회, 2002.



활성화되면서 정부는 과거 권위주의적인 시대에 시행되었던 민간부문에 대한 임금개입을 자제하고 임금교섭은 해당 기업의 노사가 자율적으로 하여야 한다는 입장 변화 때문이었다. 우리나라에서 성과배분제도에 대한 사회적 관심이 높아지고 논의가 본격화되기 시작한 것은 1991년 정부가 임금정책으로 총액임금제를 제시하면서 성과배분제도의 도입을 권고하기 시작하면서부터였는데 정부는 임금인상액의 기준을 각종 수당을 포함한 총액임금으로 하는 '총액임금제'를 제시하고 성과급은 이 총액임금의 범위에 포함시키지 않을 것을 요구하면서 도입을 적극적으로 권고하고 홍보하였다, 그 결과 3년이 지난 1994년 조사 당시 성과배분제도를 도입하였거나 한적이 있는 기업은 528개의 조사대상 기업 중 96개로 18.2%에 달하였고, 이중 1991년 이후에 도입한 기업의 비중은 72.9%에 달하였다.²²¹⁾ 특히 도입 동기와 관련하여 임금인상의 편의적 활용이라는 응답은 전체의 9.4%에 불과하였고 근로의욕 고취 및 생산성 향상이라는 응답이 전체의 81.3%에 해당하였고, 성과배분제도의 기준은 대부분이 이익분배제의 유형인 매출액 기준(30.2%), 이익 기준(26.0%), 매출액 및 이익기준(30.2%)이었다.

즉, 우리나라의 경영성과급의 도입 연혁 및 배경을 살펴보면 경영성과급은 임금인상의 편의적 활용을 위해 도입된 것이 아니라 근로의욕 고취 및 생산성 향상을 위해 도입되었고, 그 도입 형태도 매출이나 영업이익 등을 중심으로 하였음을 알 수 있다.

제2절 경영성과급의 임금성 관련 다양한 견해

I. 경영성과급 임금성 관련 논의 필요성

2018년 말 공공기관 경영평가성과급의 임금성이 대법원에서 인정된 이후 2020년부터 민간기업의 경영성과급의 임금성(퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금)이 인정되는 지에 관한 하급심 법원의 판결이 내려지기 시작했다. 민간기업은 공공기관과 다르게 경영성과급의 지급원인, 지급형태, 지급기준, 지급방식 등이 매우 다양하기 때문에 향

221) 박영범, 「주요 선진국의 성과배분제도」, 한국노동연구원, 1994, 1~3면 참조



후 법원에서 다른 회사의 경영성과급의 임금성 여부가 판결되더라도 명확한 판단기준과 판단기준별 동일한 해석과 논거가 통일되게 제시되지 않는다면 줄소송이 나올 수 있다. 이러한 사회적 비용을 최소화하기 위해서라도 경영성과급의 임금성 특히 활발한 분쟁이 진행 중인 민간기업의 경영성과급의 임금성 여부 판단 기준에 대한 명확한 해석과 통일된 논거 그리고 이에 대한 신속한 정리가 필요한 상황이다.

그러나, 현재 법원에서는 유사한 사실관계 심지어 동일 사실관계에 있는 민간기업의 경영성과급에 대해서도 임금성 여부에 대해 상반된 결론을 내리고 있고 임금성에 관한 각 쟁점마다 극심하게 양분된 논리를 취하고 있다. 마찬가지로 학계에서도 경영성과급의 임금성에 관해 각 쟁점을 기준으로 대립되는 견해가 제기되고 있다.

II. 경영성과급의 (평균)임금성 관련 학설

경영성과급에 대해서도 임금성이 인정되기 위해서는 사용자가 근로자에게 지급하는 근로의 대가로 볼 수 있어야 하는바, 앞서 제시한바와 같이 ① ‘근로제공 관련성’과 ② ‘지급의무성’이 인정되어야 한다. 따라서 이를 중심으로 살펴보면, 현재 쟁송 중인 대부분의 사안이 경영성과급을 평균임금성 산정시 포함해달라는 청구인 점을 감안하여²²²⁾ 평균임금성 판단 요건인 ③ ‘평균임금의 취지에 부합 여부’를 포함하여 경영성과급의 임금성에 관한 대립된 견해의 논거를 살펴본다.

1. 근로제공 관련성

경영성과급은 ‘경영실적 달성 여부’ 따라 그 ‘지급 여부’도 달라진다는 점에서 근로자에게 지급되는 다른 급부와 구분되는 특징을 가지고 있다. 예를 들어 SK하이닉스 사건의 경우 “EVA(economic value added)”를 경영실적 달성의 기준으로 하였고, 현대해상화재보험·발레오전장시스템스코리아·한국유리공업의 경우 “당기순이익”을 기준으

222) 평균임금의 요건인 ‘계속성·정기성’에 대해서는 학자들마다 견해 차가 없어 별도로 검토하지 아니한다.



로 하였으며, 삼성전자 1차 및 2차 사건의 경우 “경영성과에 대한 평가 또는 EVA”를 그 기준으로 하였다.

경영성과급의 임금성 여부에 대한 판단 기준에 대한 해석과 논거가 가장 극심히 대립하는 부분은 단연코 근로제공 관련성 부분이라고 할 수 있다. ‘경영실적 달성’과 근로계약에 따른 ‘근로제공’ 간에 판례에서 제시한 ‘직접 또는 밀접한 관련성’을 인정할 수 있는지에 대해 아래와 같이 긍정설과 부정설이 모두 제기되고 있다.

(1) 긍정설

긍정설²²³⁾은 경영성과 달성은 근로자들의 ‘협업 근로’의 총체적 결합으로 달성되며 경영성과급은 이러한 근로자의 기여 부분에 대한 가치를 평가하여 지급하는 것으로 근로의 대가로 볼 수 있고, 불확정적인 급부는 현시점에서 불분명한 경우가 아니고 현시점에서 불확정적인 급부가 임금이 아니라면 개인성과급의 임금성도 부정되어야 하나 이러한 개인성과급의 임금성을 긍정함하고 있고, 개인성과급의 임금성과 다르게 경영성과급의 임금성만 부정할 이유가 없다고 본다.

i) 경영성과란 회사 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여, 협업에 의한 근로자들의 근로제공 등이 총체적으로 결합하여 이루어진 것이다. 그래서 회사는 경영성과를 경영진에 대한 보수, 주주에 대한 배당, 근로자들에 대한 성과상여 등으로 배분한다.²²⁴⁾

ii) 근로자들이 받는 경영성과급은 근로자들이 제공한 ‘협업 근로’가 경영성과에서 차지한 가치를 평가하여 그 몫을 지급하는 것이므로 근로의 양이나 질과 밀접한 관련이 있다고 평가되어야 한다. 또한 경영성과 창출에 근로자의 기여 부분 외에 다른 부분이 있다 하더라도, 여러 기여 부분 중 근로자 자신의 기여 부분에 대한 대가를 근로

223) 임상민, 앞의 논문, 1128면; 이셋별·권오성, “임금에 관한 최근 판결 경향의 검토”, 「노동법포럼(제36호)」, 노동법이론실무학회, 2022, 168면; 심재진, 앞의 논문, 82면; 유성재, 앞의 글, 33면; 김홍영, 앞의 논문, 85면(단, 김홍영 교수는 경영성과급의 임금성을 긍정하면서도 통상의 생활임금을 사실대로 산정한다는 평균임금의 기본원리에 비추어 부적절한 면이 있다고 보아 임금성을 인정하더라도 평균임금의 기본원리에 어긋나므로 평균임금에는 포함시키지 않는다는 판례법리가 형성되어야 한다고 본다.)

224) 임상민, 앞의 논문, 1128면



자가 받는 것이 왜 근로의 대가가 아닌 것으로 되는지에 대한 근거도 불분명하다. 만일 경영성과가 근로자의 근로제공과 전혀 무관하다면 이를 배분하는 회사의 대표이사는 경영진에 대한 보수, 주주에 대한 배당, 회사 유보 등으로 처리해야 할 부분을 임의로 근로자에게 배분함으로써 회사에 손해를 끼쳤으므로 회사 등을 피해자로 한 횡령이나 배임 등이 성립한다고 보아야 한다. 그러나 아무도 이와 같은 논리를 주장하지 않고 이와 같이 보지도 않는다. 또한 회사는 이윤을 추구하는 사업자이지 자선사업자가 아니므로 근로자가 제공한 근로에 대한 대가가 아니라면 집단성과상여금을 근로자에게 지급할 특별한 이유나 동기가 없다.²²⁵⁾ 경영성과금은 협업의 질까지를 포함하여 회사가 요구하는 근로의 질을 높인 것에 대한 대가로 지급되는 것이다.²²⁶⁾ 결과가 개별 근로자의 근로제공과 관련성이 낮은 경우에도, 그러한 결과를 초래한 원인(근로자들의 협업)이 ‘근로제공과의 관련성’이 인정되는 경우에는 근로의 대가로 볼 수 있다.²²⁷⁾

iii) 법원이 판단하고 있는 ‘특수하고 우연한 사정’이란 ① 근로자가 특수한 근무조건에서 근로를 이행하기 위해 비용이 발생하는 경우 ② 근로 제공과는 무관한 개별 근로자의 특수한 상황 및 자격을 충족할 때 금품을 지급하는 경우 ③ 금품 지급의무가 현시점에서는 불분명한 개인의 실적 등에 달린 경우이다. 이 중 ③의 경우는 그 이후의 판결에 따라 ‘특수하고 우연한 사정’에서 제외되었다. 제반 경영 상황을 둘러싼 외부 요인들이 목표달성 여부에 개입한다고 하더라도 노사가 합의하여 경영성과에 대한 목표를 정하고, 연간 목표 달성하기 위해 근로자들이 협력하여 근로를 이행했다면, 목표달성으로 지급되는 경영성과금이 곧바로 ‘특수하고 우연한 사정’으로 해석될 수 없다.²²⁸⁾

iv) 근로자 개인의 실적 역시 근로자가 통제할 수 없는 불확정적이고 외부적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있다. 그럼에도 개인성과상여금의 임금성을 인정함이 판례와 통설의 입장이다. 근로자가 통제할 수 없는 불확정적이고 외부적 요인에 의하여 영

225) 임상민, 앞의 논문, 1128면

226) 심재진, 앞의 논문, 82면

227) 유성재, 앞의 글, 33면

228) 이선헌, 권오성, 앞의 논문, 168면



향을 받을 수 있다고 하여 근로자가 제공한 근로의 성과에 대하여 그 몫으로 받는 것(배분된 구체적인 성과급 액수는 근로자가 개개인에게 개별적으로 귀속되고 있음)²²⁹⁾이 왜 근로의 대가가 아닌 것으로 되어야 하는지 분명한 논거도 없다. 근로자가 자신이 개인적으로 이룬 성과에 대하여 그 대가를 지급받는 것(개인성과급)이나 근로자집단이 이룬 성과 중 개인의 몫을 안분하여 그 대가를 지급받는 것(집단성과급)이나 결국 근로자가 제공한 근로에 대한 대가라는 점에서 그 본질을 같이 한다.²³⁰⁾

v) 대법원에서 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정하였는바, 민간기업의 경영성과급도 공공기관 경영성과급과 다르게 판단할 이유가 없다고 한다.

(2) 부정설

부정설²³¹⁾은 경영성과 달성은 시장상황 등 근로조건 관련성이 현저히 떨어지는 외부적 요인이 주된 결정 요소로, 경영성과급은 이익을 분배하여 근로자들에게 동기를 부여하기 위해 지급되는 것일 뿐 그 자체가 근로의 대가라고 볼 수 없고, 경영성과급의 외부적 요인은 근로자가 통제할 수 없는 결정적 요소로 이러한 불확정성은 근로의 대상성과 양립할 수 없고, 개인성과급은 경영성과급과 다르게 개인의 성과와 성과급 지급 간에 연관이 명확히 드러나기 때문에 개인성과급의 임금성이 인정된다고 하여 경영성과급의 임금성이 인정될 필요는 없다고 본다. 주요 논거는 아래와 같다.

i) 경영성과급은 회사 전체가 위 다양한 외부적 요건에 따라 매출목표를 달성하거나 영업이익이 창출된 경우 이를 일정 조건을 갖춘 근로자들에게 분배함으로써 근로자에 대한 동기를 부여하며 업무를 독려하기 위한 차원에서 지급되는 것일 뿐, 그 자체로 개별 근로자의 근로제공에 대한 대가로 지급되는 것으로 볼 수 없다.²³²⁾

ii) 근로제공 관련성은 근로자의 근로 제공과 사용자의 경영성과급 지급 사이에

229) 김홍영, 앞의 논문, 85면 단, 김홍영 교수는 무분규(또는 조기타결)이 지급조건인 금원은 경영성과급과 다르게 근로제공과는 직접 또는 밀접한 관련이 있는 금원으로 보기 어려우므로 임금성이 부정된다고 본다.

230) 임상민, 앞의 논문, 1128면

231) 박지순·이진규, 앞의 논문, 199면; 김희성·성대규, 앞의 논문, 21면, 권혁, 앞의 논문, 209면, 김도한, 앞의 논문, 148면

232) 박지순·이진규, 앞의 논문, 199면



쌍무적 견련관계가 존재하는지에 따라 판단되어야 하며, 구체적으로는 경영성과급의 지급이 개별 근로자의 근로제공과 ‘직접적’으로 또는 ‘밀접’하게 관련되어 있는지에 따라 판단되어야 하는데, 경영성과급은 경영성과급의 지급을 위한 성과의 창출에 근로자가 기여하는 부분이 있다는 사정은 있지만, ‘시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등’ 개별 근로자의 근로제공과의 관련성이 현저히 떨어지는 사정들이 경영성과급의 지급여부 및 지급조건 결정에 있어 주요한 요소로 경영실적은 근로제공과는 직접적으로 또 밀접하게 관련되어 있다고 볼 수 없고²³³⁾ 간접적인 관련성만이 있다.²³⁴⁾

iii) 근로의 제공과 ‘직접’ 관련되거나 ‘밀접’하게 관련되어 있기 ‘때문에’ 지급된 금품이라면 이는 임금으로 인정될 수 있는데 ‘직접’ 관련되어 있다는 것은 근로제공과 임금지급 사이에 어떠한 요소도 개입되지 않아야 함을 말하고, ‘밀접’하게 관련되어 있다는 것은 ‘직접’ 관련되어 있다고 인정할 수 있을 정도로 근로제공과 임금지급 사이가 아주 가깝게 맞닿아 있어야 함을 말한다. 경영성과급의 경우 ‘근로의 제공’과 ‘경영성과급 지급의무의 발생 및 이행’ 사이에는 개별 근로자가 전혀 통제할 수 없는 결정적인 요소들이 반드시 개입될 수밖에 없으므로, 경영성과급이 필연적으로 내포하고 있는 ‘불확정성’과 ‘근로의 대상성(근로제공에 대한 직접적 또는 밀접한 관련성)’은 서로 양립할 수 없는 모순된 요소이다.²³⁵⁾

iv) 오늘날의 근로 형태는 개개인에게 적합한 업무도 있지만 다수의 노무 제공자가 협업하여 하나의 작업을 이루어야 하는 경우도 있다. 따라서 법원의 판단과 같이 다수 근로자의 집단적 협업 역시 근로자 개개인에게 지급되는 임금과 대가적 견련관계에 있다고 하더라도 이러한 집단적 협업으로 나타난 결과가 회사의 전체 이익에 어느 정도 영향을 끼쳤는지 판단하는 것은 그 사이에 영향을 미치는 가변적 요소와 우연적 요소가 많아 판단이 용이하지 않기 때문에 협업 업무를 통한 근로 역시 회사가 지급한 경영성과급과 대가적 견련성이 있는지 판단하기 어렵다.²³⁶⁾ 개인성과급은 근

233) 박지순·이진규, 앞의 논문, 199면

234) 권혁, 앞의 논문, 209-210면

235) 김희성, 성대규, 앞의 논문, 21면 및 44면 참조

236) 김도한, 앞의 논문, 148-149면



로자 개인의 노무 제공 및 그 성과와 인센티브 사이의 연관이 명확하게 드러나는 반면, 경영성과급은 개별 근로자가 제공한 노무 및 그 성과와 회사 전체 이익 사이에 어떠한 연관관계가 있는지 명확하게 드러나지 않기 때문이다.

v) 대법원 전원합의체 판결을 통해 「근로복지기본법」에 따른 기업복지인 복지포인트의 임금성이 부정되었고 경영성과급도 근거 법령을 「근로복지기본법」에 따르고 있는 이상 경영성과급의 법적 근거 등을 고려하면 복지포인트와 달리볼 이유가 없다.

(3) 검토

다음과 같은 이유로 긍정설이 타당하다고 본다.

i) 회사의 경영성과 달성을 위해서는 우수 인재 확보, 생산성 향상 독려, 노사관계 안정 등이 필요하기 때문에 주주의 몫인 경영성과를 자발적으로 또는 노사합의를 통해 전체 근로자들에게 배분한다. 사용자가 근로자에게 경영성과를 배분해주는 것이 경영학상 인적지원에 대한 적절한 보상으로 의미를 가질 수는 있지만, 「근로기준법」상 엄격한 보호를 받는 임금에 해당하는지는 다른 문제이다.

ii) 부정설은 경영성과급은 근로자들이 제공한 ‘협업 근로’가 경영성과에서 차지한 가치를 평가하여 그 몫을 지급하는 것이기 때문에 ‘근로제공 관련성’이 인정된다고 한다. 그러나 ‘근로제공 관련성’은 ‘개별 근로계약’이라는 쌍무적 전련관계 하에서 근로자의 근로제공의무의 이행과 사용자가 근로자에게 지급하는 급부의 관련성을 보아야 한다. 따라서 근로자의 근로제공의 내용 즉, 직무나 역할에 따라 ‘협업’이 필요하여 성과측정의 단위를 기업으로 할 필요가 있는 경우에는 경영성과를 기준으로 지급하는 성과급의 ‘근로조건 관련성’이 인정(판매직원에게 부서, 기업의 판매 실적 달성에 따라 지급되는 인센티브)될 수도 있지만, 최근 문제가된 경영성과급은 근로계약 상의 직무나 역할을 고려하여 회사의 경영목표 달성을 성과급의 발생 기준으로 한 것이 아니다,

iii) 또한 경영성과급의 발생은 주로 회사 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여 등과 회사 외부적 요인인 시장의 상황, 동종업계의 동향 등이 총체적으로 결



합되어야 하며 회사 내부적 요인인 협업에 의한 근로자들의 근로제공은 이중 하나의 요인에 불과하다. 즉, 개별 근로자의 근로제공과 전직원에게 지급되는 경영성과급 발생 간에는 ‘직접 또는 밀접한 관련성’이 인정되기는 어렵다.

iv) 앞서 살펴본 바와 같이 개인성과급과 경영성과급은 모두 근로제공과 관련이 되고 내외부적으로 영향을 받을 수는 있지만, 개인성과급은 ‘주로’ 개별 근로자의 근로제공의무 이행을 통해 개인 실적의 달성 여부가 결정된다. 즉, 개인성과급의 경우 경영성과급과는 다르게 근로제공을 통해 개인성과 달성을 통제할 수 있어 근로제공과 성과급 지급간에는 ‘직접적인 관련성’이 인정될 수 있다. 개인성과급의 임금성 여부와 경영성과급의 임금성 여부의 결론이 다른 것이 오히려 법 논리적으로 합당하다.

2. 지급의무성

임금성이 인정되기 위해서는 근로계약 상 근로제공의무에 대응하는 임금지급의무의 성질을 고려하면 지급의무 발생의 근거가 법원으로 인정될 수 있어야 한다. 경영성과급의 지급의무와 관련하여 쟁점이 되는 사항은 ① 단체협약 및 취업규칙 등에 따라 지급 요건이 규정되지 않은 경우 매번 경영성과가 달성되었기 때문에 반복적으로 지급이 된 경우에도 노동관행을 인정할 수 있는지와 ② 취업규칙 등 법원 상 경영성과급의 지급기준이 되는 목표 등은 명시되어 있으나 목표 달성에 따라 지급액이나 지급률을 특정할 수 없는 경우(달성할 경영목표, 지급대상자, 한도만 규정되어 있어 지급액이 사용자의 재량에 따라 결정되는 경우)에도 지급의무성을 인정할 수 있는지이다.

(1) 노동관행 인정 여부

경영성과급에 관한 명시적인 법원이 없음에도 경영실적 달성이 이루어져 매번 지급이 되었던 반복된 사실을 근거로 노동관행을 인정할 수 있는지가 문제 될 수 있다.

이에 대해 경영성과급이 가지는 발생의 불확실성으로 인해 노동관행을 부정하는 견해가 제기되는데 이 견해는²³⁷⁾ i) 노동 관행이 인정되기 위해서는 ‘반복된 사실’로

237) 이 견해는 경영성과급 발생과 지급을 1단계 경영성과급 지급에 대한 합의, 2단계 경영성과



서 그 규범력을 인정할 수 있어야 하는데 경영성과급 지급의무의 ‘발생’은 ‘경영성과의 달성’이라는 정지조건이 성취되지 않으면 불가능하기 때문에 설사 이행이 반복적으로 되었다고 하더라도 발생 자체가 불확정적이라면(존재할 수 없는 사실에 규범력을 인정할 수 없음) 노동관행으로 인정될 수 없는 점, ii) 일체의 사실인 ‘경영성과의 달성에 따른 경영성과급의 지급’은 그 ‘존립 근거’ 자체가 절대적으로 ‘경영성과의 달성’에 있기 때문에 속성 자체가 불확정적이어서 지급의무를 인정할 수 없는 점, iii) 이러한 경영성과급의 불확정적인 특성으로 인해 기업의 구성원들에 의해 지급의무성이 당연한 것으로 받아들여져 사실상 제도로써 확립되어 있다고 볼 수 없다는 점 등을 이유로 경영성과 달성에 따라 지급되는 경영성과급에 대해서는 노동관행을 부정한다.

그러나 경영성과 발생의 불확실성 문제는 근로제공과 무관한 요소의 달성을 통해 경영성과급이 발생한다는 관점에서 근로제공 관련성에서 검토되어야 할 문제이며 지급의무성과 관련된 문제가 아니다. 즉, 명시적인 법원이 없더라도 반복적으로 동일한 기준을 적용하여 경영성과급을 산출하여 지급이 이루어졌고, 이에 대해 기업의 구성원들이 당연한 것으로 받아들이고 있어 사실상 제도로써 경영성과급의 지급기준이 확립되어 있다면(이하에서 살펴볼 지급액의 확정성이 인정되는 것을 전제로 함) 노동관행에 따른 지급의무성을 인정할 수 있다.

(2) 지급액의 확정성

경영성과급의 법원 상 지급조건이 명시되어 있으나 해당 법원을 통해서서는 지급액을 산출할 수 없는 경우에도 지급의무의 확정성을 인정해야 하는지가 문제될 수 있다.

이에 대해 지급의무의 확정성을 인정해야 한다는 견해는 경영성과급의 지급기준 및 목표설정에 합의한 이상 그때부터 근로자들은 이미 경영성과급을 청구할 수 있는 권리를 가지게 되기 때문에 ‘경영성과의 달성’을 정지조건으로 보고, 그 달성을 ‘우연성’으로 귀결시켜 임금성을 부정하는 부정설은 논리가 빈약하다고 비판한다. 이 견해

달성이라는 불확정적 조건 성취, 3단계 지급 기준에 따른 경영성과급의 지급(배분)과 같이 3단계로 나누어 이해하며 이중 1단계 및 2단계는 발생요건으로 3단계는 이행기준(지급기준)으로 구분한다.(김희성·성대규, 앞의 논문, 9면)



는 경영성과급의 지급액은 경영 목표달성 이후에 확정되지만, 경영성과급의 지급조건은 경영 목표달성 이전의 시점에서 확정되어진다고 본다. 따라서 지급조건 확정만으로도 경영 목표달성은 불확정성에 기초하지 않는다고 본다. 즉, ‘일정한 목표치를 넘는 경영실적 달성 시 성과급을 지급한다.’라는 합의가 있는 이상 경영성과목표 달성에 따른 지급기준에 따라 지급률이 특정되지 않더라도 기업의 임금 지급의무가 확정되었다고 해석하는 것이 옳다고 본다.²³⁸⁾

그러나 지급의무성이 인정되기 위해서는 앞서 살펴본 바와 같이 법원 상 ‘지급 여부’와 ‘지급액’이 확정되어야 기대권²³⁹⁾을 인정할 수 있으며 지급의무성(금품지급의무)은 근로자의 임금청구권(소송상 소구할 수 있는 권리)을 전제로 하여야 하는바, 지급 자체에 대한 의무와 지급액에 대한 의무를 분리해서 판단하는 것은 타당하지 않다.²⁴⁰⁾ 즉, 단체협약·취업규칙 등에 따라 지급여부만 확정될 뿐 경영성과 달성 정도에 따라 지급액(지급률)을 특정할 수 없고 사용자가 지급액에 대한 재량권을 가진다면 사용자의 지급의무성도 인정할 수 없다.

3. 평균임금제도의 취지 등

평균임금의 취지가 통상적인 생활임금의 보장에 있음을 고려한다면 경영성과급의 변동폭이 큰 것은 평균임금성을 부정하는 요소가 되는 것은 명확하며 실제 판례에서도 해당 금품을 포함하여 평균임금을 산정하는 것이 현저히 부당한 경우 해당 기간 중 받은 임금을 제외하고 평균임금을 산정할 수 있도록 보고 있기 때문이다. 그러나 경영성과급이 급여에서 차지하는 비중이 큰 것이 평균임금성을 긍정하는 요소가 되는 지가 문제가 될 수 있다.

이에 대해 경영성과급이 반드시 지급된다는 것을 전제하고, 평균적인 지급액을 포함하여 산정된 연간소득을 기준으로, 경영성과급이 평균적으로 지급될 경우에 근로자

238) 이섫별·권오성, 앞의 논문, 163면 참조; 임상민, 앞의 논문, 1102면 참조

239) 김재훈, 앞의 글, 2006.5, 45면

240) 최진수, 앞의 글, 113면; 김희성, “성과배분으로서 경영성과급은 근로의 대가인 임금에 해당 하는가”, 「노동법률(통권 371호)」 57면



개인 급여 전체에서 차지하는 비중을 근거로 통상의 생활임금으로 인정된다고 판단하는 것은 타당하지 않고 오히려 경영성과급이 근로자의 전체 소득에서 차지하는 비중이 클수록, 이를 평균임금에 포함할 경우 근로자의 근로자의 통상의 생활을 종전과 같이 보장하려는 평균임금제도의 취지에는 맞지 않는다고 보는 견해가 제기된다.²⁴¹⁾

평균임금 해당 여부 판단 시 경영성과급이 전체 급여에서 차지하는 비중을 살펴 실질적인 임금성을 가지는지를 판단하는 방식 자체가 불합리한 것은 아니지만 단순히 경영성과급이 차지하는 비중만을 고려하여 평균임금 취지에 부합하는지를 판단하여 임금성 여부를 결정해서는 아니된다. 예를 들어 사용자가 비임금화를 위해 실제 임금에 해당함에도 명칭상 임금성이 부정되도록 지급하였다면 평균임금성 해당 여부 판단 시 전체 급여에서 차지하는 비중을 살펴보고 그 실질적 성격을 밝혀볼 필요는 있다. 그러나 이는 판단 시 하나의 고려 요소(요건은 아님)가 될 수 있을 뿐이며 결국 평균임금 해당 여부는 임금성의 요건인 근로제공 관련성, 지급의무성과 평균임금성에 관한 추가적인 요건인 계속성·정기성을 충족하는지 여부를 기준으로 판단해야 한다.

III. 소결

경영성과급의 임금성에 대해 가장 극심한 견해의 대립이 있는 것은 근로제공 관련성을 인정할 것인지 여부이다. 이에 대해 긍정성과 부정설이 대립되나, 모든 보상이 「근로기준법」을 비롯한 노동관계법 상 특별한 보호를 받을 대상이 되는 것은 아닌 점, 집단성과급이라고 해서 근로제공 관련성이 모두 부정되는 것이 아니지만 최근 문제가 된 경영성과급은 근로계약상의 직무나 역할과 무관한 회사의 경영목표 달성을 성과급의 발생 기준으로 한 것으로 근로제공 관련성이 낮다는 점, 개인성과급이 주로 개별근로자의 근로제공의무 이행을 통해 성과달성을 통제할 수 있는 반면 경영성과는 근로제공 뿐만 아니라 ‘시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등’에 통제 불가능한 요소에 따라 결정되며 더 큰 영향을 받는 점 등을 고려하면 근로제공 관련성이 부정된다고 보아야 한다.

241) 김희성·이준희, 앞의 논문, 272면



더불어 지급의무성과 관련해서도 지급여부와 지급대상 지급액 등 임금청구권을 확정할 수 있다면 설사 명시적 법원이 아니더라도 노동관행도 인정될 수 있지만, 지급의무성은 임금청구권을 전제로 해야 하며 지급 자체에 대한 의무와 지급액에 대한 의무를 분리하여 판단하는 것은 타당하지 않은 점 등을 고려하면 사용자의 지급의무성이 충족되기 위해서는 경영성과 달성 정도에 따라 지급여부 뿐만 아니라 지급액도 확정되어야 한다. 더불어 경영성과급의 평균임금성 판단 시 전체 급여에서 차지하는 비중만을 단순히 고려하여 평균임금성 여부를 판단하는 것은 (평균)임금의 개념 및 요건에 부합하지 않기 때문에 전체 임금에서 경영성과급이 차지하는 비중은 실질적인 임금성을 가지는지를 판단함에 있어 고려요소가 될 뿐 판단 요건이 되어서는 아니된다.

제3절 경영성과급의 임금성 관련 판례 검토

I. 의의

그간 민간부문의 집단성과급의 임금성에 대해 판결은 매우 다양하게 있었는데²⁴²⁾ ‘대우조선해양의 성과배분상여금의 임금성 사건(이하 대우조선해양 사건’이라 한다)의 판결만 임금성을 인정하였고, 나머지 판결은 모두 임금성(평균임금성)을 부정하였다.²⁴³⁾

대우조선해양 사건의 사실관계에 대해 보다 자세하게 살펴보면 조선업을 영위하는 대우조선해양에서 비등기임원인 감사실장으로 근무하다가 징계해고된 자가 해고무효를 원인으로 미지급 임금을 청구한 사안에서 대우조선해양이 ‘성과배분상여금’을 지급하여야 하는지 여부가 문제되었는데, 이에 대하여 대법원은 대우조선해양의 성과배분상여금은 급여규칙에 명시적 근거를 두고 있을 뿐만 아니라 거기에서 지급사유와 지

242) 대법원 1998. 1. 20. 선고 97다18936 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다77514 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결 등

243) 임상민, 앞의 논문, 1113면



급기준을 사전에 정해 놓았으며, 그에 따라 2001년 이후 정기적 계속적으로 지급되어 온 점을 들어 경영성과급이 임금에 해당한다는 취지로 판시하였다(대법원 2011. 10.27. 선고 2011다42324 판결).

그간 대우조선해양 사건에 대한 위 판결 이외에 회사의 경영실적 등에 따라 지급되는 성과배분 형태의 집단성과급의 임금성을 명시적으로 인정한 판결은 매우 드문 것으로 보인다.

[표 6] 집단성과급의 임금성 관련 판결

구분	임금성	주요 내용	사건번호 ²⁴⁴⁾
집단성 과급 (경영성 과급)	부정 (경영성과급)	매년 임금협약시 노사간 합의로 그 지급 여부나 구체적인 지급기준 등이 정해졌고, 위 1992년도부터 원고들이 모두 퇴직한 1998년도까지의 기간 동안에는 성과급의 지급기준이 거의 매년 틀려 그 지급액이 확정되어 있었다고 보기 어려워 경영성과급 임금 아님	대법원 2003다54322, 54339 판결 (현대미포조선)
	인정 (성과배분상 여급)	성과배분상여금은 급여규칙에 명시적 근거를 두고 있을 뿐만 아니라 거기에서 지급사유와 지급기준을 사전에 정해 놓았으며, 그에 따라 2001년 이후 정기적·계속적으로 지급되어 근로의 대가로 임금임	대법원 2011다42324 판결 (대우조선해양)
	부정 (장기성과급)	LTI(Long Term Incentive : 장기성과급)는 임직원 개인의 업무성과와 관계없이 피고가 회사 차원에서 일정한 성과를 달성한 경우 피고 회사에 3년 이상 근속한 임직원들 중 피고의 재량으로 지급대상자를 선발하여 지급한 급여로서, 원고에게 4년 연속 LTI가 지급되기는 하였지만, 이는 매년 피고가 그 재량으로 원고를 LTI 지급대상자로 선발하였기 때문이지 일정 자격 이상의 임직원들에게 LTI를 지급하기로 하는 관행이나 관례가 성립하였기 때문은 아니라고 보아 임금 아님	대법원 2012다48077 판결 (PCA생명)

244) 가독성을 고려하여 판결일은 생략함



2020년 이후 민간기업에서 지급되는 경영성과급이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 해당하는지에 관한 하급심 법원의 판결이 내려지기 시작했다.

[표 기] 경영성과급의 (평균)임금 해당성 관련 민간부문 최근 판결

사건	1심 판결	2심 판결	대법원 판결
삼성전자 (1차)	부정 (수원지법 2019가합19095)	부정 (수원고등법원 2020나26085)	계류중 (2021다248725)
삼성전자 (2차)	인정 (서울중앙지법 2019가합542535)	계류중 (서울고등법원 2021나2026947)	-
SK 하이닉스	부정 (수원지법 여주지원 2019가단50590)	부정 (수원지법 2020나55510)	계류중 (2021다219994)
현대해상 화재보험	인정 (서울중앙지법 2019가합538253)	인정 (서울고법 2021나2015527)	계류중 (2022다215715)
발레오전장	인정 (대구지법 경주지원 2019가합2438)	부정 (대구고법 2020나26233)	계류중 (2021다285182)
한국유리	인정 (서울중앙지법 2018가합507283)	인정 (서울고법 2020나2012736)	계류중 (2021다262592)
LG 디스플레이	부정 (서울남부지법 2019가소499344)	부정 (서울남부지법 2020나72056)	계류중 (2021다270517)
삼성 디스플레이	부정 (서울중앙지법 2019가단5199298)	계류중 (서울중앙지법 2021나8490)	-
서울보증보험	부정 (서울중앙지법 2020가단5094757)	인정 (서울중앙지방법원 2021나35652)	계류중 (2022다255454)
LG화학	부정(확정) (광주지법 순천지원 2021가합10983)	-	-



그 중 언론에서 보도된 주요 사건은 삼성전자의 2개의 사건, 삼성디스플레이 사건, LG디스플레이 사건, SK하이닉스 사건, 현대해상화재보험 사건, 발레오전장 사건, 한국유리 사건, 서울보증보험사건, LG화학 사건 등이 있다.²⁴⁵⁾ 상기 사건들은 대부분이 현재 법원에 계류 중으로 임금성 여부를 다투고 있으며 최종 확정된 것은 1심에서 임금성이 부정된 LG화학 판결뿐이다.

이 판결들은 경영성과에 대한 평가에 따라 지급 여부가 결정됨에도 근로에 대한 대가라고 인정할 수 있는지, 나아가 사용자의 판단에 따라 지급하지 않은 경우가 있음에도 이를 사용자에게 지급의무가 있다고 보아야 하는지에 대한 쟁점에서 판단이 갈라지고 있다.²⁴⁶⁾ 또한 상기 사건 판결에서 개인성과급, 공공기관 경영평가성과급, 복지포인트 등의 임금성 판결이 참조 판결로 제시되면서 각 판결에 대한 결론과 논거도 쟁점이 되었다.

즉, 1) 성과에 따라 지급액이 불확정적인 개인성과급이 임금으로 인정된다면 같은 불확정성을 가진 경영성과급의 임금성도 인정되어야 하는 것은 아닌지? 2) 집단성과급이자 지급여부 자체가 불확정적인 공공기관 경영평가성과급이 임금으로 인정된다면 같은 집단성과급이자 경영성과 달성 여부에 따라 발생 여부가 불확정적인 경영평가성과급도 임금성이 인정되어야 하는 것은 아닌지? 3) 복지포인트와 마찬가지로 경영성과급도 근거법이 되는 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」과의 관계, 이익분배제도의 연혁적 분석, 최초 제도의 도입 목적, 노동현장에서의 경영성과급에 대한 인식, 이익분배의 활성화 등을 고려하면 경영성과급도 임금성을 부정해야 하는 것은 아닌지에 대해 경영성과급의 임금성을 긍정 또는 부정하는 각 견해에서 논리적인 설명이 필요하다. 이하에서는 먼저 경영성과급과 개인성과급, 공공기관 경영평가성과급, 복지포인트 등의 임금성 관련 특징을 비교하여 경영성과급의 임금성의 최근 임금성에 관한 대법원 판결과의 관계를 먼저 살펴본 후 민간기업의 경영성과급에 관한 최근 하급심 판결을 검토하되 판결의 쟁점을 단순화하고 근거를 선명하게 대비하기 위해 유사한

245) 삼성디스플레이, LG디스플레이, LG화학 사건이 경우 삼성전차 1차 사건과 논리와 결론을 같이 하고 있고, 서울보증보험사건의 경우 현대해상화재보험사건과 논리와 결론을 같이 하고 있어 하기에서는 별도로 분석하지 아니한다.

246) 김희성·이준희, 앞의 논문, 257-258면 참조



사실관계하에서 상반된 판결을 내린 사건을 택하여 각 판결을 비교 분석하기로 한다.

Ⅱ. 경영성과급의 임금성과 최근 대법원 판결의 비교

1. 개인성과급과 판결과 경영성과급의 임금성 비교

(1) 비교 필요성과 쟁점

개인성과급의 임금성을 인정한 대법원 판결로 인해 ① 개인성과급이나 경영성과급 모두 지급여부나 현 시점에서는 지급여부 또는 지급액이 불확정적이라는 공통적인 특징을 가지기 때문에 대법원이 개인성과급의 임금성을 인정한 이상 경영성과급의 임금성을 부정할 이유가 없다고 주장하는 견해와²⁴⁷⁾ ② 개인성과급과 경영성과급은 ‘근로제공 관련성’에서 다르게 보아야 하기 때문에 개인성과급의 임금성이 인정된다고 하여 경영성과급의 임금성이 인정되어야 하는 것은 아니라는 견해가²⁴⁸⁾ 대립한다.

(2) 개인성과급의 임금성 인정 판결과 경영성과급의 임금성 판단 여부

우선 ①의 견해를 취하는 입장에서는 i) 근로자 개인의 실적 역시 근로자가 통제할 수 없는 불확정적이고 외부적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있고 이는 경영성과급도 동일한 점, ii) 근로자가 자신이 개인적으로 이룬 성과에 대하여 그 대가를 지급받는 것(개인성과급)이나 근로자집단이 이룬 성과 중 개인의 몫을 안분하여 그 대가를 지급받는 것(집단성과급)이나 결국 근로자가 제공한 근로에 대한 대가라는 점에서 그 본질을 같이 한다는 점을 이유로 ‘사용자 지급의무성’과 관련하여 개인성과급과 집단성과급은 차이가 없고, 경영성과급도 근로제공과 밀접한 관련이 있다고 보아 ‘근로제공 관련성’도 인정된다고 본다.²⁴⁹⁾

247) 임상민, 앞의 논문, 1128면; 심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 「월간노동리뷰」, 2021년 8월호, 한국노동연구원, 2021, 94면; 권오성, 앞의 글, 67면; 김홍영, 앞의 논문(지난 20년간 임금 법제의 해석과 입법의 동향), 85면; 유성재, 앞의 글, 33면

248) 박지순·이진규, 앞의 논문, 199면; 김도한, 앞의 논문, 144면; 정종철, 앞의 글, 113면 등

249) 임상민, 앞의 논문, 1128-1129면



이에 대해 반대하는 ②의 견해를 취하는 입장에서는 i) 근로자 개인이 제공한 개별적인 근로의 내용과 성과가 직접 성과급 지급 여부 및 액수를 결정하는 근거가 되기 때문에 근로의 제공과 급여의 지급 사이의 대가적 관련관계를 인정하는 것에 문제가 없지만, 기업이나 부서의 성과를 근로자 개인이 아닌 집단적경영성과의 관점에서 평가해서 그 성과에 따라 금품을 분배하는 소위 경영성과급은 근로자 개인의 개별적인 실적 내지 성과가 직접 금품의 지급 여부 및 액수를 결정하는 것이 아니라는 점에서 기본적인 성격이 전혀 다르다고 보아²⁵⁰⁾ 개인성과급과 다르게 집단성과급에 해당하면 ‘근로제공 관련성’을 부정하거나, ii) 개인성과급과 집단성과급을 기준으로 임금성 인정 여부를 구분하는 것이 아니라 경영성과와 연동된 성과급제의 경우에도 당사자간에 경영성과급을 임금의 구성부분으로 하는 명확한 인식과 합의가 전제된다면 임금으로 볼 수 있지만, 성과배분이 근로자의 재산형성을 위한 임금보충적 성격을 가지는 경우²⁵¹⁾에는 그러한 성과배분은 임금으로서의 실질을 가진다고 보기 어렵고 순수한 의미에서 성과배분으로서의 경영성과급(기업이 달성한 성과 내지 실현한 이익에 대한 배분의 의미로 지급)은 시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등 개별 근로자의 근로제공과의 관련성이 현저히 떨어지는 사정들이 경영성과급의 지급여부 및 지급조건 결정에 있어 주요한 요소라는 점을 이유로 ‘근로제공 관련성’을 인정하기 어려워 임금성을 부정한다.²⁵²⁾

(3) 검토

임금성 여부는 근로제공 관련성을 기준으로 해야 하며 근로제공 관련성은 직접적 관련 뿐만 아니라 밀접한 관련도 포함될 수 있다. 개인성과급의 임금성이 인정되는 이유는 근로자의 근로제공과 금품의 발생간에 직접적인 관련이 있기 때문이다. 다만, 개

250) 김희성·이준희, 앞의 논문, 253면

251) 박지순·이진규, 앞의 논문, 189면 : (i) 성과배분에 따른 지급액이 고정연봉액보다 상대적으로 낮은 경우, (ii) 근로자의 근로제공에 대한 대가로서 임금은 월급여 내지 연봉의 고정부분에 의하여 지급되고 있다고 인정되는 경우, (iii) 경영성과급의 미지급이 근로자의 근로제공을 헐값으로 보상한다고 보기 어려운 경우(다시 말해 기업의 경제적 손실을 근로자에게 전가한다고 보기 어려운 경우), (iv) 원칙적으로 재직중인 모든 종업원에게 골고루 경영성과급이 지급되는 경우 등

252) 박지순·이진규, 앞의 논문, 188-199면 참조



인성과급과 집단성과급으로 이원화하여 ‘근로제공 관련성’ 인정 여부를 일률적으로 판단하는 것에는 신중할 필요가 있다. 대부분의 집단성과급은 근로계약에 따라 수행하는 직무와 역할과 무관하게 회사 경영실적에 따라서 지급되는 경우가 많지만 근로자의 직무와 역할을 고려하여 지급하는 집단성과급의 경우 밀접한 근로제공 관련성이 인정될 수도 있기 때문이다.

예를 들어 판매조직의 경우 개인판매실적에 따라서 인센티브를 지급할 수도 있지만 조직 단위별 협업을 통해서 실적을 달성할 수 있는 경우도 있기 때문에 부서판매 실적, 기업판매실적 등에 따라 다양한 급부를 판매조직의 성과급의 발생 조건으로 할 수 있다. 이 경우 개인실적과 부서판매실적 및 기업판매실적의 ‘근로제공 관련성’을 다르게 볼 수 있을까? 효율적인 판매를 위해 실적 측정의 단위가 개인, 부서, 기업이 될 뿐 결국 판매직원에게 지급되는 성과급은 모두 판매행위를 대가로 하여 지급되는 것이다. 따라서 판매직원들에게 판매행위를 통해서 달성될 수 있는 목표를 부여하고 그 달성여부나 달성정도에 따라 지급되는 성과급이라면 근로제공과 성과급 지급간에는 밀접한 관련성이 있기 때문에 ‘근로제공 관련성’을 부인할 수 없다. 또한 경영에 대한 책임을 부담하는 관리자에게 자신이 관리하는 조직의 성과에 따라서 기본급 외의 성과급을 약정한다면 이는 관리자가 장으로 있는 조직의 관리업무를 통해서 달성될 수 있는 것이고 관리자로서의 근로제공과 성과급 지급간에는 밀접한 관련성이 있기 때문에 이 역시도 ‘근로제공 관련성’을 인정할 수 있다. 따라서 ‘근로제공 관련성’을 측정단위가 개인이나 집단이나에서 다르게 판단해야 되는 것은 아니다.²⁵³⁾

그러나, 최근 문제가 된 경영성과급은 그 성질이 다르다. 당기순이익 및 EVA는 근로자의 직무나 역할에 따른 ‘근로제공’과 관련 없이 오직 회사의 수익만을 기준으로 한다. 즉, 이러한 경영성과급은 근로자의 근로제공 외에도 시장의 상황, 경영자의 경영판단에 따른 경영전략, 회사의 재무상태 등 다양한 요소에 따라 결정이 된다는 점에서 기본적으로 ‘근로제공 관련성’을 인정하기 어렵고 특히 경영에 대한 관리 책임을

253) 김홍영, 앞의 논문, 85면 : 김홍영 교수도 개인성과급은 물론 집단적인 성격을 갖는 경영성과급도 임금성이 인정된다고 보며 경영실적이나 무쟁의 달성여부에 따라 근로의 대가인지 여부를 살펴보는 것은 의미가 있다고 본다. 다만, 김홍영 교수는 경영실적에 따라 지급되는 것은 근로제공의 대가로 보아 임금성을 인정하나, 무분규 타결과 같은 경우 근로제공 관련성이 없다고 본다.



맡고 있는 관리자에게만 지급되는 것이 아니라 회사에 소속된 전 직원에게 지급을 하기 때문에 근로자의 직무와 역할과 무관하게 지급되는 것으로 근로제공과 ‘밀접’한 관계를 인정하기 어렵다.

결론적으로 성과의 측정단위가 개인이나 집단이냐를 기준으로 ‘근로제공 관련성’ 인정 여부가 나누어지는 것이 아니라 근로자의 근로제공 즉 직무와 역할에 따라 근로제공의 대가로 약정된 급부인지가 ‘근로제공 관련성’의 판단기준이 되어야 하며 이와 무관하게 지급하는 경영성과급은 ‘근로제공 관련성’을 인정하기 어렵고, 임금성이 부정되는 것이 타당하다.

2. 공공기관 경영평가성과급 판결과 경영성과급 임금성 비교

(1) 비교 필요성과 쟁점

공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정한 대법원 판결로 인해 ① 민간기업의 경영성과급과 공공기관 경영평가성과급은 공통적인 특징을 가지기 때문에 대법원이 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정한 이상 민간기업의 경영성과급의 임금성을 부정할 이유가 없다고 주장하는 견해와 ② 민간기업의 경영성과급과 공공기관의 경영평가성과급은 다른 특징을 가지기 때문에 대법원이 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정한다고 하여 민간기업의 경영성과급의 임금성이 당연히 긍정되어야 하는 것은 아니라고 보는 견해가 상호 제기되고 있다.

(2) 공공기관 경영평가성과급의 임금성 인정 판결과 경영성과급 임금성 판단 여부

우선 ①의 견해를 취하는 입장에서는 공공기관 경영평가성과급은 i) 금품 지급이 정부의 경영평가 결과라는 외부적 요인에 따라 발생하는 점(근로제공 관련성 인정) ii) 정부의 경영평가 결과에 따라 지급 여부가 달라지기 때문에 지급액이 0원이 될 수도 있는 불확정성을 가지고 있는 점(사용자의 지급의무성 인정)이 민간기업의 경영성과급과 공통적인 특징을 가지기 때문에 대법원이 공공기관 경영평가성과급의 임금



성을 인정한다면 민간기업의 경영성과급의 임금성을 부정할 이유가 없다고 본다.²⁵⁴⁾

이에 대해 반대하는 ② 견해를 취하는 입장에서는 i) 공공기관 경영평가성과급은 정부의 경영평가지급기준에 따라 이미 예산이 확보되어 있고, 공공기관의 구성원 개개인들의 업무평가에 따라 지급액이 차등 결정된다는 점에서 일반 민간기업의 경영성과급과 다르다고 보거나²⁵⁵⁾ ii) 공공기관 경영평가성과급은 기획재정부장관이 실행하는 경영실적평가의 개념은 민간기업에서의 이윤이나 경영성과 및 실적과 개념상 본질적으로 다르고, 또한 기획재정부장관이 실행하는 경영실적 평가는 원래 정부산하기관의 장에 대한 평가가 목적이었다가 지금은 그 기관에 대한 평가를 목적으로할 뿐, 개별 근로자에 대한 성과독려나 미래 또는 과거의 충성도 등 제고하기 위해 사용자가 고안해 낸 고유한 경영 목적이 존재한다고 보기도 어렵기 때문에 민간기업에서의 성과상여금과는 다르다고 보아²⁵⁶⁾ 대법원이 공공기관 경영평가성과급의 임금성을 인정하더라도 민간기업의 경영성과급의 임금성이 부정될 수 있다라고 보았다.

(3) 검토

사용자의 ‘지급의무성’은 임금청구권과 분리되어 고려될 수 없기 때문에 지급액이 사전에 확정될 필요는 없지만 지급 조건을 달성할 경우 지급 여부뿐만 아니라 지급액이나 지급률까지 특정될 수 있어야 한다. 민간기업의 경영성과급은 공공기관 경영평가성과급과 같이 내부 규정에 그 지급대상, 지급시기까지 규정하고 있는 경우는 다수 있으나, 경영성과 등급에 따른 지급률까지 지급 조건을 특정하고 있지 않다. 특히 근로의 대가의 주된 판단 요건인 ‘근로제공 관련성’에 있어서 민간기업의 경영성과급과 공공기관 경영평가성과급은 명확한 차이를 보이기 때문에 대법원이 공공기관의 경영평가성과급 판결에서 임금성을 인정하였다고 하여 민간기업의 경영성과급의 임금성이 인정된다고 볼 수 없다는 ②의 견해가 보다 타당하다고 보인다.

민간기업의 경영성과급과 공공기관의 경영평가성과급의 차이에 대해 보다 구체적으로 살펴보면 i) 민간기업의 경영성과급은 ‘경영성과 달성’에 따라 경영성과급이 발생된

254) 심재진, 앞의 글(집단적 경영성과급의 임금성), 93면 이하 참조

255) 김도한, 앞의 논문, 144면

256) 권혁, 앞의 논문, 211면



다면 공공기관의 경영평가성과급은 ‘정부의 경영평가 결과 확정 통보’에 따라 경영평가 성과급이 발생된다. 정부는 매년 경영평가 결과를 확정하여 공공기관에 통보하며 이러한 통보 행위는 매년 행해지는 것이 당연하기 때문에 결과 확정 통보 행위가 이루어지기 위한 어떠한 외부적인 요인도 필요하지 않다. 즉, 공공기관에 소속되어 근로제공을 하면 매년 예정된 대로 정부가 소속 공공기관의 경영평가 결과를 통보해주고 이에 따라 공공기관 소속 직원들은 경영평가성과급을 수령하는 것이지 공공기관의 매출, 영업이익 등에 따라 공공기관 경영평가 결과 확정 통보 여부가 달라지는 것이 아니다. ii) 경영평가성과급은 ‘정부의 경영평가 결과 확정 통보’가 아닌 ‘정부의 경영평가 결과’가 공공기관 경영평가성과급의 발생 원인이고 이는 외부적인 요인이라는 주장도 제기될 수 있지만, 평가 결과가 외부적 요인이라면 개인 평가에 따라 지급되는 성과급도 평가 결과에 따라 지급액이 ‘0원’이 되어 지급되지 않을 수 있는 것은 마찬가지이며 이를 외부적 요인이라고 볼 것인가? 즉, ‘정부의 경영평가 결과’는 공공기관 경영평가성과급의 발생을 좌우하는 외부적 요인이 아니다. 경영평가성과급의 금액이나 지급률을 확정하는 후속 조치의 기준이 될 뿐이다. 민간기업의 경영성과급의 발생을 좌우하는 ‘당기순이익이나 영업이익의 발생 또는 달성’을 위해서는 외부적 요인이 작용하는 것과는 구분해야 할 것이다.

요약하자면 공공기관 경영평가성과급은 매년 정부의 경영평가결과 통보라는 예정된 행위에 따라 어떠한 외부적 요인과 무관하게 당연히 발생하는 것이기 때문에 ‘근로제공 관련성’이 인정될 수 있는 반면 민간기업의 경영성과급은 매년 당기순이익 또는 영업이익의 달성이라는 외부적 요인에 따라 발생 여부가 달라지는 불확정성을 가지기 때문에 ‘근로제공 관련성’을 인정할 수 없어 설사 지급 대상, 지급시기, 산출가능한 지급액 등의 규정 유무에 따라 ‘사용자의 지급의무성’이 인정되는 경우에도 대법원의 공공기관 경영평가성과급의 임금성 인정 판결과 결론을 달리할 수 있다는 것이다.

3. 복지포인트 판결과 경영성과급 임금성

(1) 비교 필요성과 쟁점

대법원은 ‘근거 법령, 연혁과 도입배경, 당사자들의 인식, 제도의 활성화 등’을 이유로 복지포인트의 임금성을 부정하였다. 근거 법령을 임금성을 부정하여야 되는 이



유 중 가장 처음으로 제시하였는데 i) 근거 법령인 「근로복지기본법」 제3조 제1항²⁵⁷⁾에서 근로복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있어 동법상 기업근로복지를 구성하는 선택적 복지제도에 기초한 복지포인트는 임금과 같은 근로조건에서 제외된다고 해석되며, ii) 임금성 판단 시 「근로기준법」 뿐만 아니라 관련 법률의 규정도 같이 고려하여 규범조화적 판단하는 것이 타당하고 「근로복지기본법」의 규정 내용 상 선택적 복지제도에 대한 입법자의 기본적인 규율 내용은 복지포인트가 임금이 아니더라고 판시하였다. 이와 관련하여 ① 경영성과급의 근거법령도 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률이기 때문에 대법원이 복지포인트의 임금성을 부정한 이상 경영성과급의 임금성도 부정되어야 한다는 견해와²⁵⁸⁾ ② 경영성과급의 임금성은 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률이 아니라 「근로기준법」을 기준으로 판단되어야 하기 때문에 복지포인트의 임금성이 부정되더라도 경영성과급의 임금성은 인정될 수 있다는 견해가²⁵⁹⁾ 상호 대립한다.

(2) 복지포인트 임금성 부정 판결과 경영성과급 임금성 판단 여부²⁶⁰⁾

우선 ①의 견해를 취하는 입장에서는 i) 「근로복지기본법」 제3장 기업근로복지 항목의 제84조(성과배분)는 “사업주는 해당 사업의 근로자와 협의하여 정한 해당 연도 이익 등 경영목표가 초과 달성된 경우 그 초과된 성과를 근로자에게 지급하거나 근로자의 복지증진을 위하여 사용하도록 노력하여야 한다.”라고 규정함으로써 기업의 성과배분 역시 근로복지의 차원에서 규율 하고 있고 「근로복지기본법」 제3조제1항은 “근로복지(임금·근로시간 등 기본적인 근로조건은 제외한다. 이하 같다)정책은 근로자

257) 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제3조(근로복지정책의 기본원칙) ① 근로복지(임금·근로시간 등 기본적인 근로조건은 제외한다. 이하 같다)정책은 근로자의 경제·사회활동의 참여기회 확대, 근로의욕의 증진 및 삶의 질 향상을 목적으로 하여야 한다.

258) 김희성, 앞의 논문, 54면

259) 심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 96면 : 삼성전자판결(수원고등법원 2021. 6. 17. 선고 2020나26085 판결)에서 법원이 「근로복지기본법」에 성과배분이 규정되어 있는 점을 이유로 근로의 대가로 보지 않아 임금성을 부정한 것은 대법원의 판례 법리(글에서 구체적으로 명시되어 있지 않지만 ‘복지포인트 판결’을 의미하는 것으로 보임)와 법규정을 오해한 것이라고 보았다.

260) 대립되는 두 개의 판결에서 각각 명확한 논거를 제시하고 있어 학계의 견해보다는 판결문의 논거를 제시한다.



의 경제·사회활동의 참여기회 확대, 근로의욕의 증진 및 삶의 질 향상을 목적으로 하여야 한다.”라고 규정하여 근로복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있는 점, ii) 위와 같은 「근로복지기본법」의 규정 내용에서 알 수 있는 입법자의 기본적인 입장은 기업이 초과된 성과를 근로자에게 지급하는 것을 기업근로복지의 차원에서 접근하고 있는 것임은 분명하고, 이는 기업의 성과 배분에 관하여 임금성을 긍정하기 어려운 중요한 사정이라는 점을 이유로 「근로복지기본법」을 근거로 복지포인트의 임금성을 부정한 대법원 판례와 동일한 논리를 제시하며 민간기업의 경영성과급의 임금성도 부정될 수 있다고 한다.²⁶¹⁾

이에 대해 반대하는 ② 견해를 취하는 입장에서는 i) 「근로복지기본법」 제84조 [성과배분]와 동법 제3조제1항의 규정은 근로자복지 향상을 위한 규율대상을 정한 것으로 보일 뿐 근로복지의 한 유형인 성과배분을 언제나 임금에서 배제하려는 입법자의 의사가 반영된 것이라고 단정할 수는 없는 점, ii) 근로자복지를 규율하는 부수적 하위 법률관계를 규율하는 법령의 해석에 따라 독자적인 보호법익에 기초하여 판단되어야 할 「근로기준법」상 임금 개념의 해석이 좌우되어서는 아니될 것인바, 어떠한 급부가 임금에 해당하는지 여부는 「근로기준법」의 관점에서 그 실질에 비추어 임금으로 보호할 필요성이 있는지를 고려하여 판단되어야 하는 점을 이유로 대법원이 「근로복지기본법」을 근거로 복지포인트의 임금성을 부정하였다하더라도 민간기업의 경영성과급의 임금성은 인정될 수 있다고 한다.²⁶²⁾

(3) 검토

1) 근거 법령의 비교

복지포인트에 대한 대법원은 다수의견은 반대의견이 「근로기준법」의 관점에서 복지포인트가 임금인지 여부가 판단되어야 한다는 논의에 대해 타당하다고 인정하면서도 i) 근거 법령인 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제3조 제1항²⁶³⁾에서 근로

261) 수원고등법원 2021. 6. 17. 선고 2020나26085 판결

262) 서울고등법원 2022. 1. 21 선고 2021나2015527 판결문 발췌

263) 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제3조(근로복지정책의 기본원칙) ① 근로복지(임금·근로시간 등 기본적인 근로조건은 제외한다. 이하 같다)정책은 근로자의 경제·사회활동의



복지의 개념에서 임금을 명시적으로 제외하고 있어 동법상 기업근로복지를 구성하는 선택적 복지제도에 기초한 복지포인트는 임금과 같은 근로조건에서 제외된다고 해석되며, ii) 임금성 판단 시 「근로기준법」 뿐만 아니라 관련 법률의 규정도 같이 고려하여 규범조화적 판단하는 것이 타당하고 「근로복지기본법」의 규정 내용 상 선택적 복지제도에 대한 입법자의 기본적인 규율 내용은 복지포인트가 임금이 아니라는 것에 있음을 명확히 하였다.

상기 대법원 전원합의체 판결의 논리에 따라 경영성과급에 대해 살펴보면 i) 경영성과급의 근거 법령은 2001. 8. 14 제정된 「근로자복지기본법」 제20조 제1항²⁶⁴⁾ (현 제84조²⁶⁵⁾내용과 동일)에서 규정하고 있는 ‘사업주에게 초과 달성된 경영성과를 근로자에게 배분하도록 노력할 의무’라고 할 수 있고²⁶⁶⁾ 이는 임금성이 부정된 복지포인트와 근거법뿐만 아니라 그 장과 절까지 같다.²⁶⁷⁾

복지포인트에 관한 대법원 판결이 소부가 아닌 전원합의체 판결임을 고려하면 「근로복지기본법」상 성과배분에 해당하는 경영성과급도 다른 논리를 적용하는 것은 타당하지 않으며 임금성이 부정된다고 보아야 한다.

2) 근거 법령 외의 요소 비교

근거법령 외의 요소로 연혁 및 도입배경과 당사자들의 인식 및 제도의 활성화에

참여기회 확대, 근로의욕의 증진 및 삶의 질 향상을 목적으로 하여야 한다.

264) 제정 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률(법률 제6510호) 제20조 (성과배분 등에 대한 지원) ①사업주는 당해 사업장의 근로자와 협의하여 정한 당해 연도 이익 등의 경영목표가 초과달성된 경우 그 초과된 성과를 근로자에게 지급하거나 근로자의 복지증진을 위하여 사용하도록 노력하여야 한다.

②사업주는 당해 사업장의 근로자가 직무와 관련하여 발명 또는 제안하거나 새로운 지식·정보·기술을 개발하여 회사의 생산성·매출액 등의 증가에 기여한 경우 이에 상응하는 정당한 보상을 하도록 노력하여야 한다. 이 경우 구체적인 보상기준은 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률에 의한 노사협의회 등을 통하여 정한다.

③국가 또는 지방자치단체는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 성과배분 등을 활성화하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

265) 현행 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제84조(성과 배분) 사업주는 해당 사업의 근로자와 협의하여 정한 해당 연도 이익 등의 경영목표가 초과 달성된 경우 그 초과된 성과를 근로자에게 지급하거나 근로자의 복지증진을 위하여 사용하도록 노력하여야 한다.

266) 박지순·이진규, 앞의 논문, 183면

267) 제3장 기업근로복지, 제3절 선택적 복지제도 및 근로자지원프로그램 등



대해 살펴보면 아래와 같고 근거 법령과 마찬가지로 복지포인트와 경영성과급은 공통의 특징을 갖고 있어 같은 논리가 적용되어야 하며 마찬가지로 임금성도 부정된다고 보아야 한다.

① 연혁 및 도입 배경

대법원은 복지포인트의 임금성을 부정하면서 복지포인트의 i) 연혁은 미국에서 기존에 전통적인 기업복리후생 제도를 개인의 선택에 기초하여 복리후생의 내용이나 수혜 수준을 달리하기 위해 시작된 새로운 복리후생제도이며, ii) 우리 법제와 기업 실무에서 도입한 배경은 종래 임금성을 가진 복지수당 위주에서 벗어나 비임금성 기업복지제도로서의 실질을 갖추기 위해 그 형식과 내용을 변화시킨 새로운 제도이기 때문에 이를 임금으로 해석하기 어렵다고 보았다.

앞서 살펴본 성과배분제도의 연혁과 도입배경을 고려하면 성과배분제도의 하나인 경영성과급은 최초 도입 시부터 임금인상을 대체하기 위한 것이 아니었고, 임금성 인정가능성이 낮은 이익배분제의 형태로 정부의 권고에 따라 임금성을 부정하는 것을 전제로 도입되었다고 볼 수 있다. 실제 최근 하급심 판결상 문제가 되었던 모든 경영성과급은 유형은 수익배분제가 아닌 이익배분제였고, 지급기준도 당기순이익이나 EVA였다.

② 당사자들의 인식 및 제도의 활성화

대법원은 복지포인트의 임금성을 부정하면서 단체협약이나 취업규칙 등에서 보수나 임금으로 명시하지 않고 있어 노사가 임금이 아니라는 데에 인식을 같이 하고 있다는 것과 복지포인트의 임금성 인정 시 오히려 복지포인트 제도활성화에 저해요인이 될 수 있다는 것을 고려 요소로 보았다.

경영성과급의 경우 일부 사안에서 성과배분으로서 보수제도로 명시된 경우(삼성전자)도 일부 있지만 이는 성과중심의 보수제도라는 특징에 기초한 것일 뿐이며, 「근로기준법」상 임금이라고 명시하고 있는 경우는 없다. 더불어 경영성과급의 경우 경영성과라는 2018년 공공기관 경영평가성과급의 임금성이 인정되기 전까지는 노사 모두 경영성과급은 「근로기준법」상 임금이 아니라고 인식하고 있었다고 볼 수 있다. 더불어



변동성이 큰 경영성과급의 임금성이 긍정될 경우 경영성과급 지급 시 오히려 인력의 유출(퇴직금을 고려한 인력 퇴직)이라는 부작용도 발생될 수 있어 경영성과급 제도의 활성화에 장애 요인이 될 수 있다.

Ⅲ. 민간기업 경영성과급 임금성에 대한 최근 하급심 판결

1. 최근 하급심 판결의 유형화

최근 문제가 된 민간기업 경영성과급 임금성에 관한 다수의 하급심 판결은 모두 당기순이익, 영업이익 등을 발생 조건으로 하고 있다. 따라서 유형을 나누어 본다면 아래와 같이 지급 조건이 취업규칙이나 단체협약 등에 사전 제도화되어 있는지 여부 및 회사의 경영성과 달성 정도에 따라 지급여부와 지급률에 대한 재량권²⁶⁸⁾ 보유 여부 그리고 실제 미지급한 사례 유무에 따라 구분해 보면 아래와 같다.

[표 8] 경영성과급 임금성 관련 하급심 판결 지급형태별 유형화

사전제도화 미지급 지급 재량권	사전제도화 ²⁶⁹⁾		사전 미제도화	
	전부 지급	일부 미지급	전부 지급	일부 미지급
유	삼성전자 1차 (HR규정, 불인정) 삼성전자 2차 (HR규정, 인정) 삼성디스플레이 (인사규정, 불인정) 발레오 전장 (단체협약, 불인정)	-	LG화학 (노사협의, 불인정)	SK하이닉스 (노사협의, 불인정) LG디스플레이 (내부품의, 불인정)
무	한국유리공업 (단체협약, 인정)	-	서울보증보험 (노사협의, 인정)	현대해상화재보험 (노사협의, 인정)

268) 경영성과 달성 정도에 따라 지급률이 명확히 규정되어 있을 경우 재량권이 없다고 분류하였다. 다만, SK하이닉스의 경우 제도 운영 초기에는 달성률에 따라 지급률이 명시되어 있었다.

269) 삼성전자, 삼성디스플레이는 HR규정이나 인사규정에서 경영성과급에 대한 지급기준이 명시되어 있었고, 발레오전장과 한국유리공업은 단체협약에 경영성과급의 지급기준이 사전제도화되어 있었다.



이하에서는 ① 동일한 사실관계를 가짐에도 불구하고 ‘근로제공 관련성’과 ‘지급의 무성’에 대해 다른 결론을 내린 삼성전자 2개의 사건 판결, ② 사전에 마련된 제도가 아닌 매년 노사합의로 지급기준을 정하고 실제 미지급된 사례가 있었음에도 특히, ‘지급의무성’에서 ‘근로제공 관련성’과 같이 다른 결론을 내린 SK하이닉스 및 현대해상 화재보험 판결을 중심으로 쟁점이 되었던 논거를 비교하고 판례의 태도를 검토한다.

2. 삼성전자 경영성과급 임금성 관련 2개 사건 판결 비교

(1) 사실관계 및 판결 결과

삼성전자(피고회사)는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매 등을 목적으로 하는 전자회사로, 피고회사는 3개의 사업부문 산하에 각각 여러 사업부를 운영하고 있었다. 삼성전자는 원고들이 소속된 사업부²⁷⁰⁾를 물적분할 후 매각하기로 하였고 원고들은 2016년 피고회사를 퇴직하였고 피고회사는 퇴직금을 지급하였다. 원고들은 피고회사가 “목표인센티브²⁷¹⁾와 성과인센티브²⁷²⁾를” 제외하고 산정한 평균 임금을 기초로 한 퇴직금만을 지급하였으므로 이 사건 각 인센티브를 평균임금에 포함하여 재산정한 퇴직금과의 차액을 각기 다른 법원에 청구하였다.

같은 날 삼성전자 1차 사건 판결(2심)은 임금성을 부정하였고²⁷³⁾ 삼성전자 2차 사건(1심)은 임금성을 인정하여²⁷⁴⁾ 각 법원이 상반된 판결을 하였다. 삼성전자의 경영성과급 임금성 관련 2개 사건 판결은 동일한 회사에 재직하여 동일한 제도를 적용받았던 직원들이 원고가 되어 사실관계가 동일함에도 각 법원이 상반된 결론을 내렸다는 특징이 있다.

목표인센티브(TAI)와 성과인센티브(OPI)의 지급실태를 구체적으로 살펴보면 삼성

270) 2016년 당시 피고회사의 조직은 3개의 부문(소비자가전사업부문, 무선사업부문, 반도체 사업부문)으로 나누어져 있었고, 사업부문은 각각 2~4개의 사업부로 나누어졌는데 원고들은 소비자가전사업부문 프린팅사업부 소속이었음

271) TAI, Target Achievement Incentive

272) OPI, Overall Performance Incentive

273) 수원고등법원 2021. 6. 17. 선고 2020나26085 판결

274) 서울중앙지법 2021. 6. 17 선고 2019가합542535 판결



전자는 1994년 이래 매 반기마다 목표인센티브를 2000년 이래 매년마다 성과인센티브를 지급해 왔고 목표인센티브와 성과인센티브의 지급기준과 지급액은 아래와 같다.

항목	목표인센티브	성과인센티브		
지급기준	각 사업부문과 사업부의 성과를 피고회사가 평가한 결과를 기준으로 지급하는 돈으로, 피고회사는 “재무성과와 전략과제를 이행한 정도를 기준”으로 각 사업부문과 사업부를 평가하고 ²⁷⁵⁾ 이를 합산한 평가결과에 따라 각각의 사업부문과 사업부에 소속된 근로자들에게 상여계산기초금액(월 기준급의 120%)의 최소 0%에서 연 최대 200%를 지급	각 사업부에서 발생한 “EVA의 20%를 재원으로 삼아 피고회사가 따로 마련된 지급기준에 따라 각 사업부에 소속된 근로자들에게 나누어주는 돈으로, 그 상한은 연봉제를 적용받는 근로자들은 연봉의 50%, 연봉제를 적용받지 않는 근로자들은 상여계산기초금액(월기준급의 120%)의 최소 0%에서 연 최대 200%의 700%임		
연도별 지급액	목표 인센티브		성과 인센티브	
	기준연도	상반기		하반기
	2010	100	100	약 976
	2011	100	75	약 279
	2012	75	75	약 510
	2013	100	50	약 279
	2014	100	75	약 65
	2015	12.5	25	약 44
	2016	100	회사 분할	
(상여계산기초금액, 단위:%)				

사내 포털에 게시된 「HR규정」상 ‘임금 구성’ 항목에 ‘월급여, 상여, 인센티브·연차수당’을 명시하고 있으며, ‘부가급여’ 항목에 ‘[S]고과 상여가급, 설·날·추석 귀성여비, 업무성과급, 목표 인센티브, 성과 인센티브’를 아래 표와 같이 명시하고 있다. 또한 세부 기준을 정한 「급여·복리후생·근태 기준」상 목표 인센티브와 성과 인센티브가 ‘지급 기준’ 목차 하에 ‘급여, 수당, 업무성과급, 설·추석상여, 퇴직금’과 같이 규정

275) 재무성과는 매출, 매출성장률, 세전이익, 세전이익률, 세전이익선○장률 등의 항목으로 구분하여 평가하며, 전략과제 이행 정도는 각 사업부문과 사업부가 설정한 과제를 얼마나 충실하게 수행했는지에 따라 평가된다. 사업부문과 사업부 평가 결과는 각 A(지급률 50%)~D(지급률 0%)의 4등급으로 나누어지며 사업부문과 사업부의 평가결과를 합산하고 최소지급률은 0%이며, 최대지급률은 100%이다.



되어 있다.

4. 목표 인센티브

- 1) 지급대상 : 지급기준일(매년 6. 30./ 매년 12. 31.) 현재 재직 중인 전 임직원
- 2) 산정기준 : 상여계산기초 * 지급률
※ 상여계산기초 : 기준급의 120%
※ 기타 세부기준은 별도의 기준에 의함
- 3) 지급일 : 상반기 7,8 하반기 12. 24

5. 성과인센티브

- 1) 지급대상 : 지급기준일(매년 12. 31) 현재 재직 중인 전 임직원
- 2) 산정기준
- 연 봉 제 : (계약연봉 + 업무성과급) * 지급률
- 비연봉제 : (상여계산기초 + 직무조정급) * 지급률
※ 기타 세부기준은 별도의 기준에 의함
- 3) 지급한도
- 연 봉 제 : 최대 50%(단, CL4는 고과에 따라 지급률 1.4배~0.8배 가급)
- 비연봉제 : 최대 700%
- 4) 지급일 : 매년 1. 31

(2) 법원 판단 기준별 논거 비교

1) 근로제공 관련성에 대한 판결의 논거

삼성전자 1차 사건 판결은 경영성과급 지급의 기준이 되는 각 사업부문과 사업부의 성과와 관련하여 ‘세계 및 국내 경제 상황, 동종 업계 동향, 전 세계 각국의 외교·통상정책, 피고 경영진의 경영판단 등 개별 근로자들이 통제할 수 없는 요인들에 의하여 결정되는 것’으로 보고, 개별 근로자들이 제공하는 근로의 양이나 질과 직접적으로 관련되기보다는 ‘개별 근로자들이 통제할 수 없는 요인²⁷⁶⁾에 따라 결정되는 것’으로 보아 밀접한 관련이 없다고 보아 ‘근로제공 관련성’을 부정하였다.

반면, 삼성전자 2차 사건 판결은 경영성과급 지급의 기준이 되는 각 사업부문과

276) 세계 및 국내경제 상황, 동종 업계 동향, 전 세계 각국의 외교·통상정책, 피고 경영진의 의사결정과 의사집행이 포함된 경영판단 등 : 피고회사가 수출의존도가 높은 제조기업임을 감안



사업부의 성과와 관련하여 ‘회사 경영진의 경영능력, 회사자본이나 자산의 기여, 협업에 의한 근로자들의 근로 제공, 전체 시장 상황 등이 총체적으로 결합한 결과’ ‘근로자들이 집단으로 제공한 협업 근로가 피고의 경영성과에 기여한 가치를 평가하여 근로자들에게 그 몫을 지급하는 것’으로 보아 밀접한 관련이 있다고 보아 근로제공 관련성’을 긍정하였다.

판단 기준	삼성전자 1차 사건 판결 요지	삼성전자 2차 사건 판결 요지
근로제공 관련성	각 인센티브는 피고회사가 전반적인 경영성과에 대한 평가나 EVA의 발생 여부와 액수의 결과에 따라 지급하는 것으로 개별 근로자들이 제공하는 근로의 양이나 질과 직접적으로 관련되기 보다는 “개별 근로자들이 통제할 수 없는 요인”에 따라 결정되는 것으로 이 사건 각 인센티브 항목과 원고들이 피고회사에 제공한 근로가 밀접하게 관련되어 있다고 볼 수 없고, 경영성과에 대한 평가를 기초로 그에 따른 이익 중 일부를 근로자들에게 배분하는 것임	개별 근로자들의 근로제공과 생산성 향상을 위한 노력이 모이지 않으면 피고의 사업 수행 자체가 불가능하며, 경영성과는 회사 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여, 협업에 의한 근로자들의 근로 제공, 전체 시장 상황 등이 총체적으로 결합한 결과로서 이 사건 각 인센티브는 근로자들이 집단으로 제공한 협업 근로가 피고의 경영성과에 기여한 가치를 평가하여 근로자들에게 그 몫을 지급하는 것이므로, 근로의 양이나 질과 밀접한 관련이 있음

특히, 삼성전자 2차 사건 판결은 개인성과급의 임금성을 인정하는 대법원 판례의 법리에 비추어 보더라도 목표 인센티브와 성과 인센티브의 임금성을 긍정해야 한다는 논거를 추가로 제시하면서도 경영성과급의 임금성을 인정하는 다수의 판결에서 명시하고 있는 한국공항공사 공공기관 경영평가성과급 판결뿐만 아니라 ‘근로제공 관련성’이 없다는 이유로 임금성을 부정한 영화진흥공사 판결과 서울의료원의 복지포인트 임금성 판결을 모두 참조 판결로 제시하였다. 즉 양 판결은 ‘근로제공 관련성’을 ‘근로의 대가성’ 판단 요소로 삼았음에도 불구하고 ‘근로제공 관련성’의 의미에 대해 상반된 견해를 취하였다.



2) 사용자의 지급의무성에 대한 판결의 논거

삼성전자 1차 사건 판결과 삼성전자 2차 사건 판결은 ‘지급의무성’에 대해서도 다른 판단을 하였는데, 특이한 점은 상기 두 판결 모두 「HR규정」, 「급여·복리후생·근태 기준」, 연도별 그간의 지급내역 등 동일한 사실관계를 판결문에 설치하였음에도 다른 판단을 하였다는 것이다. 삼성전자 1차 사건 판결은 「HR규정」, 「급여·복리후생·근태 기준」을 취업규칙에 해당하지 않았다고 보았고 사용자가 지급 대상과 지급률에 있어 광범위한 재량권을 가지고 있다는 논거로 ‘지급의무성’을 부정하였다. 반면 삼성전자 2차 사건 판결은 「급여·복리후생·근태 기준」에 지급률과 지급대상이 특정이 되어 있다고 보았고, 이를 취업규칙으로 보아 ‘지급의무성’을 인정하였다.

판단 기준	삼성전자 1차 사건 판결 요지	삼성전자 2차 사건 판결 요지
지급근거 유무 (노동관행 성립)	취업규칙 상에는 이 사건 각 인센티브 규정이 없음 매년 지속적으로 지급했다는 사정만으로 위 각 인센티브를 임금에 포함하기로 한 노동관행 성립했다고 볼 수 없음	「HR규정」은 근로자들의 ‘임금’에 인센티브를 명시, ‘부가급여’ 구성에 ‘이 사건 각 인센티브’도 포함함, 「급여·복리후생·근태 기준」상 ‘복리후생단원’이 아닌 임금 관련 ‘지급기준 단원’에서 규율
지급 조건 확정 여부	이 사건 각 인센티브를 계산하기 위한 전제가 되는 일정한 기초금액이 구체적으로 정해져 있거나 이를 특정할 수 있는 기준 등이 없고 오히려 피고의 ‘업적평가 세부 시행안’에 따르면 대상 및 지급률에 대해 경영진에게 광범위한 재량권 주어 있음	급여규정 등은 이 사건 각 인센티브의 지급대상과 산정기준, 지급일을 구체적이고 상세하게 정하고 있음 1994년 이래 매 반기마다 목표 인센티브를, 2000년 이래 매년마다 성과 인센티브를 지급해 왔고 산정기준과 지급시기 등은 급여규정 등에서 정한 것과 일치함

3) 계속성·정기성에 대한 판결의 논거

목표 인센티브와 성과 인센티브는 각각 1994년, 2000년 도입 이래 계속적·정기적으로 지급되었기 때문에 상기 두 판결 모두 계속성 및 정기성에 대해서는 다툼이 없었다.²⁷⁷⁾

277) 심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 93면 참조



4) 평균임금의 취지 등에 대한 논거

삼성전자 1차 사건 판결은 목표 인센티브와 성과 인센티브가 큰 폭으로 달라진다고 볼 수 있어 통상의 생활임금이라는 평균임금 산정 취지 상 제외되어야 한다고 보았으나, 삼성전자 2차 사건 판결은 이사건 각 인센티브의 비중이 크다는 점과 평균임금이 통상의 생활임금을 산정하는 취지를 근거로 임금성을 인정하였다.

판단 기준	삼성전자 1차 사건 판결 요지	삼성전자 2차 사건 판결 요지
평균임금 취지 (변동폭과 비중)	지급일에 지급되는 금액이 매년 변동될 수밖에 없어 연중 퇴직 시기에 따라 평균임금의 액수가 큰 폭으로 달라지게 되어 통상의 생활임금을 기초로 근로자의 통상의 생활을 종전과 같이 보장하려는 퇴직금 제도의 취지에 반함	이사건 각 인센티브는 2000년 이래 매년 지급되어 왔고, 근로자들의 전체 급여에서 차지하는 비중 또한 상당하기 때문에 평균임금 산정에서 제외한다면, '통상의 생활임금을 산정한다'는 평균임금 및 퇴직금 제도의 근본취지가 오히려 몰각하게 됨

(3) 검토

삼성전자 1차 사건 판결과 2차 사건 판결은 임금성의 법리와 판단 구조를 모두 동일하게 하였음에도 각 판단 요소별 논거가 극심히 나뉜 판결이었다.

우선 ‘근로제공 관련성’에 대한 부분을 살펴보면, ‘근로제공 관련성’은 근로제공과 금품지급간에 관련성으로 판단을 해야 할뿐 성과 달성의 측정 단위가 개인 또는 집단 인지에 따라 ‘근로제공 관련성’이 달리 판단될 이유는 없다. 따라서 개별근로자들의 생산성 향상을 위한 협업의 결과로 금품지급이 되었다고 해서 근로의 대가가 아니라고 단정할 수 없다고 본 삼성전자 2차 판결의 논거는 타당하다고 보인다. 그러나, 경영 성과 달성에 협업을 통한 개별 근로자의 근로제공이 기여를 하였다고 하여 ‘근로제공 관련성’이 인정된다는 삼성전자 2차 사건 판결의 논거에는 동의하기 어렵다. 근로자의 경영성과 달성에 대한 기여와 인센티브 지급간에 ‘근로제공 관련성’이 인정되기 위해서는 근로자가 제공해야 할 근로계약 상 근로제공의무에 인센티브의 발생 요



전인 재무적 성과 달성이 예정되어 있어야 하나, 삼성전자 1차 사건 판결 및 2차 사건 판결은 지급대상 근로자의 근로계약 상 근로제공의무의 내용과 무관하게 재무적 성과 달성을 이유로 인센티브를 지급하였다. 즉, 판매 사원에게 전사 판매실적 달성을 인센티브의 발생 요건으로 하여 판매사원이 개별적 근로제공을 통해 전사 판매실적을 달성하는 것과 자신의 근로제공의 내용과 무관하게 전사 경영실적 달성을 이유로 지급되는 인센티브와는 ‘근로제공 관련성’을 달리 보아야 한다는 것이다.

삼성전자 2차 사건 판결의 논거와 같이 경영성과를 달성하기 위해서는 협업에 의한 근로자들의 근로제공과 다른 외부적 요인이 결합할 필요는 있음은 부정할 수 없다. 그러나 대법원은 ‘직접’ 또는 ‘밀접’이라는 표현을 통해 ‘근로제공 관련성’을 범위를 제한하고 있다. 재무적 성과는 협업 등 근로의 양이나 질보다는 지급대상기간 동안의 세계 및 국내경제 상황, 동종 업계 동향, 전세계 각국의 외교·통상정책, 경영진의 경영 판단 등 외부적 요인에 의해 크게 좌우된다. 이와 같은 사정을 감안하면 근로제공과 재무적 성과 달성 간에는 간접적인 관련성만 인정될 수 있을 뿐이다. 이러한 간접적인 관련성이 있다는 사정만으로 ‘근로제공 관련성’이 인정되어야 한다면 이는 ‘직접’ 또는 ‘밀접’이라는 표현을 통해 관련성의 범위를 제한하려고 하였던 기존 대법원 판결과 배치되니 때문에 삼성전자 2차 사건 판결의 논거는 타당하지 않다. 만약 삼성전자 2차 사건 판결의 상기 논거에 따르면 사용자가 근로자에게 지급하는 모든 금품은 임금이라는 결론에 다다르게 되며 이 경우 임금 외의 금품을 근로계약 당사자간에 계약하는 것이 금지된다는 불합리한 결과를 가져오게 된다.

더불어 삼성전자 2차 판결은 근무기간에 따라 차등하여 지급한 것을 이유로 인센티브 지급의 액수가 대상기간 근로자가 제공한 근로의 양과 직접적으로 관련되어 있다고 보았다. 그러나 대법원은 근무기간에 따라 일할 지급된 복지포인트에 대해서도 임금성을 부정하였고, 삼성전자 2차 판결의 상기 논거는 복지포인트 전원합의체 판결을 고려하면 타당하다고 보기 어렵다.

‘지급의무성’과 관련하여 삼성전자 1차 사건의 판결이 HR규정 등에서 달성해야 하는 경영성과는 명시되어 있지 않아 목표 인센티브와 성과 인센티브의 지급 여부와 지급률에 있어 회사의 재량적 요소가 크다고 볼 수 있고 이로 인해 지급여부와 지급률이 불확정적일 수는 있다고 본 것은 타당하며 임금청구권을 인정할 수 있는지의 관점



에서 본다면 비록 HR규정에 따라 지급대상과 지급시기가 규정되어 있는 점, 그간 대법원 판결의 논리와 같이 급여 및 복리후생은 대표적인 근로조건이며 이에 대한 규정은 그 명칭 여부를 불문하고 취업규칙인 점 등이 인정되어 명시적인 법원이 있다고는 볼 수 있으나 취업규칙상 목표 인센티브와 성과 인센티브의 지급액을 특정할 수 없는 바 삼성전자 1차 사건 판결의 사실관계 인정의 타당성 여부는 별론으로 하더라도 ‘지급의무성’을 인정할 수 없다는 삼성전자 1차 사건의 결론이 보다 타당하다.

삼성전자 1차 사건 및 2차 사건의 판결 상 목표 인센티브 및 성과 인센티브는 최소 지급률과 최대지급률이 각 약 8배 이상, 20배 이상의 차이를 보인다. 임금성 여부를 떠나 평균임금이 통상의 생활임금을 보장하기 위한 도구적 개념이라는 점을 고려한다면 지급 시기별로 극심한 차이를 보이는 목표 인센티브와 성과 인센티브를 평균임금에 산입하는 것 자체가 타당하지 않다.

3. SK하이닉스 및 현대해상화재보험의 경영성과급의 임금성 사건 판결 비교

(1) 사실관계 및 판결 결과

SK하이닉스 PI²⁷⁸⁾ 및 PS²⁷⁹⁾의 임금성 판결(이하 ‘SK하이닉스 판결’이라 한다)과 현대해상화재보험 경영성과급의 임금성 판결(이하 ‘현대해상화재보험 판결’라 한다.)은 각각 업종은 다르지만 ‘매년 사전에 노사합의 또는 내부품의로 경영성과급의 지급조건을 달리 정하였고, 실제 상당기간 계속하여 금액을 달리하여 지급된 것은 맞지만 미지급 합의(또는 미합의)나 경영성과를 달성하지 못해 미지급된 경우도 있다’는 사실관계가 유사하였다. SK하이닉스 판결은 ‘지급의무성’을 부정하며 임금성을 부정한 반면, 현대해상화재보험 판결은 ‘경영성과급 지급에 대한 묵시적 합의나 노동관행이 성립되었다’고 보아 ‘지급의무성’을 인정하고 임금성을 인정하여 각 판결이 유사한 사실관계에도 불구하고 상반된 결론을 내렸다는 특징이 있다.

278) Productivity incentive

279) Profit sharing



사건명 (판결결과)	SK하이닉스 판결(부정)	현대해상화재보험 판결(인정)
청구취지 및 판결결과	피고 회사는 반도체소자 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 제조사로, 원고들 ²⁸⁰⁾ 은 2007년부터 당기순이익을 기준으로 지급된 경영성과급인 PI, PS의 임금성을 주장하며 퇴직금 차액을 청구하였고, 1심 및 2심 모두 임금성을 부정하였다. ²⁸¹⁾	피고 회사는 손해보험업을 주된 사업으로 영위하는 보험사로 원고들은 경영성과급(이하 ‘이 사건 경영성과급’이라 한다)의 임금성을 주장하며 확정기여형 퇴직연금 부담금의 차액을 청구하였고, 1심 및 2심 모두 임금성을 긍정하였다. ²⁸²⁾

양 회사의 지급실태를 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

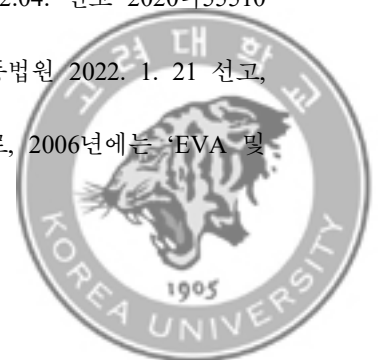
SK하이닉스는 1999년부터 매년 노동조합과의 교섭으로 경영성과급 지급 여부, 지급기준 및 한도, 지급률, 대상 기간 등을 달리 정한 다음, 이에 따라 근로자에게 경영성과급을 지급하여 왔다. 경영성과급의 명칭은 연도마다 변경되었으나²⁸³⁾ 2007년부터는 PI 및 PS란 동일한 명칭으로 지급되었고, 그 지급기준이나 한도, 지급률, 기타 지급 조건 등은 연도마다 차이가 있지만 지급시기는 PI는 반기 각 1회, PS는 연 1회 지급되었다. 다만, 2001년 및 2009년에는 경영성과급을 미지급하기로 합의하여 지급되지 않았고, 2005년부터 2015년까지는 지급합의는 있었으나 PI 및 PS가 미지급된 적도 있는 등 실제 연도별 지급률은 하기 표와 같다. 회사 연봉제 급여규칙(제4조 제2호)이 ‘경영성과급’을 연봉 외 급여의 일종으로, 월급제 급여규칙(제4조 제1항), 단체협약(제44조), 취업규칙(제54조의2), 단체협약(제44조)이 ‘상여금’을 임금의 일종으로 정하고 있기는 하나, “지급할 수 있다.”, “별도로 정할 수 있다”라고만 정하고 있고 경영성과급의 지급기준, 지급률 등은 노사합의안에서만 정하고 있다.

280) 원고 1은 생산직 월급제 직원이었고, 원고 2는 기술사무직 연봉제 직원이었다.

281) 수원지방법원 여주지원 2019가단50590 판결, 수원지방법원 2021.02.04. 선고 2020나55510 판결, 대법원 2021다219994 계류중

282) 서울중앙지방법원 2021.4. 15. 선고 2019가합538253 판결, 서울고등법원 2022. 1. 21 선고, 2021나2015527 판결

283) 1999년, 2000년에는 ‘성과급’으로, 2002년~2005년에는 ‘인센티브’로, 2006년에는 ‘EVA 및 생산성 인센티브’였다.



연도	실지급률				노사 합의 지급 한도
	생산성 인센티브 (2005년, 2006년), 이 사건 PI(2007년~)		영업이익 인센티브 (2005년) EVA 인센티브(2006년) 이 사건 PS(2007년~)	합계	
	상반기	하반기			
2005	80	미지급	270	350	600
2005	80	80	440	600	760
2007	100	100	미지급	200	800
2008	60	미지급	미지급	60	800
2009	해당 없음(미지급 합의)				
2010	100	100	750	950	950
2011	100	100	미지급	200	900
2012	100	100	미지급	200	900
2013	100	미지급	580	680	1,000
2014	100	100	1000	1,200	1,200
2015	100	100	910	1,100	1,200
(상여금 지급기준, 단위:%)					

현대해상화재보험은 2001년도부터 2008년까지는 노사협의회와의 합의 또는 노동조합과의 단체협약 따라²⁸⁴⁾ 2009년부터는 회사 내부품의에 따라 익년도에 지급할 경영성과급의 지급기준(세후 당기순이익의 금액별 지급률로 최소지급액 없음)을 사전에 정한 후 익년도에 지급기준을 충족하는 경우 경영성과 달성 정도에 따라 경영성과급을 연 1회 지급하였다. 다만, 2002년에는 사전에 지급기준이 정해지지 않아 경영성과급이 지급되지 않았고 2005년 및 2006년에는 사전 합의는 있었지만 당기순이익이 지급기준에 미치지 못해 지급되지 않아 미지급된 적도 있는 등 실제 연도별 지급률은 하기 표와 같다.

284) 2001년은 노사협의회와 합의하였고, 2003년부터는 노동조합(전국손해보험 노동조합 현대해상화재보험 지부)과 합의하였다. 2002년에는 노사협의회 합의 또는 노동조합과의 단체협약으로 사전에 지급기준이 정해지지 않아 지급되지 않았다.



연도	지급률	연도	지급률
2001	100	2010	500
2002	미지급(합의 없음)	2011	700
2003	100	2012	500
2004	200	2013	100
2005	미지급	2014	200
2006	미지급	2015	100
2007	500	2016	700
2008	350	2017	716.453
2009	500	2018	450
(기준월봉 기준, 단위:%)			

(2) 법원 판단 기준별 논거 비교

1) 근로제공 관련성에 대한 판결의 논거

SK하이닉스 판결은 i) PI 및 PS의 지급조건은 생산목표달성 및 추가적인 부가조건과 EVA의 발생을 전제로 하고 있고²⁸⁵⁾ 지급조건이 동종업계의 동향, 전체 시장의 상황, 피고 회사의 영업상황이나 재무상태 등을 비롯하여 사용자의 우연하고 특수한 사정에 의하여 좌우되는 요소들을 내용으로 하고있어 금품의 지급 여부가 근로의 제공과는 직접적인 관련이 없는 불확정적인 조건에 의존하는 경우 근로의 대가라고 보기 어려운 점, ii) PI 및 PS의 지급조건이 회사의 영업이익 내지 EVA의 발생을 전제로 하고 있는 부분을 고려하여 볼 때 배분적 성격이 강한 것으로 보이는 점 등을 이유로 ‘근로제공 관련성’을 부정하였다.

285) PI는 기본적으로는 생산목표의 달성을 기준으로 하여 추가적으로 부가조건[정상화 이행평가 결과 일정 등급 이상(2003년~2005년), 기말 현금 1조 2,000억 원 보유(2010년~2012년), 영업이익 발생(2013년~2014년)]이 충족될 것을 요하였고, 2015년은 사업변동 등 중대 사안 발생 시 별도 협의하도록 하고 함

PS는 피고 회사에 EVA[= 영업이익 - (자기자본 × 자기자본비용) - 차입금 이자비용 - 법인세]가 발생할 것을 전제로 함



반면 현대해상화재보험 판결은 i) 사용자가 근로자 집단에 대하여 회사의 목표나 성과 달성을 위한 근로 동기 의욕을 고취하고 장려하기 위하여 집단적인 성과급을 지급하였다면, 이는 ‘협업의 질’까지 포함하여 회사가 요구하는 근로의 질을 높인 것에 대한 대가로도 볼 수 있는 점, ii) 근로 제공의 결과로서 달성한 사업목표가 지급원인이 되어 전 직원에게 지급되어 임의적·은혜적 성질의 것이라 볼 수 없는 점, iii) 오히려 지급대상 기간 동안의 근무기간에 비례적으로 지급율이 정해진 점, iv) 특히, 피고의 업종(손해보험업, 자산운용을 목적으로 하는 법인) 특성 상 당기순이익²⁸⁶⁾은 ‘근로자의 근로제공을 발생원인으로 생성된 결과물’로 고유의 업무수행 이외의 사유에 기하여 지급되는 은혜적 성격의 급부가 아니라는 점을 이유로 ‘근로제공 관련성’을 긍정하였다.²⁸⁷⁾

양 판결은 앞서 살펴본 삼성전자의 2개 사건과 마찬가지로 ‘근로의 대가’의 요건인 ‘근로제공 관련성’의 개념에 대한 명확한 견해의 차이를 각각 반영한 것으로 보인다. 다만, 현대해상화재보험 사건은 개인성과급에서 근로제공 관련성을 인정하면서 논거로 제시한 근로의 내용과 업종의 관련성을 추가적인 판단요소로 제시하였다는 특징이 있다.

2) 지급의무성에 대한 판결의 논거

SK하이닉스 판결은 i) 피고 회사의 단체협약, 취업규칙, 급여규정 등에 이 사건 PI 및 PS의 지급근거가 명시되어 있지 않다는 점, ii) 피고 회사는 매년 노동조합과의 임금교섭에 따라 PI, PS의 지급 여부 및 구체적 지급조건을 결정해 왔기 때문에 임금교섭 결과에 따라 PI, PS의 지급여부나 지급기준·지급액수 등이 매년 달라졌다는 점을 이유로 지급이 확정적이지 않다고 보아 PI 및 PS의 ‘지급의무성’을 부정하였다

현대해상화재보험 판결은 i) 경영성과급 지급기준은 지속적인 적용을 전제로 한 것이 아니므로 취업규칙에 해당한다고 보기 어렵다²⁸⁸⁾고 보아 단체협약, 취업규칙, 급

286) 당기순이익=영업이익(영업수익과 영업비용의 차액)+영업외 이익-영업외 비용-법인세 비용
영업수익은 보험영업이익, 투자영업수익, 특별계정수익, 특별계정수입수수료로 구성되고 영업비용은 보험영업비용, 투자영업비용, 특별계정비용, 특별계정지급수수료로 구성된다.

287) 1심 판결 상 당기순이익과 업종 특성에 대한 언급은 없었으나, 2심 판결에서 새로운 논거를 추가하여 판시하였다.



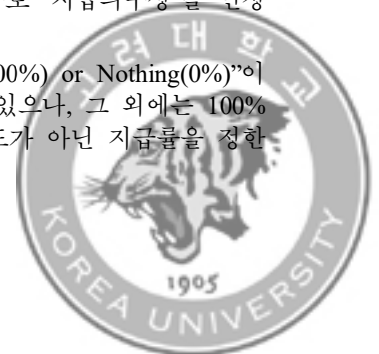
여규정 등에 지급근거가 명시되어 있지 않지만, ii) 2003년도부터 15년 이상 해마다 노사합의나 내부결재 등을 통하여 미리 경영성과급 지급기준을 정하고, 해당 사업연도의 결산이 끝나고 당기순이익이 확정되면 그 지급기준에 따라 산정된 경영성과급을 지급하여 미리 정하여진 지급기준에 맞는 경영실적을 달성하였다면 피고로서도 그 실적에 따른 경영성과급의 지급을 거절할 수 없을 것으로 보이는 점, iii) 매년 당기순이익이 미리 정하여진 지급기준에 해당하면 그에 따른 경영성과급을 예외 없이 지급하여 은혜적 급부로 보기 어렵다는 점을 이유로 매년 한 차례씩 경영성과급 지급에 관한 노동관행(지급율이나 지급액수에 관한 노동관행은 미인정)이 인정된다²⁸⁹⁾고 보아 경영성과급의 ‘지급의무성’을 긍정하였다.

양 판결은 취업규칙에는 지급근거가 명확하지 않고(재량사항으로 규정되거나 규정 없음), 실제 노사합의가 없던 경우 지급되지 않았음에도 지급에 대한 노사관행을 인정할 수 있는지와 관련하여 극심하게 입장이 나뉜다. 이에 대해 현대해상화재보험 판결은 세후 당기순이익의 달성 정도에 따라 경영성과급의 지급률이 세분화되어 명시되어 있어 SK하이닉스 판결보다 지급기준이 더 명확하다는 차이(지급액이 특정)가 있어 판결의 결론이 달라졌다고 볼 수도 있다. 참고로 SK하이닉스 판결도 도입 초기에는 경영성과 달성 정도에 따라 지급률이 세분화되어 명시되어 있었고 PI의 경우 지급률이 현대해상화재보험과 동일하게 특정되어 있었다.²⁹⁰⁾ 한편, SK하이닉스가 최근까지도 노사합의를 통해서 PI 및 PS의 지급기준을 정하고 있는 반면 현대해상화재보험의 경

288) ① 각 지급기준 자체에서 해당연도 경영성과급에 관하여 1회적으로 적용됨을 명시하여 시적 적용범위를 한정하고 있는 점, ② 2018년도 경영성과급 지급기준 변경 이전에도 당기순이익 기준에 관하여 3차례 변경되는 등(2005년도, 2008년도, 2012년도) 지급기준이 변동되어 왔는바 위 시적 적용범위가 형식적인 것에 불과하다고 보기 어려운 점에서 2017년도 경영성과급 지급기준은 당해연도 경영성과급에 한하여 적용되는 것이고 그 이후 효력이 소멸된다고 보아야 하므로, 2018년도 경영성과급 지급기준의 작성이 취업 규칙 변경에 해당한다고 볼 수 없다.

289) 1심 판결에서는 묵시적 합의가 이루어졌거나 노동관행이 성립하였다고 볼 수 있다고 하였으나, 2심에서는 묵시적 합의에 대한 언급 없이 노동관행만을 이유로 ‘지급의무성’을 인정하였다.

290) PI는 지급한도라고 표시되어 있으나 2013년 노사합의서 상 “All(100%) or Nothing(0%)”이라고 명시되어 있고 2008년 상반기 단 한차례 60%를 지급한적도 있으나, 그 외에는 100%를 지급하거나 미지급을 한 점을 고려하면 PI의 100%는 지급한도가 아닌 지급률을 정한 것으로 볼 수 있다.



우 2009년 이후 매년 사용자가 품의를 통해 재량으로 지급기준을 정하고 있다는 차이가 있고 오히려 이러한 점을 고려하면 사용자의 재량이 더욱 강하게 인정되는 현대해상화재보험의 경영성과급이 ‘지급의무성’을 인정하기 어려움에도 반대의 판단결과가 나온 것은 쉽게 납득하기 어렵다.

3) 계속성·정기성에 대한 판결의 논거

SK하이닉스 판결은 2005년부터 2015년까지 사이에 PI 및 PS 중 일부²⁹¹⁾가 지급되었다는 점을 이유로 ‘계속성·정기성’을 부정하였다.

현대해상화재보험 판결은 경영성과급이 2003년부터 2018년까지 15년 이상 해마다 계속하여 기준연도의 당기순이익 달성에 관한 사업목표를 제시하고 일정한 세후 당기순이익 달성시 일정율의 경영성과급을 지급하는 내용의 지급기준을 작성한 뒤, 기준연도 결산 후 지급기준 달성 시 지급기준에 따라 일부 연도를 제외²⁹²⁾하고 연 1회씩 지급된 점을 이유로 ‘계속성·정기성’을 긍정하였다.

최근의 지급실태만 놓고 본다면 현대해상화재보험의 경우 약 10년간 미지급된 적이 없는 것은 맞지만 양 판결 모두 사실관계 판단에 있어 미지급을 인정하였고 횡수에 있어 차이가 있을 뿐임에도 ‘계속성·정기성’에 대한 판단을 달리하였다.

4) 평균임금의 취지 등에 대한 논거

SK하이닉스 판결은 i) PI 및 PS는 전혀 지급되지 않는 경우부터 최소 지급액에서 최다 지급액까지 그 액수가 상이하여(상여지급기준 대비 60%~1,200%), ii) PI 및 PS가 ‘전체 급여에서 차지하는 비중’도 일률적으로 평가하기 어렵고 PS 및 PI를 포함하여 평균임금을 산정하여야만 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정하는 ‘평균임금 제도의 취지’에 부합하는 것이라고 보기도 어렵다고 보아 임금성을 부정하였다.

291) 앞서 살펴본 바와 같이 노사는 경영 악화를 이유로 2001년과 2009년 경영성과급 미지급 결의를 하였고, 노사의 지급 결의가 있었음에도 실적 부진을 이유로 PI는 2007년 하반기, 2008년 하반기, 2013년 하반기 지급되지 않았고, PS도 2007년, 2008년, 2011년, 2012년 지급되지 않았다.

292) 2001년 사전 합의 없음을 이유로 2005년, 2006년에 지급기준 미달로 경영성과급이 지급되지 않았다.



현대해상화재보험 판결은 i) 실제 지급된 경영성과급의 변동폭이 크고(기준월봉 대비 0%에서 716%) ‘2005년도와 2006년도에 지급기준 미달로 경영성과급이 지급되지 않은 사정은 있지만 ii) 경영성과급이 ‘전체 급여에서 차지하는 비중(연간 총 급여의 4.2% ~ 26%)’이 적지 않고²⁹³⁾ 매년 일정한 시기에 지급되기 때문에 통상의 생활 임금이라는 평균 임금 부합한다보아 임금성을 긍정하였다.

양 판결의 모두 지급이 이루어진 경우에는 매년(매 반기)일정한 시기에 지급이 이루어졌다는 점과 변동폭이 크다는 것에는 차이가 없지만 전체 급여에서 차지하는 비중이라는 논거에 대해 상반된 판단하였다.

(3) 검토

SK하이닉스 판결과 현대해상화재보험 판결은 ‘근로조건 관련성’, ‘지급의무성’, ‘계속성·정기성’, ‘평균임금의 취지 등’ 최근 하급심에서 경영성과급의 임금성을 판단함에 있어 쟁점이 되는 요소에 대해 판단을 하였고 각 요소에 있어 논거를 달리하였다.

왜 이런 결과가 도출되었을까? 우선 SK하이닉스 판결과 현대해상화재보험 판결은 참조 판결에서 차이를 두고 있다. SK하이닉스 판결은 참조 판결로 복지포인트의 임금성을 부정한 판결에서 참조 판결로 명시된 영화진흥공사 자가운전보조비 임금성 판결(대법원 1995. 5. 12. 선고 94다55934 판결)을 명시하였고, 현대해상화재보험 판결은 참조 판결로 공공기관의 경영평가성과급의 임금성을 부정한 판결인 한국공항공사 판결을 참조 판결로 명시하였다. 즉, SK하이닉스 판결은 근로제공 관련성을 임금성 판단의 중요한 기준으로 보며, 현대해상화재보험 판결은 사용자의 지급의무성을 임금성 판단의 중요한 기준으로 보고 있음을 알 수 있다.

특히 SK하이닉스 판결과 현대해상화재보험 판결은 지급의무성에 있어 극명한 견해 차이가 있다. 양 판결 모두 단체협약이나 취업규칙에 이사건 PI 및 PS의 지급근거가 명시되어 있지는 않았다고 보았고, ‘매년’ 노사합의(일부는 내부결재)를 통해 구체적 지급조건을 결정하여 지급율이나 지급액이 매년 달라졌다고 보았다. 그러나 ‘매년’

293) 1심에서는 경영성과급이 ‘전체 급여에서 차지하는 비중’에 대한 부분을 판단하지 않았으나, 2심에서 새롭게 판단함



노사합의로 지급조건을 결정한 것의 의미에 대해 SK하이닉스 판결은 지급 여부가 불확정적이라고 본 반면 현대해상화재보험 판결은 지급조건 충족 시 지급에 대한 거절이 불가능하다는 점을 추가로 실시하여 ‘매년 지급’에 대한 노사관행을 인정할 수 있다고 보았다.

즉, SK하이닉스 판결과 현대해상화재보험 판결은 지급의무의 불확실성의 판단 시점을 지급의무 발생 조건 충족의 단계에서의 불확실성으로 보느냐 아니면 지급의무 이행 조건 충족의 단계에서의 불확실성으로 보느냐로 다르게 인식하고 있기 때문에 다른 상반된 결론을 내린 것으로 보인다. 상기 두 판결 모두 최초 제도 시행 이후 지급기준에 미달한 일부 기간에 대해서는 이사진 PI 및 PS 또는 경영성과급이 지급되지 않은 사례가 있었음을 확인하였다. 장기간 제도를 운영한 점은 상기 두 판결 모두 동일함에도 SK하이닉스 판결의 미지급 횟수가 현대해상화재보험 판결의 미지급 횟수보다 많았다.

PI 및 PS 그리고 경영성과급의 ‘변동폭’, ‘전체 급여에서 차지하는 비중’을 고려하여 ‘평균임금의 취지’에 부합하였는지를 판단한 점과 실제 지급된 변동폭이 크다고 인정한 것은 동일하다. 그러나, SK하이닉스 판결은 통상의 생활임금이라는 평균임금의 취지를 매년 동일한 수준의 유지로 보아 변동폭에 보다 중점적인 판단기준으로 삼은 반면 현대해상화재보험 판결은 각각 당해연도내에서 총 보상의 유지로 보아 연간 급여에서 차지하는 비중을 보다 중점적인 판단기준으로 삼았다. 즉, SK하이닉스 판결과 현대해상화재보험 판결은 평균임금의 취지에 있어 변동폭과 비중 중 어느 것을 더 중시할 것인지에 따라 다른 결론을 내린 것으로 보인다.

IV. 소결

종래 집단성과급의 임금성이 인정된 사례는 매우 드물었으나, 공공기관의 경영평가성과급의 임금성이 인정되면서 경영성과급의 임금성에 관한 논란이 촉발되었고, 임금성을 인정하는 견해와 부정하는 견해 각각 모두 그간 임금성 관련 이슈가 되었던 개인성과급, 공공기관 경영평가성과급, 복지포인트의 임금성과 관련한 법원 판결을 각자



의 논거로 제시하고 있다. 경영성과급의 임금성을 긍정하는 견해는 공공기관 경영평가성과급과 같이 사용자가 근로자에게 지급하는 급부를 특별한 사정이 없는 이상 임금으로 보고자 하는데 최근 하급심 판결을 보면 경영성과급의 임금성을 부정하더라도 기존의 공공기관 경영평가성과급과 달리 개인성과급의 임금성 및 복지포인트의 임금성과 마찬가지로 영화진흥공사 사건 판결에 따라 근로제공 관련성을 모두 판단의 지표로 삼고 있다.

경영성과급의 임금성을 긍정하는 견해는 개인성과급의 임금성을 긍정하고 있는 판례의 경향을 근거로 삼고 있는데 개인성과급은 근로제공에 따라 발생여부를 통제할 수 있고 근로제공에 따른 직무나 역할이 경영성과 목표 달성간에 관련성이 인정되는 반면 경영성과급은 삼성전자 1차 판결과 SK하이닉스 판결에서 설명하고 있듯이 근로제공외 재무적 성과는 협업 등 근로의 양이나 질보다는 지급대상기간 동안의 세계 및 국내경제 상황, 동종 업계 동향, 전세계 각국의 외교·통상정책, 경영진의 경영판단 등 외부적 요인에 의해 크게 좌우된다. 긍정설과 같이 ‘협업의 질 향상’이 경영성과 달성에 영향을 미친다고 하더라도 이는 간접적 영향에 지나지 아니한다. 이러한 간접적 관련성만으로 근로제공 관련성을 인정하는 것은 어렵다. 우리 판례가 직접 또는 밀접한 관련성을 요하는 것과 긍정설의 입장은 배치된다.

다만, 지급의무성은 앞서 살펴본 바와 같이 법원(法源)에 의거 지급사유 달성 시 지급액이 특정되어야 하는데 삼성전자 1차 및 2차 사건과 SK하이닉스 사건²⁹⁴⁾은 그 지급액이 특정되지 않고 한도만 명시하였다. 반면 현대해상화재보험 사건은 모두 단체협약 및 회사 기안문에 따라 지급액을 특정할 수 있다는 사실이 달랐다. 삼성전자 1차사건 및 SK하이닉스 사건과 현대해상화재보험의 지급의무성에 대한결과가 달리 판단된 것을 보더라도 법원에 의해 지급액을 특정할 수 있으면 지급의무성이 인정될 수 있다고 보아야 한다. 근로의 대가는 위의 두가지 요건을 기준으로 판단하여야 한다.

또한 상기 하급심 사건들이 모두 평균임금이 문제된 건임을 고려하면 실생활임금을 반영하는 평균임금의 취지와 계속성·정기성을 판단 요소로 삼을 수는 있으나, 경영

294) PS를 기준으로 함



성과급이 임금에서 차지하는 비중이 크더라도 단순히 비중만을 놓고 판단해서는 아니 되며 오히려 통상적인 실생활의 보장이라는 측면을 고려하면 경영성과급의 변동 정도(변동폭)를 판단 요소로 고려하는 것이 타당하다.

제4절 경영성과급의 임금성 관련 비교법적 검토

I. 의의

비교법적 검토를 통해 임금의 개념과 판단 요건을 보다 명확히 하기 위한 개선방향을 도출해보고자 임금의 개념과 판단 요건 그리고 경영성과급의 임금성과 관련하여 평균임금과 통상임금을 인정하고 있어 우리나라의 임금 법제와 가장 유사한 일본과 임금의 정의 규정이 없음에도 불구하고 우리나라 경영성과급의 도입 시 참고가 되었고 각종 급부 청구권의 범위에 대한 단단을 매우 상세한 규정과 방침을 두고 있는 미국, 그리고 임금에 관한 개념적 정의가 없고 우리나라의 임금제도와는 다르지만 근로조건 관련성과 지급의무성(임금청구권)을 중심으로 각종 급부 청구권의 범위를 판단하는 독일에 대해 간략히 살펴보도록 한다.

II. 외국의 임금의 개념 및 경영성과급의 임금성

1. 일본

(1) 임금의 개념(정의)

일본 민법(제623조)은 “고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노동에 종사할 것을 약속하고, 상대방이 이에 대하여 그 보수를 지급할 것을 약속함으로써 그 효력이 생긴다.”²⁹⁵⁾고 규정하고 있고, 일본 노동기준법(제11조)은 “법률에서 임금이란 임금, 급여,

295) 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方



수당, 상여 그밖에 명칭 여하에 상관없이 노동의 대상으로서 사용자가 근로자에게 지불해야하는 것을 말한다” 라고 규정하고 있다.

위와 같은 일본 민법과 노동기준법의 규정은 우리의 민법 및 「근로기준법」 규정과 매우 유사하다.

구분	일본의 민법 및 노동기준법	우리나라의 민법 및 「근로기준법」
법조항	민법 제623조 고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노동에 종사할 것을 약속하고, 상대방이 이에 대하여 그 보수를 지급할 것을 약속함으로써 그 효력이 생긴다. 노동기준법 제11조 법률에서 임금이란 임금, 급료, 수당, 상여 <u>그밖에 명칭 여하에 상관없이 노동의 대상으로서 사용자가 근로자에게 지불해야하는 것을 말한다</u>	민법 제655조(고용의 의의) 고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다. 근로기준법 제2조(정의) ① 5. “임금”이란 <u>사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.</u>

(2) 임금의 요건

노동기준법의 임금의 정의에 따르면 임금성이 인정되기 위해서는 ‘노동의 대상’이라는 요건을 충족해야 한다. 사용자가 근로자에게 지급하는 어떠한 급부가 ‘노동의 대상’에 해당되는지 여부는 문제가 되는 급부의 성질 및 내용에 비추어 개별적으로 판단될 수밖에 없다. 그러나, 개별 급부 중 무엇이 ‘근로의 대상’으로 지급되는 것인지를 명확히 밝히는 것은 쉽지 않다.

이에 일본은 행정 실무상 개별적 판단을 위해 ‘노동의 대상’으로 지급된 것인지를 판단함에 있어 ① ‘임의적·은혜적 급여’, ② ‘복리후생 급여’, ③ ‘기업설비·업무비’라는 세 개의 개념을 규정하고 있고, 임금성이 문제되는 개별 급부가 위 3개의 유형 중 하나에 해당하는 경우 임금성을 부정하고 있다. 다만, 예외적으로 근로의 대상이라 볼 수 없는 위 세 개의 개념에 해당하는 급부라고 하더라도 단체협약이나 취업규칙에

がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる



해당 급부의 지급요건이 명시되어 있는 경우는 임의적 급여로 볼 수 없어 지급청구권이 있다고 보아 노동기준법상의 임금에 해당하는 것으로 해석하고 있다.²⁹⁶⁾

즉, 사용자가 근로자에게 지급하는 급부의 지급요건이 단체협약이나 취업규칙 등에 의해 명확하게 명시되어 있고 그에 따라 사용자의 지급의무성을 인정할 수 있다면 ‘노동의 대상’으로 보아 임금성을 인정한다는 것이다.²⁹⁷⁾ 이러한 일본의 행정실무 상 판단 기준은 임금을 넓게 인정하게 되는 결과를 가져올 수는 있다.

(3) 경영성과급의 임금성 여부

일본에서는 사용자가 근로자에게 매월 고정적으로 지급하는 월례 임금과는 별도로 1년에 두 번 하계(6월)와 동계(12월)에 보너스나 일시금의 명목으로 상여를 지급하고, 이와 별개로 전사적으로나 개인이 목표이익을 초과하거나 달성했을 때 ‘업적상여 또는 결산상여(경영성과급)’를 지급하는 사례 지급하는 경우가 있다. 또한 이러한 일시금을 일반적으로 ‘상여’ 또는 ‘보너스’라고 한다. 일본에서 상여금을 지급하는 경우에 취업규칙이나 단체협약에 상여에 대한 규정을 두고 있는 것이 일반적이다. 상여금에 관한 규정을 두고 있는 경우를 유형별로 나누어 보면 ① 지급액이 사전에 결정되어 있는 케이스, ② 지급 유 및 지급액이 매번 결정되는 케이스, ③ 지급 유무가 명확하지 않은 케이스(지급 유무가 사용자의 재량인 경우)로 나눌 수 있다.²⁹⁸⁾

일본도 우리와 같이 평균임금과 통상임금을 구분하여 규정하고, 그 산정방법도 우리와 매우 비슷하나, 일본에서는 우리나라와는 달리 통상임금 산정 시에 1개월의 지급주기를 초과하는 임금에 대해서는 산정대상에서 제외하고 있고, 3개월의 초과하는 기간마다 지급되는 임금을 평균임금에서 제외하고 있다. 즉, 일본의 경우 평균임금 및 통상임금 사정시 기간을 제한하는 점이 우리나라와 다르기 때문에 지급의무성을 기준으로 임금성을 넓게 인정하더라도 실질적인 근로자의 편익과 관련되는 평균임금과 통상임금에는 큰 문제를 가져오지 않아 법적안정성이 저해될 가능성이 낮다.

296) 노상헌, “임금의 법리와 쟁점-한국과 일본의 비교법적 검토”, 「노동법학」 제31호, 한국노동법학회, 2009, 108-109면

297) 문무기 외 3명, 앞의 보고서, 77면

298) 이정, 앞의 논문, 152~154면



2. 미국

(1) 임금(일반급)의 개념

미국은 몇몇 주법에서 임금을 “근로자가 수행한 근로나 서비스에 대하여 시간, 업무, 작업량, 수수료 혹은 그 외 계산 방법으로 정해지는 것으로서 근로자가 지급받으리라는 합리적인 기대를 가지고 있는 금품으로 받을 권리를 보유하게 되는 모든 임의적이지 않은 대가”라 정의하고는 있다.²⁹⁹⁾ 그러나, 우리나라의 「근로기준법」에 해당하는 「공정 근로기준법」(The Fair Labor Standards Act : FLSA)상 ‘임금(Wages)’의 개념에 관한 구체적인 법률 규정은 두고 있지 않다. 또한 동법 제3조 (m) (1)에서 “근로자에게 지급되는 임금(Wages)은 사용자가 관례상 근로자에게 식사, 숙박 또는 기타 편의를 제공하는 경우에는 국장(The Administrator of the Wage and Hour Division)이 정하는 합리적 수준의 비용이 포함된다”고만 규정하고 있어³⁰⁰⁾ 임금의 개념을 정의하기는 어렵다.

다만, 「공정 근로기준법」 제7조 (e)는 초과근로수당(Overtime Pay)과 유급병가(Paid Sick Leave) 등의 산정기초가 되는 ‘일반급(Regular Rate of Pay)’의 정의를 두고 있다. 일반급은 “근로자에게 또는 근로자를 위하여 지급되는 모든 보수”라고 정의하고 있고,³⁰¹⁾ 일반급의 산정방식은 “근로자가 받는 특정 주의 총보상액(Total Compensation)을 총근로시간으로 나눈 금액”이다. 미국의 「공정 「근로기준법」」은 우리나라 「「근로기준법」」상에 나타나는 임금, 통상임금이나 평균임금의 개념을 가지고 있지 않지만,³⁰²⁾ 일반급이 초과근로수당의 산정기초가 되는 점을 고려하면 미국의 일반급은 우리나라의 통상임금과 유사하다.³⁰³⁾

299) ILO, □Protection of Wages□ 2003, 20~21면; 문무기 외 3명, 앞의 보고서, 30면.

300) §203. Definitions (m) (1) ""Wage" paid to any employee includes the reasonable cost, as determined by the Administrator, to the employer of furnishing such employee with board, lodging, or other facilities, if such board, lodging or other facilities are customarily furnished by such employer to his employees.

301) §207. Maximum hours (e) "Regular rate" defined

As used in this section the "regular rate" at which an employee is employed shall be deemed to include all remuneration for employment paid to, or on behalf of, the employee

302) 문무기외 3명, 앞의 보고서, 59면

303) 김상률, 앞의 논문, 143면; 성대규, 앞의 논문, 384면 참조



(2) 임금(일반급)의 요건

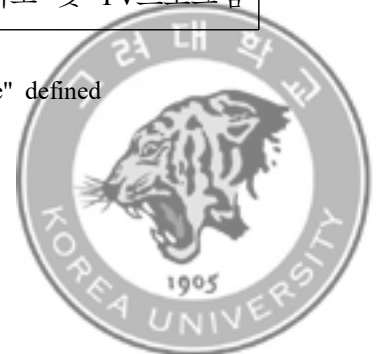
미국의 「공정 「근로기준법」」은 일반급에 포함되지 않는 급여항목들을 명시하고 있다. 일반급에 포함되지 않는 항목들은 총 8가지로 「공정 「근로기준법」」 제7조 (e)에서 아래와 같이 나열하고 있다.³⁰⁴⁾ 이를 구체화하고 있는 「연방시행규칙」(Code of Federal Regulations)³⁰⁵⁾에서 각각에 대해 일반급에서 제외되는 일반적인 기준을 규정하고 있다. 미국은 일반급의 산정시 어떠한 임금이 포함되는지에 대해서도 「공정 「근로기준법」」(FLSA)과 「연방시행규칙」(CFR)에서 비교적 상세한 일반기준을 설정하고 있다. 이러한 미국의 법제는 비록 초과근로수당의 산정으로 국한되는 문제이긴 하지만, 단순화화 법률로써 일정한 기준을 설정하여 복잡한 임금문제를 간편하게 처리한다는 장점이 있다.³⁰⁶⁾

- (1) 선물로 지급한 총액 : 성격상 성탄절이나 그 밖에 특별한 상황에 지급하는 복무에 대한 포상으로서 근로시간·생산량·효율성을 척도로 하거나 그에 따라 달리 지급하지 아니하는 선물
- (2) 휴가, 휴일, 질병, 사용자의 충분한 근로 제공 실패 또는 기타 유사한 사유로 인해 작업이 수행되지 않는 경우 때때로 지급된 급여와 사용자의 이익을 증진시키고 사용자가 적절하게 변상할 수 있으나, 근로자가 부담한 여행비용 또는 기타 비용에 대한 합리적인 급여 또는 고용 시간의 보상으로서 지급되지 않은 기타 유사한 급여
- (3) 일정 기간 동안 수행된 서비스의 공로로 받게 된 지급총액
 - (a) 지급 여부 및 지급 금액에 대한 결정이 해당 기간 말일 이전에 사용자의 단독 재량에 따른 것으로서, 근로자가 정기적 수급을 기대하는 근거인 기존의 계약·협약·약정에 따른 것이 아닌 경우, 또는 (b) 국장이 규정으로 정하여 공표하는 요건을 충족하는 선의의 이익분배계획·신탁 또는 선의의 절약·저축 제도에 따라 근로시간, 생산량, 능률과 관계없이 다른 관련 요인을 고려하여 금액을 결정하여 지급하는 경우, 또는 (c) 아나운서 등 라디오 및 TV프로그램

304) 29 USC Ch. 8: FAIR LABOR STANDARDS § 207(e) "Regular rate" defined

305) 29 CFR § 778.200-225

306) 김상률, 앞의 논문, 144~145면 참조



출연자에게 지급된 출연료(국장이 규정으로써 정의하고 범위를 정하는 출연료를 말한다)인 경우 중 어느 하나에 해당하는 금액

- (4) 진정한 계획(방침)에 따라 근로자에게 제공되는 노령, 퇴직, 생명, 상해, 건강보험 또는 이와 유사한 혜택을 사용자가 수탁자나 제3자에게 지급하는 기여금
- (5) 초과근로수당
- (6) 토요일, 일요일, 휴일, 정기휴무일, 또는 1주의 6일차 또는 7일차에 일하는 경우 선의에 따라 성립된 지급물로 지급된 초과근로수당
- (7) 근로계약서 또는 단체협약에 따라 선의로 확립된 기본(basic)·일반(normal)·통상(regular) 1일 근로시간(8시간 이하) 또는 1주 근로시간을 벗어난 근로에 대하여 근로계약서 또는 단체협약에 따라 근로자에게 가산요금을 적용하여 지급하는 추가수당
- (8) 스톡옵션(stock option), 주식증가차액청구권(stock appreciation right), 진정한 근로자 주식 매수 제도(bona fide employee stock purchase program)에 따라 사용자가 제공하는 보조금이나 권리에서 파생된 모든 가치(value)나 소득(income)

(3) 경영성과급의 일반급 여부³⁰⁷⁾

일반급의 제외 항목 중 보너스와 이익배분이 우리나라의 경영성과급의 임금성 논란에 해당되는 항목이라고 할 수 있고, 보너스와 이익배분 등이 일반급에 포함되지 않는다는 원칙 하에 사례에 따라 판단기준을 분석하여 일반급 여부를 판단하고 있다.

1) 보너스

보너스는 수수료(Commission), 인센티브(Incentives) 등 명칭 여하에도 불구하고 근로자의 정기적인 소득에 부가하여 지급되는 급여를 말한다. 보너스가 「공정「근로기준법」」상 일반급의 제외 항목으로 분류되는지는 동법 제7조 (e)에 규정되어 있지 않으나, 「연방시행규칙」 제778.208조에서 확인할 수 있다.³⁰⁸⁾ 다만, 노동부는 보너스가 일

307) 성대규, 앞의 논문, 384면~401면 참조

308) 29 CFR § 778.208-Inclusion and exclusion of bonuses in computing the “regular



반급의 제외 항목으로 분류되는 법적 근거를 「공정 「근로기준법」 제7조 (e) (1)과 (3)으로 보고 있다. 이에 「연방시행규칙」은 제778.208조에서 보너스의 일반급 제외 원칙과 예외를 구체적으로 규정하고 있다.³⁰⁹⁾

보너스는 재량적 보너스와 비재량적 보너스로 나눌 수 있는데, 보너스 중 재량적 보너스는 일반급에서 제외되지만, 비재량적 보너스는 일반급에 포함된다. 재량적 보너스는 ‘① 사용자는 보너스 지급 여부를 결정하는 단독 재량권을 지급기간 종료일 또는 그 직전까지 가지고 있어야 하며, ② 사용자는 보너스의 양을 결정하는 단독 재량권을 지급기간 종료일 또는 그 직전까지 가지고 있어야 하고, ③ 근로자에게 정기적으로 보너스가 지급될 것이라고 예상할 수 있는 사전 계약, 합의, 약속이 없어야 한다.’는 3가지 요건을 모두 충족하는 경우 일반급에서 배제된다.³¹⁰⁾

2) 이익배분

이익배분이란 근로자에게 조직의 성과 또는 이익을 배분하는 성과급제도를 말한다. 이익배분이 「공정 「근로기준법」 상 일반급의 제외 항목으로 분류되는지는 동법 제7조 (e)(3)(b)에서 규정하고 있고, 구체적인 내용은 하위 규정인 「연방시행규칙」 제778.213조에서 규정하고 있다.³¹¹⁾

이익배분이 「공정 「근로기준법」 상 일반급의 제외 항목이 되기 위해서는 우선, 「연방시행규칙」 제549.1조에서 규정하고 있는 노동부장관이 요구하는 하기 6가지 필수 요건인 (b)~(g)을 모두 갖추어야 하며, 더불어 동 규칙 제549.2조에 명시된 하기 5가지 부적격 조항 (a)~(e) 중 어느 하나에도 해당되지 않아야 한다.

필수 요건 ³¹²⁾	부적격 조항 ³¹³⁾
① (b) 이익배분제도는 명확한 서면 또는 약정에 따라 마련되거나 직원에게 전달되어야함	① 개별 근로자의 배분이 출근, 업무의 질과 양, 생산성 및 능률에 근거하여 실질적으로 결정되는 경우
② © 사용자가 기금 또는 신탁에 적립하는 기	

309) 29 CFR § 778.208 Inclusion and exclusion of bonuses in computing the “regular rate.”

310) 성대규, 앞의 논문, 386면 참조

311) 29 CFR § 778.213 Profit-sharing, thrift, and savings plans.



여금 또는 분배금을 산출하여야 함 ③ (d) 이익배분의 자격요건은 최소한 「공정 「근로기준법」」상 최저임금과 초과근로수당을 적용받는 모든 근로자이거나 사용자의 사업체 등에 종사하는 모든 근로자(단, 이러한 자격요건은 서비스의 기간 또는 근무 기간이나 근무 일수의 최소기간과 같은 요소들에 따라 결정될 수 있음을 이익배분제도 내에 명시할 수 있음) ④ (e) 근로자 개인에게 지급되는 이익배분금은 이익배분제도에 명시된 확정식이나 계산방법에 따라 결정되어야 함 ⑤ (f) 이익배분금은 다른 보수로 인해 감액되지 않아야 함 ⑥ (g) 만약 이익배분제도에 명시된 지정된 기간 후 또는 예기치 못한 상황이 발생한 경우 이익배분금의 총당금이 마련될 수 있음	② 사용자가 정기적으로 기금 또는 신탁에 납입하는 금액이 고정된 금액인 경우 ③ 사용자가 근로자에게 주기적으로 최소한도의 급여지급을 보장하는 경우, ④ 이익배분제도의 규정에 따라 개별 근로자의 배분이 미리 고정금액으로 결정 또는 제한되어 있거나, 시간당 특정비용의 금액으로 결정 또는 제한되어 있는 경우, ⑤ 기금 또는 신탁에 대한 사용자의 기여금 또는 할당금이 근로시간, 생산성, 효율성, 판매 또는 비용 절감 등 이익 이외의 요소에 근거하는 경우 중 어느 하나에도 해당하지 않아야 한다.
--	--

3. 독일³¹⁴⁾

(1) 임금의 개념

독일의 경우는 임금의 정의에 관한 법률 규정은 존재하지 않는다. 다만, 독일 민법 제611조에 근로계약에 관한 정의 규정을 두면서, 임금은 근로자의 노무의 제공(Dienstvertrag)에 대한 반대 급부로서 결정된 금전가치의 이익을 말하며, 민법 체계 내에서 임금은 교환관계(Synallagma)에 있는 사용자의 주된 의무로서 「민법」 제611조는

312) 29 CFR § 549.1 Essential requirements for qualifications.

313) 29 CFR § 549.2 Disqualifying provisions.

314) 권혁, 앞의 논문, 193면 이하 참조



이를 보수(Vergütung)로 규정하고 있다.³¹⁵⁾ 실무상 ‘사무직에 대한 임금은 Gehalt라고 하고, 생산직 근로자에 대한 임금은 Lohn이라고 용어를 달리하나, 그 실질은 동일하며 산정주기에 있어 차이가 있을 뿐이다. 통상적으로 사무직 임금은 월 단위로 산정되고 지급된다. 이에 비해 생산직 임금은 시급 단위로 계산되고 주 단위로 지급된다.³¹⁶⁾

따라서 독일은 우리나라의 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호의 임금이나, 동법 동조 동항 제6호의 평균임금에 해당하는 법률규정이나 통상임금의 개념도 존재하지 않는다. 독일은 오랜 동안 단체협약의 역사적 발전에 의해서 주로 임금의 지급 근거나 지급종류, 지급액 등은 단체협약에 의해서 결정되고 상세히 규정되어 있기 때문에 지급 받은 금품의 임금성 여부가 다투어지는 것이 아니라 해고보상금, 재해보상금, 질병시 임금의 계속 지급, 휴업수당 등에 대한 청구권의 근거와 청구 금액의 문제가 주로 다투어진다. 즉, 이들 급여는 광의의 의미에서 모두 보수에 속하지만 과연 그러한 보수를 각각 개별적으로 청구할 수 있는 청구권의 근거가 무엇인지가 문제가 된다. 예를 들어 성과급의 임금성 여부가 문제가 아니라 성과급에 대한 지급청구권을 행사할 수 있는지 하는 문제에 초점이 맞추어져 있다.³¹⁷⁾

(2) 임금의 요건

독일에서 근로관계로부터 도출되는 수익(보수: Verguetung)이라도 ‘근로자’의 구체적인 노무제공과 직접적인 ‘관련성’을 가지지 않는다면 임금으로 보기 어렵다.³¹⁸⁾

1) 근로제공과 금품 제공 목적

임금은 그 속성상 ‘노동력 제공행위에 연계된’(Leistungsbezogen) 금품으로서 근로 제공의 대가 외 별도의 목적을 내포되지 않아야 한다. 상여금(Gratifikation)이나 복리후생금품은 임금에 해당하지 않는다. ‘상여금’(Gratifikation)이란, 본래 근로 제공의 대가로서의 속성을 가지는 임금과 달리 사용자가 ‘일정한 목적’(Zweck) 하에 지급하는

315) 김상률, 앞의 논문, 156면

316) 권혁, 앞의 논문, 195면

317) 김상률, 앞의 논문, 133면 및 136면

318) 권혁, 앞의 논문, 195면.



금품을 말한다. 이때 목적이란 독일 판례에 따르면 두 가지로 요약될 수 있는데 근로자로 하여금 (i) 과거 기간 동안의 기업충실성을 격려하기 위한 목적 또는 (ii) 미래에의 기업 충실성을 제고하기 위한 목적도 있다. 이처럼 별도의 목적을 내포한 금품은 상여금이지 임금인 아니다. 더불어 근로제공이 이루어진 이후(외부적 요인과 결합하여) 발생한 결과와 연계된 금품은 달리 보아야 한다. 결과에 연계된(Erfolgsbezogen) 대가라면 그것은 임금이 아니다. 독일의 논의에 따르면 이러한 금품은 근로제공 그 자체에 대한 반대급부로서가 아니라, 격려나 분발 등 별도의 목적(Zweck)을 가진 금품이라고 평가하게 된다.³¹⁹⁾

2) 지급청구권 배제 가능 여부

성과급이나 상여금에 대해 현재 재직 중인 근로자뿐만 아니라 회사를 이미 퇴직한 근로자가 부분적으로 추급하여 청구할 수 있다면, 그것은 임금으로 보아야 할 개연성이 높다. 재직 당시 제공한 근로의 대가로서 평가될 수 있기 때문이다.³²⁰⁾ 통상 상여금 등의 명칭을 가진 금품이 그 지급 시점에서 재직하고 있는 근로자에게만 지급하고, 그 이전에 이미 근로자로서의 지위를 상실한 근로자에게는 지급하지 아니한다면, 그 금품은 임금으로 볼 수 없다. 나아가 노사가 합의로서 해당 금품의 지급 기한을 별도로 정해 놓고, 실제로 그 기한을 넘기면 금품지급청구권이 소멸하는 경우라면 임금으로 보기 어렵고 이러한 금품은 별도의 지급 목적을 가진 금품으로 평가해야 한다. 근로 그 자체에 대한 대가라면 지급청구권 발생이나 소멸에 대해 별도의 합의로써 제한할 수는 없다.³²¹⁾

(3) 상여금의 임금성 여부

‘상여금’(Gratifikation)이란, 본래 근로 제공의 대가로서의 속성을 가지는 임금과 달리 사용자가 ‘일정한 목적’(Zweck) 하에 지급하는 금품을 말한다. 이때 목적이란, 독일 판례를 통해 축적된 바에 따르면 두 가지로 요약될 수 있다. 우선 근로자로 하여금

319) 권혁, 앞의 논문, 199~202면 참조

320) Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 9.Aufl., S.248; 권혁 201면.

321) 권혁, 앞의 논문, 201~202면 참조



(i) 과거 기간 동안의 기업충실성(Vergangene Betriebstreue)을 격려 하기 위한 목적이 다. 또한 (ii) 미래에의 기업 충실성(Zukünftige Betriebstreue)을 제고하기 위한 목적도 있다. 이처럼 별도의 목적을 내포한 금품은 상여금이지 임금인 아니다. 가장 전형적인 것이 바로 크리스마스 상여금이다. 국경일이나 축제를 동기(Motiv)로 하지만 지급 ‘목적’(Zweck)은 따로 있다. 바로 소속 기업에의 자부심을 높임으로써 기업에의 충실성을 강화하는 것이다. 같은 이유에서 결혼축의금이나 조의금, 재해위로금 등이 비록 단체 협약이나 취업규칙 또는 근로계약 등에 의하여 그 지급의무가 정하여져 있는 경우라도 이를 임금으로 파악할 수는 없음은 분명하다. 통상 상여금 등의 명칭을 가진 금품이 그 지급 시점에서 재직하고 있는 근로자에게만 지급하고, 그 이전에 이미 근로자로서의 지위를 상실한 근로자에게는 지급하지 아니한다면, 그 금품은 임금으로 볼 수 없다. 나아가 노사가 합의로서 해당 금품의 지급 기한을 별도로 정해놓고, 실제로 그 기한을 넘기면 금품지급청구권이 소멸하는 경우라면 임금으로 보기 어렵다.

(4) 경영성과금의 임금성 여부

원칙적으로 도급제 임금근로자가 아닌 이상 일정한 결과에 연계되어 지급여부가 결정되는 금품은 임금으로 볼 수 없다. 임금의 개념 본질을 근로의 대가성에 두는 한, 일정한 결과 발생을 조건으로 한 금품을 임금으로 평가할 수는 없기 때문이다. 오히려 특별한 목적을 가진 금품으로 봄이 타당하다. 독일의 경우 성과에 연계된 이른바 상여금은 ① 회사의 관리자급에게 지급되는 이익분배금과 ② 특정한 기간 동안에 일정한 성과 목표를 설정하는 개인 합의에 따라 지급하는 목표달성상여금 등 대체로 두 가지 유형으로 나뉜다.

1) 목표달성상여금

목표달성상여금(Zielvereinbarungsprämie)은 특정한 기간 동안에 일정한 결과(성과)목표를 설정하는 개별적 합의에 근거한 것이다. 근로자와 사용자 간에 근로계약에 부수하여 합의한 바 소정의 목표가 실제로 달성되면 해당 근로자에게 추가적으로 금품을 지급하게 된다. 이 금품이 바로 목표달성상여금이다. 이는 개개 근로자의 개별적 성과에 따라 목표달성 여부가 결정된다는 점에서 집단적 성과 여부에 의존하여 지급하게



되는 이익분배금과 구별된다. 목표달성상여금에 대한 근로자의 지급청구권은 근로계약 내용에 따라 당연히 보장되는 것이 아니라, 노사 양당사자가 근로계약과는 별도로 일정한 목표와 그 달성 시 금원을 지급하도록 한다는 개별 합의에 따라 인정되는 것이다. 이때 목표는 양적인 것과 질적인 것으로 나뉜다. 양적 목표는 판매실적, 매출실적 또는 수주실적 등의 내용으로 설정된다. 이러한 양적 목표의 설정은 그 달성여부를 확인하는 것이 용이하다. 다른 한편 질적 목표도 있다. 이에 비해 질적 목표는 그 달성 여부를 판단하기가 용이하지 않아서, 법적 분쟁이 발생할 위험도 있다.

2) 이익분배금

이익분배금(Tantieme)은 사업조직 전체 또는 특정 분야에서 발생한 이익금 규모 등 영업 성과로서의 결과물을 산정기준으로 하여 그 지급 여부 또는 지급 규모가 결정된다. 이렇게 사업장의 집단적 성과에 연계하여 지급되는 성과금이므로 해당 금품의 지급의무는 대개 연말 결산이 이루어지고 난 후에 비로소 발생한다. 구체적인 금액도 그 때 확정되며, 그 이후 지급되는 것이 통례이다. 사전에는 그 성과의 발생이나 규모 등 제반 결과사실을 예측할 수가 없는 만큼 이익분배금은 ‘가변적’이면서도 ‘우연적’인 속성을 가진다. 그러므로 임금성은 부정되며 상여금으로 평가된다.

4. 검토

일본은 우리나라와 유사한 법제를 두고 있으나 지급의무성을 중심으로 임금성을 판단하고 있다. 다만, 이러한 입장을 취하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 통상임금과 평균임금에 대한 논란이 크지 않다. 이는 입법적으로 통상임금의 경우 1개월 이내로 지급되는 급부만을 산입하고 평균임금은 3개월 이내로 지급되는 급부만을 산입하고 있기 때문이다. 그러나 우리나라는 일본과 달리 평균임금이나 통상임금 산정 시 기간의 제한을 두고 있지 않다. 오히려 2013년 대법원 전원합의체 판결을 통해 정기적으로만 지급된다면 1년마다 지급하는 것도 통상임금성을 인정하고 있어 일본과 같이 평균임금 및 통상임금의 산정 취지를 고려하여 기간을 제한하는 법제화를 하지 않는다면 법적안정성을 확보하기 위해 결국 임금성을 중심으로 임금의 범위를 제한할 수밖에



에 없다.

미국은 우리나라와는 다르게 법상 임금의 개념을 명확히 정의하고 있지는 않으나, 지침 등을 통해 각 금품 항목마다 임금성 관련 별개의 기준을 실태에 맞게 사전에 상세하게 규정을 하고 이를 적용하고 있어 당사자간에 불필요한 갈등을 줄이기 위해 노력하고 있다는 점을 참고할 필요가 있다. 더불어 미국이 경영성과급의 임금성 판단 기준 상 사전에 제도를 마련하도록 하여 제도의 취지(당사자의 의사)를 중시한다는 점에 대해 보다 세밀하게 살펴볼 필요가 있다. 미국은 보너스의 경우 지급여부와 금액에 대한 사용자의 실질적인 재량권의 존부에 따라 일반급 해당 여부를 판단하고 있고 이익배분제도의 경우 사전에 마련된 제도에 따라 지급금에 대한 산정 산식이 정해져 있고 모든 근로자(기간에 따른 제한 등은 가능)에게 지급된다면 즉, 사용자가 실질적인 이익배분의 요건을 갖추어 지급하였다면 고정급 또는 최소보장금액이 정혀져 있는 것이 아닌 이상 일반급에 해당한다고 보고 있다. 일반급 인정에 있어 엄격한 요건을 요하면 서도 사용자의 재량 여부와 당사자의 의사를 중요한 판단 기준으로 하고 있다. 미국의 이익배분 금품의 일반급 인정에 대한 대부분의 요건은 우리나라의 경영성과급의 임금성 요건과 상당히 부합한다고 볼 수 있다.³²²⁾ 그러나, 우리나라는 경영성과급의 지급 근거 또는 지급조건이 단체협약, 취업규칙 등에 명시되어 있는 경우 지급조건외의 근거가 되는 법원이 존재한다고 보아 ‘지급의무성’을 인정하며 임금성을 인정하는 요소로만 보고 있는 반면, 미국의 경우 이익배분제의 경우 사전에 이익배분제에 대한 서면이나 약정이 있어야 하고 개인에게 지급되는 이익배분금이 이익배분제도에 명시된 확정식이나 계산방법에 따라 결정되어야 한다고 보아 동일한 사실관계가 우리나라와 미국에서는 각각 임금성(일반급)을 긍정하거나 부정하는 요소로 상반되게 작용되고 있다. 우리나라도 당사자간에 단체협약, 노사합의, 취업규칙, 근로계약 등을 통해 이익배분의 목적으로 지급되는 금품임을 명확히 하였다면 임금성 판단 시 ‘지급의무성’을 긍정하는 요소로만 고려할 것이 아니라, 미국과 같이 해당 금품의 실질적 성격에 따른 당사자의 의사를 존중하여야 하여 임금성 판단의 가장 중요한 요건인 ‘근로제공 관련성’을 부정하는 요소로도 동시에 고려하는 것을 고려해 볼 필요가 있다고 보인다.

독일의 경우 임금의 개념에 대한 법제화 없이도 특정 사유 발생 시 지급할 금부에

322) 성대규, 앞의 논문, 403면



대해 단체협약 등에서 매우 상세하게 규정하고 있어 임금성에 대한 논란이 크지 않다. 다만, 독일은 근로관계로부터 도출되는 수익(보수 : Verguetung)이라도 근로자의 구체적인 노무제공과 직접적인 관련성을 가지지 않는 상여금(Gratifikation)이나 복리후생금 등은 임금에 해당하지 않는다고 보고 있으며, 특히 우리나라의 경영성과급에 해당하는 이익배분금(Tantieme)에 대해 성과의 발생이나 규모 등 제반 결과사실을 예측할 수가 없는 만큼 이익분배금은 ‘가변적’이면서도 ‘우연적’인 속성을 가지는 것으로 보아 임금성은 부정하고 있다. 우리나라의 경영성과급의 임금성 판단 시에도 독일의 판단 논리를 참고해 볼 수 있다.

III. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 일본, 미국, 독일 모두 경영성과급의 임금성을 부정하고 있다. 즉, 경영성과급의 임금성을 부정하는 것이 비교법적으로 보편적인 것임을 확인할 수 있었다.

우리나라의 경우 미국이나 독일과 다르게 일본과 같이 예외적으로 임금의 개념을 법제화 하고 있다. 즉, 우리나라에서는 경영성과급의 임금성 판단을 위해서는 앞서 살펴본바와 같이 입법자의 의사를 존중하여 법규정을 기초로 개념과 범위를 명확히 하고 각 사안별로 임금성을 판단하는 것이 법체계적으로 가장 부합한 판단 방법일 것이다. 다만, 근로자의 임금 보호를 위해서 일본과 같이 지급의무성을 기준으로 임금성을 판단하는 것은 우리나라 법제와 맞지 않다. 우리나라는 일본과 같이 기간을 제한하지 않은 이상 오히려 (평균)임금성 여부에 대한 당사자간의 다툼을 더욱 촉발하게 될 수 있다.

우리나라와 다르게 임금의 개념을 법제화하지 않은 미국은 급부의 성격에 따라 일반급 해당 여부를 지침 등에서 구체적으로 규정하고 있다. 현재 다수의 사건이 하급심 법원 및 대법원에 계류되어 있다. 우리 대법원이 금번 경영성과급의 임금성 판결을 계기로 임금성 즉, 근로의 대가의 의미에 대해 명확히 밝히고 과거 통상임금성 사건과 같이 유형화 하여 임금성에 대한 기본 입장을 밝혀준다면 미국과 같이 사실상 지침으



로 해석될 수 있고, 불필요한 분쟁을 사전에 방지하는 방법이 될 수도 있어 향후 대법원의 역할이 중요하다고 보인다. 더불어 법원은 임금성 판단 시 사용자가 급부의 성격을 사전에 명확히 한 경우(근로의 대가가 아니며 경영성과에 대한 보상임을 명확히 한 경우) 다시 말해 경영성과급을 사전에 제도화하는 경우(근로의 대가가 아님을 명확히 한 경우)에는 비록 지급의무성은 긍정되더라도 당사자의 의사를 존중하여 근로제공 관련성을 부정하는 요소로 보아 임금성을 불인정하는 것을 고려해 볼 필요가 있다.

또한 지급의무성에 있어 미국의 경우에도 사용자가 재량으로 지급할 수 있는 보너스에 대해서는 임금성을 부정하고 있는바, 경영성과급 판단 시 사용자의 재량이 인정될 수 있는 경우 지급의무성을 부정할 수 있는 요소가 될 수 있음을 참고할 필요가 있다. 독일도 미국과 같이 근로의 대가로 지급되는 것이 아니라는 지급 목적이 명확한 금품 및 사용자가 지급의 재량권을 가진 금품을 임금에서 제외하고 있다.

결론적으로 우리나라의 임금 법제는 비록 일본과 동일하나, 평균임금과 통상임금을 산정기간을 법으로 제한하고 있지 않은 점을 고려하면 지급의무성을 중심으로 경영성과급의 임금성을 넓게 해석하여 임금의 보호를 넓히는 것은 임금 관련 법제 및 그간의 판례를 고려하면 현재로서는 어려운 일이다. 만약 지급의무성을 중심으로 판단하여 임금의 범위를 넓게 보고자 한다면 일본과 같이 편익 실현을 위한 평균임금과 통상임금에 대해서는 그 제도의 취지에 맞게 기한을 제한하는 것을 법을 개정할 필요가 있다. 법 개정이 없는 현 상황에서는 임금 관련 법규정에 충실한 해석을 할 필요가 있다. 따라서 미국이나 독일과 같이 지급목적에 대한 당사자의 의사(법원 등을 통해 확인되는 의사)를 고려하여 ‘근로제공 관련성’을 판단하여야 하며, 특히 경영성과임이 명확하게 사전에 명시되어 있다면 사용자의 지급의무성(지급액에 대한 사용자의 재량권)에서만 고려할 것이 아니라 ‘근로제공 관련성’에서도 동시에 고려하여 판단하는 것이 현행 법규 하에서 합리적인 경영성과급의 임금성 판단 방법일 것이다.



제5장 결 론

최근 쟁점이 되고 있는 경영성과급의 임금성의 문제를 해결하기 위해서는 먼저 임금성 특히 임금의 가장 핵심 개념인 ‘근로의 대가’에 대한 개념과 판단 요건을 명확히 확정하는 것이 선행되어야 한다. 이를 위해 임금의 본래적인 법적 성격, 임금 관련 다른 법제와의 관계, 임금의 법규정과 평균임금·통상임금과의 비교를 통해 임금의 본질에 부합하며 통일적이고 법체계 상 유기적인 임금의 개념을 도출하고자 하였다.

임금의 법적 성격에 관한 이론적 논의만을 가지고 연역적 방법에 따라 임금성 여부를 결정하는 것은 오늘날 사용자가 근로자에게 지급하는 급부의 다양성을 고려하면 임금성의 개념과 범위를 함에 있어 충분한 방법이 될 수는 없지만 임금의 본질을 파악함에 있어 이론적 배경이 될 수 있음을 확인하였다. 임금의 법적 성격과 관련하여 노동대가설, 노동력대가설 등 다양한 견해가 일본을 중심으로 논의되어 우리나라에도 소개되었으나, 우리 「근로기준법」상 임금에 관한 정의 규정과 쌍무유상계약인 근로계약에 따라 임금이 노무급부에 대한 반대급부로서 지급되는 점을 고려하면 노동대가설이 우리 법제하에서 타당하다고 볼 수 있다.

다른 나라와 다르게 우리나라는 「근로기준법」상 임금에 관한 정의를 명확히 규정하고 「근로기준법」을 포함한 노동관계법에서 「근로기준법」의 임금을 준용하여 사용하고 있다. 각각의 법령에서 임금에 관한 사항에 대해 강행규정성을 부여하여 위반 시 수급자를 처벌하고 임금에 관한 특별한 보호를 하고 있는 우리나라 법제를 고려하면 「근로기준법」상 임금은 「민법」상 보수보다 더 범위를 제한하여 해석할 필요가 있고 그 과정에서 법적안정성과 근로자 보호라는 합목적성의 적절한 조율이 필요하다. 또한 임금은 특정한 사유가 발생할 경우 적용할 급여금의 산출을 위한 도구적 개념인 평균임금 및 통상임금과는 구분되어야 한다. 통상임금의 경우 대법원이 2013년 전원합의체 판결을 통해 그 개념과 요건을 명확히 하며, 소정근로의 대가, 정기성, 일률성, 고정성이 전제된 임금만을 의미하게 되었기 때문에 임금과 일치할 수



없는 것이 명확하나 평균임금의 경우 임금과 동일시 할 수 있는지 아니면 구분되는 개념인지에 대해 논란이 있다. 그러나 평균임금은 통상의 생활을 보장하기 위한 실생활 임금이라는 점, 이러한 취지가 「근로기준법」 시행령 제2조 제2항에 반영되어 평균임금 산정 시 임시로 지급되는 임금과 수당을 제외하도록 규정되어 있는 점을 고려하면 임금과 평균임금의 개념은 구분되며 임금성이 인정된다고 하더라도 평균임금성이 부정될 수 있기 때문에 임금과 평균임금의 개념은 구별되어야 한다.

그간 판례는 근로의 대상(대가), 계속성·정기성, 사용자의 지급의무성 등 객관적 판단 지표를 설정하고 개별 사안마다 유형론적인 해석을 하며 임금성 판단의 통일적 기준을 마련하지 못하였다. 특히 대법원은 1995년 영화진흥공사 사건 판결에서 최초로 ‘근로제공 관련성’을 근로의 대가의 핵심 지표로 제시하였음에도 이후에도 ‘근로제공 관련성’에 대한 판단 없이 나머지 2개의 지표만으로 근로의 대가 여부를 판단하기도 하였다. 최근 임금성과 관련한 논란이이 되었던 개인성과급 임금성 판결(적용), 공공기관 경영평가성과급의 임금성 판결(미적용), 복지포인트의 임금성 판결(적용)에서도 ‘근로제공 관련성’에 대해 개별 사안별로 적용여부를 달리하였다. 이로 인해 근로의 대가의 의미와 판단 요건에 대해 다양한 학설이 제기되었고 각 학설은 크게 ‘근로제공 관련성’을 중심으로 근로의 대가를 판단하는지 아니면 ‘지급의무성’을 중심으로 근로의 대가를 판단하는지, 계속성·정기성도 근로의 대가의 판단요소로 삼는지, 세부적으로는 근로의 대가 여부가 불분명할 경우 다른 요소를 통해 근로의 대가를 추정할 수 있는지(입증책임 전환), 각 판단지표별 우위성을 인정할 것인지에 따라 견해가 나뉜다.

위와 같은 임금성에 관한 종래 판결의 변화 및 최근 판결 그리고 다양한 학설에 대한 분석을 통해 근로의 대가의 개념을 구성하는 요건은 임금의 본래적 특성상 근로제공과 상호 전련성을 가지는 점, 법문상 근로의 대가임이 명확히 명시되어 있는 점, 근로관계하에서 지급되는 모든 금품을 근로의 대가로 보고자 하였다면 임금의 정의에 근로의 대가를 굳이 명시할 필요가 없다는 점, 근로제공을 전제로 하지 않고 임의로 지급하는 금품은 임금의 본래적 속성상 임금성을 인정하기 어려운 점, 지급의무는 청구권에 바탕을 둘 때에만 의미가 있다는 점, 지급액의 확정과 지급 여부의 확정을 구분할 필요가 없다는 점, 판단 요건과 요소를 구분한다면 우위성은 자연스럽게 나누어지는 점, 법적안정성과 합목적성의 조화, 임금청구권에 대한 입증책임 주체 등을 고려



하면 근로의 대가의 판단 요건은 판단 요소와 구분되어야 하고, 판단 요건은 ① 근로 제공 관련성(근로제공과 금품 지급간에 직접 또는 밀접한 관련성)과 ② 지급의무성(임금청구권을 인정할 수 있도록 지급액 등을 산출할 수 있는 구체적인 지급조건에 관한 법원의 존재)으로 한정되어야 한다. 판단 방법은 위 두 개의 요건을 기준으로 당사자의 의사(목적), 지급목적과 생성배경, 단체협약·취업규칙 등 명시적 법원과 노동관행 등의 지급요건, 산정방법 및 지급방법 등의 지급 실태를 판단요소로 삼아 위 두 요건을 모두 충족하는지 여부에 따라 근로의 대가를 판단하여야 한다. 더불어 근로의 대가의 요건이 아닌 다른 요소를 통한 추정(임증책임 전환)의 문제는 다시 말해 사용자가 근로자에게 지급하는 금품에 대해 특별한 사정이 없는 이상 근로의 대가성을 인정하는 것은 임금의 보호 범위를 넓히기 위한 방법이 될 수는 있으나 우리나라의 임금관련 법제가 일본(평균임금 산정 시 기간 제한 없음)과는 달라 임금의 범위를 폭넓게 인정할 경우 임금의 강행규정성 등 특별한 법적 보호에도 영향을 미치게 되는데, 법적인 정성을 고려하면 현행 법제하에서는 적절하지 않다. 따라서 임금의 개념과 요건을 명확히하여 이에 대한 직접적 판단을 통해 임금성을 판단하는 것 즉, 임금에 대한 청구권을 가지는 근로자가 근로의 대가를 포함하여 입증하는 것이 법체계상 일관성을 가질 수 있어 보다 합리적인 방법이다.

본 논문은 위와 같은 근로의 대가의 의미를 전제로 경영성과급의 임금성에 대해 살펴보았다. 경영성과급은 집단적 성과급이자 성과배분제의 한 유형으로 우리나라에 도입 시 임금인상을 대체하는 제도가 아닌 성과독려를 위한 제도로 도입되었다. 2018년 공공기관 경영평가성과급의 임금성이 인정된 이후 최근까지 민간기업의 경영성과급에 대해서도 쟁송이 이어지고 있는데 각 판결이 임금성을 판단하는 동일한 요건을 제시하면서도 각 요건에 대해 상반된 결론을 내리고 있어 문제가 되고 있다. 경영성과급은 협의의 성과배분제에 해당하며 최근 문제된 경영성과급은 이익배분제의 형태를 띄고 있다. 이러한 경영성과급은 기업 내 조직 또는 기업 전체가 달성한 성과 또는 이익에 근로자의 근로제공이 어떤 영향을 끼쳤는지 판단하는 것이 용이하지 않기 때문에 근로의 대가의 판단 요건인 ‘근로제공 관련성’ 부분에서 학계와 각 하급심 법원 판결이 가장 상반되게 대립하고 있다. 또한 각 견해와 판결은 임금성과 관련한 최근 판결(개인성과급, 공공기관 경영평가성과급, 복지포인트)을 경영성과급의 임금성 여부와



연계하여 논의하고 있다.

경영성과급을 근로의 대가로 보기 위해서 근로제공 관련성이 인정되어야 하는데 i) 경영성과의 달성에 따른 보상은 경영확장 인적자원 관리에 대한 보상의 하나로 반드시 근로의 대가와 견련관계 하에서 발생된 금원이 아닌 점 ii) 경영성과의 달성은 주로 회사 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여 등과 회사의 외부적 요인인 시장상황 동종업계 동향 등이 총체적으로 결합되어 이루어지는 것으로 근로제공은 이중에 하나의 요인에 불과하다는 점 iii) 근로제공과 쌍무적 견련관계에 있는 근로의 대가로서의 임금의 근로제공의 내용을 살펴보아야 하는데 집단성과급이라고 해서 근로제공 관련성이 부정되는 것이 아니라 직무나 역할에 따라 ‘협업’이 필요하여 성과측정의 단위를 기업으로 할 필요가 있는 경우에는 경영성과를 기준으로 지급하는 성과급의 ‘근로조건 관련성’이 인정될 수 있지만, 최근 문제가된 하급심 판결은 직무나 역할에 대한 고려가 없이 회사의 경영목표 달성을 성과급의 발생기준으로 한 것으로 근로제공 관련성이 없다고 볼 수 있는 점, iv) 개인성과급은 경영성과급과 다르게 주로 개인의 근로제공에 따라 성과급의 발생여부가 달라지며 개인이 실적 달성을 통제하는 것이 가능한 점 등을 고려하면 개인성과급의 임금성 인정과 경영성과급의 임금성 인정은 반드시 연계될 필요는 없다는 점, 공공기관 경영평가성과급은 매년 평가가 실시되고 평가 결과가 산출이 되면 지급이 되는 것으로 경영성과 달성이라는 별도의 조건을 필요로 하지 않기 때문에 공공기관 경영평가성과급과 민간기업의 경영성과급은 근로제공 관련성에 있어 달리 볼 수 있어 양자가 결론을 달리하는 것이 불합리하지 않은 점, 입법자의 의사 등을 고려하여 복지포인트의 임금성을 부정한 대법원 전원합의체 판결 등을 고려하면 경영성과급의 근로조건 관련성을 부정하는 견해가 보다 타당하다.

경영성과급의 경우 지급의무성 인정 여부에 대해 경영성과 달성(정지조건)과 지급(이행)을 일체로 보아 불확정성을 가지며 반복된 지급이 되었다더라도 노동관행을 인정할 수 없다고 보는 견해가 있으나 근로제공에도 불구하고 경영성과 달성이라는 추가적인 조건이 필요하다는 것은 근로제공 관련성의 문제로 보는 것이 타당하기 때문에 지급이라는 반복된 사실과 이에 대한 구성원의 신뢰를 인정할 수 있다면 노동관행 자체를 부정할 필요는 없다. 다만, 지급의무성의 의미는 근로자가 청구 시 사용자가 지



급을 거절할 수 없는가의 관점으로 보아야 하며 이 때 청구는 사용자의 재량에 따라 임의로 지급을 결정할 수 있는 것이 아니라 임금지급청구권이 인정될 수 있다는 의미로 보아야 한다. 따라서 적어도 법원(法源)상 경영성과 달성 정도에 따라 지급액을 특정할 수 없는 경우(현대해상화재보험 사건과 다르게 SK하이닉스 및 삼성전자 사건과 같이 한도만을 설정한 경우)에는 임금성을 인정할 수 없으며 민법상 보수에는 포함될 수 있더라도 특별한 보호를 받는 「근로기준법」상 임금성은 부정하는 것이 타당할 것이다. 또한 하급심 판결을 중심으로 통상적인 생활임금의 보장이라는 평균임금의 취지를 고려하여 경영성과급의 임금성을 판단하고 있는데 기존 대법원 판결과 같이 변동 폭이 큰 경영성과급은 평균임금의 취지에 부합하지 아니하며 경영성과급이 급여에서 차지하는 비중은 최저임금을 위반하지 않는 이상 당사자 간에 임금 아닌 금품의 지급을 약정할 수 있는바, 비중 그 자체만을 놓고 임금성 여부를 판단할 것이 아니라 비중이 높은 경영성과급에 대해서는 실질이 임금임에도 경영성과급이라는 명칭하에 비임금화한 것이 아닌지에 대한 판단을 위한 고려 요소에 불과하다고 보아야 할 것이다.

참고로 우리나라와 유사한 법제를 두고 있는 일본의 경우 임금성을 판단함에 있어 지급의무성을 중심으로 판단하고 있고 이로 인해 임금성을 매우 폭넓게 인정하면서도 평균임금과 통상임금을 산정함에 있어서는 기간을 제한하는 방법을 통해 법적안정성과 합목적성을 조화시키고 있다. 그러나, 우리나라는 법제 및 그간의 판례를 고려하면 기간 한정을 통해 평균임금과 통상임금을 제한 것은 현재로서는 어렵다. 따라서 법적안정성 확보를 위해서는 임금성 판단 시 법문에 충실하게 근로제공 관련성과 지급의무성 양자 모두를 고려하는 것이 필요하다. 참고로 미국의 경우 연방정부가 각각의 급부가 기본급으로 인정되기 위한 요건을 매우 세부적으로 지침 등을 통해 규정하고 있다, 향후 대법원에서 임금성에 대한 판단 기준을 2013년 통상임금에 관한 전원합의체 판결과 같이 명확히 해준다면 고용노동부가 (평균)임금에 대해서도 세부적인 지침을 만들어 불필요한 분쟁을 최소화 할 수 있도록 할 수 있을 것이다. 따라서 대법원이 금번 경영성과급의 임금성에 관한 판결 시 임금 개념의 핵심이 되는 근로대가성의 의미에 관한 상세한 판결을 내려 줄 것을 기대한다. 더불어 미국은 당사자의 의사를 중시하며 경영성과급이 일반급에 해당하지 않기 위해서는 사전에 성과급에 대한 제도를



요구하고 있다, 우리나라도 경영성과급이 제도화를 통해 규정에 명시되어 있을 경우 지급의무성을 긍정하는 요소로만 해석할 것이 아니라 당사자의 의사가 근로의 대가로 보지 않고자 하였음을 고려하여 근로제공 관련성을 부정하는 요소로도 해석할 필요가 있다. 참고로 독일도 근로제공 관련성을 인정할 수 없는 경영성과급에 대해 미국과 마찬가지로 임금성을 부정하고 있다. 특히 미국과 독일은 상여금이나 성과급 판단 시 사용자의 지급 재량이 인정되는 경우 임금성(일반급)을 부정하고 있다. 향후 대법원에서 경영성과급의 임금성 여부 판단 시 비교법상 임금성이 부정되는 것이 보편적임을 고려할 필요가 있다.



참 고 문 헌

[단행본]

- 김영문 · 이상훈 · 이정, 『임금개념과 평균임금 · 통상임금의 산정범위』, 법문사, 2004.
- 김유성, 『노동법 I』, 법문사, 2005.
- 김형배, 『노동법(제27판)』, 법문사, 2021
- 김형배 · 박지순, 『노동법 강의(제11판)』, 신조사, 2022.
- 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 『근로기준법 주해 I(제2판)』, 박영사, 2020.
- 문무기 · 윤문희 · 이철수 · 박은정, 『임금제도 개편을 위한 노동법적 과제』, 한국노동연구원, 2006.
- 사법연수원, 『해고와 임금』, 2016.
- 임종률, 『노동법(제18판)』, 박영사, 2020.
- 하경호, 『임금법제론』, 신조사, 2013

[논 문]

- 권오성, “경영 성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 346호)」, 중앙경제, 2020.
- 권 혁, “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 「노동법포럼(제28호)」, 노동법이론실무학회, 2019.
- 김기선, “개인실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 280호)」, 중앙경제, 2014.
- 김도한, “경영성과급의 임금성”, 「중앙법학(제24집 제1호)」, 중앙법학회, 2022.



- 김상률, 「임금의 개념과 제도상 문제점에 관한 연구」, 박사학위 논문, 경북대학교, 2011.
- 김영문, “임금개념과 평균임금·통상임금의 산정범위”, 「기업법연구(제18권 제2호)」, 한국기업법학회, 2004.
- 김재훈, “성과금은 임금에 포함되는가?”, 「노동법률(통권 180호)」, 중앙경제, 2006.
- 김홍영, “성과급의 임금성 여부”, 「노동법연구(제17호)」, 서울대학교노동법연구회, 2004.
- 김홍영, “지난 20년간 임금 법제의 해석과 입법의 동향”, 「노동법연구(제26호)」, 서울대노동법연구회, 2009.
- 김희성, “성과배분으로서 경영성과급은 근로의 대가인 임금에 해당하는가”, 「노동법률(통권 371호)」, 2022.
- 김희성·성대규, “성과배분으로서 경영성과급의 임금성에 대한 고찰”, 「노동법포럼(제35호)」, 노동법이론실무학회, 2022.
- 김희성·이준희, “경영성과급의 근로 대가성 인정요건에 관한 판례 검토”, 「노동법논총(제54집)」, 한국비교노동법학회, 2022.
- 노상현, “임금의 법리와 쟁점-한국과 일본의 비교법적 검토”, 「노동법학(제31호)」, 한국노동법학회, 2009.
- 박영범, 「주요 선진국의 성과배분제도」, 한국노동연구원, 1994.
- 박은규, 「임금의 개념에 관한 연구」, 박사학위 논문, 한양대학교, 2013.
- 박종희, “복지포인트의 임금성”, 「노동법포럼(제28호)」, 노동법이론실무학회, 2019.
- 박종희·강선희, “비정규근로자에 대한 차별시정제도의 현황과 몇 가지 쟁점에 대한 검토”, 「산업관계연구(제22권 제2호)」, 한국고용노사관계학회, 2012.
- 박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 「노동법논총(제49집)」, 한국비교노동법학회, 2020.
- 박진엽 “집단적 경영성과급의 임금성”, 「법학연구(제30권 제3호)」, 경상대학교 법학연구소, 2022.



- 박진호, “현행법상 임금의 본질과 통상임금에 관한 연구”, 「노동법학(제61호)」, 한국노동법학회, 2017.
- 신동윤·성대규, “경영성과급의 임금성 판단기준에 관한 고찰”, 「사회법연구(제46호)」, 2022.
- 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 「산업관계연구(제29권제3호)」, 한국고용노사관계학회, 2019.
- 심재진, “집단적 경영성과급의 임금성”, 「월간노동리뷰(2021년 8월호)」, 한국노동연구원, 2021.
- 양재현, 「민법상 고용계약에 관한 연구」, 박사학위 논문, 숭실대학교, 2010.
- 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 「노동법률(통권 343호)」, 중앙경제, 2019.
- 이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 「법제논단」(2014. 4), 법제처, 2014.
- 이셋별·권오성, “임금에 관한 최근 판결 경향의 검토”, 「노동법포럼(제36호)」, 노동법이론실무학회, 2022.
- 이선신, “근로기준법 상 임금정의규정의 합리적 해석방안” 「노동법학(제46호)」, 2013.
- 이선신, 「임금의 유연성 제고에 관한 법리 연구」, 박사학위 논문, 고려대학교, 2010.
- 이수정·박지순, “임금의 개념과 경영성과급의 법적 성격”, 「노동법포럼(제37호)」, 노동법이론실무학회, 2022.
- 이영면, “이익분배제에 대한 노사의 입장변화 : 미국의 경험과 시사점”, 「산업관계연구(제12권)」, 한국고용노사관계학회, 2002.
- 이장원·김동배·이상준, 「성과배분제도의 실태와 발전방안」, 한국노동연구원, 2020.
- 이 정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구”, 「외법논집(제44호 제2권)」, 한국외국어대학교 법학연구소, 2020.
- 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 「노동법률(통권 343호)」, 중앙경제, 2019.



임상민, “성과상여금의 (평균)임금성”, 「사법(55호)」, 사법발전재단, 2020.

정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 「노동법률(통권 340호)」, 중앙경제, 2019.

조상욱, “경영성과급 임금성의 법적 쟁점”, 「노동법률(통권 367호)」, 중앙경제, 2021.

최진수, “임금의 양대 요건으로 본 경영성과급”, 「노동법률(통권 371호)」, 중앙경제, 2022.

한광수·김희성, “복지포인트의 임금해당성”, 「노동법논총(제48집)」, 한국비교노동법학회, 2020.

한국노동연구원, “6~7차년도 사업체패널조사 기초분석보고서(한국의 사업체로 본 노동 시장 현황)”, 2020.

